

Coordenação
Sabrina Dourado



COLEÇÃO
Descomplicando

Direito Constitucional

3ª EDIÇÃO

Flavia Bahia

Atualização
pelo site

Atualizado de
acordo com o
Novo CPC



EDITORA
ARMADOR

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Coleção Descomplicando - Direito Constitucional/3ª Edição

Flavia Bahia - Coordenação: Sabrina Dourado

Recife, PE: Armador, 2017.

416 p.; 16 × 23,5 cm.

ISBN: 978-85-9483-010-4

1. Direito. 2. Direito Constitucional. I. Título

CDU 342

Índice para catálogo sistemático:

1. Direito Constitucional. 342

Coordenação: Sabrina Dourado

Flavia Bahia

Descomplicando Direito Constitucional

3ª edição

Recife – PE



**EDITORA
ARMADOR**

2017

© Copyright 2017
Armador

Coordenação:
Sabrina Dourado

Autora
Flavia Bahia

Editores
Geovane Moraes
Maurício Gieseler

Projeto gráfico e Diagramação
Lee Marvin

Capa
Isabella Giordano

Revisão
Edvaldo Ferreira

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, inclusive por meio de processos xerográficos, sem permissão expressa do editor (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos reservados à:
ARMADOR
Rua Pio IX, 301, Madalena
Recife-PE, CEP: 50710-265
Tel.: (81) 3128-6650
Site: www.armador.com.br
e-mail: armador.atendimento@gmail.com

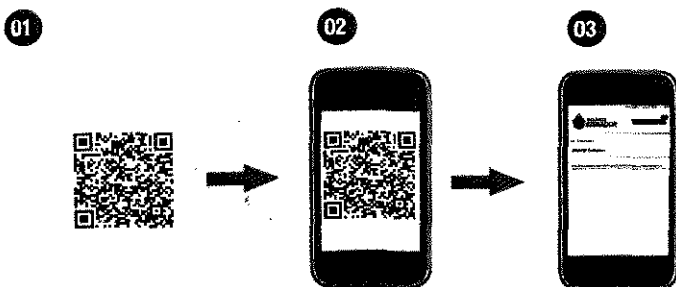
COMO ACESSAR AS ATUALIZAÇÕES VIA QR CODE:

Na loja de aplicativos do seu smartphone,
baixe um leitor de QR Code.
Disponível para iOS e Android.



O leitor permite que você tenha acesso
a conteúdos exclusivos deste livro.

Passo a passo:



Com o leitor aberto, posicione-o para o código a fim de fotografá-lo.
Em seguida, uma página será aberta automaticamente.

ACESSE JÁ:



Agora você pode
aproveitar todo o
conteúdo exclusivo!



Sumário

CAPÍTULO 1

A TEORIA DO PODER CONSTITUINTE	21
1.1 Histórico.....	23
1.2 Natureza do Poder Constituinte Originário.....	24
1.3 Conceito de Poder Constituinte	24
1.4 Titularidade X Exercício	25
1.5 Poderes Constituídos.....	25
1.6 Espécies de Poder Constituinte.....	26
1.6.1 O Poder Constituinte Originário	26
1.6.2 O Poder Constituinte Derivado Reformador	27
1.6.3 O Poder Constituinte Derivado Decorrente	27
1.7 Características	27
1.8 Direito Adquirido e as Normas do Poder Constituinte	
Originário e Derivado	28

CAPÍTULO 2

A NOVA CONSTITUIÇÃO E O DIREITO ANTERIOR	33
2.1 Introdução	35
2.2 A teoria da Revogação Global.....	35
2.3 A teoria da Desconstitucionalização	35
2.4 A teoria da Recepção e da Não Recepção.....	36
2.5 A teoria da Repristinação	38

CAPÍTULO 3

CONCEPÇÕES SOBRE A CONSTITUIÇÃO	39
3.1 Introdução	41
3.2 Sentido Sociológico	41
3.3 Sentido Político.....	42
3.4 Sentido Jurídico-Normativo.....	43
3.5 Outras Concepções.....	44

CAPÍTULO 4

CLASSIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO..... 45

4.1 A importância da Classificação	47
4.2 Quanto à Forma.....	47
4.3 Quanto à Origem.....	47
4.4 Quanto ao Modo de Elaboração.....	48
4.5 Quanto à Extensão	49
4.6 Quanto ao Conteúdo	49
4.7 Quanto à Alterabilidade	50
4.8 Quanto à Finalidade	51
4.9 Quanto à Correspondência com a Realidade	52
4.10 A Classificação da Constituição de 1988	52

CAPÍTULO 5

LIMITAÇÕES AO PODER DE REFORMA 53

5.1 Limitações ao Poder de Reforma	55
--	----

CAPÍTULO 6

EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS 65

6.1 A Influência da Segunda Dimensão de Direitos Fundamentais sobre o Tema	67
6.2 Teoria Bipartida Americana (Thomas Colley)	68
6.3 Teoria Tripartida Clássica Brasileira (José Afonso da Silva).....	68

CAPÍTULO 7

A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL 71

7.1 A Difícil Tarefa de “Interpretar”	73
7.2 Métodos Clássicos de Interpretação Constitucional	73
7.2.1 Método Gramatical ou Literal.....	73
7.2.2 Método Sistemático	74
7.2.3 Método Histórico	74
7.2.4 Método Lógico.....	75
7.2.5 Método Teleológico	75

7.3 A Abertura das Constituições aos Princípios e a Nova Interpretação Constitucional	76
7.4 Métodos Modernos de Interpretação Constitucional	79
7.4.1 Método Tópico-Problemático	79
7.4.2 Método Hermenêutico-Concretizador	80
7.4.3 Método Científico-Espiritual	80
7.4.4 Método Normativo Estruturante	80
7.4.5 Método da Comparação Constitucional.....	81
7.5 Os Principais Princípios de Interpretação Constitucional.....	81
7.5.1 Princípio da Supremacia da Constituição	81
7.5.2 Princípio da Unidade da Constituição	82
7.5.3 Princípio da Concordância Prática (ou da Harmonização).....	82
7.5.4 Princípio do Efeito Integrador (ou da Eficácia Integradora).....	82
7.5.5 Princípio da Justeza (ou da Conformidade Funcional).....	83
7.5.6 Princípio da Correção Funcional	83
7.5.7 Princípio da Força Normativa da Constituição e da Máxima Efetividade das Normas Constitucionais.....	83
7.5.8 Princípio da Interpretação Conforme a Constituição.....	84
7.5.9 Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.....	85

CAPÍTULO 8

NOTAS SOBRE AS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS	87
8.1 Constituição de 1824.....	89
8.2 Constituição de 1891.....	90
8.3 Constituição de 1934.....	91
8.4 Constituição de 1937.....	92
8.5 Constituição de 1946.....	93
8.6 Constituição de 1967.....	95
8.7 Emenda Constitucional nº 1, de 1969	96

CAPÍTULO 9

DIREITOS FUNDAMENTAIS	97
9.1 Teoria dos Direitos Fundamentais.....	99
9.2 Direitos Humanos e Direitos Fundamentais	102
9.3 Direitos e Garantias Fundamentais	103
9.4 Titularidade	104
9.5 Positivção	104
9.6 Nas Normas Infraconstitucionais	105
9.7 Dupla Dimensão dos Direitos Fundamentais.....	105
9.8 Eficácia Vertical e Horizontal dos Direitos Fundamentais.....	105
9.9 Características	106
9.10 Gerações ou Dimensões dos Direitos Fundamentais	109
9.11 A Constitucionalização Formal dos Tratados sobre Direitos Humanos. art. 5º, § 3º	111
9.12 Incidente de Deslocamento de Competência para a Justiça Federal.....	112
9.13 Análise Doutrinária e Indicação de Jurisprudência sobre o art. 5º	113
9.14 Princípio da Igualdade	114
9.15 Princípio da Legalidade	117
9.16 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana	119
9.17 Manifestação de Expressão Responsável.....	120
9.18 Liberdade Religiosa	123
9.19 Liberdade de Expressão Artística.....	124
9.20 Proteção à Intimidade e a Vida Privada	127
9.21 Liberdade Profissional	138
9.22 Liberdade de Comunicação.....	139
9.23 Liberdade de Locomoção.....	139
9.24 Direito de Reunião	140
9.25 Direito de Associação	142
9.26 Direito de Propriedade	144
9.27 Direitos do Consumidor.....	150
9.28 Direito à Informação	151
9.29 Direito de Petição e de Obtenção de Certidões.....	152
9.30 Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional e do amplo acesso à Justiça.....	154

9.31 Princípio da Segurança das Relações Jurídicas e da Irretroatividade das Leis	157
9.32 Princípio do Juiz Natural	162
9.33 Direito Penal Constitucional	168
9.34 Extradicação	177
9.35 O Devido Processo Legal	183
9.36 Princípio da Presunção de Inocência	188
9.37 Identificação Criminal.....	191
9.38 Ação Penal Privada Subsidiária da Pública	192
9.39 Publicidade dos Atos Processuais	192
9.40 A Prisão	192
9.41 Direito ao Silêncio	194
9.42 A Prisão Civil por Dívida.....	196

CAPÍTULO 10

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS	199
10.1 Remédios Constitucionais.....	201
10.2 Habeas Corpus	201
10.3 Mandado de Segurança	203
10.4 Habeas Data	207
10.5 Mandado de Injunção.....	210
10.6 Ação Popular.....	212

CAPÍTULO 11

DIREITOS SOCIAIS	215
11.1 Conceito e Desafios.....	217
11.2 Classificação dos Direitos Sociais na Constituição Brasileira	217
11.3 Os Direitos Sociais do Trabalhador	218
11.4 Mecanismos de Efetivação dos Direitos Sociais na Constituição de 1988.....	218
11.5 Os Princípios Norteadores de Proteção aos Direitos Sociais	219

CAPÍTULO 12

NACIONALIDADE	223
12.1 Conceito	225
12.2 Espécies de Nacionalidade.....	225
12.3 Critérios de Atribuição de Nacionalidade Originária.....	225
12.4. Aquisição de Nacionalidade Originária	225
12.5 Aquisição de Nacionalidade Derivada	227
12.6 Tratamento Diferenciado entre Brasileiros	229
12.7 Perda da Nacionalidade.....	231

CAPÍTULO 13

DIREITOS POLÍTICOS	233
13.1 Direitos Políticos.....	235
13.2 Aquisição de Direitos Políticos: Alistamento Eleitoral.....	235
13.3 Inalistabilidade	235
13.4 Direitos Políticos Ativos	236
13.5 Direitos Políticos Passivos	237
13.6 Os Direitos Políticos Negativos	238

CAPÍTULO 14

PARTIDOS POLÍTICOS	245
14.1 Conceito	247
14.2 Preceitos Fundamentais	247
14.3 A Criação dos Partidos Políticos	248
14.4 A Fidelidade Partidária.....	248
14.5 A Verticalização das Coligações	252

CAPÍTULO 15

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO	253
15.1 Organização do Estado	255
15.2 A Federação Brasileira	256
15.2.1 Características Da Federação Brasileira	256
15.2.2 O Equilíbrio Federativo	257
15.3 Autonomia X Soberania	258

15.4 Da União	258
15.5 Dos Estados Federados	261
15.6 Dos Municípios	263
15.7 Do Distrito Federal	265
15.8 Dos Territórios	265
15.9 Intervenção	265
15.9.1 Hipóteses Constitucionais Taxativas.....	266
15.9.2 Natureza Jurídica	266
15.9.3 Espécies de Intervenção.....	266
15.9.4 Pressupostos do Decreto Interventivo.....	268
15.9.5 Controle Político.....	268
15.9.6 Controle Jurisdicional.....	269
15.9.7 Intervenção da União em Municípios de Territórios (art. 35).....	269
15.9.8 Repartição de Competências.....	269

CAPÍTULO 16

MECANISMOS DE DEFESA DO ESTADO..... 275

16.1 Do Sistema Constitucional das Crises	277
16.2 Princípios Informadores do Estado de Defesa e do Estado de Sítio	277
16.3 Requisitos para o Estado de Defesa.....	278
16.3.1 Medidas Coercitivas que podem vigorar durante o Estado de Defesa.....	278
16.4 Requisitos para o Estado de Sítio.....	279
16.4.1 Medidas que podem vigorar durante o Estado de Sítio	279
16.5 Controle Político e Jurisdicional.....	280

CAPÍTULO 17

PODER LEGISLATIVO 283

17.1 Conceito	285
17.2 Estatuto dos Congressistas.....	286

CAPÍTULO 18

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 295

18.1 Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)	297
18.2 Requisitos para sua Criação	297
18.3 CPI nos Estados, Distrito Federal e Municípios	298
18.4 Poderes das CPI	299
18.5 Vedações à CPI.....	299
18.6 Posição do STF sobre o Direito ao Silêncio	300

CAPÍTULO 19

TRIBUNAIS DE CONTAS 303

19.1 Histórico do Tribunal de Contas	305
19.2 Características do Tribunal de Contas da União	306
19.3 Ministros do Tribunal de Contas da União	306
19.4 O Ministério Público perante o TCU	307
19.5 Aspectos importantes sobre o TCU.....	307
19.6 Os Tribunais de Contas nos Estados e Distrito Federal	310
19.7 Os Tribunais de Contas Municipais	311

CAPÍTULO 20

PROCESSO LEGISLATIVO..... 313

20.1 Processo Legislativo	315
20.2 Introdução	315
20.3 Fases do Processo Legislativo de elaboração da Lei Ordinária e Complementar	316
20.4 MEDIDAS PROVISÓRIAS	322
20.5 Lei Delegada	326
20.6 Resoluções e Decretos Legislativos.....	327

CAPÍTULO 21

PODER EXECUTIVO 329

21.1 Conceito	331
21.2 Sistemas de Governo.....	331
21.3 Formas de Governo.....	331

21.4 Requisitos para Presidente e Vice (art. 14, § 3º)	331
21.5 Mandato Presidencial (art. 77)	332
21.6 Atribuições do Presidente da República (art. 84)	332
21.7 Hipóteses de perda do Mandato	333
21.8 Vacância e Substituição	333
21.9 Prerrogativas e Responsabilidades do Presidente da República	334
21.10 Os Ministros de Estado	338
21.11 Órgãos de apoio ao Presidente da República	338

CAPÍTULO 22

PODER JUDICIÁRIO 341

22.1 Conceito	343
22.2 Órgãos do Poder Judiciário	343
22.3 Garantias Constitucionais do Poder Judiciário e de seus Integrantes	348
22.3.1 Garantias Orgânicas ou Institucionais	348
22.3.2 Garantias da Magistratura (art. 95)	348
22.3.3 Vedações – Garantias de Imparcialidade (art. 95, parágrafo único, I, II, III, IV e V, alterado pela EC 45/2004)	349
22.4 Reforma do Poder Judiciário – Algumas Alterações	350
22.5 A Súmula Vinculante	351

CAPÍTULO 23

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 363

23.1 Conceito	365
23.2 Princípios Orientadores do Controle de Constitucionalidade	365
23.3 Parâmetro do Controle	366
23.4 Tipos de Inconstitucionalidade	366
23.4.1 Inconstitucionalidade Material e Formal	366
23.4.2 Inconstitucionalidade Total e Parcial	367
23.4.3 Inconstitucionalidade por Ação ou por Omissão	367
23.5 Modalidades de Controle	368
23.5.1 Exceções	368
23.6 Formas de Controle Repressivo Judicial	369

23.7 Controle Difuso	370
23.8 Controle Concentrado	375
23.8.1 Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica (ADI).....	375
23.9 Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC).....	383
23.10 Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão.....	385
23.11 Arguição de descumprimento de Preceito Fundamental	388

CAPÍTULO 24

QUESTÕES RELEVANTES NO CONTROLE

DE CONSTITUCIONALIDADE	393
24.1 A Reclamação Constitucional	395
24.2 Jurisprudência sobre Reclamação	397
24.3 Natureza do Ato Inconstitucional.....	398
24.4 Controle de Constitucionalidade Concentrado	
Abstrato Estadual	398
24.5 Controle de Constitucionalidade Concentrado	
Abstrato Distrital e Municipal.....	401
24.6 ADI Interventiva Federal (ou Representação de	
Inconstitucionalidade Interventiva) e ADI	
Interventiva Estadual	402
24.7 Coletânea de Jurisprudência sobre alguns temas	
do Controle de Constitucionalidade.....	406

CAPÍTULO 1

A TEORIA DO PODER CONSTITUINTE

1.1 HISTÓRICO

No Século XVIII, a França era cenário de uma sociedade completamente estratificada, dividida em três Estados. O 1º (primeiro) e o 2º (segundo) Estados, juntos, formavam o clero e a nobreza e representavam 2% (dois por cento) da população francesa. O 3º (terceiro) Estado era formado pela burguesia alta, média, baixa, proletariados e desempregados e totalizavam os restantes 98% (noventa e oito por cento) da população francesa.

Nesse país marcado pelo autoritarismo e completo desrespeito aos direitos fundamentais da população, o clero e a nobreza comandavam as decisões políticas fundamentais em nome de todo o povo francês e o 3º (terceiro) Estado ficava à margem de toda possibilidade de manifestação política importante para o país.

Nos idos de 1788 o Abade Emmanuel Joseph de Sieyès distribuiu um panfleto na França intitulado “Qu’est-ce que le Tiers État?”, ou seja, “O que é o Terceiro Estado?”, que expressava as reivindicações da burguesia contra os privilégios e o absolutismo, incentivando o nascimento de um sentimento político na população discriminada no sentido de reivindicar a sua posição na tomada das decisões políticas fundamentais da França. Esse documento, conforme a doutrina, foi lançado pouco tempo antes da Revolução Francesa de 1789¹.

Nesse manifesto estava presente a necessidade de restauração da legitimidade da tomada das decisões políticas na França, com a substituição do Estado Absolutista e dominador, para um Estado fundado pela vontade da Nação². Daí nasceu a consagração de que a Constituição (a lei fundamental desse Estado) deve nascer da vontade de todos, inspirando a convocação de Assembleia Nacional Constituinte para elaboração da Declaração de Direitos francesa de 1791³.

1. BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada, 5ª ed. Saraiva, São Paulo, 2003, p. 44/45.

2. Segundo Bulos, em ob. cit p. 46, para Sieyès, “povo e nação não se confundem, pois o primeiro seria o conjunto de pessoas reunidas e submetidas a um poder e a nação seria mais do que conjunto; seria a encarnação dos interesses dos indivíduos como um todo, na sua generalidade e permanência. Generalidade, no sentido de o poder soberano não se limitar, em seu exercício, a nenhuma parcela de indivíduos posto que a soberania pertence à comunidade inteira. Permanência, se se considerar o interesse permanente das gerações futuras, que não pode ficar renegado ao interesse transitório de um grupo de indivíduos”.

3. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 18ª ed., Malheiros, São Paulo, 2006, p. 146.

Pode-se concluir que a teoria de Sieyès foi importante para coroar o processo de resgate da legitimidade política e a despersonalização do poder, fundamento do Estado Constitucional moderno. O nascimento de uma Constituição com raízes populares marca a teoria do Poder Constituinte Originário.

1.2 NATUREZA DO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO

- Poder de Direito
- Poder de Fato
- Poder Político

Segundo o Abade de Sieyès e os demais jusnaturalistas, o poder constituinte teria como fonte principal os valores que são superiores às leis escritas, ou seja, o direito natural e, nesse sentido, seria um poder de direito. É como se a Constituição não fosse verdadeiramente formar direitos; é como se ela viesse apenas consolidar, em documento escrito, direitos que já foram formados antes da própria existência da lei, os direitos advindos do poder natural, do poder divino, a liberdade, a igualdade, a ideia da vida, etc.

Os juspositivistas, como Hans Kelsen, dentre outros, entendiam que o poder constituinte se legitimava nele próprio e que não havia nenhum alicerce prévio efetivo, seja em direito natural ou em direito positivo anterior. Com isso, o poder constituinte seria um poder de fato.

Segundo Paulo Bonavides⁴, o poder constituinte em sua origem é poder de direito, mas na sua aplicação seria um poder de fato, ou seja, seu nascimento é baseado nos valores de direito natural, mas na sua aplicação ele é um poder de fato, é um poder que não se discute, importante para o Estado e que deve ser cumprido pelos cidadãos sem questionamentos.

1.3 CONCEITO DE PODER CONSTITUINTE

Com o desenvolvimento da teoria do poder constituinte ao longo da história do direito constitucional, o poder criador, originário, defendido por Sieyès, passou a ser analisado sobre outros ângulos. Considerando-se que Constituição sem mecanismo de reforma é antidireito, e ainda com o surgimento do federalismo americano em 1787, que tem como principal vetor a autonomia dos Estados membros com a sua auto-organização por

4. BONAVIDES, Paulo, ob. cit., p. 148.

meio de uma Constituição, a doutrina refletiu sobre outras necessárias manifestações do poder constituinte, derivadas do poder inicial.

Dai porque o Poder constituinte pode ser conceituado, em síntese, como: o poder que fundamenta a criação de uma nova Constituição, a reforma desse texto constitucional e, nos Estados federativos, o poder que legitima a auto-organização dos Estados Membros por meio de suas próprias constituições, bem como as respectivas reformas aos textos estaduais.

1.4 TITULARIDADE X EXERCÍCIO

Analizando o Poder Constituinte à luz da Constituição de 1988, encontramos a titularidade e o exercício do Poder Constituinte no seu art. 1º, parágrafo único⁵, por meio do qual podemos afirmar que o titular do poder não se confunde sempre com o seu exercente.

De acordo com o dispositivo constitucional citado, a titularidade do poder está nas mãos do povo, mas a exteriorização desse poder pode ser dividida em direta e indireta.

Movidos por seus direitos políticos, o povo toma decisões políticas diretas quando participa de plebiscito, de referendo, ajuíza ação popular, participa de projetos de lei populares, etc. Em suma, quando o povo toma decisões políticas sem necessidade de intermediações, sem representação, diz-se que o exercício do poder está sendo realizado de forma direta. Por sua vez, o exercício indireto é realizado pelos nossos representantes, que recebem o voto para, em nosso nome, tomar as decisões políticas fundamentais para o nosso país. Esse dispositivo constitucional expressa a base democrática em nosso país, com um modelo de democracia semidireta ou participativa.

1.5 PODERES CONSTITUÍDOS

O poder de tomada de decisões políticas fundamentais é uno e indivisível, entretanto, como será analisado em capítulo posterior, para evitar a concentração de poder, manifesta-se por meio das funções legislativa, executiva e judiciária⁶.

5. Art. 1º, parágrafo único da CRFB/88: "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição".

6. Art. 2º, da CRFB/88: "São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário".

Essas manifestações do poder são consagradas como poderes constituídos porque foram desenhados pela vontade da Constituição, fruto do poder constituinte originário. Com isso, os trabalhos legislativo, executivo e judiciário estão subordinados ao texto constitucional. Como exemplos dessa sujeição dos poderes à Constituição, poderíamos concluir: se o legislador elabora leis contrárias à Constituição, o juiz deverá declará-las inconstitucionais (Ex.: art. 102, I, “a”, da CRFB/88); se o chefe do executivo descumprir a Constituição, deverá ser processado na forma do art. 85, da CRFB/88.

1.6 ESPÉCIES DE PODER CONSTITUINTE

Com base no conceito acima exposto, poderíamos dividir o poder constituinte em três manifestações: o Poder Originário (poder criador, de 1º grau) e suas manifestações derivadas (de 2º grau); o Poder Reformador (realizando a alteração formal do texto da Constituição) e o Poder Decorrente (que permitirá, nos estados federativos, a elaboração e reforma das Constituições estaduais).

1.6.1 O Poder Constituinte Originário

É o poder criador, é o poder institucionalizador de uma Constituição central. Podemos dizer que a sua última manifestação no Brasil foi no dia 5 de outubro de 1988, quando da promulgação da nossa atual Constituição.

É claro que se desenha um modelo ideal, num Poder Constituinte Originário sempre pautado na vontade popular. Mas aqui no país nem sempre isso foi possível, diante da nossa história conturbada de ditadura e pseudodemocracias. Então é possível se dizer que o Poder Constituinte Originário se manifestou no Brasil por meio de todas as Constituições de 1824 a 1988⁷.

Por sua vez, em suas manifestações posteriores, o Poder Constituinte originário se manifesta de maneira derivada, dando ensejo ao Poder Constituinte Derivado, com as suas espécies, Reformador e Decorrente.

7. Com a ressalva ao texto da EC 1/69, fruto do poder reformador.

1.6.2 O Poder Constituinte Derivado Reformador

É o que possibilita a reforma formalizada da Constituição. Em nossa Constituição, exterioriza-se por meio das espécies normativas: emendas revisionais (art. 3º, do ADCT) e emendas constitucionais (art. 60, CRFB/88), que serão estudadas em capítulo posterior.

1.6.3 O Poder Constituinte Derivado Decorrente

É o que possibilita, nos estados federativos, a auto-organização dos Estados membros na forma dos arts. 25, da CRFB/88 e art. 11, do ADCT. Frise-se que essa manifestação de poder é peculiar aos Estados Federativos diante da autonomia dos entes que o compõem, não existindo, em regra geral, nos Estados Unitários, que não possuem Constituições Estaduais.

Levando-se em consideração que no Brasil o Distrito Federal e os Municípios também fazem parte da nossa federação, qual seria o poder que fundamenta a elaboração de uma Lei Orgânica do Distrito Federal e de uma Lei Orgânica de Município brasileiro? Segundo a doutrina, seriam fruto do poder constituído legislativo, municipal, tendo em vista que a Câmara Municipal elabora a Lei Orgânica do Município (art. 29, CRFB/88) e distrital, considerando que a Câmara Legislativa elabora a Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 32, CRFB/88).

1.7 CARACTERÍSTICAS

O Poder Constituinte Originário tem como principais características as de ser:

- Inicial
- Ilimitado
- Incondicionado

É inicial, pois inaugura uma nova ordem jurídica, rompendo com o ordenamento jurídico anterior. A partir daí nasce a importância de se analisar o que acontecerá com o ordenamento anterior constitucional e infraconstitucional, objeto do capítulo seguinte. É ilimitado⁸, pois

8. De acordo com a posição jusnaturalista, é possível se identificar valores que devem ser respeitados pelo poder constituinte originário, como os relativos à vida, à liberdade, à

não está de modo algum limitado ao direito positivo anterior, e também incondicionado, pois não tem que se submeter a nenhuma forma pré-fixada para sua manifestação. Nesse sentido, pode surgir de uma revolução, golpe, plebiscito, referendo.

O Poder Constituinte Derivado, por sua vez, possui as seguintes características principais:

- Subordinado
- Condicionado
- Limitado

É subordinado, pois as suas manifestações (reformadora e decorrente) encontram fundamento de validade na Constituição Federal e devem respeitá-la, sob pena de declaração de inconstitucionalidade. A exteriorização das espécies normativas baseadas nesse poder (emendas e normas constitucionais estaduais) deve ser realizada, em razão de seu condicionamento, em harmonia com a Constituição Federal, e as suas limitações se fazem presentes de acordo com as normas que devem ser obedecidas para sua elaboração, bem como ao conteúdo que não podem desrespeitar.

1.8 DIREITO ADQUIRIDO E AS NORMAS DO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO E DERIVADO

O parágrafo 2º do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estatui: “Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.”. Poderíamos asseverar que o direito adquirido é aquele que já se incorporou definitivamente ao patrimônio e/ou à personalidade de seu titular.

De acordo com a liberdade jurídica do poder constituinte originário, não gera debates doutrinários ou jurisprudenciais a posição normalmente aceita de que não há direito adquirido em face das normas constitucionais originárias⁹, diante de suas inúmeras características de ilimitações jurídicas. O ministro Aliomar Baleeiro, sobre o assunto, tem voto curioso: “Uma

igualdade etc.

9. STF, ADI nº 248, Rel. Min. Celso de Mello, J. 1.03.1994, DJU 08.04.1994.

Constituição pode fazer do quadrado redondo, do branco preto, segundo a velha fórmula dos juristas antigos”¹⁰.

Diferente é saber se o direito adquirido existe frente ao que estabelece o chamado Constituinte Derivado, de 2ª grau, limitado, precisamente aquele que altera o ordenamento jurídico através das emendas constitucionais. Sobre o assunto, a doutrina e a jurisprudência não compartilham da mesma opinião.

Na doutrina, José Afonso da Silva e Raul Machado Horta firmam posicionamento no sentido da possibilidade de invocação de direito adquirido em face das emendas constitucionais. Para o primeiro doutrinador: “a reforma constitucional não pode ofender direito adquirido, pois está sujeita a limitações materiais expressas, entre as quais está precisamente a de que não pode pretender abolir os direitos e garantias individuais, e dentre estas está o direito adquirido”¹¹. De acordo com o segundo jurista: “o poder constituinte originário poderá, em tese, suprimir o direito adquirido, de modo geral, incluindo nessa supressão a regra que veda a lei prejudicial de direito adquirido. No caso do poder constituinte de reforma, será questionável a emenda ou revisão que propuser a supressão do direito adquirido assegurado pelo constituinte originário.”¹²

Em sentido contrário, Celso Ribeiro Bastos e José Pinto Ferreira entendem pela impossibilidade de invocação de direito adquirido em face das normas constitucionais derivadas. Para o primeiro jurista: “à emenda ou revisão, pela força de que está revestida de norma constitucional, cabe cassar os direitos adquiridos”¹³ e para o segundo: “a reforma constitucional pode revogar o direito adquirido, visto que tem eficácia revogatória completa”¹⁴.

Em nosso entendimento, em que pese opinião de doutrina abalizada em sentido contrário, é inegável a existência do direito adquirido em face das emendas constitucionais, principalmente em face de dois argumentos, a saber: a) A Constituição de 1988, em seu art.5º, XXXVI, assegurou o direito adquirido como uma garantia individual e a expressão “lei” deve ser

10. STF, RE nº 74.284, RTJ, 66/220.

11. SILVA, José Afonso da. Reforma Constitucional e Direito adquirido *in* Revista de Direito Administrativo, nº 213, 1998, p.131.

12. HORTA, Raul Machado. Constituição e Direito Adquirido *in* Revista Trimestral de Direito Público nº 1, 1993, p. 60.

13. BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil, 1ª ed. Vol. II, São Paulo, Saraiva, 1989, p. 191.

14. FERREIRA, José Pinto. Comentários à Constituição Brasileira, 1ª ed. Vol. I, São Paulo, Saraiva, 1989, p.148.

entendida em sentido material, englobando todas as espécies normativas; b) Os direitos e garantias individuais não podem ser abolidos ou sofrerem restrições por meio das emendas (art.60, § 4º, IV, CRFB/88), ficando clara a impossibilidade do Poder de Reforma violar tal preceito, por ser cláusula pétrea; c) como as emendas estão sujeitas ao controle de constitucionalidade, podem vir a ser declaradas inconstitucionais caso violem os direitos adquiridos.

O assunto, entretanto, não é também pacífico na jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal, antes da promulgação da Constituição de 1988, decidiu pela inexistência de direito adquirido contra texto constitucional, resulte ele do poder constituinte originário ou do poder constituinte derivado¹⁵. Na vigência da atual Constituição, a Corte já se manifestou pela declaração de inconstitucionalidade de emenda constitucional que violasse direito adquirido¹⁶.

Hodiernamente, entretanto, entendemos que a posição do STF, com o advento da Emenda Constitucional nº. 41/2003 (a “taxação dos inativos”), e com o julgamento das ADI’s 3105 e 3128, é no sentido da inexistência de direito adquirido em face das emendas constitucionais, como concluímos de acordo com os argumentos a seguir expostos.

A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP e a Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR, ajuizaram no STF Ações Diretas de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar — respectivamente, ADI 3105 e ADI 3128 —, pedindo, ambas, a declaração da inconstitucionalidade do art. 4º da Emenda Constitucional nº. 41, de 19 de dezembro de 2003¹⁷.

Em seus argumentos, alegaram que a norma impugnada contrariava o disposto no art. 5º, inciso XXXVI da CRFB/88, uma vez que houve afronta ao direito adquirido dos servidores inativos à não incidência da contribuição previdenciária. Argumentaram que os servidores públicos aposentados e aqueles que reuniam os requisitos necessários à inativação, antes da promulgação da Emenda Constitucional nº. 41/2003, estavam submetidos, quando das suas aposentadorias ou do momento em que poderiam se

15. STF, RE n. 94.414, Rel.Min. Moreira Alves, DJU de 19.04.85.

16. STF, ADI 939, Rel. Min.Sydney Sanches, J. 15.12.1993, RDA 198/123.

17. Eis o art. 4º da referida Emenda: “Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo de benefícios na data de publicação desta Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no seu art. 3º, contribuirão para o custeio do regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos”.

aposentar, a regime previdenciário que não tinha caráter contributivo ou solidário (antes da Emenda Constitucional nº. 20, de 15 de dezembro de 1998), ou apenas tinha caráter contributivo (depois dessa mesma Emenda Constitucional nº. 20, de 1998). Assim, em decorrência de tais circunstâncias, tinham eles incorporado a seu patrimônio o direito de não contribuírem para a Previdência Social.

O polêmico assunto foi decidido com o julgamento das ações diretas pela sua improcedência, sob o argumento, em síntese, de que não haveria norma de natureza tributária absoluta, ou seja, não existiria em nosso ordenamento jurídico nenhuma norma válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões de modo absoluto à tributação da ordem constitucional, qualquer que seja o tributo eleito, donde não haver a respeito direito adquirido com o aposentamento.¹⁸

Mesmo diante da complexidade do tema, aqui tratado de maneira sucinta, entendemos que os servidores inativos possuem efetivamente direito adquirido à não incidência da contribuição previdenciária, concluindo no sentido de que a posição do STF nesses julgamentos foi pela inexistência de direito adquirido em face de emenda à Constituição, opinião já manifestada pela Corte em julgados anteriores sobre o tema.¹⁹

18. STF, ADI 3105, Min. Rel. Ellen Gracie, J.18.08.2004 e DJU 18.02.2005; STF, ADI 3105, Min. Rel. Ellen Gracie, J.18.08.2004 e DJU 18.02.2005.

19. STF, RE n. 95.175, Rel.Min. Soares Muñoz, J. 20.04. 1982 e STF, RE n. 94.414, Rel.Min. Moreira Alves, DJU de 19.04.85.

CAPÍTULO 2

A NOVA CONSTITUIÇÃO E O DIREITO ANTERIOR

2.1 INTRODUÇÃO

Com a chegada de uma nova Constituição, inaugura-se um momento também novo na vida de um país e, por isso, faz-se imperiosa a análise sobre o que acontece com as normas preexistentes, constitucionais e infraconstitucionais. Em nome da supremacia constitucional e da importância que a Constituição desfruta no ordenamento jurídico, serão as normas que a precederam mantidas perante a nova ordem constitucional, ou perderão seus efeitos jurídicos?

Serão estudados a seguir os fenômenos da revogação global e da desconstitucionalização, acerca da influência da nova Constituição sobre o ordenamento constitucional anterior e ainda a recepção (e a não-recepção) e a repristinação, exemplos de fenômenos que podem ocorrer com as normas infraconstitucionais anteriores quando da chegada da nova Constituição.

2.2 A TEORIA DA REVOGAÇÃO GLOBAL

No Brasil, entre um ordenamento constitucional novo e as normas constitucionais anteriores sempre se operou o fenômeno da revogação global, que significa dizer que a Constituição nova revoga a Constituição que a antecedeu, deixando esta última de produzir seus efeitos jurídicos. Como são normas de mesma hierarquia e versam sobre matéria constitucional, aplica-se o princípio geral do direito no sentido de que a lei nova revoga completamente a anterior.

O fenômeno é simples de entender se consideramos a instabilidade da vida política do país, num contexto que sempre oscilou entre regime ditatorial (civil ou militar com a pseudodemocracia). Nada impede, entretanto, que com base na liberdade jurídica do Poder Constituinte Originário, outro fenômeno venha a ser adotado no Brasil.

2.3 A TEORIA DA DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO

A desconstitucionalização ocorre quando a nova Constituição dispõe que alguns (ou até mesmo todos) dispositivos da ordem constitucional anterior serão mantidos válidos perante o novo ordenamento, mas não sob a forma de Constituição, e sim sob a forma de norma infraconstitucional. Não é um fenômeno automático e, para acontecer, deverá vir expresso no novo texto da Constituição. Ressalte-se que até o momento não foi acolhido pelo

direito constitucional brasileiro tendo sido já adotado pelo direito português na Constituição de 1976²⁰.

2.4 A TEORIA DA RECEPÇÃO E DA NÃO RECEPÇÃO

Apesar de a CRFB/88 ter revogado toda a Constituição que a precedeu, não poderia jamais ter revogado todas as normas infraconstitucionais elaboradas antes da sua existência. Com a ausência de leis, teríamos, além de uma desconsideração completa à história legislativa do país, possivelmente um governo de tiranos. Então, o que de fato ocorre com as normas ordinárias preexistentes?

Segundo a teoria dominante no Brasil, se houver compatibilidade de conteúdo, assunto, com a nova Constituição, as normas do direito ordinário anterior serão bem-vindas e recebidas perante a nova ordem constitucional e continuarão a produzir completamente seus efeitos jurídicos. Se, por sua vez, não existir harmonia de conteúdo, as normas não serão recebidas. É o que o trata os fenômenos da recepção e da não-recepção.

A recepção é um fenômeno de natureza material porque não analisa o processo legislativo que fundamentou a elaboração da norma, fixando-se na análise de seu conteúdo, pois, se o olhar da Constituição sobre o ordenamento anterior fosse muito rigoroso, pouquíssimas seriam as normas efetivamente recepcionadas. Além do que, a norma que vai reger o processo legislativo é a que existia no momento de sua elaboração e não as normas de uma Constituição futura. Por isso a recepção vai analisar o conteúdo da lei: se este for compatível com os princípios e as regras da nova Constituição, vai ser mantido; não sendo compatível, vai ser afastada, deixando de produzir seus efeitos jurídicos. A recepção é um fenômeno automático, tendo sido previsto expressamente apenas na Constituição brasileira de 1937²¹.

As normas anteriores, incompatíveis formalmente com a nova Constituição serão por ela recebidas se houver compatibilidade material e passarão a ter

20. Constituição de Portugal de 1976. Artigo 290.º: (Direito anterior)

1. As leis constitucionais posteriores a 25 de Abril de 1974 não ressalvadas neste capítulo são consideradas leis ordinárias, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2. O direito ordinário anterior à entrada em vigor da Constituição mantém-se, desde que não seja contrário à Constituição ou aos princípios nela consignados.

21. O art. 183 da Constituição brasileira de 1937 dizia: “Continua em vigor, enquanto não revogadas, as leis que explícita ou implicitamente não contrariarem as disposições desta Constituição”.

status formal determinado pelo novo ordenamento constitucional. Podemos citar, como exemplos, o Código Tributário Nacional²² – CTN, o Código Penal Brasileiro²³ – CP e o Código de Processo Penal²⁴ – CPP. O CTN foi feito sob a forma de lei ordinária e a Constituição de 1988 determina que as normas gerais tributárias sejam tratadas por lei complementar²⁵, por sua vez, decreto-lei não é espécie normativa presente no novo ordenamento constitucional e as matérias do direito penal e processual penal devem ser cuidadas por leis ordinárias federais²⁶. Com a nova determinação constitucional, as normas citadas foram recebidas naquilo que não contrariavam materialmente a nova Constituição e as suas alterações futuras só podem ser realizadas de acordo com o novo processo legislativo previsto na CRFB/88.

As normas não compatíveis materialmente com a nova Constituição²⁷, como já dissemos, não serão recepcionadas. Mas não serão mantidas dentro do novo sistema porque são inconstitucionais ou porque foram revogadas?

Segundo posição dominante no STF²⁸, o momento de aferição da constitucionalidade/inconstitucionalidade que analisa o plano de validade da norma é realizado em sua origem, de acordo com a Constituição vigente à época de sua elaboração. Com isso, norma válida (constitucional) não se torna inválida (inconstitucional) com a superveniência de uma nova Constituição. Em face da incompatibilidade material com a nova Constituição, deixará

22. Lei nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966

23. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940

24. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941

25. Art. 146 da CRFB/88: “Cabe à lei complementar:

(...) III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre...”

26. Art. 22 da CRFB/88:

“Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho”.

27. Como exemplo de normas não-recepcionadas por serem contrárias ao princípio da igualdade entre homens e mulheres presente no art. 5º, I, da CRFB/88: anulação de casamento por defloração da mulher e a disposição que previa que o marido era chefe da sociedade conjugal, ambas presentes no Código Civil de 1916, a seguir expostas:

“Art. 218. É também anulável o casamento, se houver por parte de um dos nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro.

“Art. 219. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge:

(...) IV - o defloração da mulher, ignorado pelo marido”.

“Art. 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce com a colaboração da mulher, no interesse comum do casal e dos filhos (arts. 240, 247 e 251). (Redação dada pela Lei nº 4.121, de 27.8.1962)”

28. STF, ADI nº 438, Min. Rel. Sepúlveda Pertence, J. 07.02.1992, DJU 27.03.92

de produzir seus efeitos jurídicos por força da revogação. Nesse mesmo sentido, Luís Roberto Barroso²⁹ e Gilmar Ferreira Mendes³⁰.

De acordo com o trecho do voto do Min. Paulo Brossard, é possível se observar a jurisprudência ainda dominante no STF:

"É cediço na doutrina, quanto na jurisprudência que a inconstitucionalidade se afere em relação à Constituição contemporânea ao ato impugnado. A nova ordem constitucional revoga a norma por ela não ser recebida por motivo de incompatibilidade. Não torna, evidentemente, inconstitucional o que antes nascera sem esse vício"[...]”³¹

2.5 A TEORIA DA REPRISTINAÇÃO

De acordo com o art. 2º, §3º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro³², uma lei validamente revogada não volta a produzir efeitos jurídicos com a revogação da lei que a revogou. Esse é um fenômeno salutar de sucessão legislativa no país. A sociedade muda e as normas precisam acompanhá-la, sob pena de descompasso temporal entre a realidade e as leis.

Entretanto, conforme a parte inicial do dispositivo da referida Lei, é possível que mediante disposição expressa a lei nova, revogadora de outra, que revogou a que a antecedeu, poderá “repristinar” (restaurar os efeitos jurídicos) de uma norma já revogada, realizando o fenômeno da repristinação, que não se confunde com os efeitos repristinatórios, presentes na Lei nº 9868/99³³, que serão estudados no capítulo referente ao controle de constitucionalidade.

29. Barroso, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, 2ª ed. Saraiva, São Paulo, 2006, p. 29.

30. Mendes, Gilmar Ferreira; Coelho, Inocêncio Mártires e Branco, Paulo Gustavo Gonet. Em Curso de Direito Constitucional, 2ª ed., Saraiva, São Paulo, 2008, p. 1015.

31. STF, ADI nº 2, Min. Rel. Paulo Brossard, J. 06.02.1992, DJ de 21.11.97

32. “Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência”.

33. “Art. 11. §2º: A concessão da medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa”.

CAPÍTULO 3

CONCEPÇÕES SOBRE A CONSTITUIÇÃO

3.1 INTRODUÇÃO

Numa linguagem informal, todas as coisas materiais possuem a sua própria constituição: a mesa pode ser de ferro ou de madeira; a caneta pode ser azul ou vermelha, o vestido, rosa ou branco, enfim, os objetos normalmente possuem uma constituição que lhes define a própria estrutura, cor, profundidade e não é diferente com um Estado.

A Constituição, lei fundamental que é, coração de todo o ordenamento jurídico, tem como papel mais importante o de caracterizar as singularidades de um país, reunindo as suas principais feições, como por exemplo: a sua forma de Estado e de Governo, a Organização dos poderes do Estado, os direitos e garantias fundamentais que devem ser protegidos ao seu povo ou até mesmo as metas que devem ser cumpridas pelos governantes³⁴. É conhecendo a Constituição de um Estado que aprendemos um pouco mais sobre os seus costumes, política e a sua própria história.

O verdadeiro sentido ou concepção de uma "Constituição" sempre despertou muitas controvérsias e, na realidade não temos uma única teoria chave, servindo as teorias a seguir apresentadas fonte de maior destaque sobre o tema que gera muitas controvérsias.

3.2 SENTIDO SOCIOLÓGICO

Segundo Ferdinand Lassale, a Constituição seria resultado dos fatores reais do poder. Em sua obra "Qué es una constitución?", traduzida como "A Essência da Constituição",³⁵ Lassale defende que a Constituição é a realidade, o somatório dos fatores econômicos, culturais, sociais e políticos de uma sociedade e, se não obedecesse a esses fatores, não passaria de uma mera folha de papel.

Com base em seus escritos poderíamos fazer a seguinte análise: imagine que só há em um país dois textos escritos de uma Constituição: um na casa do rei e outro na biblioteca pública. Num dado momento, a biblioteca pega fogo e a casa do rei inunda. Os textos constitucionais, os únicos naquele país, desaparecem. Bem, se essa Constituição for formada pelos fatores reais do poder, mesmo na inexistência do texto escrito, ela vai ser seguida porque o que a respalda não é o documento escrito, é a sua motivação popular. Mas

34. Numa Constituição dirigente como a nossa, essas normas se fazem muito presentes.

35. Lassalle, Ferdinand. A Essência da Constituição, 6ª ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2001.

se, em contrapartida, essa Constituição for filha da tirania, fruto unilateral apenas de quem estava no poder, com o desaparecimento desses textos escritos, haverá uma desordem e ninguém irá cumprir os postulados do texto ilegítimo.

É uma visão mais marxista e social da concepção de Constituição. É como se fosse uma Constituição que não traduzisse exatamente o que está na sociedade; ela não seria uma Constituição, não passaria de uma mera folha de papel!

3.3 SENTIDO POLÍTICO

De acordo com Carl Schmitt em sua obra “Teoría de la Constitución”³⁶ a Constituição seria uma decisão política fundamental, que comporta matérias como a estrutura e órgãos do Estado, direitos individuais, entre outros. O referido autor distingue Constituição (decisão política fundamental) das leis constitucionais, que seriam os demais dispositivos do texto constitucional não relacionados a esse tema. Com base nesse conceito se visualizam normas materialmente constitucionais e formalmente constitucionais.

As normas materialmente constitucionais seriam aquelas que não poderiam deixar de estar presentes em um texto constitucional e as demais são intituladas de leis constitucionais. O jurista alemão faz uma separação cartesiana: a Constituição é a norma hierárquica fundamental e que as outras leis constitucionais estão subordinadas a elas pela matéria. Se a norma trata de conteúdo político essencial é Constituição, senão é lei constitucional.

Analisando a Constituição de 1988 pelo prisma de Schmitt, teríamos, por exemplo, do artigo 1º ao 4º (princípios fundamentais) normas essencialmente (ou materialmente) constitucionais e por sua vez o art. 242, §2º³⁷ seria para Schmitt, em nossa opinião, uma lei constitucional; não estaria dentro do aparelho que o jurista alemão designava ser uma Constituição.

No Brasil essa teoria foi acolhida apenas na Constituição de 1824, que no seu art. 178³⁸ fazia distinção entre a natureza das normas constitucionais.

36. Schmitt, Carl. “Teoría de la Constitución”, Madrid: Alianza Editorial, 1992.

37. “Art. 242, § 2º, da CRFB/88: O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal”.

38. “Art. 178 da Constituição de 1824: É só Constitucional o que diz respeito aos limites, e atribuições respectivas dos Poderes Políticos, e aos Direitos Políticos, e individuais dos Cidadãos. Tudo o que não é Constitucional pode ser alterado sem as formalidades referidas, pelas Legislaturas ordinárias”.

3.4 SENTIDO JURÍDICO-NORMATIVO

Segundo a teoria positivista de Hans Kelsen, o fundamento do direito não é transcendental ao homem e à sociedade, mas se encontra no pressuposto lógico (a norma fundamental) de que as leis são válidas e devem ser obedecidas, quando forem editadas segundo um processo regular (isto é, organizadas por regras aceitas pela comunidade) e pela autoridade competente, legitimada de acordo com princípios também anteriormente estabelecidos e aceitos. É a explicação formal da validade do direito.

No início do século XX, Kelsen relata em famosa obra "Teoria Pura do Direito"³⁹, uma concepção de ciência jurídica com a qual se pretendia finalmente ter alcançado, no Direito, os ideais de toda a ciência: objetividade e exatidão. Visando alcançar essa finalidade, o eminente jurista propôs como regra metodológica principal a extração de qualquer conteúdo valorativo da norma, com a finalidade de garantir autonomia científica para a disciplina jurídica, que, segundo ele, vinha sendo, ao longo dos anos, deturpada pelos estudos sociológicos, filosóficos e políticos. É o próprio Kelsen que reconhece:

"A norma fundamental de uma ordem jurídica não é de forma alguma uma norma de justiça. Por isso, o direito positivo, isto é, uma ordem coativa criada pela via legislativa ou consuetudinária e globalmente eficaz, nunca pode estar em contradição com a sua norma fundamental, ao passo que esta ordem pode muito bem estar em contradição com o direito natural, que se apresenta com a pretensão de ser o direito justo" 40 (grifos nossos).

Essa concepção que acaba retratando a supremacia formal da Constituição, que sempre foi de extrema importância para a ciência do direito, hoje é analisada à luz da abertura das Constituições aos princípios no pós-guerra, pois é inegável que os valores, a moral e a ética são também importantes para a análise do direito.

39. Kelsen, Hans. *Teoria Pura do Direito*. 5ª ed. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

40. KELSEN, Hans - A Justiça e o Direito Natural. Tradução de João Baptista Machado. Coimbra: Armenio Amado, 1963, pág. 170.

3.5 OUTRAS CONCEPÇÕES

Além desses três sentidos clássicos de Constituição, é possível mencionarmos outros. Vejamo-los:

a) **Conceito Ideal de Constituição:** de acordo com o art. 16 da Declaração Francesa de 1789, “A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição”. Essa é uma concepção de valor da Constituição, justamente em oposição à visão positivista formalista do ordenamento jurídico;

b) **Sentido jusnaturalista:** a Constituição seria concebida de acordo com as leis naturais, anteriores à própria existência humana;

c) **A concepção de Constituição Total:** de acordo com Canotilho⁴¹, a Constituição é repleta de diferentes significados e não deve ser estudada isoladamente, pois se relaciona com outras categorias políticas e conjuntos sociais;

d) **A concepção de Konrad Hesse** em “A Força Normativa da Constituição”⁴² também contribui para o sentido axiológico de Constituição e destaca a peculiar força normativa que todas as normas do texto constitucional possuem para ordenar e conformar a realidade político-social de um país.

41. GOMES CANOTILHO, J.J. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*, Coimbra: Livraria Almedina, 6ª ed, 2002, p. 39/40.

42. HESSE, Konrad. *A força normativa da Constituição*, Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, tradução de Gilmar Ferreira Mendes, 1991.

CAPÍTULO 4

CLASSIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO



4.1 A IMPORTÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO

Da mesma maneira que destacamos no capítulo anterior a importância da análise sobre as diversas concepções da Constituição, a sua classificação ou tipologia é assunto de grande destaque na teoria geral do direito constitucional. Ao conhecermos um pouco mais das características das normas constitucionais de um país, também aprendemos um pouco mais sobre a história, a cultura, os poderes e as funções estatais e as suas peculiaridades.

Podemos adotar com apoio na doutrina prestigiada vários parâmetros classificatórios, mas escolhemos como principais, sem esgotar o tema, os seguintes: forma, origem, modo de elaboração, extensão, alterabilidade, conteúdo, finalidade e quanto à correspondência com a realidade, a seguir expostos.

4.2 QUANTO À FORMA

- Escritas (instrumentais ou positivas)
- Não escritas (costumeiras)

A forma é a maneira que se exterioriza alguma coisa, o seu próprio estereótipo. Sob esse prisma, as Constituições se dividem em escritas e não escritas. As primeiras estariam inteiramente codificadas e sistematizadas em um documento único intitulado de Constituição. A maior parte dos países que possui organização constitucional traz constituições escritas. As não escritas possuem muitas vezes documentos escritos, mas que não estão codificados e sistematizados em único texto, possuindo como fonte de Constituição os tratados, convenções, usos e costumes. Como exemplo dessas Constituições mais raras, teríamos as da Inglaterra, Israel e Nova Zelândia.

4.3 QUANTO À ORIGEM

- Promulgadas (democráticas ou populares)
- Outorgadas
- Cesaristas

As promulgadas são chamadas de democráticas ou populares, porque advêm da vontade do povo, manifestada diretamente ou indiretamente por uma Assembleia Nacional Constituinte. Essas são Constituições que em nossa opinião seguem exatamente a teoria do Poder Constituinte originário do Abade de Sieyès. As Constituições promulgadas são as verdadeiras Constituições legítimas que expressam a vontade do povo. As Constituições outorgadas, por sua vez, são impostas, autocráticas e frutos de ato unilateral de quem está no poder, sem prévia consulta popular.

O Brasil já vivenciou os dois modelos, as Constituições de 1824, 1937, 1967, EC 1/69 foram outorgadas pelos dirigentes à época e os demais textos: 1891, 1934, 1946 e 1988 foram promulgados pelas Assembleias Nacionais Constituintes.

José Afonso da Silva⁴³ ainda destaca a existência de Constituições cesaristas, que não seriam nem propriamente promulgadas e nem outorgadas, pois a participação popular visava apenas ratificar a vontade do detentor do poder. Destaca como exemplos os plebiscitos napoleônicos e ainda o plebiscito de Pinochet, no Chile.

4.4 QUANTO AO MODO DE ELABORAÇÃO

- Dogmáticas
- Históricas

Quanto ao Modo de Elaboração uma Constituição pode ser: Dogmática ou Histórica (ainda denominada de costumeira ou consuetudinária). A primeira é uma Constituição momentânea, que reflete o máximo de ideais políticos predominantes no momento de sua elaboração. É a Constituição chamada normalmente pela doutrina de momentânea e instável. É a história das Constituições Brasileiras. Normalmente são também escritas. As demais são construídas e sedimentadas ao longo da vida de um país, têm compromisso com as tradições e história de um determinado povo, são mais estáveis e normalmente não escritas (a da Inglaterra, por exemplo).

43. AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito Constitucional Positivo, 23ª ed, Malheiros, São Paulo, 2004, p. 42.

4.5 QUANTO À EXTENSÃO

- Analíticas
- Sintéticas

As Constituições mais extensas são consideradas analíticas (prolixas), como é o caso da CRFB/88, que possui 250 (duzentos e cinquenta) artigos no corpo fixo, e ainda 95 (noventa e cinco) na parte transitória. A Constituição da Índia também seria um exemplo desse modelo, possuindo 395 (trezentos e noventa e cinco) artigos apenas no seu corpo fixo. Normalmente esses textos extrapolam as matérias consideradas essencialmente constitucionais e versam sobre tantos outros assuntos que entendem relevantes para o país. Em contraposição, as Constituições sintéticas ou breves são mais concisas e tratam, em regra, apenas de matéria essencialmente constitucional, por isso possuem um número reduzido de dispositivos (A Constituição americana de 1787, por exemplo).

4.6 QUANTO AO CONTEÚDO

- Materiais
- Formais

As Constituições materiais são Constituições que consagram como normas constitucionais todas as leis, tratados, convenções desde que tratem de assunto essencialmente constitucional (ou materialmente constitucionais), estejam ou não consagradas em um documento escrito. A Constituição Inglesa é um exemplo, pois reconhece como fonte constitucional as disposições que versam sobre decisão política fundamental presentes em tratados, usos e costumes. A Constituição da Austrália, apesar de ser uma Constituição escrita, quanto ao conteúdo podemos dizer que é material, porque vários assuntos importantes relativos à nacionalidade, direitos políticos e demais direitos fundamentais estão espalhados nos diversos "Acts".

No Brasil, pode-se dizer que a única Constituição material foi a de 1824, de acordo com a separação entre as normas constitucionais feita no já citado art. 178⁴⁴, porque fazia uma clara distinção entre o conteúdo de suas normas e privilegiava e destacava o conteúdo das decisões políticas fundamentais ainda que em detrimento do conteúdo dos demais dispositivos.

A partir de 1891 o país passou a adotar Constituições formais, sem divisão entre as suas normas, privilegiando a forma, o estereótipo em privilégio ao conteúdo de seus dispositivos. É claro que se analisa a essência das normas, mas não há distinção hierárquica alguma entre as normas que estão em nossa Constituição. A Constituição é um todo harmônico que não possibilita verdadeiras antinomias entre os seus dispositivos. Em regra, as Constituições escritas são também formais.

4.7 QUANTO À ALTERABILIDADE

- Imutáveis
- Super-Rígidas
- Rígidas
- Semirrígidas
- Flexíveis

Nesse subitem nós analisaremos qual é o processo de alteração da Constituição, que classicamente promoveu a divisão tripartida: flexíveis, semirrígidas ou rígidas.

Se as normas constitucionais puderem ser alteradas pelo procedimento simplificado, por um procedimento legislativo comum ordinário, ela vai ser chamada de flexível. As semirrígidas adotam um modelo híbrido de alteração porque parte do texto, normalmente os dispositivos materialmente constitucionais, só podem ser alterados por um procedimento mais rigoroso e a parte flexível normalmente é formada pelas normas formalmente constitucionais.

As Constituições rígidas só podem ser alteradas por um procedimento legislativo mais solene e dificultoso do que o existente para as demais normas jurídicas que se vinculam em regra a Constituições Escritas. A rigidez

44. Art. 178 da Constituição de 1824: “É só Constitucional o que diz respeito aos limites, e atribuições respectivas dos Poderes Políticos, e aos Direitos Políticos, e individuais dos Cidadãos. Tudo o que não é Constitucional pode ser alterado sem as formalidades referidas, pelas Legislaturas ordinárias”.

constitucional está associada à hierarquia das leis, a supremacia formal da Constituição e ao controle de constitucionalidade, como analisaremos em capítulo destinado ao tema. Entretanto, é imperioso não confundir rigidez com estabilidade. A Constituição de 1988 é rígida porque o seu mecanismo de reforma é diferenciado do processo legislativo ordinário, na forma do art. 60, entretanto, até o momento⁴⁵, já sofreu, em sua jovem história, 93 (noventa e três) emendas constitucionais e 6 (seis) emendas de revisão, não podendo ser considerada estável...

Normalmente as Constituições flexíveis estão associadas às não escritas e como no Brasil nunca tivemos uma Constituição não escrita, então a rigidez sempre esteve presente em nosso ordenamento jurídico (ainda que a Constituição de 1824 tenha adotado uma semirrigidez, presente no dispositivo supramencionado, art. 178).

Alexandre de Moraes⁴⁶ adota ainda a teoria da super-rigidez constitucional, assim classificando quanto à alterabilidade a CRFB/88 em razão de suas cláusulas pétreas (art. 60, §, 4º).

As imutáveis são as Constituições não passíveis de qualquer modificação. Na verdade, poderíamos considerá-las antidireito, pois sem mecanismo de reforma não possuem oxigênio suficiente para acompanhar as diversas mudanças que um país enfrenta ao longo de sua história⁴⁷.

4.8 QUANTO À FINALIDADE

- Dirigentes (sociais ou programáticas)
- Garantias (negativas ou liberais)

As Constituições dirigentes nascem com a evolução dos Estados Sociais. São textos mais compromissórios e determinam atuação positiva por parte do Estado na concretização das políticas públicas. Em regra são também analíticas. Por sua vez, as negativas cuidam apenas daquelas normas que não poderiam deixar de estar expressas numa Constituição. Destacam-se no

45. Precisamente até o dia 7 de outubro de 2016.

46. MORAES, Alexandre de. Curso de Direito Constitucional, 23ª ed. Atlas, São Paulo, 2008, p.6.

47. Pode-se dizer que durante quatro anos, contados de sua publicação, a Constituição de 1824 foi imutável: “Art. 174. Se passados quatro anos, depois de jurada a Constituição do Brasil, se conhecer que algum dos seus artigos merece reforma, far-se-á a proposição por escrito, a qual deve ter origem na Câmara dos Deputados, e ser apoiada pela terça parte deles”.

período inicial da consagração dos direitos relativos às liberdades públicas e políticas nos textos constitucionais, já que impunham a omissão ou negativa de ação por parte dos países. São normalmente sintéticas.

4.9 QUANTO À CORRESPONDÊNCIA COM A REALIDADE

- Normativas
- Nominativas
- Semânticas

Segundo o constitucionalista alemão Karl Loewenstein⁴⁸, as Constituições podem ser classificadas ainda de acordo com a sua correspondência ou não com a realidade de um país. As normativas estão em consonância com a vida do Estado e conseguem efetivamente regular a vida política do Estado; as nominativas não conseguem efetivamente cumprir o papel de regular a vida política do Estado, apesar de elaboradas com este intuito e, as semânticas, desde a sua elaboração não têm o objetivo de regular a vida política do Estado, limitando-se apenas em dar legitimidade formal aos atuais detentores do poder. Apesar de certa divergência doutrinária, entendemos que a Constituição de 1988 ainda não conseguiu atingir os seus objetivos principais, portanto pode ser considerada nominativa.

4.10 A CLASSIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988

Com base nas explicações acima desenvolvidas, pode-se classificar a Constituição de 1988 como: escrita, promulgada, dogmática, analítica, formal, rígida (ou super-rígida), dirigente e nominativa.

48. LOEWENSTEIN, Karl, Teoria de la Constitucion, Barcelona, Editorial Ariel, 1976.

CAPÍTULO 5

LIMITAÇÕES AO PODER DE REFORMA



5.1 LIMITAÇÕES AO PODER DE REFORMA

Como a Constituição de 1988 é rígida (ou super-rígida segundo alguns autores), adota um procedimento mais formal e dificultoso para a sua alteração. E este procedimento se encontra no art. 60, que apresenta uma série de limitações que devem ser observadas, como a seguir apresentamos.

- **Temporais** – Segundo doutrina majoritária, não há limitações dessa natureza no art. 60. A Constituição Imperial de 1824 foi a única que trouxe limitações temporais, fixando no art. 174 que nos 4 anos posteriores à outorga da Constituição esta não poderia sofrer qualquer alteração. Com isso, podemos afirmar que desde a data de sua promulgação a Constituição de 1988 poderia ter tido reformas.
- **Limitações de ordem material (explícitas e implícitas)** § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
 - I – a forma federativa de Estado;
 - II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
 - III – a separação dos Poderes;
 - IV – os direitos e garantias individuais.

As limitações materiais expressas do art. 60, § 4º, recebem o nome na doutrina de cláusulas pétreas, mas, na verdade, não significa que são dispositivos alheios a qualquer tipo de reforma. Pelo contrário, as emendas mais protetoras são muito bem-vindas⁴⁹. Como as cláusulas pétreas evitam a ruptura com os princípios e estrutura essenciais da Constituição, o que não se permite é a alteração que vise restringir ou abolir os direitos protegidos pelos dispositivos, que serão a seguir analisados.

I – a forma federativa de Estado

Consagrada como cláusula pétrea desde a Constituição de 1891, a forma federativa de Estado é uma das principais características do Estado brasileiro e representa a divisão geográfica do poder político no território nacional.

São características de destaque das Federações: o sistema de repartição de competências e a autonomia de seus entes federativos, sendo esse, portanto, o núcleo principal da proteção desse dispositivo. Mas será que todas as PECs que visem a modificar uma regra da repartição de competência ofenderá a

49. Foi o caso da EC no 45/2004, que acrescentou ao art. 5º a razoável duração do processo como garantia fundamental (LXXVIII).

forma federativa de Estado? A resposta é negativa, desde que a reforma mantenha a autonomia do ente federativo inabalada. Um exemplo é o da EC 69/12, que destinou ao Distrito Federal a responsabilidade pela organização da sua Defensoria Pública, matéria esta até então sob a responsabilidade da União Federal.

Poderíamos, em síntese, afirmar que fere cláusula pétrea a PEC que vise a: extinguir o Senado Federal, que é o órgão federativo por excelência; transferir competências de uma esfera da Federação para a outra, sem que se resguarde a autonomia da entidade federativa; violar o princípio da imunidade tributária recíproca entre os entes da Federação⁵⁰, transformar o Brasil em um Estado unitário, instituir a secessão dos entes, entre outras reformas que agridam às características federativas principais.

Também nesse sentido de preservação do pacto federativo, o STF decidiu que: “Na espécie, cuida-se da autonomia do Estado, base do princípio federativo amparado pela Constituição, inclusive como cláusula pétrea (art. 60, § 4º, I). Na forma da jurisprudência desta Corte, se a majoração da despesa pública estadual ou municipal, com a retribuição dos seus servidores, fica submetida a procedimentos, índices ou atos administrativos de natureza federal, a ofensa à autonomia do ente federado está configurada” (RE 145.018/RJ, Rel. Min. Moreira Alves; Rp 1.426/RS, Rel.a Min.a Néri da Silveira; AO 258/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, entre outros).

II – o voto direto, secreto, universal e periódico

O voto é uma das expressões mais significativas do direito de participação política (o “sufrágio”) e de acordo com a proteção constitucional presente nesse dispositivo, é possível concluir que: em nome do princípio da liberdade de convicção política o voto não pode se tornar aberto, o que facilitaria pressões políticas e econômicas ao eleitor e também não poderia estabelecer discriminações arbitrárias ao exercício desse importante direito político, o que vedaria, por exemplo, em nome do voto universal, fixação de restrições à alistabilidade do analfabeto ou das pessoas mais humildes.

O nosso voto é direto. Portanto, qualquer tentativa de inserir na Constituição um Colégio Eleitoral para eleger os nossos representantes não será bem-vinda⁵¹.

50. STF, ADI 939/DF, Plenário, Min. Rel. Sydney Sanches, j. 15.12.1993, DJ 18.03.94.

51. Destacamos que há uma hipótese apenas de votação indireta no país, prevista em caso de vacância nos dois últimos anos do período presidencial, na forma do art. 81, § 1º, da CRFB/88.

O voto também é periódico, numa estreita vinculação à forma de governo existente no país, pois a República é caracterizada pela temporariedade dos mandatos, consagrada em eleições periódicas. Então, eventual PEC que venha a restringir o voto periódico, estabelecendo, por exemplo, a forma monárquica de governo, não deverá ser aceita.

Será que há impedimento jurídico a que uma proposta de emenda constitucional venha a instituir o voto facultativo no Brasil? Em princípio não, porque a obrigatoriedade formal do comparecimento do eleitor às urnas não é cláusula pétrea, estando presente apenas no art. 14, § 1º, da CRFB/88.

Também é importante frisar que o voto protegido como cláusula pétrea se refere ao que é realizado pelo eleitor no exercício dos seus direitos políticos. A EC 76/2013, inclusive, alterou os artigos 55, § 2º e 66, § 4º, da CRFB/88, tornando o voto da cassação dos parlamentares e da derrubada do veto do Presidente, que antes era sigiloso, em aberto. Não há nenhuma violação à cláusula pétrea.

III – a separação dos Poderes

A teoria da separação dos poderes será analisada em capítulo específico, mas destacaremos nesse ponto a decisão do STF no julgamento da ADI 3.367⁵², no que tange à criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade em destaque, contrariando o art. 103-B, que criou o CNJ, alegando, entre diversos fundamentos, que a composição híbrida do Conselho⁵³, com representantes que não pertencem ao Poder Judiciário,

52. STF, ADI 3.367/DF, Plenário, Min. Rel. Cezar Peluso, j. 13.04.2005, DJ 17.03.2006.

53. Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de quinze membros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e seis anos de idade, com mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004.)

I – um Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo respectivo tribunal;
 II – um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal;
 III – um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal;
 IV – um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
 V – um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
 VI – um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
 VII – um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
 VIII – um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;
 IX – um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;
 X – um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República;

feriria a separação e harmonia entre os Poderes. O STF não acolheu o pedido de inconstitucionalidade da norma entendendo que a criação do referido órgão não ofendeu a cláusula pétrea questionada, pois não afetou o núcleo das funções jurisdicionais típicas do Poder Judiciário. Além do que, segundo a Corte, as funções do advogado e do membro do Ministério Público são atividades consagradas em sede constitucional e a sua participação no Conselho só reforça a natureza democrática do instituto.

Como as imunidades parlamentares (arts. 53 a 56 da CRFB/88) e as prerrogativas do Executivo (art. 86) estão relacionadas ao exercício independente das suas funções constitucionais, podemos concluir que abolir as cláusulas que dispõem sobre esses institutos seria inconstitucional por violar a separação de poderes.

IV – os direitos e garantias individuais

Numa leitura literal e minimalista dos direitos fundamentais tutelados por cláusula pétrea, seria possível afirmar que a extensão dessa tutela se encerraria nos direitos de 1ª geração (liberdades públicas clássicas), cuja titularidade é indubitavelmente do indivíduo. Mas essa visão não é a que predomina na doutrina mais garantista.

Sustentar que apenas as liberdades clássicas estariam protegidas como cláusulas pétreas seria estabelecer primazia não prevista na própria Constituição entre os próprios direitos fundamentais, segundo Ingo Sarlet⁵⁴. Da mesma maneira, não se pode desconsiderar que os direitos sociais pertencem de início ao indivíduo e não à coletividade, como o direito à saúde, por exemplo.

Sobre a saúde, apesar de ser importante analisá-la sob o prisma coletivo, principalmente com o desenvolvimento de políticas públicas para a construção de hospitais, contratação de médicos e enfermeiros especializados, não podemos deixar de destacar que saúde é antes de tudo vida, individualmente considerada. Como podemos negar a natureza de cláusula pétrea ao direito à saúde? Se emendas constitucionais fossem

XI – um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual;

XII – dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

XIII – dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

54. SARLET, Ingo Wolfgang. “Os Direitos Fundamentais Sociais como ‘Cláusulas Pétreas’”. Cadernos de Direito; Cadernos do Curso de Mestrado em Direito da Universidade Metodista de Piracicaba, v. 3, no 5, dezembro de 2003, p. 88 a 94.

apresentadas no sentido de diminuir os limites orçamentários para os gastos com a saúde, ou mesmo desobrigando o Estado da função de protegê-la, seriam essas reformas válidas?

O assunto é tão polêmico que, em âmbito judicial⁵⁵, ainda não há uma posição uniforme sobre a proteção dos direitos sociais como cláusulas pétreas, simplesmente pela análise restrita da expressão direitos e garantias individuais (típicos de primeira geração). Sem falar que os Estados, em suas defesas nos diversos litígios que envolvem a prestação dos medicamentos gratuitos, aproveitam-se da suposta natureza unicamente coletiva do direito à saúde, para se eximirem da prestação dos serviços públicos essenciais garantidos pela Constituição⁵⁶.

Quanto à proteção dos direitos individuais se esgotarem ou não nas disposições do art. 5º da CRFB/88, doutrina e jurisprudência convergem para o entendimento de que todos os dispositivos constitucionais que tratam desses direitos configuram cláusulas pétreas, como na decisão⁵⁷ do STF, que consagrou o princípio da anterioridade em matéria tributária (art. 150, III, “b”) como cláusula pétrea.

Na interpretação da CRFB/88 é possível se identificar institutos e direitos importantes que não foram consagrados como cláusulas pétreas expressas, mas que diante de sua relevância também deveriam receber um tratamento especial pelo constitucionalismo pátrio. É a doutrina das limitações materiais

55. O STF indicou tendência à proteção dos direitos sociais como cláusulas pétreas no julgamento da ADI 1.946/DF, Min. Rel. Sydney Sanches, Plenário, j. 03.04.2003; DJ 16.05.2003, quando defendeu que o direito à licença-maternidade (art. 7º, XVIII, CRFB/88) é protegido pela imutabilidade.

56. STF, SS 3.205/AM, j. 31.05.2007; Decisão da Presidência, Ministra Ellen Gracie, decisão publicada no DJU em 08.06.2007. Vale a pena ler trecho da defesa do Estado do Amazonas na Suspensão de Segurança sob comentário: (...) ao ser compelido a adquirir medicamentos fora de suas atribuições como elemento de um sistema único, objeto da Lei no 8.080/90, toda a coletividade será prejudicada, pois, valendo-se do exemplo do caso concreto, estar-se-ia atendendo uma necessidade individual em detrimento do equilíbrio financeiro do sistema em relação à coletividade (fls. 10-11), sendo certo que essa foi a conclusão das decisões proferidas nas mencionadas STA 91/AL e SS 3.073/RN; b.2) o art. 196 da Constituição da República, ao assegurar o direito à saúde, se refere, em princípio, à efetivação de políticas públicas sendo certo que essa foi a conclusão das decisões proferidas nas mencionadas STA 91/AL e SS 3.073/RN; b.2) o art. 196 da Constituição da República, ao assegurar o direito à saúde, se refere, em princípio, à efetivação de políticas públicas que alcancem a população como um todo, não garantindo situações individualizadas, como o fornecimento de remédios excepcionais e de alto custo que estão fora da lista do Sistema Único de Saúde – SUS (grifos nossos).

57. STF, ADI 939/DF, Plenário, Min. Rel. Sydney Sanches, j. 15.12.93, DJ 18.03.94.

implícitas.

Para Nelson de Souza Sampaio seriam exemplos de tais limitações: a) a titularidade do poder constituinte; b) as relativas ao titular do poder de reforma e, ainda, c) ao processo da própria emenda⁵⁸.

Manoel Jorge e Silva Neto indica que todo o núcleo dos princípios fundamentais do Título I da Constituição (arts. 1º a 4º) são limitações implícitas, levando-se em consideração que fariam parte da própria razão ontológica da unidade estatal brasileira⁵⁹.

Guilherme Pena de Moraes destaca que são exemplos de cláusulas tácitas a forma e o sistema de governo, que não poderiam ser modificadas por uma reforma constitucional após o resultado do plebiscito de 21 de abril de 1993, quando o povo confirmou a vontade de viver em uma república-presidencialista⁶⁰.

Ressaltando a limitação implícita que veda a alteração do próprio art. 60, com o intuito de facilitar o processo de reforma, nasce a vedação à dupla reforma ou à dupla revisão. Tal instituto significaria, em sentido simples, realizar, por meio de duas emendas constitucionais, o que não seria possível de se conseguir com uma só. Exemplificando: se a EC X pudesse retirar o § 1º do art. 60, a EC Y poderia livremente ser promulgada durante a intervenção federal, hipótese esta não desejada pelo constituinte por colocar em risco a própria Constituição; ou então, se a EC W pudesse retirar o § 4º do art. 60, a EC J poderia estabelecer pena de morte para crimes hediondos, situação também não defendida pelo constituinte originário.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em sentido contrário, defende a possibilidade da dupla revisão, tendo em vista a inexistência de vedação constitucional expressa que a proíba⁶¹.

- **Circunstanciais** – art. 60 §1º. Durante a intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, não é possível aprovar alteração do texto da Constituição. São situações de crise, de anormalidades institucionais. Então, o objetivo foi de evitar alterações casuísticas. O que é vedada

58. SAMPAIO, Nelson de Souza. O poder de reforma constitucional. Salvador: Livraria Progresso, 1954, p. 93 e ss.

59. SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 22.

60. PENA DE MORAES, Guilherme. Curso de Direito Constitucional. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Impetus, 2008, p. 34-35.

61. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. "Significação e Alcance das Cláusulas Pétreas". Revista de Direito Administrativo, no 202, 1995, p. 17.

é a aprovação de EC durante o período de anormalidade. É possível a apresentação de PEC e início das discussões. Somente não é possível votação, promulgação e publicação.

- **Formais ou processuais** – art. 60, I, II e III §§ 2º, 3º e 5º.

a) Iniciativa (art.60, I, II e III): o rol dos legitimados para propor a alteração da Constituição é taxativo. A legitimidade é concorrente, ou seja, não é necessário que todos os legitimados ajam em conjunto, basta que um deles apresente o projeto de emenda.

- 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou 1/3, no mínimo, dos membros Senado Federal;
- Presidente da República;
- Mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, que se manifestem pela maioria relativa de seus membros.

b) Elaboração (art.60, §2º): Apresentada a proposta perante o Congresso Nacional, ela será discutida e votada em dois turnos, em cada casa separadamente. (Não há, portanto, sessão conjunta). Será considerada aprovada quando conseguir 3/5 dos votos dos membros de cada Casa, em cada turno de votação.

- **Casa iniciadora:** Em regra, será a Câmara dos Deputados (na forma do art. 64, caput). O Senado normalmente fica com o papel de cada revisora, salvo se iniciar o processo legislativo, pois nessa hipótese, haverá inversão na ordem de votação entre as casas, e a Câmara ficará com o papel de casa revisora.

Câmara dos Deputados – 3/5 equivalem a 308 votos

Senado Federal – 3/5 equivalem a 49 votos

c) Promulgação (art.60, § 3º): Aprovada a proposta nas duas Casas, a emenda será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado, com o respectivo número de ordem. Não há sanção ou veto do Presidente da República no que tange à PEC (proposta de emenda à Constituição).

d) Rejeição da PEC: Matéria objeto de PEC rejeitada ou prejudicada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa! Cuidado! A sessão legislativa vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Assim, se uma PEC foi rejeitada em 5/1/2016 durante sessão extraordinária convocada durante o recesso parlamentar, poderá ser reapresentada em 2/2/2016, já que se trata de nova sessão legislativa. No entanto, se for rejeitada no recesso do meio do ano de 2016, não poderá ser reapresentada em 1º de agosto, porque ainda estaremos na mesma sessão legislativa.

ATENÇÃO - MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL

Importante destacar que além do procedimento formal de mudança da Constituição existe o fenômeno da **MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL** (ou manifestação de Poder Constituinte Difuso), que é a mudança informal da Constituição à luz dos novos fatos sociais, econômicos, políticos, culturais, permitindo que o texto esteja sempre atualizado com a sociedade. O fenômeno não é exclusivo do Poder Judiciário, pode ser realizado pelo Legislativo, Executivo e também pelo povo. Entretanto, como o STF é o guardião da Constituição, e as questões mais polêmicas acabam chegando à sua análise, podemos dizer que o Tribunal está na posição mais privilegiada para a sua realização.

Como exemplos de mutações constitucionais, de acordo com a jurisprudência do STF, podemos citar:

a) A decisão da Corte no MS 26.603-1, que reconheceu a fidelidade partidária no país, realizando uma releitura dos arts. 14, § 3º, e 55 da CRFB/88;

b) O novo entendimento sobre a prisão civil do depositário infiel (art. 5º, LXVII), representado pela Súmula Vinculante nº 25;

c) A decisão do STF acerca da relação homoafetiva e da entidade familiar em que considerou cabível o mecanismo da integração analógica para que sejam aplicadas às uniões homoafetivas as prescrições legais relativas às uniões estáveis heterossexuais, excluídas aquelas que exijam a diversidade de sexo para o seu exercício, até que o Congresso Nacional lhe dê tratamento legislativo (releitura do art. 226, § 3º, da CRFB/88).

d) A redefinição do papel do AGU no controle concentrado de constitucionalidade – ADI 3.916/DF. O Tribunal, por maioria de votos, entendeu que o art. 103, § 3º, da CRFB/88 deve ser alvo de uma interpretação sistemática, pois o que o referido dispositivo pretende garantir é que o AGU emita seu parecer e não estabelecer obrigatoriedade deste em defender o ato normativo impugnado;

e) O cancelamento da Súmula no 394 do STF, que previa a prorrogação de sua competência para processar ex-parlamentares;

f) A criação da Súmula Vinculante nº 13 que, ao vedar o nepotismo, fez uma sadia releitura dos princípios da Administração Pública previstos no art. 37, caput, da CRFB/88.

CAPÍTULO 6

EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS



6.1 A INFLUÊNCIA DA SEGUNDA DIMENSÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS SOBRE O TEMA

O sociólogo inglês T. H. Marshal, em seus estudos sobre cidadania e classes sociais, foi responsável pela realização de uma análise empírica acerca da conexão existente entre os direitos políticos, civis e sociais na formação do cidadão, dentro de uma concepção política e histórica. O tema inspirou Norberto Bobbio⁶², que muitas vezes é citado pela doutrina brasileira como o precursor do assunto, ao escrever sobre as gerações ou dimensões dos direitos fundamentais, classicamente divididas em: direitos políticos e civis (1ª geração), direitos sociais, econômicos e culturais (2ª geração) e direitos difusos (3ª geração), que serão estudadas em capítulo específico.

Sob a inspiração da Constituição Mexicana de 1917, a Declaração Soviética dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, de 1918 e a Constituição de Weimar, de 1919, nasce a denominada segunda geração de direitos fundamentais, que traz proteção aos direitos sociais, econômicos e culturais, onde do Estado não mais se exige uma abstenção, mas, ao contrário, impõe-se a sua intervenção, visto que a liberdade do homem sem a sua participação não seria protegida integralmente. Esta necessidade de prestação positiva do Estado corresponderia aos chamados direitos sociais dos cidadãos, direitos não tão somente considerados individualmente, mas sim de caráter econômico e social, com o objetivo de garantir à sociedade melhores condições de vida. Nesse diapasão, seriam exemplos clássicos desses direitos: o direito à saúde, ao trabalho, à assistência social, à educação, o direito de greve.

Em descompasso com a evolução do constitucionalismo, os Estados não estavam aparelhados para cumprir essas grandes missões porque, para garantir saúde e educação, precisa de investimento e vontade política. E aí começou a crise que até hoje o Direito Constitucional enfrenta: a da alta programaticidade de suas normas, gerando a sina sobre a juridicidade da Constituição⁶³.

62. BOBBIO, Norberto. *A Era dos Direitos*, Rio de Janeiro: Campus, 1992.

63. Sobre o assunto afirma Paulo Bonavides: "Ali desaguarão todo o ímpeto, as correntes políticas mais radicais. Quase todo o edifício jurídico das Constituições liberais erguido durante o século XIX veio abaixo. A programaticidade dissolveu o conceito jurídico de Constituição, penosamente elaborado pelos constitucionalistas do Estado liberal e pelos juristas do positivismo. De sorte que a eficácia das normas constitucionais volveu à tela em

O questionamento acerca da produção de efeitos jurídicos de suas normas inspirou em 1927 Thomas Cooley, nos Estados Unidos, a desenvolver a divisão bipartida de produção de efeitos jurídicos entre as normas da Constituição, que será a seguir analisada.

6.2 TEORIA BIPARTIDA AMERICANA (THOMAS COLLEY)

- self executing provisions (mandatory, autoaplicáveis)
- not self executing provisions (directory, não autoaplicáveis)

As normas autoaplicáveis, segundo Cooley⁶⁴, seriam aquelas que desde a sua entrada em vigor estariam plenamente aptas a produzir todos os seus efeitos jurídicos essenciais. As não autoaplicáveis seriam as que tratam de regulamentações, sugeririam programas a serem seguidos e funcionariam como uma espécie de proclamações políticas sem eficácia jurídica e que dependeriam, para a produção de algum efeito prático, de regulamentação pelo legislador.

As normas não autoaplicáveis são as que mais se relacionam com os direitos sociais, frutos da segunda geração de direitos fundamentais acima mencionada.

6.3 TEORIA TRIPARTIDA CLÁSSICA BRASILEIRA (JOSÉ AFONSO DA SILVA)

O assunto sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais foi estudado com maestria por José Afonso da Silva, ensejando a publicação de uma monografia específica sobre o tema em 1968⁶⁵. A sua proposta de classificação tripartida ainda continua sendo a de maior destaque na Teoria Geral da Constituição. Segundo o doutrinador, as normas se dividem em:

- Plenas
- Contidas
- Limitadas: de princípio programático e de princípio institutivo

debate, numa inquirição de profundidade jamais dantes lograda". Ob. cit., p. 232.

64. COLLEY, Thomas. *Treatise on the Constitutional Limitations*, 6ª ed., p. 93, traduzida por Rui Barbosa em *Comentários à Constituição Federal Brasileira*, II, 1933, Saraiva, p. 495, citado por Paulo Bonavides em ob. cit., p. 242.

65. AFONSO DA SILVA, José. *Aplicabilidade das Normas Constitucionais*. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

As normas constitucionais de eficácia plena seriam aquelas que desde o momento de sua entrada em vigor na Constituição estariam plenamente aptas a produzir todos os seus efeitos jurídicos essenciais. São autoaplicáveis e têm incidência direta, imediata e integral. Exemplos na CRFB/1988: arts. 1º e 2º, 5º, III. Os remédios constitucionais também são apresentados por meio de normas plenas (art. 5º, LXVIII a LXXIII).

À semelhança das normas plenas, as contidas também estão plenamente aptas a realizar todos os seus efeitos jurídicos essenciais desde a sua entrada em vigor, produzindo, igualmente, incidência direta, imediata, mas não integral, pois podem sofrer restrições ou condicionamentos futuros por parte do Poder Público. À guisa de exemplo, podemos citar: arts. 5º, XIII e XV e art. 93, IX. É importante destacar que esse condicionamento pode ser feito por lei, por atos administrativos ou até mesmo por uma outra norma constitucional.

Já as normas constitucionais limitadas produzem efeitos jurídicos reduzidos, tendo em vista que dependem da atuação futura por parte do Poder Público. Dividem-se em: Programáticas ou Institutivas (ou organizatórias). As primeiras traçam objetivos, metas ou ideais que deverão ser delineados pelo Poder Público para que produzam seus efeitos jurídicos essenciais. Estão vinculadas normalmente aos direitos sociais de segunda geração. Exemplos na CRFB/1988: arts. 196, 205 e 211. As últimas criam novos institutos, serviços, órgãos ou entidades que precisam de legislação futura para que ganhem vida real. Exemplos: art. 134, § 1º, e art. 93, caput, ambos da CRFB/1988.

Sobre as normas programáticas, Celso Ribeiro Bastos⁶⁶ afirma que elas seriam extremamente generosas quanto às dimensões do direito que disciplinam e, por outro lado, são muito avaras nos efeitos que imediatamente produzem. A sua gradativa implementação, que é o que no fundo se almeja, fica sempre na dependência de resolver-se um problema prévio e fundamental: quem é que vai decidir sobre a velocidade dessa implementação? Trata-se, portanto, de matéria, segundo o autor, insuficientemente juridicizada. O direito dela cuidou, sim, mas sem evitar que ficasse aberta uma porta para o critério político.

A eficácia dessas normas de conteúdo programático é deveras complexa, por não apenas exigir a atuação efetiva do legislador, mas por depender de políticas públicas a serem desenvolvidas pelo Governo, com a fiscalização,

66. RIBEIRO BASTOS, Celso e BRITO, Carlos Ayres de, *Interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais*, São Paulo, Saraiva, 1982.

orientação e pressão populares.

Entretanto, é imperioso ressaltar que modernamente a elas é reconhecido valor jurídico idêntico ao dos restantes preceitos da Constituição, como cláusulas vinculativas que são, contribuindo para o sistema através dos princípios, dos fins e dos valores que incorporam.

CAPÍTULO 7

A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL

7.1 A DIFÍCIL TAREFA DE “INTERPRETAR”

A interpretação faz parte da realidade de cada um de nós desde o nascer do sol até o momento do descanso. Interpretamos símbolos relativamente fáceis, como os sinais e placas de trânsito, ou ainda, a forma e cor dos objetos. Em razão de seu vestuário (um símbolo), esperamos de um policial fardado o zelo pela segurança pública e, de um médico, normalmente com a roupa branca, proteção à saúde, e não o contrário.

A tarefa de interpretar a Constituição, entretanto, é muito diferente. Talvez se aproxime da própria interpretação dos sentimentos e emoções humanas, dotada de subjetivismo, abstração e inúmeras incertezas. Poderia ser inconclusivamente definida como: um diálogo qualificado e atencioso com a norma, levando-se em consideração a riqueza dos seus valores, princípios e regras, coerentes com a realidade brasileira, que espera das normas constitucionais a máxima produção de seus efeitos jurídicos.

Os métodos clássicos de interpretação jurídica podem ser imputados a Savigny, fundador da Escola Clássica do Direito em 1840, e podem ser sintetizados em métodos: gramatical (ou literal), sistemático, histórico, lógico e teleológico, que serão a seguir analisados.

7.2 MÉTODOS CLÁSSICOS DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL

7.2.1 Método Gramatical ou Literal

Segundo a análise gramatical, a norma significaria justamente o que nela está escrito, a sua própria literalidade. Aqui se faz imperiosa a distinção entre dispositivo ou texto e a própria norma. O dispositivo é o significante ou o enunciado que expressa o comando, de onde o mesmo é extraído, e a norma é a regra de conduta que se extrai do dispositivo, sendo, portanto, inconfundíveis. Os dispositivos traçam o roteiro para compreensão das normas⁶⁷.

A título de exemplo, poderíamos mencionar a diferença entre o texto e a norma do art. 5º, LVI, da CRFB/88. O texto afirma que são inadmissíveis no processo as provas ilícitas, mas, de acordo com a jurisprudência do STF,

67. SLAIBI FILHO, Nagib. “A Norma Constitucional”. Disponível em: <www.nagib.net/artigos>. Último acesso em: 25 ago. 2014.

em nome do princípio da proporcionalidade, excepcionalmente essas provas podem ser admitidas como, por exemplo, na hipótese de legítima defesa das liberdades públicas. Da mesma maneira, poderíamos analisar a titularidade dos direitos fundamentais de acordo com o art. 5º, caput, que afirma serem protegidos os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Segundo a interpretação mais correta, todas as pessoas naturais (estrangeiros de passagem pelo território nacional, inclusive) e jurídicas devem ter os seus direitos respeitados. Essa é mais uma clara diferença entre o texto e a norma.

A interpretação gramatical seria o ponto de partida, sendo a guia inicial da tarefa do intérprete, mas não é normalmente o seu ponto de chegada, diante da pluralidade de normas que podem ser extraídas do mesmo dispositivo.

7.2.2 Método Sistemático

Esse método avalia a Constituição como um todo, realizando uma verificação completa do sistema constitucional para melhor compreensão de seus institutos. Analisando a proteção constitucional ao meio ambiente, que ganhou um papel de destaque na Constituição de 1988, é possível relacionar uma série de dispositivos que destacam o compromisso do país e da sociedade com a sua preservação, a saber: art. 5º, LXXIII (ação popular na defesa do meio ambiente); art. 186 (descumpra a função social da propriedade aquele que atentar contra o meio ambiente); art. 129, III (ação civil pública pode ser proposta em sua defesa); art. 23 (é matéria de competência comum da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou seja, cada ente da Federação é responsável pela preservação do meio ambiente); e ainda, o art. 225, quando afirma o compromisso na preservação do meio ambiente para as futuras gerações.

7.2.3 Método Histórico

O método histórico remonta à constituinte, à origem da nossa Constituição, e, sem dúvida, é um método importante, principalmente para uma Constituição jovem como a nossa, a qual surgiu da influência de vários movimentos sociais e políticos, que combateram a ditadura militar.

É fácil compreender, com base nesse método histórico, por exemplo, a razão da disposição do art. 5º, III, da CRFB/88, que impede a tortura e o tratamento desumano ou degradante, justamente porque é sabido que muita tortura foi realizada no Brasil no período da ditadura militar. Nesse mesmo

diapasão, o crime de tortura é considerado inafiançável na forma do art. 5º, XLIII. Também nos parece que a motivação do habeas data (art. 5º, LXXII) tenha sido a de permitir aos perseguidos do regime anterior o acesso a dados pessoais e demais informações recolhidas à época pelos órgãos do governo.

Importante destacar que o constituinte originário não pode aprisionar as futuras gerações, pois de fato o que é mais importante não é a *ocasio legis* (a ocasião da elaboração da Constituição), e sim a *ratio legis*, ou seja, é o fundamento racional que vai acompanhar aquele texto constitucional ao longo da produção dos seus efeitos jurídicos⁶⁸, porque a Constituição é maleável. O processo histórico deve ser analisado sobre o prisma mais evolutivo, não descuidando da atualidade.

7.2.4 Método Lógico

O método lógico foi muito criticado pelo realismo americano, porque pretende transformar a Constituição em silogismos matemáticos. Seria como se todo eventual conflito entre direitos fundamentais tivesse uma única resposta dos juízes.

Hoje em dia é possível se observar que para cada problema existe uma solução, sem que nenhuma delas esvazie (ou possa esvaziar) o comando constitucional restringido no caso concreto. Invariavelmente, por exemplo, os litígios que envolvem liberdade de imprensa x intimidade produzem decisões diferentes, em razão das provas que instruíram o processo e das situações concretas.

7.2.5 Método Teleológico

A teleologia é o estudo filosófico dos fins, isto é, do propósito, objetivo ou finalidade dos institutos. O método teleológico, então, reconhece que o Direito não é um fim em si mesmo e que os meios são indispensáveis para a busca da justiça. Com isso, determina ao intérprete que analise mais a fundo as normas legais, sempre em busca da sua essência e verdadeiro ideal.

Como exemplo de aplicação do referido método podemos citar a decisão do TSE que reconheceu a inelegibilidade reflexa (art. 14, § 7º, da CRFB/88) numa relação homoafetiva, em que pese a Constituição até o momento não

68. BARROSO, Luís Roberto. *Interpretação e Aplicação da Constituição*. 6. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2004.

referendar expressamente essa forma de união estável⁶⁹.

Apesar de não termos esse reconhecimento expresso na Lei Maior, importante frisar que na ADI 4277, o STF realizou uma “mutação constitucional” no art. 226, p. 3, da CRFB/88 e estendeu o conceito de união estável também para as relações homoafetivas.

7.3 A ABERTURA DAS CONSTITUIÇÕES AOS PRINCÍPIOS E A NOVA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL

Logo após a Primeira Guerra Mundial, as Constituições começaram a adotar em seus textos os chamados direitos sociais, inspirados na ideia de Estado Social, e os homens passaram a exigir determinadas prestações, tais como: educação, saúde, trabalho, assistência, previdência. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as Constituições modernas também passaram a defender a tutela dos chamados “direitos difusos” e o novo jogo de valores socioculturais apontou, diante desse novo cenário, os princípios frente às regras específicas, como se observa principalmente nas Constituições da Itália (1947), Alemanha (1949), Portugal (1976), Espanha (1978) e na brasileira de 1988.

Expressões como “dignidade da pessoa humana”, “prevalência dos direitos humanos”, “função social da propriedade”, “valores sociais do trabalho”, “boa-fé”, “solidariedade” e tantas outras associadas ao caráter compromissório e diretivo das Constituições modernas ficam sem sentido algum se analisadas a partir das regras traçadas pela racionalidade do positivismo jurídico. O mito cartesiano clássico de que tudo pode ser explicado pela lei perde o seu valor diante da nova realidade constitucional. Dentro desse novo prisma forma-se o Estado Constitucional de Direito, no qual os princípios deixaram o papel de coadjuvantes das regras para serem os protagonistas nesse novo momento da história.

Hodiernamente, como nos ensina Canotilho⁷⁰, embora tanto o princípio como a regra sejam espécies de norma, o princípio se diferencia da regra porque, em livre resumo, tem um maior grau de abstração, por trazer sempre um caráter de fundamentalidade dentro do sistema e um maior compromisso com a ideia de justiça e, enfim, por ser o próprio fundamento da regra, sendo esta um desdobramento casuístico do princípio. A abertura das Constituições

69. TSE, REspe 24.564/PA, Rel Min. Gilmar Mendes, j. em 1º.10.2004.

70. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1999, p. 1.085 e ss.

aos princípios é assim captada pelo jurista português: O direito do Estado de Direito do século XIX e da primeira metade do século XX é o direito das regras e dos Códigos; o direito do Estado Constitucional Democrático e de Direito leva a sério os princípios, é um direito de princípios.

Tendo em vista que a condensação axiológica dos princípios dificulta a sua tradução em regras que os esgotem, os princípios passaram a “fulgurantes pilares no ordenamento jurídico”,⁷¹ e é nesse contexto que nasce também uma nova perspectiva sobre os direitos fundamentais, tão alicerçados e protegidos pelos princípios.

Um dos expoentes dessa importante teoria de princípios é Ronald Dworkin, que, em sua obra *Levando os Direitos a Sério*⁷², contribuiu para a abertura do ordenamento jurídico, colaborando para o nascimento do Estado Constitucional de Direito, bem marcado pela beleza dos princípios.

O jurista anglo-saxão começa a sua análise sobre o tema, definindo o esqueleto principal das proposições positivistas, catalogando-as, em síntese, da seguinte forma: (i) o direito de uma comunidade é um conjunto de regras especiais utilizado direta ou indiretamente pela comunidade com o propósito de determinar qual comportamento será punido ou coagido pelo Poder Público; (ii) o conjunto dessas regras jurídicas é coextensivo com o “direito”, de modo que se o caso de alguma pessoa não estiver claramente coberto por uma regra dessas, não poderá ser decidido mediante a “aplicação do direito”; (iii) dizer que alguém tem uma “obrigação jurídica” é dizer que seu caso se enquadra em uma regra jurídica válida que exige que ele faça ou se abstenha de fazer alguma coisa⁷³.

Em seus escritos, Dworkin frisa que o soberano não pode antecipar todas as contingências sociais por meio de um sistema de ordens, pois algumas de suas proposições serão inevitavelmente vagas ou pouco claras, e o postulado (i) restará, dessa forma, fragilizado. Em contrapartida, se não há regra clara protegendo o direito do indivíduo, abre-se passagem para uma ampla discricionariedade judicial para criar novas ordens, e o primado (ii) também fica prejudicado. No item final, significaria dizer que, na ausência de tal regra jurídica válida, não existiria obrigação jurídica, então, ao decidir uma matéria controversa exercendo a sua discricção, o juiz não estaria fazendo valer um direito jurídico correspondente a essa matéria?

71. SLERCA, Eduardo. *Os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.

72. DWORKIN, Ronald. *Levando os Direitos a Sério*. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

73. DWORKIN, Ronald. *Ob. cit.*, p. 27-28.

Essas e outras críticas são lançadas pelo jurista americano para chegar ao que denominou de “ataque geral contra o positivismo”⁷⁴, e revela que a sua estratégia de combate se inicia em torno do fato de que, quando os juristas raciocinam ou debatem a respeito de obrigações jurídicas, eles recorrem a padrões que não funcionam como regras, mas operam de maneira diferente, como princípios, políticas e outros tipos de padrões, que são batizados em sentido genérico como “princípios”. Nesse sentido, reitera que uma das diferenças entre princípios e regras seria de natureza lógica. Os dois padrões apontariam para decisões particulares acerca da obrigação jurídica em circunstâncias específicas, mas se distinguiriam quanto à natureza da orientação que oferecem. As regras seriam aplicadas à maneira do tudo ou nada, pois, presentes os fatos que uma regra estipula, será válida e, nesse caso, a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não será válida, e neste caso em nada contribui para a decisão.

Os princípios também possuem uma dimensão que as regras não retratam: a dimensão do peso e da importância. Quando os princípios se inter cruzam (como por exemplo, a liberdade de imprensa e a intimidade), o intérprete deverá levar em consideração a força relativa de cada um. Em contrapartida, as regras seriam, nas palavras de Dworkin, funcionalmente importantes ou desimportantes, e dessa maneira: (...) *uma regra jurídica pode ser mais importante do que outra porque desempenha um papel maior ou mais importante na regulação do comportamento. Mas não podemos deixar de dizer que uma regra é mais importante que outra quando parte do mesmo sistema de regras, de tal modo que se duas regras estão em conflito, uma suplanta a outra em virtude de sua importância ser maior*⁷⁵.

Acrescentaríamos, ainda, que, embora princípios e regras devam atender igualmente aos ideais de justiça, os princípios estão mais próximos dessa finalidade do que as regras, em razão de seu alto conteúdo axiológico e moral e, ademais, por constituírem a própria ratio das normas jurídicas.

Essa distinção entre regras e princípios, lembra-nos Lênio Streck⁷⁶, não pode significar que as regras sejam uma espécie de renegação do passado e de seus fracassos, tampouco que os princípios traduzam o ideal da “boa norma”. Regras e princípios são fontes do ordenamento jurídico, de onde se

74. DWORKIN, Ronald. Ob. cit., p. 35.

75. DWORKIN, Ronald. Ob. cit., p. 43.

76. STRECK, Lênio. “A resposta hermenêutica à discricionariedade positivista em tempo de pós-positivismo”, p. 285-315. In: Teoria do Direito Neoconstitucional, Ed. Método, São Paulo, 2008.

extraem normas. As primeiras são produzidas democraticamente e podem e devem, junto aos princípios, traduzir a institucionalização da moral no direito.

Dentro desse novo panorama, aqui sintetizado por não ser objeto principal deste trabalho, podemos asseverar que a nova interpretação constitucional assenta-se em um modelo de princípios, aplicáveis mediante ponderação, cabendo ao intérprete proceder à interação entre fato e normas (divididas entre regras e princípios) e realizar escolhas fundamentadas, dentro das possibilidades e limites oferecidos pelo sistema jurídico, visando a uma solução justa para o caso concreto.

7.4 MÉTODOS MODERNOS DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL

Segundo Gilmar Mendes, são métodos modernos de interpretação constitucional os abaixo desenvolvidos.

7.4.1 Método Tópico-Problemático

Esse método de interpretação tem por pressupostos: 1) que a Constituição é um sistema aberto de normas, o que significa dizer que cada uma das normas constitucionais admite interpretações distintas, que podem variar no tempo; 2) que um problema é uma questão que admite, também, respostas distintas; 3) que a tópica é uma técnica de pensar a partir do problema, ou seja, primeiro se avalia o caso em si para, posteriormente, se analisar a norma que será aplicada para resolver o conflito.

O seu principal idealizador, Theodor Vehweg, com sua obra *Topik und jurisprudenzen* (1953), defendeu um processo aberto de argumentação jurídica, sendo a tópica uma grande “técnica de pensamento problemático”. Os argumentos (*topoi*) são submetidos a opiniões favoráveis e contrárias, a fim de descobrir qual é a interpretação mais conveniente⁷⁷.

77. VIEHWEG, Theodor. *Tópica e Jurisprudência*. Coleção Pensamento Jurídico Contemporâneo. Brasília; Departamento de Imprensa Nacional, 1979. v. 1.

7.4.2 Método Hermenêutico-Concretizador

Esse método se assemelha ao tópico-problemático no ponto em que também considera que o intérprete deve exercer uma atividade concretizadora (“reconstruir” o Direito no caso prático, a partir de um procedimento argumentativo e racional, ao invés de procurar um sentido “inerente” à norma). Porém, diferencia-se daquele, por partir do pressuposto de que há necessidade de uma pré-compreensão da norma que deverá ser aplicada para solucionar o conflito, ou seja, o ponto de partida dos dois métodos é completamente diferente.

Sob a influência de Han-Georg Gadamer a respeito da compreensão do texto normativo, Konrad Hesse desenvolveu o método em referência valendo-se de pressupostos subjetivos (as pré-compreensões do intérprete sobre o tema) e o seu papel de mediador entre a norma e o caso concreto, que surge da realidade social (pressupostos objetivos). Há um verdadeiro círculo hermenêutico, um vaivém até a decisão final.⁷⁸

7.4.3 Método Científico-Espiritual

As Constituições devem ser interpretadas de modo aberto e flexível, para que possam acompanhar o dinamismo do Estado, em constante processo de transformação (Rudolf Smend).

Desenvolvido por Rudolf Smend, esse método analisa o sistema de valores subjacentes à Constituição e o papel desta no processo de integração, tendo em vista que a Constituição não é apenas norma, mas também realidade social⁷⁹.

7.4.4 Método Normativo Estruturante

Segundo esse método não haveria identidade entre a norma jurídica e o texto normativo. Com isso, a cada conflito caberá ao intérprete avaliar a concretização da norma à luz da sua realidade social. Segundo Friedrich Müller, a norma não seria o ponto de partida da interpretação, mas, sim, o

78. HESSE, Konrad. Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. 13. ed. Heidelberg; C. E. Müller, 1986.

79. SMEND, Rudolf. Verfassung und Verfassungsrecht in Staatrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze. 3. ed. Berlin: Duncker & Humblot, 1955.

produto final dessa atividade⁸⁰.

7.4.5 Método da Comparação Constitucional

Esse método alia os métodos hermenêuticos clássicos propostos por Savigny ao direito comparado, de modo a buscar as melhores soluções jurídicas para os conflitos vivenciados no dia a dia de um Estado (Peter Häberle).

7.5 OS PRINCIPAIS PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL

7.5.1 Princípio da Supremacia da Constituição

Esse princípio deverá ser considerado como premissa para a interpretação constitucional, tendo em vista que não se admite nenhum tipo de interpretação que coloque em risco a supremacia formal e material do texto constitucional.

Sobre esse importante princípio, núcleo essencial da interpretação constitucional, o Min. Celso de Mello assim se manifestou:

“O princípio da supremacia da ordem constitucional – consectário da rigidez normativa que ostentam os preceitos de nossa Constituição – impõe ao Poder Judiciário, qualquer que seja a sede processual, que se recuse a aplicar leis ou atos estatais reputados em conflito com a Carta Federal. A superioridade normativa da Constituição traz, insita em sua noção conceitual, a ideia de um estatuto fundamental, de uma fundamental law, cujo incontestável valor jurídico atua como pressuposto de validade de toda a ordem positiva instituída pelo Estado dentro dessa concepção, reveste-se de nulidade o ato emanado do Poder Público que vulnerar os preceitos inscritos na Constituição. Uma lei inconstitucional é uma lei nula, desprovida, consequentemente, no plano jurídico, de qualquer conteúdo eficaz”⁸¹.

80. MÜLLER, Friedrich. Rechtsstaatliche Form, Demokratische Politik-Beiträge zu Öffentlichem Recht, Methodik Rechts – und Staatsstheorie. Berlin: Duncker & Humblot, 1977.

81. STF, RE 107.869-SP, Rel. Min. Célio Borja, DJ 21.08.92.

7.5.2 Princípio da Unidade da Constituição

Segundo esse princípio, a Constituição formaria um sistema equilibrado de regras e princípios, não colidentes entre si, e o intérprete deveria observar essa unidade constitucional na hora de interpretá-la. Nesse diapasão, pode-se dizer que a posição já assentada pela jurisprudência do STF⁸² é a de que não há hierarquia entre as normas constitucionais, competindo à Corte a defesa dessas normas, e não a fiscalização do poder constituinte originário.

As disposições idealizadas pelo constituinte originário devem ser analisadas harmoniosamente, pois não há verdadeira antinomia entre as normas constitucionais. Por isso, devemos utilizar a expressão “aparente conflito” entre normas constitucionais, e não “verdadeiro conflito”. O intérprete deverá nas situações de litígio ora determinar a aplicação de um princípio, ora de outro, privilegiando um direito em detrimento de outro, mas jamais esvaziando o núcleo principal do direito fundamental que sofreu restrição.

É um princípio de natureza abstrata e estático.

7.5.3 Princípio da Concordância Prática (ou da Harmonização)

A concordância prática ou princípio da harmonização deriva do princípio da unidade e recomenda ao intérprete que, ao se deparar com situações concretas de concorrência entre bens constitucionalmente protegidos, adote a solução para otimizar a realização de todos, mas sem negar completamente um direito ou um princípio. Ex.: prisões processuais x princípio da presunção da inocência; ou ainda, liberdade de informação x proteção à vida privada.

É um princípio aplicável ao caso concreto e é dinâmico.

7.5.4 Princípio do Efeito Integrador (ou da Eficácia Integradora)

Esse princípio reforça a importância da integração política e social e conduz a decisões judiciais pluralisticamente integradoras. Não é utilizado em todos os casos de interpretação, mas concebe a Constituição como elemento inafastável de integração comunitária.

82. STF, ADI 815/DF; Plenário, Rel. Min. Moreira Alves, j. 28.06.1996, DJU 10.05.96.

7.5.5 Princípio da Justeza (ou da Conformidade Funcional)

O Poder Judiciário não poderá interpretar a Constituição subvertendo o esquema organizatório-funcional nela estabelecido. Com isso, o significado das normas constitucionais não pode ser deturpado, sob pena de se colocar em risco o próprio Estado Democrático de Direito.

Podemos citar como exemplo de inobservância do princípio da conformidade funcional, o entendimento dos Ministros Eros Grau e Gilmar Mendes sobre o art. 52, X, da Constituição, o qual, segundo eles, serviria apenas para dar publicidade às decisões do STF, que, no controle difuso ou concentrado, produziriam efeitos *erga omnes*⁸³.

7.5.6 Princípio da Correção Funcional

O princípio da correção funcional é muito utilizado em sede de controle de constitucionalidade e visa a preservar a vontade do constituinte originário com relação ao pacto federativo e à separação de poderes. Para que haja equilíbrio da República Federativa, é importante que cada ente da Federação e cada Poder estejam bastante conscientes das suas funções e de seus limites estabelecidos pelo texto constitucional.

Podemos citar como exemplos de utilização do princípio da correção pelo STF o julgamento sobre a questão dos bingos⁸⁴ e também a formulação da Súmula Vinculante número 2 sobre o mesmo assunto, a saber: É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Em face desse entendimento, leis estaduais que tratavam dos bingos foram declaradas inconstitucionais, considerando-se que a matéria deve ser tratada por lei federal, na forma do art. 22, XX, da CRFB/88.

7.5.7 Princípio da Força Normativa da Constituição e da Máxima Efetividade das Normas Constitucionais

Os dois princípios impõem que à norma constitucional, sujeita à atividade hermenêutica, deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe conceda,

83. STF, Rel 4.335/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes. Trataremos do tema de forma específica na parte relativa ao Controle de Constitucionalidade.

84. STF, ADI 2.950/RJ, Plenário, DJ 01.02.2008, Min. Relator Marco Aurélio, j. 29.08.2007

sendo vedada a interpretação que lhe supra ou diminua a finalidade. São princípios que buscam o máximo de efeitos jurídicos que uma norma constitucional pode produzir, inclusive as normas de conteúdo programático.

Em voto importante sobre a máxima efetividade da Constituição, o Min. Celso de Mello, em julgado sobre o direito à saúde, assim concluiu:

Cabe assinalar, presente esse contexto – consoante já proclamou esta Suprema Corte – que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado⁸⁵.

E é nesse sentido que a sociedade espera que a sua Constituição seja interpretada, na busca pela exegese da norma que lhe confira mais efeitos práticos, ou seja, uma força concreta mais intensa. Com esses princípios iluminados, os direitos sociais (relacionados à saúde, à educação, à assistência, por exemplo) ganham ainda mais espaço e proteção jurídica no país.

7.5.8 Princípio da Interpretação Conforme a Constituição

A interpretação conforme a Constituição não é apenas um princípio de interpretação constitucional, mas também uma técnica de decisão em controle concentrado de constitucionalidade, na forma do art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99, que será estudado em capítulo próprio. Em nome da presunção de constitucionalidade das leis, se a norma em questionamento permitir plúrimas interpretações, umas incompatíveis e pelo menos uma compatível com a Constituição, o intérprete poderá afastar as contradições, mantendo a norma no sistema jurídico desde que interpretada em conformidade com a Constituição.

85. STF, ADPF 45 MC/DF; Info 345, Min. Rel. Celso de Mello, j. 29.04.2004, DJU 04.05.2004.

André Ramos de Tavares ⁸⁶ faz lúcidas ponderações sobre a utilização do princípio quando destaca que não há permissão para a interpretação da Constituição a partir das leis em geral (de baixo para cima), tendo em vista que seria absolutamente vedada a interpretação dessa maneira, dada a supremacia constitucional.

7.5.9 Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade

Histórico

O princípio da razoabilidade encontra guarida no direito norte-americano, principalmente na 5a e na 14a Emendas. A 5a Emenda faz parte do Bill of Rights norte-americano, adicionado à Constituição Federal em 1789, que dispunha, no tocante ao nosso estudo, que nenhuma pessoa poderia ser privada de sua vida, liberdade ou propriedade sem o *due process of law*. Já a 14a Emenda foi inserida com o intuito de estender a garantia do *due process of law* aos ex-escravos, após a Civil War, e ao direito dos Estados federados, acrescentando, no entanto, o primado do tratamento igualitário pela lei, também para o direito federal. É importante destacar que a cláusula do *due process of law* (que deve ser entendida nos seus contornos processual e substantivo) deve ser aplicada como meio de interpretação jurisprudencial da Suprema Corte norte-americana, e passou de uma simples garantia processual, para o controle de mérito das decisões estatais.

Em suma, a noção de razoabilidade guarda afinidade com a ideia de equilíbrio, moderação e harmonia. Busca aquilo que atende ao senso comum, aos valores vigentes em dado momento, em última análise, pretende alcançar a justiça. Carrega, portanto, forte elemento subjetivo e abstrato.

O princípio da proporcionalidade, por sua vez, é posterior à razoabilidade norte-americana e foi desenvolvido a partir da década de 1950, pelo Tribunal Constitucional Alemão. A Corte o desenhou como um método de interpretação e aplicação dos direitos fundamentais, empregado particularmente nos casos em que um ato estatal, destinado a promover a realização de um direito fundamental ou de um interesse coletivo, implica a restrição de um direito fundamental. É na Alemanha que o princípio da proporcionalidade ganha raízes mais profundas.

De acordo com a doutrina alemã defendida por Robert Alexy, o princípio seria composto por três sub-regras: a adequação, a necessidade

86. TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 85.

e a proporcionalidade em sentido estrito. Adequada seria a medida capaz de fomentar e não obrigatoriamente atingir determinado fim; necessária, aquela que, quando comparada a outras tão eficazes quanto restringisse em menor escala o direito fundamental violado; e proporcional em sentido estrito à medida que promovesse a realização de um direito fundamental mais importante do que o que com ele colide.

A partir disso, a proporcionalidade passou a ser utilizada por diversos países, entre eles Portugal, onde foi incorporada ao conceito de razoabilidade, proveniente do Direito anglo-saxão, através do qual se examina a compatibilidade entre os meios e os fins. No Direito lusitano, o princípio da proporcionalidade em sentido amplo, também conhecido como princípio da proibição de excesso, foi erigido à dignidade de princípio constitucional, consagrando-se, no art. 18, do Texto Magno de 1976, que assim dispõe: “A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos”.

Na França o princípio da proporcionalidade é compreendido apenas no âmbito da jurisdição administrativa, manifestando-se, todavia, a partir do denominado *pouvoir descriptif* (poder discricionário), que é limitado pelo *détournement du pouvoir* (desvio de poder), e, na Suíça, ele é definido sumariamente apenas como a necessidade de se respeitar uma relação entre os meios empregados para tomar uma medida e atingir o fim procurado⁸⁷.

Segundo Suzana de Toledo Barros⁸⁸, na Itália, a Corte Constitucional vem controlando de forma rigorosa se os limites aos direitos insculpidos na Constituição, estabelecidos pela lei, são razoáveis em face dos princípios consagrados na Carta. Segundo a autora, os juristas italianos já falam em *idoneità*, *necessità* e *proporzionalità del provvedimento*, sem contudo apresentar um estudo sistemático sobre o tema, que ainda se ressentia da falta de unanimidade nas técnicas e terminologias utilizadas.

87. SLERCA, Eduardo. Ob. cit.

88. TOLEDO BARROS, Suzana de. O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2003, p. 52-53.

CAPÍTULO 8

NOTAS SOBRE AS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS

Neste capítulo será apresentada uma análise sistematizada dos principais aspectos relacionados às Constituições anteriores, como os relativos à sua forma de estado, de governo, direitos e garantias fundamentais e suas demais características essenciais.

8.1 CONSTITUIÇÃO DE 1824

- Forma de Governo: monárquico, hereditário, constitucional e representativo;
- Forma de Estado: unitário. As províncias não tinham autonomia;
- O Estado é confessional, ou seja, adota uma religião oficial, que é a Católica Apostólica Romana;
- Contém um extenso rol de liberdades públicas;
- Os Poderes Políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são quatro: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder Executivo e o Poder Judicial;
- A Constituição serviu bem a uma sociedade pouco dinâmica, em que a participação política era baixa – e por isso a mais longa do país.

Elencamos, ainda, algumas manifestações políticas que merecem destaque:

1. Tipo de sufrágio:

Na primeira das constituições brasileiras as eleições eram indiretas e censitárias.

Obs.: Até a edição da Lei Saraiva em 1881, quando as eleições diretas foram concebidas, ainda que por colégio eleitoral censitário, poucas modificações foram introduzidas pelo Império em duas décadas. As eleições eram marcadas pela exclusão, conflito e manipulação.

2. Alistamento eleitoral e voto:

Os brasileiros naturalizados com mais de vinte cinco anos, militares com mais de vinte um anos, padres e bacharéis que possuíssem renda superior a cem mil-réis estavam habilitados a votar nas eleições paroquiais ou de primeiro grau – onde eram escolhidos em assembleia paroquial os eleitores da província -, e os com renda superior a duzentos mil-réis aptos a escolherem deputados, senadores, nas eleições consideradas de segundo grau – quando eleitores de província, já escolhidos, votavam em deputados e senadores.

Logo, podiam votar e se candidatar aos cargos eletivos pessoas que possuísssem determinada renda e patrimônio.

Eram proibidos de votar: os menores de vinte e cinco anos, os escravos libertados, os religiosos, os brasileiros naturalizados, as pessoas que não tivessem a religião oficial do Império, ou seja, a católica, e os que não tivessem renda líquida anual de cem mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego.

3. Plebiscito, referendo e iniciativa popular:

O texto constitucional não faz nenhuma menção à participação popular. Dessa forma conclui-se que inexistiam tais institutos no período Imperial.

8.2 CONSTITUIÇÃO DE 1891

- Forma de Estado: Federal. O Brasil copia não só o modelo político dos EUA como a estrutura do nome “Estados Unidos do Brasil” (federalismo atípico);
- Forma de Governo: República;
- O Estado é leigo ou laico, ou seja, mantém neutralidade religiosa em matéria constitucional. O Brasil passa por um processo de Laicização ou Secularização, em razão da separação entre Estado e Igreja em 1890;
- Os Poderes Políticos reconhecidos pela Constituição Republicana são três: o Poder Legislativo, o Poder Executivo, e o Poder Judicial, harmônicos e independentes entre si;
- Trouxe o *habeas corpus* sempre que o indivíduo sofresse ou se achasse em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder.

Destacamos, ainda, algumas manifestações políticas que merecem destaque:

1. Tipo de sufrágio:

Segundo José Afonso da Silva, o fato da Constituição de 1891 ter excluído os mendigos do direito de sufrágio revela um aspecto censitário da Carta.

2. Alistamento eleitoral:

O exercício dos direitos da cidadania foram disciplinados com critérios

mais abrangentes. A idade para aquisição de tais direitos passou a vinte e um anos.

Eram proibidos de votar: os mendigos, os religiosos, praças e analfabetos.

3. Plebiscito, referendo e iniciativa popular:

Assim como na Constituição anterior, o texto constitucional de 1891 não faz nenhuma menção à participação popular.

8.3 CONSTITUIÇÃO DE 1934

- Inspirada na Constituição Alemã de 1919 (Weimar);
- Forma de Estado: Federal;
- Forma de Governo: República;
- Primeira Constituição a consagrar os direitos dos trabalhadores, como a jornada de oito horas e a proibição do trabalho infantil;
- Introduz o mandado de segurança individual no texto da Constituição.

Elencamos, ainda, algumas manifestações políticas que merecem destaque:

1. Tipo de sufrágio:

Assim como a Carta Constitucional de 1891, ao excluir os mendigos do direito de sufrágio, esta também revelou um aspecto censitário.

2. Alistamento eleitoral:

O exercício dos direitos da cidadania sofreram modificações significativas, pois foi alterada a idade para o início do seu exercício, que passou para dezoito anos. Também foi conferido o direito de votos às mulheres quando exercessem função pública remunerada.

Eram proibidos de votar: os mendigos, praças, analfabetos e os que estivessem privados, temporária ou definitivamente, do exercício de seus direitos políticos.

3. Plebiscito, referendo e iniciativa popular:

O texto constitucional novamente não faz nenhuma menção à participação popular. Inexistiam tais institutos.

4. Ação Popular:

Havia previsão expressa da Ação Popular nos seguintes termos:

Art. 113, n° 38. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou anulação dos actos lesivos ao patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios.

8.4 CONSTITUIÇÃO DE 1937

- Inspirada num modelo fascista da Carta ditatorial polonesa de 1935, foi extremamente autoritária. Conhecida por Constituição “polaca”;
- Além dos casos previstos na legislação militar para o tempo de guerra, a lei poderá prescrever a pena de morte para alguns crimes, inclusive os de homicídio cometido por motivo fútil e com extremos de perversidade;
- A lei pode prescrever censura prévia da imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da radiodifusão, facultando à autoridade competente proibir a circulação, a difusão ou a representação;
- A greve e o *lock-out* são declarados recursos antissociais nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional;
- São dissolvidos a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as Assembleias Legislativas dos Estados e as Câmaras Municipais.

Seguem abaixo algumas manifestações políticas que merecem destaque:

1. Tipo de sufrágio:

Houve a suspensão das eleições livres e o estabelecimento de eleições indiretas para Presidente com mandato de seis anos, tendo sido o sufrágio censitário.

2. Alistamento eleitoral e voto:

Eram proibidos de votar: os mendigos, militares em serviço, analfabetos e os cidadãos que estivessem privados, temporária ou definitivamente, do exercício de seus direitos políticos.

3. Plebiscito, referendo e iniciativa popular:

Em relação aos institutos, podemos destacar que a Carta de 1937 foi

a primeira Constituição brasileira a trazer expressamente o instituto do plebiscito, em dois casos: no caso de emenda, modificação ou reforma da Constituição e nos casos de incorporação, subdivisão ou desmembramento do Estado, respectivamente nos seguintes termos:

"Art. 174 - A Constituição pode ser emendada, modificada ou reformada por iniciativa do Presidente da República ou da Câmara dos Deputados. (Redação dada pela Lei Constitucional nº 9, de 1945)

§ 4º - No caso de ser rejeitado o projeto de iniciativa do Presidente da República, ou no caso em que o Parlamento aprobe definitivamente, apesar da oposição daquele, o projeto de iniciativa da Câmara dos Deputados, o Presidente da República poderá, dentro de trinta dias, resolver que o projeto seja submetido ao plebiscito nacional. (Redação dada pela Lei Constitucional nº 9, de 1945)

O plebiscito realizar-se-á noventa dias depois de publicada a resolução presidencial. O projeto se transformará em lei constitucional se lhe for favorável o plebiscito. (Incluído pela Lei Constitucional nº 9, de 1945)."

"Art 5º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, ou desmembrar-se para anexar-se a outros, ou formar novos Estados, mediante a aquiescência das respectivas Assembleias Legislativas, em duas sessões, anuais consecutivas, e aprovação do Parlamento Nacional.

Parágrafo único - A resolução do Parlamento poderá ser submetida pelo Presidente da República ao plebiscito das populações interessadas."

8.5 CONSTITUIÇÃO DE 1946

- É restabelecida a democracia;
- O Distrito Federal é a capital da União;
- É livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas;
- É estabelecida a função social da propriedade, prevendo-se desapropriação com indenização;

-
- Não haverá pena de morte, de banimento, de confisco nem de caráter perpétuo. São ressalvadas, quanto à pena de morte, as disposições da legislação militar em tempo de guerra com país estrangeiro;
 - É reconhecido o direito de greve, cujo exercício a lei regulará.

Elencamos, ainda, algumas manifestações políticas que merecem destaque:

1. Tipo de sufrágio:

O sufrágio universal pode ser percebido através do art. 134 da Constituição:

Art 134 - O sufrágio é universal e, direto; o voto é secreto; e fica assegurada a representação proporcional dos Partidos Políticos nacionais, na forma que a lei estabelecer.

2. Alistamento eleitoral e voto:

O início do exercício dos direitos da cidadania continuou aos dezoito anos.

Eram proibidos de votar: os analfabetos, os que não se comunicavam na língua nacional e os cidadãos que estivessem privados, temporária ou definitivamente, do exercício de seus direitos políticos.

3. Plebiscito, referendo e iniciativa popular:

Também trouxe a previsão de plebiscito nos casos de incorporação, subdivisão ou desmembramento dos Estados, nos seguintes termos:

Art 2º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante voto das respectivas Assembleias Legislativas, plebiscito das populações diretamente interessadas e aprovação do Congresso Nacional.

4. Ação Popular:

Havia previsão expressa da Ação Popular nos seguintes termos:

Art. 141, §38. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio da União, dos Estados, dos Municípios, das entidades autárquicas e das sociedades de economia mista.

8.6 CONSTITUIÇÃO DE 1967

- Militares preparam o projeto de Constituição e impõem que o Congresso Nacional vote;
- Privilegia a função executiva em detrimento das funções legislativa e judiciária;
- Preocupa-se fundamentalmente com a segurança nacional;
- Cria a ação de suspensão de direitos individuais e políticos;
- Modifica rigidamente o sistema tributário nacional e a discriminação de rendas;
- Ficam aprovados e excluídos de apreciação judicial os atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução de 31 de março de 1964;
- Em 1968, instituiu-se o AI-5.

Elencamos, ainda, algumas manifestações políticas que merecem destaque:

1. Tipo de sufrágio:

O sufrágio universal pode ser percebido através do art. 143 da Constituição:

Art 143 - O sufrágio é universal e o voto é direito e secreto, salvo nos casos previstos nesta Constituição; fica assegurada a representação proporcional dos Partidos Políticos, na forma que a lei estabelecer.

2. Alistamento eleitoral e voto:

A eleição para a Presidência se tornou indireta, sendo realizada por um colégio eleitoral. Foram mantidas as normas para o início do exercício dos direitos da cidadania, bem como as proibições.

Eram proibidos de votar: os analfabetos, os que não se comunicavam na língua nacional e os cidadãos que estivessem privados, temporária ou definitivamente, do exercício de seus direitos políticos.

Obs.: Importante destacar que as disposições do AI nº 5, que permitiam ao Presidente da República decretar o recesso do Congresso Nacional e a intervenção em Estados e Municípios foram referendadas pela EC nº 1/69.

3. Plebiscito, referendo e iniciativa popular:

A Carta de 1967 também trouxe a necessidade de plebiscito no que tange à criação de novos municípios, o que se repetiu na EC nº 1/69.

Art 14 - Lei complementar estabelecerá os requisitos mínimos de população e renda pública e a forma de consulta prévia às populações locais, para a criação de novos municípios.

8.7 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1, DE 1969

- A Constituição de 1967 é novamente escrita, sendo denominada Emenda Constitucional nº 1/69;
- Nesse texto emendado, o poder ficou cada vez mais centralizado, tanto horizontalmente (Legislativo, Executivo e Judiciário), quanto verticalmente (União, Estados e Municípios), nas mãos do Presidente da República;
- Elimina as imunidades parlamentares materiais e processuais;
- Determina a liberdade de criação de partidos políticos;
- A Emenda Constitucional nº 26, em 27 de novembro de 1985, convocou a Assembleia Nacional Constituinte, que iniciou os seus trabalhos em fevereiro de 1987.

CAPÍTULO 9

DIREITOS FUNDAMENTAIS



9.1 TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Breve histórico sobre os direitos humanos, sua importância no mundo pós-guerra e a dignidade da pessoa humana

As primeiras formulações históricas dos direitos humanos na segunda metade do século XVIII (*Bill of Rights* da Declaração de Virgínia, em 1776, e a Declaração Francesa dos Direitos do Homem, de 1789), movidas por ideais iluministas, retratavam a importância do direito natural (resguardando-se a existência de valores superiores aos das leis escritas), invocando-o expressamente em seus textos.⁸⁹

O direito natural é, muitas vezes, associado à moral, elemento subjetivo, desconsiderado no estudo da ciência jurídica pelos positivistas. Direito positivo era o não natural, o estabelecido por arbítrio, sem permanência, mutável de acordo com condições sociais variáveis. Para Nino,⁹⁰ os direitos humanos são, ao menos em sentido originário, direitos morais. Sua existência independe do reconhecimento pelo direito positivo, pois são concebidos como direitos outorgados pelo direito natural.

Tal concepção também é compartilhada de certa forma por Boaventura de Sousa Santos.⁹¹ Para o autor, o conceito de direitos humanos seria baseado em um conjunto de pressupostos ocidentais, designadamente pautados em uma natureza universal, que pode ser reconhecida racionalmente. A natureza humana seria essencialmente diferente e superior à restante realidade e, nesse sentido, o indivíduo possuiria uma dignidade absoluta e irredutível que teria que ser defendida da sociedade ou do Estado.

Segundo Eugênio Bulygin,⁹² no transcurso do século XIX a fundamentação jusnaturalista perdeu sua força em razão do positivismo jurídico ter se convertido na concepção jusfilosófica dominante. Nesse momento, os direitos humanos são recebidos pelos países civilizados (para

89. A título de exemplo, o primeiro parágrafo da Declaração de Virgínia expressa os direitos inatos, naturais de cada pessoa, como podemos visualizar a seguir:

“Que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes e têm certos direitos inatos, dos quais, quando entram em estado de sociedade não podem por qualquer acordo privar ou despojar seus pósteros e que são: o gozo da vida e da liberdade com os meios de adquirir e de possuir a propriedade e de buscar e obter felicidade e segurança”.

90. Nino, Carlos Santiago. *Ética y derechos humanos*. Buenos Aires: 1984, p. 24.

91. Sousa Santos, Boaventura de. “Por uma concepção multicultural de direitos humanos”. In: _____. (Org.). *Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo cultural*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 429-461.

92. BULYGIN, Eugênio; ALCHOURRON, Carlos E. *Análisis lógico y derecho*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 620.

a época, precisamente, Europa e Estados Unidos) sob a forma de direitos e garantias constitucionais. Contudo, as duas Grandes Guerras Mundiais vieram espalhando o horror e o caos; institucionalizaram a morte, a fome, o preconceito e a dor, marcando para sempre o século XX com a separação dos direitos fundamentais e a desconfiança de todos sobre as leis que não conseguiram evitar os massacres. O mundo sentiu uma necessidade urgente de proporcionar aos direitos humanos uma fundamentação mais sólida do que a prevista pelo direito positivo, que não os protegeu dos regimes totalitários.

Nesse contexto, a reconstrução da dignidade perdida nas guerras foi pilar fundamental desse momento de releitura do direito e, como bem afirma Flávia Piovesan:⁹³

Sob o prisma histórico, a primazia jurídica do valor da dignidade da pessoa humana é resposta à profunda crise sofrida pelo positivismo jurídico, associada à derrota do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Esses movimentos ascenderam ao poder dentro do quadro da legalidade.

E foi com a motivação da necessária proteção aos direitos humanos e consequente abertura das Constituições do mundo pós-guerra a valores e princípios, que se propôs o diálogo entre o direito positivo e o direito natural, permitindo a revisão das antigas “verdades jurídicas positivistas”, conforme observamos das sábias palavras de Dworkin,⁹⁴ para quem os princípios incorporam as exigências de justiça e dos valores éticos ao ordenamento jurídico, como já tratamos em capítulo específico.

Com a ascendência da valorização da ética e da moral, a dignidade da pessoa humana reaparece como unidade axiológica do ordenamento jurídico, irradiando a sua força para a concretização dos direitos humanos. Nessa relação simbiótica, poderíamos dizer que os direitos humanos constituem revelações da dignidade da pessoa humana, pelo menos de início.

Consagrado como valor jurídico universal, principalmente após a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, quando passou a receber contornos jurídicos, a dignidade da pessoa humana – entendida como o atributo imanente ao ser humano para exercício da liberdade e

93. PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 28.

94. Dworkin, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 1 a 120.

de direitos como garantia de uma existência plena e saudável – passou a ter amparo como um objetivo e uma necessidade de toda humanidade, vinculando governos, instituições e indivíduos. Nesse momento da história, o valor fundante da dignidade da pessoa humana se irradiou para as novas Constituições do mundo pós-guerra, permitindo-lhes inaugurar novas ordens jurídicas professando a dignidade humana como fim a ser atingido, verdadeiro substrato de valor de todo o ordenamento jurídico.

São exemplos desses novos textos constitucionais, o da República italiana, editado em 27 de dezembro de 1947, que afirmou, em seu art. 3º: “todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei”, e o da Lei Fundamental de Bonn (Alemanha), de 23 de maio de 1949, no seu art. 1.1: “A dignidade do homem é intangível. Os Poderes Públicos estão obrigados a respeitá-la e a protegê-la”. Mais tarde, a Constituição da República Portuguesa, promulgada em 1976, determinou, em seu art. 1º, que: “Portugal é uma República soberana, baseada, entre outros valores na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e igualitária”. Um pouco depois da queda do regime de exceção, comandado pelo generalíssimo Franco, a nova Constituição espanhola de 1978 seguiu na mesma trilha de seus contemporâneos: “A dignidade da pessoa, os direitos invioláveis que lhe são inerentes, o livre desenvolvimento da personalidade, o respeito pela lei e pelos direitos dos outros são fundamentos da ordem pública e da paz social”.

Hoje em dia, praticamente todas as Constituições do mundo ocidental remetem à dignidade da pessoa humana uma das esperanças de sua concretização, sem dúvida ali constando uma das mais saudáveis quimeras dos legisladores respectivos. Na esteira da nova ordem internacional, a Constituição brasileira de 1988 acolheu a dignidade da pessoa humana como um fundamento da República Federativa brasileira (art. 1º, III), um princípio fundamental (incluído no Título I) e um direito fundamental (art. 5º, III).

A dignidade da pessoa humana, segundo Maria Celina Bodin,⁹⁵ possui raízes filosóficas e foi com o cristianismo que primeiro se concebeu a ideia de uma dignidade pessoal, atribuída a cada indivíduo. Nesse sentido, a doutrinadora complementa que Kant consolida filosoficamente a dignidade da pessoa humana com o primado de que o ser humano jamais seja visto, ou usado, como um meio para atingir outras finalidades, mas sempre como um fim em si mesmo. Daí decorre o imperativo categórico de orientar-se, então,

95. Bodin de Moraes, Maria Celina. *Danos à Pessoa Humana: Uma Leitura Civil Constitucional dos Danos Morais*. São Paulo/Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 76-93.

pelo valor básico e universal da dignidade da pessoa humana.

A definição do princípio da dignidade da pessoa humana é um dos mais fáceis de ser compreendido, mas, sem dúvida, um dos mais difíceis de ser conceituado. Talvez por ser o mais carregado de sentimentos. Como unidade mais fundamental de valor do sistema jurídico, esse princípio universal funciona como paradigma, fundamento, limite e desiderato de um ordenamento jurídico, de um Estado e de uma sociedade aos quais confere legitimidade. Apesar de difícil conceituação, podemos compreender que o conteúdo do princípio diz respeito ao atributo imanente a todo ser humano e que justifica o exercício da sua liberdade e a perfeita realização de seu direito à existência plena e saudável.

Acreditamos que o importante princípio signifique a elevação do ser humano ao patamar mais alto das considerações, com a finalidade de impedir a sua degradação e a sua redução a um mero objeto de manipulação. Compreende a proteção e a promoção das condições fundamentais para uma vida adequada, o respeito à igualdade entre os indivíduos, a garantia da independência e de sua autonomia e a coibição de qualquer obstáculo que impeça o desenvolvimento do potencial de sua personalidade.

9.2 DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS

A carga axiológica que lastreia o vértice dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais é a mesma, é o centro dos direitos mais valiosos que nós temos. A vida, a liberdade, a propriedade, a segurança e a igualdade, com todos os seus desdobramentos, encontram-se protegidas por ambas as expressões, entretanto, a denominação “direitos humanos” é utilizada pela Filosofia do Direito e ainda pelo Direito Internacional Público e Privado. Já os “direitos fundamentais” seriam os direitos humanos positivados em um sistema constitucional. Os direitos humanos, sob a análise do Direito Constitucional, podem ser denominados de direitos fundamentais. A título de exemplo, o Título II da Constituição de 1988 se refere aos “direitos e garantias fundamentais” (tutelados pelo constituinte brasileiro), enquanto o art. 5º, § 3º, que trata da constitucionalização dos tratados, refere-se aos tratados sobre direitos humanos, fazendo referência aos documentos internacionais, dos quais o Brasil é signatário perante a comunidade jurídica internacional.

9.3 DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

“Direito”, em sua acepção clássica, seria a disposição meramente declaratória que imprime existência legal ao direito reconhecido. É a proteção ao bem, ao interesse tutelado pela norma jurídica configurando verdadeiro patrimônio jurídico. Ao lado dos direitos encontramos os deveres, que são normas de caráter limitativo, que buscam impor comportamento de respeito às normas que definem a proteção ao direito fundamental. A todo direito corresponde um dever. Exemplo: ao lado da norma que declara a liberdade de expressão (art. 5º, IV), encontramos o dever de exercício dessa liberdade sem ofensa a terceiros, sob pena de aplicação de sanção a quem dele abusa (art. 5º, V).

As “garantias”, por sua vez, traduzem-se no direito dos cidadãos de exigir dos Poderes Públicos a proteção de seus direitos. Servem para assegurar os direitos através da limitação do poder, possuindo caráter instrumental, atuando como mecanismos prestacionais na tutela dos direitos.

As garantias constitucionais, segundo a visão bipartida⁹⁶ da doutrina, classificam-se em gerais e específicas:

a) garantias fundamentais gerais: são aquelas que vêm convertidas em normas constitucionais que proíbem os abusos de poder e todas as espécies de violação aos direitos que elas asseguram e procuram tornar efetivos. Realizam-se por meio de princípios e preceitos constitucionais como o princípio da legalidade, o princípio da liberdade, princípio do devido processo legal, e pelas cláusulas de inviolabilidade (art. 5º, VI, X, XI, XII etc.);

b) garantias fundamentais específicas: são aquelas que instrumentalizam, verdadeiramente, o exercício dos direitos, fazendo valer o conteúdo e a materialidade das garantias fundamentais gerais. Por elas, os titulares do direito encontram a forma, o procedimento, a técnica, o meio de exigir a proteção incondicional de suas prerrogativas, como por exemplo o *habeas corpus*, o mandado de segurança, o *habeas data*, o mandado de injunção, a ação popular, o direito de petição etc. São chamados de “remédios constitucionais” por designar um recurso àquilo que combate o mal, qual seja, o desrespeito ao direito fundamental.

96. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 187-188.

9.4 TITULARIDADE

De acordo com o art. 5º, *caput*, são destinatários dos direitos fundamentais os brasileiros e os estrangeiros residentes no Brasil, ou seja, literalmente, a Constituição de 1988 não adotou o sentido universalista na defesa dos direitos fundamentais. Entretanto, não há dúvidas de que a interpretação gramatical do texto não encerra toda a essência da norma, pois, segundo orientação da doutrina e da jurisprudência, todas as pessoas naturais, independente de sexo, idade, nacionalidade ou de quaisquer outros fatores de discriminação, também possuem os seus direitos fundamentais garantidos. Além do mais, as pessoas jurídicas também encontram proteção a certos direitos fundamentais, como a honra e a imagem, por exemplo.⁹⁷

9.5 POSITIVAÇÃO

Na Constituição de 1988

Sob o prisma da Constituição Federal de 1988, os direitos fundamentais se classificam em:

a) direitos individuais, que são aqueles que delimitam a esfera de autonomia dos indivíduos, estabelecendo as áreas onde estão a salvo da interferência do Estado e de outros homens (art. 5º);

b) direitos coletivos, que representam os direitos do homem integrante de uma coletividade (art. 5º);

c) direitos sociais, reguladores das relações sociais e culturais, dividindo-se em direitos sociais propriamente ditos (art. 6º) e direitos trabalhistas (arts. 7º a 11);

d) direitos à nacionalidade, definidores da forma de obtenção, exercício e perda da nacionalidade (arts. 12 e 13);

e) direitos políticos e partidos políticos, que definem a forma de participação no exercício do poder político (arts. 14 a 17).

Importante destacar que eles não se esgotam no Título II da CRFB/88, pois estão espalhados em vários dispositivos constitucionais, como por exemplo: arts. 196, 205, 211, 225 etc.

97. Como exemplo, podemos citar a Súmula no 227, do STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

9.6 NAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS

Além da proteção constitucional efetiva, os direitos fundamentais também estão tutelados por normas infraconstitucionais, como, por exemplo: no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e no Código Civil brasileiro (Lei nº 10.406/2002), entre vários outros diplomas normativos que ajudam a fortalecer a proteção.

9.7 DUPLA DIMENSÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Os direitos fundamentais sob a perspectiva subjetiva significam que as pessoas podem exigir de outrem (particulares e Estado) uma determinada prestação, que pode ser comissiva ou omissiva.

Além da natureza facultativa de sua exigência, os direitos fundamentais encontram uma tutela também objetiva. É como se todo direito fundamental trouxesse um valor que deverá se irradiar pelo ordenamento. É a chamada força irradiante dos direitos fundamentais. Com base nesse conceito, fala-se também na teoria dos deveres de proteção aos direitos fundamentais. O Estado, mesmo em relação aos direitos fundamentais de caráter clássico, individuais, que eram vistos tradicionalmente como direitos a uma abstenção, deve agir, manifestando-se objetivamente para proteger o direito diante de ameaças vindas de terceiros.

9.8 EFICÁCIA VERTICAL E HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

A aplicação dos direitos fundamentais na relação Estado-indivíduo (eficácia vertical) é inquestionável. O Poder Público está vinculado à Constituição e, caso a viole, o Poder Judiciário deverá ser acionado para decidir sobre a situação em conflito. Como o princípio da supremacia do interesse público deve nortear toda a ação estatal, também existem situações em que os particulares são colocados em situações desvantajosas, que se justificam em nome do bem da coletividade (no caso da desapropriação ou da requisição administrativa, por exemplo).

Entretanto, a violação a direitos fundamentais não ocorre somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas naturais e jurídicas de direito privado, ou seja, nas

relações intersubjetivas.

Surgida na Alemanha pós-guerra,⁹⁸ a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais já encontra vasta jurisprudência e posição consolidada na doutrina, ainda que as situações concretas devam ser analisadas à luz do método da ponderação, em respeito à autonomia da vontade das partes, que é também direito fundamental.

Sobre o assunto, é possível se observar nas decisões do STF que quanto mais desigualdade existir entre as partes, maior será a possibilidade de intervenção judiciária para evitar o predomínio dos arbítrios, como nas relações trabalhistas e do consumidor, pois a autonomia privada não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional. A autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais.

Em importante decisão sobre a eficácia direta nas relações privadas, o STF decidiu pela reintegração de associado excluído do quadro de uma sociedade civil, sob o entendimento de que foram violadas as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e de que a sociedade havia extrapolado a liberdade do direito à associação.⁹⁹

9.9 CARACTERÍSTICAS

As características a seguir expostas identificam algumas peculiaridades do núcleo dos direitos fundamentais, ou seja, do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, e não de suas manifestações concretas. Por exemplo, a pessoa pode renunciar à herança – que é um dos desdobramentos concretos da propriedade – mas não poderá renunciar ao direito que tem à propriedade.

a) Relatividade

98. Devido às tensões nas relações de trabalho entre empregadores e empregados na exploração do mundo capitalista.

99. STF, RE 201.819/RJ, Rel.a Min.a Ellen Gracie, Segunda Turma, RE 161.243/ DF; Segunda Turma, Rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, j. 11.10.2005, DJ 27.10.2006. Sobre o assunto, ver ainda: STF, RE 161.243, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 29.10.1996, DJ 19.12.97.

Os direitos fundamentais não são absolutos, pois podem ser relativizados diante de situações em conflito, como por exemplo: apesar de o Estado brasileiro proteger o direito à vida como direito fundamental, vedando-se, como exemplo, a pena de morte, é possível que num caso excepcional, de guerra, a vida seja sacrificada em prol de outras vidas e dos valores da nação. É esse o entendimento do STF, nas palavras do Min. Celso de Mello, abaixo transcritas: *Os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas – e considerado o substrato ético que as informa – permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros*¹⁰⁰ (grifamos).

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos¹⁰¹ existiriam alguns direitos fundamentais que não poderiam em hipótese alguma ser desrespeitados, como, por exemplo, a vedação à escravidão e à tortura. Não há posicionamento formal do STF à respeito do assunto, então prevalece o entendimento de que a sua natureza, apesar de especial, é relativa.

b) Complementariedade

Os direitos fundamentais não são analisados sob o prisma isolado, pois estão numa relação de complementação, ou seja, os direitos sociais reforçam os direitos individuais, os direitos difusos ampliam as garantias para a tutela coletiva e é nessa simbiose que eles devem ser compreendidos e respeitados.

100. STF, MS 23.452/RJ, Plenário, j. 16.09.99, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 12.05.2000.

101. Adotada e proclamada pela Resolução no 217-A (III), da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Assim dispõe sobre o assunto:

“Artigo IV Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas.

Artigo V Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante”.

c) Indisponibilidade

Como não possuem natureza econômico-financeira, o núcleo dos direitos fundamentais não poderá ser transacionado por inteiro, ainda que alguns aspectos concretos dos direitos fundamentais possam ser eventualmente passíveis de negociação, como nos contratos de *reality show*, por exemplo.

d) Imprescritibilidade

Os direitos fundamentais não estão sujeitos ao decurso do tempo, por isso se diz que são imprescritíveis, o que não quer dizer que algumas manifestações concretas dos direitos não possam prescrever, como, por exemplo, a reclamação trabalhista que deverá ser ajuizada no prazo fatal de até dois anos após extinto o contrato de trabalho (art. 7º, XXIX, CRFB/88).

e) Universalidade

Essa característica está em harmonia com o envolvimento dos países com a comunidade jurídica internacional depois da Segunda Guerra Mundial de uma maneira muito contundente e pode ser analisada sob dois enfoques. Inicialmente, a titularidade deverá proteger o maior número de destinatários, sem preconceitos de raça, cor, sexo, idade, nacionalidade ou condição social. Em segundo lugar, podemos falar na relativização do próprio conceito de soberania estatal, em prol da soberania do indivíduo. Quando o Estado estiver prejudicando os direitos fundamentais do seu povo, da sua gente, a comunidade jurídica internacional poderia se organizar para atuar naquele Estado, para tentar restabelecer e resgatar a dignidade das pessoas que lá habitam, independente da vontade do governante do país. Esse assunto está em harmonia com o próprio art. 4º, II, da CRFB/88, quando pela primeira vez o Brasil inseriu o princípio da prevalência dos direitos humanos como guia nas relações internacionais.

f) Irrenunciabilidade

Não há possibilidade de alguém renunciar ao núcleo do seu direito fundamental, esvaziando-o por completo. Com isso, o Estado estaria protegendo o indivíduo contra si mesmo, quando, por exemplo, proíbe a eutanásia.

g) Historicidade

Os direitos fundamentais não têm natureza definitiva, pois continuam sendo construídos ao longo da história e se encontram em constante processo de modificação. Enfrentaram guerras, morte, lutas; ficaram no ápice e em

verdade as gerações dos direitos fundamentais explicam justamente isso, o ganho pontual que os direitos foram recebendo ao longo da história.

h) Aplicabilidade imediata

Na forma do art. 5º, § 1º, da CRFB/88, os direitos fundamentais possuiriam aplicação imediata, daí se infere que não podem ser entendidos como meras proclamações retóricas, devendo o intérprete extrair o máximo de efeitos jurídicos que eles podem produzir para a sociedade.

9.10 GERAÇÕES OU DIMENSÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

De acordo com a sua natureza histórica, os direitos foram sendo garantidos pelos ordenamentos jurídicos de maneira gradual. Em alguns momentos, receberam tratamento jurídico adequado e à altura de sua natureza e importância; em outros, foram completamente desconsiderados, como durante o período das grandes guerras mundiais.

Em que pese os momentos de involuções enfrentados pelos direitos fundamentais, pode-se dizer que formam uma categoria aberta e potencialmente ilimitada; não são estanques, imutáveis, pois seu conteúdo é entendido de formas diferentes dependendo do período histórico em que houve a sua evolução ou retrocessos.

Dentro dessa perspectiva transformadora, a doutrina¹⁰² resolveu dividi-los em gerações para apontar quando e como foram sendo consagrados na história do constitucionalismo. O termo “gerações” recebe algumas críticas tendo em vista que pode gerar uma visão errônea de substituição de direitos com o tempo, ou de superação de direitos, e hoje o termo mais aceito seria o que traz a ideia de “dimensões”.

Tradicionalmente as dimensões se dividem em 1ª – a das liberdades públicas, civis e políticas; 2ª – a dos direitos sociais, econômicos e culturais; 3ª – a da proteção aos direitos difusos, e modernamente, ainda se fala em 4ª e 5ª dimensões, todas tratadas em seguida.

a) Direitos de primeira dimensão

A primeira dimensão é conhecida por inaugurar o movimento

102. Como exemplo a teoria de T. H. Marshall, disponível em <http://www.lse.ac.uk/resources/LSEHistory/marshall.htm> e os escritos de Norberto Bobbio em *A era dos Direitos*, Rio de Janeiro: Campus, 1992.

constitucionalista, fruto dos ideários iluministas do século XVIII. Os direitos defendidos nessa dimensão cuidam da proteção das liberdades públicas e dos direitos políticos. Atualmente, quase todas as Constituições existentes os consagram, mesmo aquelas de Estados onde impera a sua escancarada violação como, por exemplo, os ditatoriais. Os titulares são os indivíduos, que os exercem contra os poderes constituídos dos Estados. Nessa fase, o Estado teria um dever de prestação negativa, isto é, um dever de nada fazer, a não ser respeitar as liberdades do homem. Seriam exemplos desses direitos: o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à manifestação, à expressão, ao voto, ao devido processo legal.

b) Direitos de segunda dimensão

Sob a inspiração da Constituição Mexicana de 1917, a Declaração Soviética dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, de 1918, e a Constituição de Weimar, de 1919, nasce a denominada segunda dimensão de direitos fundamentais, que traz proteção aos direitos sociais, econômicos e culturais, em que do Estado não mais se exige uma abstenção, mas, ao contrário, impõe-se a sua intervenção, visto que a liberdade do homem sem a sua participação não é protegida integralmente. Essa necessidade de prestação positiva do Estado corresponderia aos chamados direitos sociais dos cidadãos, direitos que transcendem a individualidade e alcançam um caráter econômico e social, com o objetivo de garantir a todos melhores condições de vida. Nesse diapasão, seriam exemplos clássicos desses direitos: o direito à saúde, ao trabalho, à assistência social, à educação e os direitos dos trabalhadores.

c) Direitos de terceira dimensão

Marcada pelo espírito de fraternidade entre os povos com o fim da Segunda Guerra Mundial, a terceira geração representa a evolução dos direitos fundamentais para alcançar e proteger aqueles direitos decorrentes de uma sociedade já modernamente organizada, que se encontra envolvida em relações de diversas naturezas, especialmente aquelas relativas à industrialização e densa urbanização. Nesta perspectiva, são exemplos desses direitos: direito ao desenvolvimento, direito à paz, e direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

d) Direitos de quarta e quinta dimensões

Sob a influência da globalização (política e de direitos fundamentais), Paulo Bonavides ainda sustenta a existência de uma quarta geração de

direitos, que seria formada pelos avanços tecnológicos, pluralismo político, informação, sedimentação do modelo político democrático e pelo próprio futuro da cidadania.¹⁰³ Poderíamos, ainda, incluir nessa análise a manipulação do patrimônio genético, como os advindos da clonagem, da fertilização *in vitro*, entre outros avanços da ciência e da tecnologia.

Segundo o autor, o direito à paz traria uma quinta dimensão de direitos fundamentais, sendo condição indispensável ao progresso de todas as nações, grandes e pequenas, em todas as esferas.

9.11 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO FORMAL DOS TRATADOS SOBRE DIREITOS HUMANOS. ART. 5º, § 3º

A EC nº 45/2004 ao inserir no art. 5º o § 3º trouxe uma nova possibilidade para os tratados sobre Direitos Humanos, que podem vir a ser constitucionalizados caso sejam submetidos ao procedimento previsto no próprio dispositivo. Segundo os defensores da teoria do bloco de constitucionalidade, esse dispositivo visaria formalizar o que materialmente já estaria consolidado em face do art. 5º, § 2º.

A partir daí passamos a conviver com um processo híbrido de incorporação de tratados. O primeiro, aplicável a todos os tratados em geral, fruto da combinação do art. 84, VIII, com o art. 49, I, qual seja: o Presidente da República assina o documento perante a comunidade jurídica internacional, posteriormente o encaminha para o Congresso Nacional, tendo em vista a elaboração de um decreto legislativo que deverá ser promulgado por meio de um decreto presidencial, que terá força interna de norma infraconstitucional. O segundo, advindo da EC nº 45/2004, aplica-se apenas aos tratados sobre direitos humanos, e permitiria que, após a assinatura do presidente da República, os documentos internacionais fossem submetidos ao crivo dos legisladores com o intuito de sua incorporação constitucional formal com *status* de emenda constitucional, depois de seguido o processo previsto no art. 5º, § 3º.

Até o momento, destacamos apenas a constitucionalização formal da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. O Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, conforme o procedimento do § 3º do art. 5º da

103. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, item no 6, p. 570-572.

Constituição a referida Convenção, que foi promulgada pelo presidente da República por meio do Decreto nº 6.949/2009.

Segundo entendimento do STF, os demais tratados sobre direitos humanos que não passarem pelo crivo do art. 5, § 3º da CRFB/88, terão status de norma supralegal. Já os tratados que não versem sobre direitos humanos, serão incorporados com status de lei ordinária federal.

9.12 INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL

A previsão do art. 109, § 5º, da CRFB/88, acrescentado pela EC nº 45/2004, possibilita que inquérito ou processo criminal em curso perante a Justiça Estadual seja deslocado para a Justiça Federal, quando houver violação grave a direitos humanos.

Art. 109, § 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.

O STJ fixou os pressupostos para o deslocamento da competência, nos termos do art. 109, § 5º, da CRFB/88:

- **Existência de grave violação a direitos humanos** - Para que seja acolhido o pleito de deslocamento da competência, não é qualquer violação que pode ser invocada. A violação deve ser grave, sendo que tal análise fica a cargo do Superior Tribunal de Justiça. Não são somente as condutas violadoras de direitos fundamentais, mas sim todas as condutas que violem direitos humanos. A Declaração Universal de Direitos Humanos reconhece expressamente alguns direitos como sendo direitos humanos (igualdade, prestação jurisdicional efetiva, prisão fundamentada, julgamentos públicos, princípio da anterioridade em matéria penal, inviolabilidade da intimidade própria e da família, liberdade de locomoção, livre locomoção, entre os países, asilo político, nacionalidade, matrimônio, família como núcleo essencial de uma sociedade, propriedade, liberdade de consciência política, religiosa, liberdade de opinião, liberdade de reunião, acesso ao serviço

público, livre participação política, poder legítimo do povo, segurança social, igualdade remuneratória pela identidade de trabalho, remuneração justa e satisfatória, liberdade sindical, repouso e lazer, entre outros).

- **Risco de responsabilização internacional decorrente do descumprimento de obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais.**

- **Incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer respostas efetivas** – seja pela inércia deliberada, seja pela limitação ou precariedade dos instrumentos colocados à disposição da Justiça Estadual. Presentes os pressupostos, deve ser instaurado o **incidente de deslocamento de competência**, procedimento judicial a ser proposto perante o **STJ**, sendo que o único legitimado para tanto é o **Procurador-Geral da República**. O pedido de deslocamento pode ser formulado em qualquer fase do inquérito ou do processo. Dada a redação ampla do dispositivo, a doutrina sustenta que será possível o deslocamento da competência até mesmo na fase executiva, após o trânsito em julgado, porque é possível que a violação de direitos humanos somente ocorra nessa fase.

9.13 ANÁLISE DOUTRINÁRIA E INDICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA SOBRE O ART. 5º

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

O art. 5º ressalta o núcleo principal dos direitos fundamentais e os seus destinatários. O direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade são desdobrados nos setenta e oito incisos e nos quatro parágrafos que com ele se relacionam e ainda em uma série de dispositivos constitucionais que reforçam a proteção ao núcleo.

Apesar de o estrangeiro de passagem no país e às pessoas jurídicas carecerem de proteção na literalidade do dispositivo, não há dúvidas quanto a serem titulares de direitos fundamentais ao lado dos brasileiros e dos estrangeiros que aqui residem.

O princípio da dignidade da pessoa humana lastreia um dos fundamentos principais da República Federativa do Brasil (art. 1º, III) e é carga axiológica

presente em todos os direitos fundamentais. Portanto, negar proteção constitucional a alguma pessoa no país seria ir de encontro aos próprios alicerces da Constituição.

A seguir, faremos uma análise simples de cada um dos incisos do art. 5º, à luz da jurisprudência do STF.

9.14 PRINCÍPIO DA IGUALDADE

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

O constituinte originário expressou neste dispositivo as lutas históricas travadas contra a discriminação do sexo feminino. Assim, homens e mulheres que se encontrarem em situação idêntica não poderão sofrer qualquer cerceamento em suas prerrogativas e nos seus deveres. As discriminações são toleradas apenas quando a finalidade pretendida for a diminuição dos desníveis entre homem e mulher, ou entre as pessoas em geral, tendo em vista as diferenças de idade, sexo, capacidade econômica etc.

O direito à igualdade ganha reforço em vários dispositivos no restante do corpo da Constituição, como por exemplo: art. 3º, III e IV; art. 7º XXX e XXXI; arts. 193 e 196, dentre muitos outros.

Como as pessoas não são iguais, o respeito à diferença e às necessidades de cada um é um dos pilares mais importantes do conceito. Deve haver uma relação direta entre a desigualdade e a diferença observada, para que esta relação tenha pertinência.

A isonomia pode ser formal ou material:

a) Isonomia formal: fica proibida a discriminação arbitrária;

b) Isonomia material: do Poder Público é exigido que adote providências concretas que diminuam a desigualdade. Chama-se “política de ação afirmativa ou discriminação positiva” a providência que leve à diminuição da desigualdade. É atingida quando o Estado edita normas que privilegiam os desfavorecidos da sociedade e estas se tornam efetivas.

Além disso, a Constituição determina de forma expressa a igualdade perante a lei e de forma implícita a igualdade na lei. Significam:

c) Igualdade perante a lei: é um comando que se dirige a todos: legislador, juiz, administrador público na aplicação da norma jurídica ao caso concreto, para que esta seja aplicada de modo igual àqueles que se

encontrem em posições idênticas ou substancialmente semelhantes;

d) Igualdade na lei: é o comando que se dirige especialmente ao legislador, no sentido de que ele tem que cuidar para que não se estabeleçam na lei, comportamentos abusivos, ilícitos, arbitrários, contrários à igualdade, diferenciando pessoas que se encontram em situações idênticas, salvo motivo razoável.

As políticas das ações afirmativas também são formas encontradas pelos governantes para minimizar as diferenças existentes entre as pessoas e, dessa forma, alcançar a verdadeira igualdade.

Princípio da igualdade e concurso público I:

Súmula 683 do STF: *“O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”*

Princípio da igualdade e concurso público II: “em se tratando de concurso público para agente de polícia, mostra-se razoável a exigência de que o candidato tenha altura mínima de 1,60m. Previsto o requisito não só na lei de regência, mas também no edital de concurso, não concorre a primeira condição do mandado de segurança, que é a existência de direito líquido e certo”¹⁰⁴.

Princípio da igualdade e concurso público III: “A vedação constitucional de diferença de critério de admissão por motivo de idade (CRFB/88, art. 7º, XXX) é corolário, na esfera das relações de trabalho, do princípio fundamental de igualdade, que se entende, à falta de exclusão constitucional inequívoca (como ocorre em relação aos militares — CRFB/88, art. 42, § 1º), a todo o sistema do pessoal civil. É ponderável, não obstante, a ressalva das hipóteses em que a limitação de idade se possa legitimar como imposição da natureza e das atribuições do cargo a preencher.”¹⁰⁵

104. STF, RE 148.095, Rel. Min. Marco Aurélio, J em 3-02-1998, DJ, 3-4-1998.

105. STF, RMS 21.046, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, J em 14-12-90, DJ de 14-11-91). No mesmo sentido: RE 141.357, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, J em 14-9-04, DJ de 8-10-04; RE 212.066, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 18-9-98, DJ 12-3-99.

Princípio da igualdade e concurso público IV: “Viola o princípio constitucional da isonomia norma que estabelece como título o mero exercício de função pública.”¹⁰⁶

Princípio da igualdade e carreira militar: “Promoção de militares dos sexos masculino e feminino: critérios diferenciados: carreiras regidas por legislação específica: ausência de violação ao princípio da isonomia”¹⁰⁷.

Princípio da igualdade e estrangeiros: “Tratamento igualitário de brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. O alcance do disposto na cabeça do artigo 5º da Constituição Federal há de ser estabelecido levando-se em conta a remessa aos diversos incisos. A cláusula de tratamento igualitário não obstaculiza o deferimento de extradição de estrangeiro”¹⁰⁸.

Princípio da igualdade e habeas corpus: “A concessão de habeas corpus a determinados corréus, em situações processuais diversas, não implica violação ao princípio da isonomia”¹⁰⁹.

O princípio da igualdade e o tratamento diferenciado para portadores de deficiências:

“O Tribunal, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta ajuizada pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal, Interestadual e Internacional de Passageiros - ABRATI contra a Lei nacional 8.899/94, que concede passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes. (...) Rejeitou-se, de igual modo, a apontada ofensa ao princípio da igualdade, ao fundamento de que a lei em questão teria dado forma justa ao direito do usuário que, pela sua diferença, haveria de ser tratado nesta condição desigual para se igualar nas oportunidades de ter acesso àquele serviço público. (...) Concluiu-se que a Constituição, ao assegurar a livre concorrência, também

106. STF, ADI 3.443, Rel. Min. Carlos Velloso, J em 8-9-05, DJ de 23-9-05. No mesmo sentido: ADI 3.522, Rel. Min. Marco Aurélio, J em 24-11-05, DJ de 12-5-06.

107. STF, AI 511.131-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, J em 22-3-05, DJ, de 15-4-05.

108. STF, Ext 1.028, Rel. Min. Marco Aurélio, J em 10-8-06, DJ de 8-9-06.

109. STF, HC 90.138, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J em 11-9-07, DJ de 28-9-07

determinou que o Estado deveria empreender todos os seus esforços para garantir a acessibilidade, para que se promovesse a igualdade de todos, em cumprimento aos fundamentos da República de cidadania e dignidade da pessoa humana, o que se realizaria pela definição de meios para que eles fossem atingidos. Um desses meios se poria na lei analisada que dotaria de concretude os valores constitucionais percebidos e acolhidos pelos constituintes e adotados como princípios e regras da CRFB/88."¹¹⁰

9.15 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

O Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput) repousa sob o signo da legalidade, exposto no dispositivo sob comento em seu sentido material ou amplo. O princípio da legalidade, portanto, expressa a sujeição ou subordinação das pessoas, órgãos ou entidades às prescrições emanadas do Legislativo, Executivo e Judiciário. Para o particular, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei (aqui em sentido amplo ou material, referindo-se a qualquer espécie normativa), diante da sua autonomia da vontade. Já quanto ao administrador, deverá ser adotado o princípio da legalidade em sentido estrito, pois só é possível fazer o que a lei autoriza ou determina.

Deste dispositivo também deriva o princípio da reserva legal que determina que algumas matérias sejam regulamentadas exclusivamente por lei formal, ou seja, lei oriunda do processo legislativo constitucional, como é o exemplo das matérias penais, que não podem ser tratadas por medida provisória (editada por ato unilateral do Chefe do Executivo), por expressa vedação constitucional (art. 62, § 1º, I, "b").

Princípio da legalidade e da reserva legal I:

"A reserva de lei em sentido formal qualifica-se como instrumento constitucional de preservação da integridade de direitos e garantias fundamentais. O princípio da reserva de

¹¹⁰ STF, ADI 2.649, Rel. Min. Cármen Lúcia, J em 8-5-08, Informativo 505

lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal. O abuso de poder regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua contra legem ou praeter legem, não só expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo, tal a gravidade desse comportamento governamental, o exercício, pelo Congresso Nacional, da competência extraordinária que lhe confere o art. 49, inciso V, da Constituição da República e que lhe permite 'sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar (...)'''''.

Princípio da legalidade e da reserva legal II:

"O princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação ao exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. A reserva de lei — analisada sob tal perspectiva — constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não-legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na autoridade da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador. Não cabe, ao Poder Executivo, em tema regido pelo postulado da reserva de lei, atuar na anômala (e inconstitucional) condição de legislador, para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder Executivo passaria a desempenhar atribuição que lhe é

111. STF, ACO 1.048-QO, Rel. Min. Celso de Mello, J em 30-8-07, DJ de 31-10-07

institucionalmente estranha (a de legislador), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes."(grifamos)¹¹²

9.16 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

III - ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

A definição do princípio da dignidade da pessoa humana é um dos mais fáceis de ser compreendido, mas, sem dúvida, um dos mais difíceis de conceituar. Talvez por ser o mais carregado de sentimentos. Como unidade mais fundamental de valor do sistema jurídico, esse princípio universal funciona como paradigma, fundamento, limite e desiderato de um ordenamento jurídico, de um Estado e de uma sociedade aos quais confere legitimidade. Apesar de difícil conceituação, podemos compreender que o conteúdo do princípio diz respeito ao atributo imanente a todo ser humano e que justifica o exercício da sua liberdade e a perfeita realização de seu direito à existência plena e saudável.

Significa a elevação do ser humano ao patamar mais alto das considerações, com a finalidade de impedir a sua degradação e a sua redução a um mero objeto de manipulação. Compreende a proteção e a promoção das condições fundamentais para uma vida adequada, o respeito à igualdade entre os indivíduos, a garantia da independência e de sua autonomia, a coibição de qualquer obstáculo que impeça o desenvolvimento do potencial de sua personalidade.

Nesse diapasão, após os 21 (vinte e um) anos de ditadura militar, o constituinte originário, inovando na história brasileira, resolveu consagrar expressamente a tortura, buscando assegurar a integridade física e psíquica do indivíduo, em nome do próprio direito à vida e à sua ampla dimensão.

Dignidade da Pessoa Humana e uso de algemas I:

Súmula Vinculante 11: "Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à

112. STF, ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, J em 7-2-01, DJ de 27-6- 03

integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado."

Dignidade da Pessoa Humana e uso de algemas II: "O uso legítimo de algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional, a ser adotado nos casos e com as finalidades de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer, e para evitar agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo. O emprego dessa medida tem como balizamento jurídico necessário os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."¹¹³

9.17 MANIFESTAÇÃO DE EXPRESSÃO RESPONSÁVEL

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

A manifestação do pensamento é um dos atributos da liberdade de expressão, entretanto deverá ser realizada de maneira responsável. A identificação da autoria da manifestação (seja em cartas, e-mails, artigos nos jornais) é indispensável para tentar coibir as manifestações que tenham como intuito apenas o prejuízo da moral ou do bom nome alheio.

Aquele que se sentir agredido pela expressão do pensamento do outro tem direito de resposta, que será proporcional ao agravo. O direito de resposta é garantia inviolável da pessoa, permitindo ao ofendido corrigir equívocos e desfazer dúvidas, utilizando-se do mesmo veículo, tempo, modo e lugar utilizados para a ofensa. Se for negado pelo ofensor, este direito será tutelado pelo Poder Judiciário. Além do que é assegurada a ampla reparabilidade pelos prejuízos sofridos, sejam de natural material (pecuniária), moral (que tenha ofendido a honra subjetiva) ou à imagem (que tenham ofendido a honra objetiva).

113. STF, HC 89.429, Rel. Min. Cármen Lúcia, J em 22-8-06, DJ de 2-2-07

Insta ressaltar que as liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição.

Vedação ao anonimato e denúncia anônima:

“(...) entendo que um dos fundamentos que afastam a possibilidade de utilização da denúncia anônima como ato formal de instauração do procedimento investigatório reside, precisamente, como demonstrado em meu voto, no inciso IV do art. 5º da Constituição da República. Impende reafirmar, bem por isso, na linha do voto que venho de proferir, a asserção de que os escritos anônimos não podem justificar, só por si, desde que isoladamente considerados, a imediata instauração da persecutio criminis, eis que peças apócrifas não podem ser incorporadas, formalmente, ao processo, salvo quando tais documentos forem produzidos pelo acusado, ou, ainda, quando constituírem, eles próprios, o corpo de delito (como sucede com bilhetes de resgate no delito de extorsão mediante sequestro, ou como ocorre com cartas que evidenciem a prática de crimes contra a honra, ou que corporifiquem o delito de ameaça ou que materializem o crimen falsi, p. ex.). Nada impede, contudo, que o Poder Público (...) provocado por delação anônima — tal como ressaltado por Nelson Hungria, na lição cuja passagem reproduzi em meu voto — adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, com prudência e discrição, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da persecutio criminis, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas.”¹¹⁴

114. STF, Inq 1.957, Rel. Min. Carlos Velloso, voto do Min. Celso de Mello, J em 11-5-05, DJ de 11-11-05)

Vedação ao anonimato e denúncias ao TCU:

“A Lei 8.443, de 1992, estabelece que qualquer cidadão, partido político ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU. A apuração será em caráter sigiloso, até decisão definitiva sobre a matéria. Decidindo, o Tribunal manterá ou não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia (§ 1º do art. 55). Estabeleceu o TCU, então, no seu Regimento Interno, que, quanto à autoria da denúncia, será mantido o sigilo: inconstitucionalidade diante do disposto no art. 5º, incisos V, X, XXXIII e XXXV, da Constituição Federal.”¹¹⁵

Liberdade de expressão e racismo:

“O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o ‘direito à incitação ao racismo’, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica.”¹¹⁶

Direito de Resposta e Lei de imprensa

“(…) O pedido judicial de direito de resposta previsto na lei de imprensa deve ter no pólo passivo a empresa de informação ou divulgação, a quem compete cumprir a decisão judicial no sentido de satisfazer o referido direito, citado o responsável nos termos do § 3º do art. 32 da Lei n. 5.250/67, sendo parte ilegítima o jornalista ou o radialista envolvido no fato. Falta interesse recursal ao requerido pessoa física, já que, no caso concreto, o Juiz de Direito proferiu decisão condenatória apenas no tocante à empresa de radiodifusão. O não-conhecimento da apelação do requerido pessoa física, hoje Deputado Federal, implica a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que julgue a apelação da pessoa jurídica que não tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal (…)”¹¹⁷.

115. STF, MS 24.405, Rel. Min. Carlos Velloso, J em 3-12-03, DJ de 23-4-04)

116. STF, HC 82.424, Rel. p/ o ac. Min. Maurício Corrêa, J em 17-9-03, DJ de 19-3-04

117. STF, Pet. 3.645, Rel. Min. Menezes Direito, J em 20-2-08, DJE de 2-5-08.

9.18 LIBERDADE RELIGIOSA

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

A liberdade de religião exterioriza-se pela manifestação de pensamento e pode ser apresentada sob duas formas: a) liberdade de consciência e de crença: é a liberdade de foro íntimo. Ninguém pode obrigar ninguém a pensar deste ou daquele modo ou a acreditar nisto ou naquilo. Ambas as liberdades situam-se no recanto mais profundo da alma humana e são invioláveis; b) liberdade de culto religioso: protege o conjunto de manifestações que levam o crente a expressar sua religião (ritos, cerimônias, cultos, manifestações, reuniões, hábitos, tradições etc.).

O Estado também incentiva a busca do amparo espiritual ao isentar de pagamentos de impostos os templos de qualquer culto (art. 150, VI, "b" da CRFB/88).

Diante desta liberdade, a Constituição impede que as pessoas que se encontrem internadas em estabelecimentos como delegacias, cadeias, presídios, hospitais, asilos e manicômios, a assistência religiosa, principalmente se solicitada e independentemente da orientação religiosa predominante no local de internação coletiva.

O inciso VIII consagra a escusa de consciência, imperativo de consciência ou escusa absolutória. Essas três expressões servem para denominar o direito que nós temos, de deixar de cumprir a obrigação legal a todos imposta (ser mesário nas eleições, cumprir serviço militar obrigatório etc.), que seja contrária à religião ou convicção filosófica ou política. Neste caso, o Estado determinará, no lugar da obrigação principal, a realização de uma prestação alternativa, que se descumprida, gerará a privação de direitos políticos (do status de cidadão) na forma do art. 15, IV.

É importante ressaltar que para a ocorrência da restrição aos direitos políticos é necessária a concorrência de dois requisitos: o não cumprimento

de uma obrigação legal a todos imposta e o descumprimento da prestação alternativa, fixada em lei.

9.19 LIBERDADE DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

A liberdade de expressão do pensamento por meio da arte, da ciência e da comunicação não podem sofrer censuras ou submeter-se à qualquer licença por parte do Estado em nome da própria democracia instituída no país em 1988. Entretanto, como não há liberdade absoluta, é preciso que músicas, livros, poesias, inventos e quaisquer formas de exteriorização dessa modalidade de liberdade estejam afinados com o princípio da dignidade da pessoa humana e de acordo com a legislação. Não são permitidos, portanto, livros com conteúdo racista, músicas que incitem a realização de crimes etc.

Importante registrar que censura e licença não podem ser confundidas com a classificação etária, que às vezes o Poder Público faz com relação aos programas teatrais cinema e televisão, pois, o Estado tem a responsabilidade juntamente com a sociedade na educação das crianças e adolescente e esta seria também forma de sua participação.

Liberdade da ciência e Lei de Biossegurança:

“Em conclusão, o Tribunal, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República contra o art. 5º da Lei federal 11.105/2005 (Lei da Biossegurança), que permite, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não usados no respectivo procedimento, e estabelece condições para essa utilização (...). Prevaleceu o voto do Min. Carlos Britto, relator. (...) Considerou, também, que, se à lei ordinária seria permitido fazer coincidir a morte encefálica com a cessação da vida de uma certa pessoa humana, a justificar a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo ainda fisicamente pulsante para fins

de transplante, pesquisa e tratamento (Lei 9.434/97), e se o embrião humano de que trata o art. 5º da Lei da Biossegurança é um ente absolutamente incapaz de qualquer resquício de vida encefálica, a afirmação de incompatibilidade do último diploma legal com a Constituição haveria de ser afastada. Por fim, acrescentou a esses fundamentos, a rechaçar a inconstitucionalidade do dispositivo em questão, o direito à saúde e à livre expressão da atividade científica. Frisou, no ponto, que o § 4º do art. 199 da CRFB/88(...) faria parte, não por acaso, da seção normativa dedicada à saúde, direito de todos e dever do Estado (CRFB/88, art. 196), que seria garantida por meio de ações e serviços qualificados como de relevância pública, com o que se teria o mais venturoso dos encontros entre esse direito à saúde e a própria Ciência (CRFB/88, art. 5º, IX)''¹¹⁸.

Liberdade de comunicação e censura:

"O Tribunal, por maioria, referendou liminar deferida em arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT para o efeito de suspender a vigência da expressão 'a espetáculos de diversões públicas, que ficarão sujeitos à censura, na forma da lei, nem', contida na parte inicial do § 2º do art. 1º; do § 2º do art. 2º; da íntegra dos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 65; da expressão 'e sob pena de decadência deverá ser proposta dentro de 3 meses da data da publicação ou transmissão que lhe der causa', constante da parte final do art. 56; dos §§ 3º e 6º do art. 57; dos §§ 1º e 2º do art. 60; da íntegra dos artigos 61, 62, 63 e 64; dos artigos 20, 21, 22 e 23; e dos artigos 51 e 52, todos da Lei 5.250/67 (Lei de Imprensa). Preliminarmente, tendo em conta o princípio da subsidiariedade, o Tribunal, também por maioria, conheceu da ação. (...). No mérito, entendeu-se configurada a plausibilidade jurídica do pedido, haja vista que o diploma normativo impugnado não pareceria serviente do padrão de democracia e de imprensa vigente na Constituição de 1988 (CRFB/88, artigos 1º; 5º, IV, V, IX e XXXIII e 220, caput e §

118. STF, ADI 3.510, Rel. Min. Carlos Britto, J em 28 e 29-5-08, Informativo 508.

1º). Considerou-se, ademais, presente o perigo na demora da prestação jurisdicional, afirmando-se não ser possível perder oportunidade de evitar que eventual incidência da referida lei, de nítido viés autoritário, colidisse com aqueles valores constitucionais da democracia e da liberdade de imprensa. (...). O Tribunal, empregando por analogia o art. 21 da Lei 9.868/99, estabeleceu o prazo de 180 dias, a contar da data da sessão, para retorno do feito para o julgamento de mérito.”¹¹⁹

Liberdade intelectual e racismo:

“Habeas corpus. Publicação de livros: antisemitismo. Racismo. Crime imprescritível. Conceituação. Abrangência constitucional. Liberdade de expressão. Limites. Ordem denegada. Escrever, editar, divulgar e comercializar livros ‘fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias’ contra a comunidade judaica (Lei 7.716/89, artigo 20, na redação dada pela Lei 8.081/90) constitui crime de racismo sujeito às cláusulas de inafiançabilidade e imprescritibilidade (CRFB/88, artigo 5º, XLII).”¹²⁰

Biografias: autorização prévia e liberdade de expressão - 1

É inexistível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes. Essa a conclusão do Plenário, que julgou procedente pedido formulado em ação direta para dar interpretação conforme à Constituição aos artigos 20 e 21 do CC (“Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para

119. STF, ADPF 130 MC, Rel. Min. Carlos Britto, J em 27-2-08, Informativo 496.

120. STF, HC 82.424, Rel. p/o ac. Min. Maurício Corrêa, J em 17-9-03, DJ de 19-3-04

impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”), sem redução de texto, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, de produção científica, de liberdade de informação e de proibição de censura (CRFB/88, artigos 5º, IV, V, IX, X e XIV; e 220). O Colegiado asseverou que, desde as Ordenações Filipinas, haveria normas a proteger a guarda de segredos. A partir do advento do CC/1916, entretanto, o quadro sofrera mudanças. Ademais, atualmente, o nível de exposição pública das pessoas seria exacerbado, de modo a ser inviável reter informações, a não ser que não fossem produzidas. Nesse diapasão, haveria de se compatibilizar a inviolabilidade da vida privada e a liberdade de pensamento e de sua expressão. No caso, não se poderia admitir, nos termos da Constituição, que o direito de outrem de se expressar, de pensar, de criar obras biográficas — que dizem respeito não apenas ao biografado, mas a toda a coletividade, pelo seu valor histórico — fosse tolhido pelo desejo do biografado de não ter a obra publicada. Os preceitos constitucionais em aparente conflito conjugar-se-iam em perfeita harmonia, de modo que o direito de criação de obras biográficas seria compatível com a inviolabilidade da intimidade, privacidade, honra e imagem. Assim, em suma, o Plenário considerou: a) que a Constituição asseguraria como direitos fundamentais a liberdade de pensamento e de sua expressão, a liberdade de atividade intelectual, artística, literária, científica e cultural; b) que a Constituição garantiria o direito de acesso à informação e de pesquisa acadêmica, para o que a biografia seria fonte fecunda; c) que a Constituição proibiria a censura de qualquer natureza, não se podendo concebê-la de forma subliminar pelo Estado ou por particular sobre o direito de outrem; d) que a Constituição garantiria a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa; e e) que a legislação infraconstitucional não poderia amesquinhar ou restringir direitos fundamentais constitucionais, ainda que sob pretexto de estabelecer formas de proteção, impondo condições ao exercício de liberdades de forma diversa da constitucionalmente fixada. ADI 4815/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, 10.6.2015. (ADI-4815)

9.20 PROTEÇÃO À INTIMIDADE E A VIDA PRIVADA

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Intimidade e privacidade têm íntima ligação, embora possam ser distinguidos. Ambos tutelam a liberdade da vida privada. Cuidam da esfera secreta das pessoas, protegendo o modo de viver, as relações afetivas, hábitos, particularidades etc. As questões da intimidade são mais internalizadas que as questões da privacidade.

Segundo orientação jurisprudencial já consolidada, a divulgação de informações colhidas em correspondências (cartas, telegramas e dados) fere o direito à intimidade da pessoa humana, como é possível se observar da jurisprudência ao final realatada.

A honra é valor humano que também veio a ser protegido pela Constituição, por estar muito próxima da dignidade, do respeito e da boa reputação. É um bem imaterial que consiste no apreço que uma pessoa goza na sociedade ou o respeito e a boa reputação que possui perante seus concidadãos. A imagem, por sua vez, pode ser compreendida no seu aspecto físico e social, este último muito próximo da honra objetiva. A reprodução da imagem pelos meios de comunicação (televisivos, radiodifusão, revistas, jornais) devem guardar atenção com o respeito ao indivíduo.

Eventual violação destes bens pode gerar indenização por danos materiais e morais. A reparação do patrimônio material e/ou moral atingidos pela violação da intimidade, privacidade, honra e imagem das pessoas pode ser determinada cumulativamente, segundo Súmula 37 do STJ:

“São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”.

Os direitos da personalidade da pessoa jurídica também podem ser ofendidos, cabendo neste caso a tutela, e nos mesmos moldes, ou seja, dando origem ao dever de reparação, notadamente, dos danos morais a ela causados, de acordo com o entendimento já sumulado pelo STJ:

Súmula 227 do STJ: *“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.*

Privacidade e Sigilo Fiscal:

“O chamado sigilo fiscal nada mais é que um desdobramento do direito à intimidade e à vida privada. Aqui se cuida de pessoa jurídica que exerce atividade tributável. Contribuinte, portanto. Os documentos foram apreendidos no interior da sede da empresa e não no domicílio do seu responsável legal.

A atividade da pessoa jurídica está prevista como crime contra a ordem econômica. Legítima, assim, a atuação do Fisco, com respaldo na legislação pertinente. Legítima, também, a atuação do Ministério Público instando a autoridade policial à instauração do inquérito policial, com vista a apurar a ocorrência de um fato típico (...)"¹²¹

Privacidade e gravação clandestina.

"Paciente denunciado por falsidade ideológica, consubstanciada em exigir quantia em dinheiro para inserir falsa informação de excesso de contingente em certificado de dispensa de incorporação. Gravação clandestina realizada pelo alistando, a pedido de emissora de televisão, que levou as imagens ao ar em todo o território nacional por meio de conhecido programa jornalístico. (...) A questão posta não é de inviolabilidade das comunicações e sim da proteção da privacidade e da própria honra, que não constitui direito absoluto, devendo ceder em prol do interesse público."¹²²

Privacidade e sigilo bancário.

"O sigilo bancário, espécie de direito à privacidade protegido pela Constituição de 1988, não é absoluto, pois deve ceder diante dos interesses público, social e da Justiça. Assim, deve ceder também na forma e com observância de procedimento legal e com respeito ao princípio da razoabilidade"¹²³.

Direito à imagem e publicação não consentida:

"Dano moral: fotografia: publicação não consentida: indenização: cumulação com o dano material: possibilidade. Constituição Federal, art. 5º, X. Para a reparação do dano moral não se exige a ocorrência de ofensa à reputação do indivíduo. O que acontece é que, de regra, a publicação

121. STF, HC 87.654, voto da Min. Ellen Gracie, J em 7-3-06, DJ de 20-4-06.

122. STF, HC 87.341, Rel. Min. Eros Grau, J em 7-2-06, DJ de 3-3-06

123. STF, AI 655.298-AgR, Rel. Min. Eros Grau, J em 4-9-07, DJ de 28-9-07

da fotografia de alguém, com intuito comercial ou não, causa desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X."¹²⁴

Intimidade e Exame de DNA:

*"Coleta de material biológico da placenta, com propósito de se fazer exame de DNA, para averiguação de paternidade do nascituro, embora a oposição da extraditanda. (...) Bens jurídicos constitucionais como 'moralidade administrativa', 'persecução penal pública' e 'segurança pública' que se acrescem, — como bens da comunidade, na expressão de Canotilho, — ao direito fundamental à honra (CRFB/88, art. 5º, X), bem assim direito à honra e à imagem de policiais federais acusados de estupro da extraditanda, nas dependências da Polícia Federal, e direito à imagem da própria instituição, em confronto com o alegado direito da reclamante à intimidade e a preservar a identidade do pai de seu filho."*¹²⁵

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Este dispositivo consagra mais um desdobramento da vida privada, a inviolabilidade da "casa" é consagrada pela Constituição. Em regra geral, as pessoas só podem entrar nas casas alheias mediante permissão. Com consentimento válido, não há limite de hora para que haja penetração na casa das pessoas.

Entretanto, como não há inviolabilidade absoluta, esta fórmula cede espaço em algumas hipóteses. Nas situações de urgência, como flagrante delito, socorro ou desastre, é possível entrar na casa de alguém sem consentimento do morador, a qualquer hora do dia ou da noite, tendo em vista que a vida das pessoas está em risco.

124. STF, RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, J em 4/6/02, DJ de 28/6/02

125. STF, Rcl 2.040-QO, Rel. Min. Néri da Silveira, J em 21-2-02, DJ de 27-6-03

Fora destas situações urgentes, somente será possível adentrar a casa de alguém sem o consentimento do morador mediante ordem judicial, e com a limitação do horário. Segundo a Constituição, a determinação judicial só pode ser cumprida durante o dia, que segundo a doutrina mais moderna significa enquanto houver luz natural.

É possível se perceber que a inviolabilidade domiciliar está protegida pelo princípio da reserva de jurisdição, ou seja, como já visto, salvo nas hipóteses excepcionais (que se exigissem a ordem judicial seria cometer a maior das injustiças), somente o juiz poderá determinar a restrição desse direito fundamental.

Importante ressaltar que o significado da palavra “casa” sofreu muitas mutações ao longo do tempo. A atual jurisprudência do STF (abaixo transcrita), influenciada pelos novos fatos sociais, considera “casa”, para efeito da proteção do dispositivo em comento, os locais de trabalho onde as pessoas exercem profissão ou atividade privada (escritórios de advocacia, consultórios médicos etc.)

Não é possível, entretanto, segundo Grandinetti¹²⁶, aproveitar-se a proteção ao domicílio para os veículos de transporte público ou particular. Em consequência, a proteção a quem transita em um automóvel deve ser a mesma de quem transita na rua a pé, estando regulada pelo art. 244 do CPP, que disciplina a busca pessoal. Com isso, é lícita a busca em automóveis quando houver fundada suspeita de seu uso no transporte de armas e de objetos que constituam corpo de delito, ou nos quais esteja sendo praticada alguma infração penal em estado de flagrância.

Ampliação do conceito de casa I:

“Garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (CRFB/88, art. 5º, XI). Consultório profissional de cirurgia-dentista. Espaço privado sujeito à proteção constitucional (CP, ART. 150, § 4º, III). Necessidade de mandado judicial para efeito de ingresso dos agentes públicos. Jurisprudência. Doutrina. (...). Impõe-se destacar, por necessário, que o conceito de ‘casa’, para os fins da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5º, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo, pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar,

126. DE CARVALHO, L.G. Grandinetti, Processo Penal e Constituição. 4ª ed. Editora Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2006, p. 86.

(a) qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado onde alguém exerce profissão ou atividade. Esse amplo sentido conceitual da noção jurídica de 'casa' — que abrange e se estende aos consultórios profissionais dos cirurgiões-dentistas (...) — revela-se plenamente consentâneo com a exigência constitucional de proteção à esfera de liberdade individual e de privacidade pessoal."¹²⁷

Ampliação do conceito de casa II:

"Para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da Constituição da República, o conceito normativo de 'casa' revela-se abrangente e, por estender-se a qualquer aposento de habitação coletiva, desde que ocupado (CP, art. 150, § 4º, II), compreende, observada essa específica limitação espacial, os quartos de hotel. Doutrina. Precedentes. Sem que ocorra qualquer das situações excepcionais taxativamente previstas no texto constitucional (art. 5º, XI), nenhum agente público poderá, contra a vontade de quem de direito (invito domino), ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em aposento ocupado de habitação coletiva, sob pena de a prova resultante dessa diligência de busca e apreensão reputar-se inadmissível, porque impregnada de ilicitude originária. Doutrina. Precedentes (STF)."¹²⁸ (grifamos)

Ampliação do conceito de casa III:

"Para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da Constituição da República, o conceito normativo de 'casa' revela-se abrangente e, por estender-se a qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade (CP, art. 150, § 4º, III), compreende, observada essa específica limitação espacial (área interna não acessível ao público), os escritórios profissionais, inclusive os de contabilidade, 'embora sem conexão com a casa de moradia propriamente dita' (Nelson Hungria). Doutrina. Precedentes. Sem que ocorra qualquer das situações

127. STF, RE 251.445, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 03/08/00

128. STF, RHC 90.376, Rel. Min. Celso de Mello, J em 3-4-07, DJ de 18-5-07

excepcionais taxativamente previstas no texto constitucional (art. 5º, XI), nenhum agente público, ainda que vinculado à administração tributária do Estado, poderá, contra a vontade de quem de direito (invito domino), ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em espaço privado não aberto ao público, onde alguém exerce sua atividade profissional, sob pena de a prova resultante da diligência de busca e apreensão assim executada reputar-se inadmissível, porque impregnada de ilicitude material. Doutrina. Precedentes específicos, em tema de fiscalização tributária, a propósito de escritórios de contabilidade (STF). O atributo da auto-executoriedade dos atos administrativos, que traduz expressão concretizadora do privilégio du préalable, não prevalece sobre a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, ainda que se cuide de atividade exercida pelo Poder Público em sede de fiscalização tributária. Doutrina. Precedentes."¹²⁹

Flagrante delito e crime permanente:

*"Cuidando-se de crime de natureza permanente, a prisão do traficante, em sua residência, durante o período noturno, não constitui prova ilícita."*¹³⁰

Princípio da reserva de jurisdição:

"A cláusula constitucional da reserva de jurisdição — que incide sobre determinadas matérias, como a busca domiciliar (CRFB/88, art. 5º, XI), a interceptação telefônica (CRFB/88, art. 5º, XII) e a decretação da prisão de qualquer pessoa, ressalvada a hipótese de flagrância (CRFB/88, art. 5º, LXI) — traduz a noção de que, nesses temas específicos, assiste ao Poder Judiciário, não apenas o direito de proferir a última palavra, mas, sobretudo, a prerrogativa de dizer, desde logo, a primeira palavra, excluindo-se, desse modo, por força e autoridade do que dispõe a própria Constituição, a possibilidade do exercício de iguais atribuições, por parte de

129. STF, HC 82.788, Rel. Min. Celso de Mello, J em 12-4-05, DJ de 2-6-06

130. STF, HC 84.772, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 19-10-04, DJ de 12-11-04. No mesmo sentido: HC 70.909, Rel. Min. Paulo Brossard, J em 11-10-94, DJ de 25-11-94.

quaisquer outros órgãos ou autoridades do Estado (...) ¹³¹ .

CPI e busca domiciliar:

Ofensa ao princípio da reserva de jurisdição:

“Mandado de segurança contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o avanço e a impunidade do narcotráfico. Apreensão de documentos e equipamentos sem fundamentação em locais invioláveis. Parecer da Procuradoria-Geral da República pela concessão da ordem. O fato da autorização judicial para a perícia dos equipamentos, oriunda de autoridade judiciária de primeiro grau, após a apreensão, sem mandado judicial, não legitima os resultados da perícia que se tenha realizado ou em curso. Mandado de segurança que se defere para determinar a devolução dos bens e documentos apreendidos, declarando-se ineficaz eventual prova decorrente dessa apreensão com infração do art. 5º, XI, da Lei Maior.” ¹³²

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

Este dispositivo divide a proteção aos meios de comunicação dividindo-os em algumas modalidades:

- por correspondência
- por telegramas
- por dados: cadastrais, fiscais, bancários, telefônicos
- por telefone

Em que pese a má redação do dispositivo, que peca pela imprecisão na disposição de tão importante matéria, podemos inferir, em nome do desiderato maior da proteção à privacidade, que em regra geral todos esses meios de comunicação são invioláveis, ou seja, apenas excepcionalmente podem sofrer restrições, que devem vir precedidas de ordem judicial ou

131. STF, MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello, J em 16-9-99, DJ de 12-5-00

132. STF, MS 23.642, Rel. Min. Néri da Silveira, J em 29-11-00, DJ de 9-3-01

autorização legal.

Ressalte-se que a proteção do dispositivo dirige-se à comunicação da correspondência (seja a carta, o telegrama ou dados) e, não à correspondência já aberta pelo seu destinatário (essa tem proteção do inciso X, ora analisado). Na mesma disciplina deve-se compreender a emissão de e-mail. Sua interceptação é ilícita, tanto pela proteção da correspondência postal, quanto pela proteção da comunicação de dados, mas, uma vez transmitido, torna-se dados estanques, semelhantes à carta ou ao telegrama já recebidos, enquadrando-se na proteção do inciso X.¹³³

Quanto à parte final do texto, o dispositivo contém uma exceção que se aplica apenas à comunicação telefônica. Assim, para que se tenha acesso ao conteúdo de uma comunicação telefônica, é necessário o cumprimento simultâneo de três requisitos:

- ordem judicial (em nome do Princípio da Reserva de Jurisdição);
- atender à finalidade de apuração de crimes, seja na fase do inquérito penal ou no curso da ação penal proposta em juízo;
- cumprir os requisitos da Lei 9296/96¹³⁴.

Pode-se perceber que a interceptação das comunicações telefônicas (com acesso ao teor da conversa) só pode ser determinada por ordem judicial, de acordo com o princípio da reserva de jurisdição. Mas, como o texto não faz menção específica à imperiosa necessidade de ordem judicial para as demais violações (correspondências), podemos concluir que em havendo uma previsão legal, ou a ordem judicial, será possível a realização da violação aos demais meios de comunicações, desde que se indique a necessidade de tal restrição, como podemos perceber da jurisprudência a seguir exposta.

CPI e quebra de sigilo de dados.

“A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que

133. DE CARVALHO, L.G. Grandinetti, Ob. cit. p. 75.

134. “Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

- I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;
- II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;
- III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção”.

*esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária.*¹³⁵”

Quebra de sigilo de dados.

Não incidência do princípio da reserva de jurisdição I.

*“O princípio constitucional da reserva de jurisdição — que incide sobre as hipóteses de busca domiciliar (CRFB/88, art. 5º, XI), de interceptação telefônica (CRFB/88, art. 5º, XII) e de decretação da prisão, ressalvada a situação de flagrância penal (CRFB/88, art. 5º, LXI) — não se estende ao tema da quebra de sigilo, pois, em tal matéria, e por efeito de expressa autorização dada pela própria Constituição da República (CRFB/88, art. 58, § 3º), assiste competência à Comissão Parlamentar de Inquérito, para decretar, sempre em ato necessariamente motivado, a excepcional ruptura dessa esfera de privacidade das pessoas.*¹³⁶”

Quebra de sigilo de dados.

Não incidência do princípio da reserva de jurisdição II

“Proteção constitucional ao sigilo das comunicações de dados — art. 5º, XII, da CRFB/88: ausência de violação, no caso. Impertinência à hipótese da invocação da AP 307 (Pleno, 13-12-94, Galvão, DJ 13-10-95), em que a tese da inviolabilidade absoluta de dados de computador não pode ser tomada como consagrada pelo Colegiado, dada a interferência, naquele caso, de outra razão suficiente para a exclusão da prova questionada — o ter sido o microcomputador apreendido sem ordem judicial e a consequente ofensa da garantia da inviolabilidade do domicílio da empresa — este segundo fundamento bastante, sim, aceito por votação unânime, à luz do art. 5º, XI, da Lei Fundamental. Na espécie, ao contrário, não se questiona que a apreensão dos computadores da empresa

135. STF, MS 23.639, Rel. Min. Celso de Mello, J em 16-11-00, DJ de 16-2-01

136. STF, MS 23.652, Rel. Min. Celso de Mello, J em 22-11-00, DJ de 16-2-01. No mesmo sentido: MS 23.639, Rel. Min. Celso de Mello, J em 16-11-00, DJ de 16-2-01.

do recorrente se fez regularmente, na conformidade e em cumprimento de mandado judicial. Não há violação do art. 5º, XII, da Constituição que, conforme se acentuou na sentença, não se aplica ao caso, pois não houve 'quebra de sigilo das comunicações de dados (interceptação das comunicações), mas sim apreensão de base física na qual se encontravam os dados, mediante prévia e fundamentada decisão judicial'.¹³⁷

Quebra de sigilo de dados e legitimidade do Ministério Público:

"(...) O poder de investigação do Estado é dirigido a coibir atividades afrontosas à ordem jurídica e a garantia do sigilo bancário não se estende às atividades ilícitas. A ordem jurídica confere explicitamente poderes amplos de investigação ao Ministério Público — art. 129, incisos VI, VIII, da Constituição Federal, e art. 8º, incisos II e IV, e § 2º, da Lei Complementar n. 75/1993. Não cabe ao Banco do Brasil negar, ao Ministério Público, informações sobre nomes de beneficiários de empréstimos concedidos pela instituição, com recursos subsidiados pelo erário federal, sob invocação do sigilo bancário, em se tratando de requisição de informações e documentos para instruir procedimento administrativo instaurado em defesa do patrimônio público."¹³⁸

Violação de correspondência em penitenciárias.

"A administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, pode, sempre excepcionalmente, e desde que respeitada a norma inscrita no art. 41, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84, proceder à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas."¹³⁹

137. (RE 418.416, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 10-5-06, DJ de 19-12-06)

138. STF, MS 21.729, Rel. p/ o ac. Min. Néri da Silveira, J em 5-10-95, DJ de 19-10-01

139. STF, HC 70.814, Rel. Min. Celso de Mello, J em 1º-3-94, DJ de 24-6-94

9.21 LIBERDADE PROFISSIONAL

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

Este dispositivo é um exemplo claro de norma de eficácia contida, ou seja a Constituição assegura a plena liberdade profissional, exceto quando a lei determinar a satisfação de certos requisitos, como é o caso da comprovação de três anos de atividade jurídica para quem pretender ingressar na carreira da magistratura ou do Ministério Público (arts. 93, I e 129, § 3º, da CRFB/88, respectivamente), ou ainda, da prova exigida pela Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício da advocacia. Ressalte-se que a restrição deve ser feita por lei (reserva de lei) e tem que ser proporcional à natureza da função que será exercida.

Requisitos concurso público. Compatível com o exercício profissional.

"A exigência de especificidade, no âmbito da qualificação, para a feitura de concurso público não contraria o disposto no inciso XIII do artigo 5º da Constituição Federal, desde que prevista em lei e consentânea com os diplomas regedores do exercício profissional."¹⁴⁰

Exame da OAB e constitucionalidade - 1

O Plenário desproveu recurso extraordinário em que discutida a constitucionalidade dos artigos 8º, IV e § 1º; e 44, II, ambos da Lei 8.906/94, que versam sobre o exame da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB ["Art. 8º Para inscrição como advogado é necessário: ... IV - aprovação em Exame de Ordem; ... § 1º O Exame da Ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. ... Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade: ... II - promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil"]. Na espécie, o recorrente alegava que o bacharel em Direito deveria ser considerado apto a exercer a advocacia

¹⁴⁰ STF, MS 21.733, Rel. Min. Marco Aurélio, J em 9-2-94, DJ de 8-4-94

até prova em contrário, bem como que a referida entidade teria condições de avaliar a capacidade do profissional, considerada a citada lei, que versa as sanções disciplinares para o advogado. Sustentava também violação ao princípio da igualdade, visto que a exigência de exame para o ingresso no órgão de classe ocorreria somente para esta profissão e que nem mesmo médicos seriam submetidos à seleção equivalente, embora lidassem com bem valioso. Alegava que a avaliação não poderia se sobrepor às das próprias universidades e que o bacharel, examinado e avaliado por instituição credenciada pelo Poder Público — o qual a OAB não integraria — teria direito ao livre exercício profissional. Aludia à necessidade de lei para a criação do exame, previsto apenas em regulamento, e que a entidade de classe, interessada em restringir a concorrência, não seria isenta, impessoal e imparcial ao avaliar os candidatos. Argumentava, ainda, que o exame teria sido derogado, tacitamente, pela Lei 8.906/94 e que não seria compatível com a Lei 8.884/94. RE 603583/RS, rel. Min. Marco Aurélio, 26.10.2011 (603583)

9.22 LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

A liberdade de comunicação deve ser interpretada em coerência com a proteção constitucional à privacidade, e os excessos devem ser coibidos, sob pena de responsabilização do agente divulgador por todos os prejuízos causados (danos materiais e morais).

O sigilo da fonte visa proteger a pessoa do informante ou a fonte das informações dos jornalistas, em nome da própria liberdade de imprensa e não se confunde com o anonimato, vedado pelo inciso IV, pois quem divulga as informações recebidas precisará se apresentar, assumindo a responsabilidade pelos exageros cometidos.

9.23 LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar,

permanecer ou dele sair com seus bens;

Este inciso protege a liberdade de ir, vir e permanecer, englobando: o direito de entrar e sair do território nacional, de permanecer e de se deslocar nesse território. Ressalte-se que o dispositivo faz referência à liberdade em tempo de paz.

Essa regra cede espaço em caso de legalidade extraordinária, como na hipótese de estado sítio (art. 139, I), quando a proteção da vida pode levar o Estado a determinar que as pessoas permaneçam em lugares determinados.

Ressalte-se que o genuíno remédio constitucional para salvaguarda desse direito é o habeas corpus (art. 5º, LXVIII), que será estudado em capítulo específico.

9.24 DIREITO DE REUNIÃO

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.

A liberdade de reunião é um direito coletivo, se analisado em seu exercício conjunto, ou ainda um direito individual de expressão coletiva. Para a manifestação desse importante direito num país democrático, a Constituição apenas exige que a autoridade competente seja comunicada previamente sobre o dia, horário e local da reunião, a fim de que possa tomar providências necessárias à sua realização, que a reunião não frustre outra convocada para o mesmo local, e, ainda, que os manifestantes não estejam armados.

São elementos da reunião¹⁴¹:

- pluralidade de participantes, pois a reunião é considerada manifestação coletiva;
- tempo, devido ao caráter episódico e temporário da reunião;
- finalidade, que demonstra o propósito da manifestação coletiva;

141. MORAES, Alexandre. Direitos Humanos Fundamentais. 6 ed. Atlas, São Paulo, 2005, p. 158.

- lugar, locais públicos, em área certa e delimitada.

Restrição ao direito de reunião.

“Decreto 20.098/99, do Distrito Federal. Liberdade de reunião e de manifestação pública. Limitações. Ofensa ao art. 5º, XVI, da Constituição Federal. A liberdade de reunião e de associação para fins lícitos constitui uma das mais importantes conquistas da civilização, enquanto fundamento das modernas democracias políticas. A restrição ao direito de reunião estabelecida pelo Decreto distrital 20.098/99, a toda evidência, mostra-se inadequada, desnecessária e desproporcional quando confrontada com a vontade da Constituição (Wille zur Verfassung).¹⁴²”

Liberdades fundamentais e “Marcha da Maconha” - 1

Por entender que o exercício dos direitos fundamentais de reunião e de livre manifestação do pensamento devem ser garantidos a todas as pessoas, o Plenário julgou procedente pedido formulado em ação de descumprimento de preceito fundamental para dar, ao art. 287 do CP, com efeito vinculante, interpretação conforme a Constituição, de forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas, ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Preliminarmente, rejeitou-se pleito suscitado pela Presidência da República e pela Advocacia-Geral da União no sentido do não conhecimento da ação, visto que, conforme sustentado, a via eleita não seria adequada para se deliberar sobre a interpretação conforme. Alegava-se, no ponto, que a linha tênue entre o tipo penal e a liberdade de expressão só seria verificável no caso concreto. Aduziu-se que se trataria de arguição autônoma, cujos pressupostos de admissibilidade estariam presentes. Salientou-se a observância, na espécie, do princípio da subsidiariedade. Ocorre que a regra penal em comento teria caráter pré-constitucional e, portanto, não poderia constituir objeto de controle abstrato mediante ações diretas, de acordo com a jurisprudência da Corte. Assim, não haveria outro modo eficaz de se sanar a lesividade arguida, senão pelo meio adotado. Enfatizou-se a multiplicidade de interpretações às quais a norma penal em questão estaria submetida, consubstanciadas em decisões

142. STF, ADI 1.969, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J em 28-6-07, DJ de 31-8-07

a permitir e a não permitir a denominada “Marcha da Maconha” por todo o país. Ressaltou-se existirem graves consequências resultantes da censura à liberdade de expressão e de reunião, realizada por agentes estatais em cumprimento de ordens emanadas do Judiciário. Frisou-se que, diante do quadro de incertezas hermenêuticas em torno da aludida norma, a revelar efetiva e relevante controvérsia constitucional, os cidadãos estariam preocupados em externar, de modo livre e responsável, as convicções que desejariam transmitir à coletividade por meio da pacífica utilização dos espaços públicos. ADPF 187/DF, rel. Min. Celso de Mello, 15.6.2011.

9.25 DIREITO DE ASSOCIAÇÃO

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização;

XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

A liberdade de associação é outro direito coletivo, ou individual de expressão coletiva, que deve ser exercido de maneira plena, desde que tenha fins lícitos, vedada a organização de caráter paramilitar, que seriam aquelas que se apresentam com características típicas de instituições oficiais, fardadas ou não, com organização hierárquica própria e ideologia contrária à ordem do Estado.

Importante assinalar que a liberdade de associação tem uma dimensão positiva, pois assegura a qualquer pessoa (natural ou jurídica) o direito de associar-se e de formar associações e também possui uma dimensão

negativa, pois garante, a qualquer pessoa, o direito de não se associar, nem de ser compelida a filiar-se ou a desfiliar-se de determinada entidade.

Em nome da preservação dessa importante liberdade, o constituinte determinou que tanto para a suspensão das atividades da associação, quanto para a sua dissolução será necessária ordem judicial, em nome do princípio da reserva de jurisdição. No caso da dissolução, ainda se exige que a decisão tenha transitado em julgado.

A Constituição ainda autoriza que uma associação represente os interesses de seus associados, facilitando a vida das pessoas. Chama-se representação processual o poder que uma entidade tem de ingressar em juízo em nome de seus filiados. Esta representação pode ser exercida também extrajudicialmente e a jurisprudência admite que a autorização possa ser extraída dos estatutos da entidade, ou tomada em assembleia geral.

Liberdade de associação e criação de sindicatos.

“Não se há de confundir a liberdade de associação, prevista de forma geral no inciso XVII do rol das garantias constitucionais, com a criação, em si, de sindicato. O critério da especificidade direciona à observação do disposto no inciso II do artigo 8º da Constituição Federal, no que agasalhada a unicidade sindical de forma mitigada, ou seja, considerada a área de atuação, nunca inferior à de um município.”¹⁴³

Suspensão e Dissolução das Associações e princípio da reserva de jurisdição.

“Cabe enfatizar, neste ponto, que as normas inscritas no art. 5º, incisos XVII a XXI da atual Constituição Federal protegem as associações, inclusive as sociedades, da atuação eventualmente arbitrária do legislador e do administrador, eis que somente o Poder Judiciário, por meio de processo regular, poderá decretar a suspensão ou a dissolução compulsórias das associações. Mesmo a atuação judicial encontra uma limitação constitucional: apenas as associações que persigam fins ilícitos poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou suspensas. Atos emanados do Executivo ou do Legislativo, que provoquem a

143. STF, RE 207.858, Rel. Min. Marco Aurélio, J em 27-10-98, DJ de 14-5-99

compulsória suspensão ou dissolução de associações, mesmo as que possuam fins ilícitos, serão inconstitucionais¹⁴⁴.”

Representação das associações.

“A representação prevista no inciso XXI do artigo 5º da Constituição Federal surge regular quando autorizada a entidade associativa a agir judicial ou extrajudicialmente mediante deliberação em assembleia. Descabe exigir instrumentos de mandatos subscritos pelos associados.¹⁴⁵”

Representação e Substituição processual.

“O inciso LXX do artigo 5º da Constituição Federal encerra o instituto da substituição processual, distanciando-se da hipótese do inciso XXI, no que surge no âmbito da representação. As entidades e pessoas jurídicas nele mencionadas atuam, em nome próprio, na defesa de interesses que se irradiam, encontrando-se no patrimônio de pessoas diversas. Descabe a exigência de demonstração do credenciamento¹⁴⁶.”

9.26 DIREITO DE PROPRIEDADE

XXII - é garantido o direito de propriedade;

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

O direito à propriedade configura um dos mais antigos direitos fundamentais na história das civilizações, mas sofreu muitas transformações até chegar a proteção dos dias de hoje. Não há propriedade hoje vista sob o ângulo meramente privado, com poderes ilimitados de uso e fruição do bem, tendo em vista que o direito foi remodelado em razão da função social da propriedade, que passa a integrar o seu próprio conceito.

A título de exemplo, o art. 186, da CRFB/88 afirma que a função social

144. STF, ADI 3.045, voto do Min. Celso de Mello, J em 10-8-05, DJ de 1º-6-07

145. STF, RE 192.305, Rel. Min. Marco Aurélio, J em 15-12-98, DJ de 21-5-99. No mesmo sentido: MS 23.879, Rel. Min. Mauricio Corrêa, julgamento em 3-10-01, DJ de 16-11-01.

146. STF, RMS 21.514, Rel. Min. Marco Aurélio, J em 27-4-93, DJ de 18-6-93

da propriedade rural é cumprida quando atende, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

"I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores".

A função social da propriedade.

"O direito de propriedade não se reveste de caráter absoluto, eis que, sobre ele, pesa grave hipoteca social, a significar que, descumprida a função social que lhe é inerente (CRFB/88, art. 5º, XXIII), legitimar-se-á a intervenção estatal na esfera dominial privada, observados, contudo, para esse efeito, os limites, as formas e os procedimentos fixados na própria Constituição da República. O acesso à terra, a solução dos conflitos sociais, o aproveitamento racional e adequado do imóvel rural, a utilização apropriada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente constituem elementos de realização da função social da propriedade.¹⁴⁷"

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

A desapropriação é uma forma originária de aquisição de propriedade, por meio da qual o Poder Público transfere compulsoriamente um bem do patrimônio do particular para o patrimônio público. É forma de aquisição da propriedade. É também uma espécie de limitação administrativa ao direito de propriedade, tendo em vista a realização de obras e serviços públicos, em nome do interesse da coletividade, mas sempre realizada mediante o pagamento de indenização.

Neste inciso, a desapropriação tem que observar o cumprimento

147. STF, ADI 2.213-MC, Rel. Min. Celso de Mello, J em 4-4-02, DJ de 23-4-04

simultâneo das seguintes exigências:

- indenização tem que ser justa: equivale a dizer que o valor do bem deve ser aferido por peritos, de modo a atentar para o seu valor de "mercado do bem";
- a indenização tem que ser prévia, ou seja, anterior à transferência do bem pelo poder desapropriante;
- a indenização tem que ser paga em dinheiro.

Essa desapropriação do inciso XXIV não está relacionada diretamente ao cumprimento ou não da função social da propriedade. Justifica-se pelo interesse público em jogo, diferente da situação dos art. 182, § 4º, III e art. 184, que são exemplos de desapropriação-sanção, estreitamente relacionadas ao não cumprimento da função social. O primeiro dispositivo prevê o pagamento mediante títulos da dívida pública e, no segundo caso o pagamento será realizado por meio de títulos da dívida agrária, garantida, em ambos os casos, a ampla defesa e o contraditório para a imposição da punição.

Devido processo legal e desapropriação-sanção.

“O processo de reforma agrária, em uma sociedade estruturada em bases democráticas, não pode ser implementado pelo uso arbitrário da força e pela prática de atos ilícitos de violação possessória, ainda que se cuide de imóveis alegadamente improdutivos, notadamente porque a Constituição da República — ao amparar o proprietário com a cláusula de garantia do direito de propriedade (CRFB/88, art. 5º, XXII) — proclama que ‘ninguém será privado (...) de seus bens, sem o devido processo legal’ (art. 5º, LIV)”.¹⁴⁸

Desapropriação e propriedade produtiva.

“Caracterizado que a propriedade é produtiva, não se opera a desapropriação-sanção — por interesse social para os fins de reforma agrária —, em virtude de imperativo constitucional (CRFB/88, art. 185, II) que excepciona, para a reforma agrária, a atuação estatal, passando o processo de indenização, em princípio, a submeter-se às regras constantes do inciso XXIV,

148. STF, ADI 2.213-MC, Rel. Min. Celso de Mello, J em 4-4-02, DJ de 23-4-04

do artigo 5º, da Constituição Federal, 'mediante justa e prévia indenização'".¹⁴⁹

XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

A requisição administrativa presente nesse inciso é outra forma de intervenção do Estado na propriedade particular, mas de uma maneira mais branda do que na desapropriação, pois não há transferência do bem, apenas a sua utilização.

A situação de iminência de perigo (desabamentos, enchentes, calamidades em geral) justifica a utilização do bem pelo Poder Público sem autorização do proprietário. Após a utilização temporária do bem, verificar-se-á a eventual ocorrência de dano ou prejuízo sofrido pela coisa utilizada. E apenas nesse caso será paga uma indenização. Ressalte-se que cabe a requisição administrativa de bem móvel ou imóvel e de serviços.

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

Esta regra protege o pequeno proprietário de terras rurais, que dela tira muitas vezes seu sustento e de sua família. O Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) define o que se considera "pequena propriedade rural". É uma proteção a mais trazida pela Constituição de 1988 ao produtor rural, com o fim de evitar o êxodo e a situação de miséria e de dificuldade que normalmente ocorre quando estes emigram para os grandes centros.

Imperioso reforçar que nem toda pequena propriedade rural é impenhorável, somente a que preencher, simultaneamente, aos requisitos constitucionais: a) ser trabalhada pela família (pelo menos um membro um membro) e b) a dívida deve ter sido contraída para investimento e desenvolvimento da atividade produtiva.

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

149. STF, MS 22.193, Rel. p/ o ac. Min. Maurício Corrêa, J em 21-3-96, DJ de 29-11-96

A Constituição garante neste dispositivo a proteção a uma das manifestações da propriedade, a intelectual. A tutela pode ser dividida da seguinte maneira: a) os autores das obras (artísticas, literárias, científicas e de comunicação) possuem o direito exclusivo de utilizar, publicar e reproduzir suas obras por tempo indeterminado, possuindo os direitos morais e patrimoniais sobre elas e b) esse direito é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.

De acordo com a lei 9.610/98, os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 (setenta) anos contados do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao do seu falecimento. Findo este prazo, as obras caem no domínio público, e isso quer dizer que qualquer um pode explorá-las economicamente, respeitados os direitos morais do autor.

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive em atividades desportivas;

o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

Está assegurado neste dispositivo: i) o direito de participação dos autores em obras coletivas, chamada pela doutrina de direito de arena; ii) a reprodução da imagem autoral e a proteção das vozes humanas, para proteger os apresentadores, locutores, radialistas e aqueles que trabalham em atividades desportivas; e iii) o direito de fiscalização de seus trabalhos.

Temos a consagração da imagem autoral, que deve ser interpretada em conjunto com o inciso X; e da mesma maneira, se houver abusos, o direito à ampla reparação pelos danos materiais ou morais está garantido.

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Esse dispositivo segundo José Afonso da Silva¹⁵⁰ protege a propriedade de bens incorpóreos, privilégio de invenção industrial que assegura ao inventor (criador de objeto capaz de propiciar novos resultados industriais) o direito de obter patente de propriedade do invento e o direito exclusivo de utilização; a proteção às suas criações industriais, à propriedade das marcas e seu uso exclusivo, mediante seu registro; a propriedade de marcas de serviços, a exclusividade dos nomes de empresas e de outros signos distintivos. A lei 9.279/96 afirma, entretanto, que o privilégio do inventor é temporário¹⁵¹.

XXX – é garantido o direito de herança;

XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus;

O direito de herança reafirma o direito à propriedade, já estando por ele protegida. Entretanto, com a sua constitucionalização, o direito ganha reforços e impede que a lei civil deixe de reconhecer a sucessão hereditária, sob pena de ser declarada inconstitucional.

A regra sobre a sucessão é a de que a lei brasileira irá se aplicar aos bens situados no território nacional. Entretanto, esta norma abre exceção para o caso de a lei estrangeira ser melhor para o nacional do que a lei brasileira, na hipótese de sucessão de bens (o princípio da lei mais benéfica). Em havendo conflitos entre legislações relativas a direito de herança, aplica-se aquela que mais proteger o herdeiro brasileiro, mesmo que seja estrangeira. Atente-se para o fato de que a lei estrangeira somente se aplicará sobre os bens do falecido situados no Brasil. Não há como impor a aplicação da lei brasileira sobre os bens do falecido situados em território estrangeiro. Para a aplicação deste direito é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos:

- a) que os bens se achem situados no território brasileiro, sejam móveis ou imóveis;

150. AFONSO DA SILVA, José. Comentário Contextual à Constituição. Malheiros, São Paulo, 2005, p. 125.

151. Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

- b) que o de cujus seja estrangeiro, não importando o seu domicílio;
- c) que o falecido tenha cônjuge ou filho brasileiro.

Lei da abertura da sucessão.

“Rege-se, a capacidade de suceder, pela lei da época da abertura da sucessão, não comportando, assim, eficácia retroativa, o disposto no art. 227, § 6º, da Constituição.”¹⁵²

9.27 DIREITOS DO CONSUMIDOR

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

Os direitos dos consumidores nascem no constitucionalismo brasileiro em 1988, sob a influência da Constituição Portuguesa (1976) e espanhola (1978). Na atual sociedade do consumo, com a visão preponderante sobre o lucro e a riqueza, o Estado tem o dever de coibir toda forma de abuso eventualmente praticado pelo mercado, protegendo quem normalmente é a parte mais frágil das relações de consumo, o consumidor. O art. 170, V, incluiu o direito dos consumidores como princípio informador da ordem econômica e a Lei nº 8.078/90 veio implementar a tutela infraconstitucional à proteção, que ainda está reforçada na Lei Antitruste (Lei nº 8.884/94).

Participação do Estado na economia.

“Em face da atual Constituição, para conciliar o fundamento da livre iniciativa e do princípio da livre concorrência com os da defesa do consumidor e da redução das desigualdades sociais, em conformidade com os ditames da justiça social, pode o Estado, por via legislativa, regular a política de preços de bens e de serviços, abusivo que é o poder econômico que visa ao aumento arbitrário dos lucros.”¹⁵³

152. STF, RE 162.350, Rel. Min. Octavio Gallotti, J em 22-8-95, DJ de 22-9-95

153. STF, ADI 319-QO, Rel. Min. Moreira Alves, J em 3-3-93, DJ de 30-4-93

9.28 DIREITO À INFORMAÇÃO

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

A liberdade de informação é assegurada a todas as pessoas naturais, sejam brasileiros ou estrangeiros. A Constituição faz apenas a ressalva de resguardar o sigilo daquela informação considerada importante para a segurança da sociedade e do Estado e para acesso a esse tipo de dado não há remédio constitucional previsto no ordenamento jurídico. Este dispositivo contém direito garantido pelo Mandado de Segurança (se as informações forem públicas), Habeas Data (se as informações forem de natureza pessoal), ou simplesmente pelo direito de petição ou de obtenção de certidões, descrito no inciso seguinte.

Direito à Informação e TCU:

“Tribunal de Contas da União: direito de acesso a documentos de processo administrativo. CRFB/88, art. 5º, XXXIII, XXXIV, b, e LXXII; e art. 37. Processo de representação instaurado para apurar eventual desvio dos recursos arrecadados com a exploração provisória do Complexo Pousada Esmeralda, situado no arquipélago de Fernando de Noronha/PE: direito da empresa-impetrante, permissionária de uso, ter vista dos autos da representação mencionada, a fim de obter elementos que sirvam para a sua defesa em processos judiciais nos quais figura como parte. Não incidência, no caso, de qualquer limitação às garantias constitucionais (incisos X e XXXIII, respectivamente, do art. 5º da CRFB/88). Ressalva da conveniência de se determinar que a vista pretendida se restrinja ao local da repartição, ou, quando permitida a retirada dos autos, seja fixado prazo para tanto.”¹⁵⁴

154. STF, MS 25.382, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, J em 15-2-06, DJ de 31-3-06

9.29 DIREITO DE PETIÇÃO E DE OBTENÇÃO DE CERTIDÕES

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

- a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
- b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:

- c) o registro civil de nascimento;
- d) a certidão de óbito.

Direito de petição e Direito de obtenção de certidões são garantias constitucionais para o acesso à informação e pedido de providências administrativas, conhecidas também como remédios constitucionais administrativos, que ao lado dos remédios judiciais (HC, HD, MS, MI e AP) formam mecanismos de proteção na defesa dos direitos fundamentais. Dispensam a participação do advogado e a cobrança de taxas.

O direito de petição consiste no poder de um cidadão se dirigir à autoridade um pedido de providências ou de intervenção em prol de interesses que podem ser individuais, coletivos, próprios ou de terceiros, que estejam sendo violados por ato ilegal ou arbitrário. Veicula-se por meio de um simples requerimento, pedido ou representação escrita, sem que seja exigido pagamento de alguma taxa, ou participação de advogado. É um direito exercido extrajudicialmente e não se confunde com a petição dirigida ao Poder Judiciário, ou seja, com o direito de ação, pois esta exige o preenchimento de requisitos específicos presentes na legislação.

Esse direito vinha separado do direito de representação, que consistia no oferecimento de reclamações ou queixas formuladas perante as autoridades administrativas. Hoje, esses dois aspectos, o informativo e o denunciativo, foram reunidos no direito de petição.

Apesar de a Constituição não ter feito menção ao prazo de resposta da autoridade ou a sanção que lhe será imputada em caso de falta de pronunciamento, o mandado de segurança remanescerá como salvaguarda da liberdade de acesso à informação. A ausência de resposta pela autoridade

pública constitui irresponsabilidade e insurgência contra a Constituição da República.

O direito de obtenção de certidões em repartições públicas serve para defender direitos e para esclarecer situações pessoais. A certidão serve para atestar a existência de um fato verídico, e, se negada, em regra geral também enseja a impetração do mandado de segurança.

A Constituição ainda reforçou o direito de certidão, ao garantir que aos reconhecidamente pobres¹⁵⁵ serão gratuitos o registro civil de nascimento e a certidão de óbito, na forma da lei. A Lei nº 9.534/97, que deu nova redação ao art. 30 da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), tornou gratuitos para todos (com ou sem recursos financeiros) o registro civil de nascimento e o assento de óbito; mas os reconhecidamente pobres estão isentos também do pagamento das demais certidões de registro civil.

Recurso administrativo e depósito prévio I

“A garantia constitucional da ampla defesa afasta a exigência do depósito como pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo.”¹⁵⁶

Recurso administrativo e depósito prévio II.

“A exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos como condição de admissibilidade de recurso administrativo constitui obstáculo sério (e intransponível, para consideráveis parcelas da população) ao exercício do direito de petição (CRFB/88, art. 5º, XXXIV), além de caracterizar ofensa ao princípio do contraditório (CRFB/88, art. 5º, LV). A exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos pode converter-se, na prática, em determinadas situações, em supressão do direito de recorrer, constituindo-se, assim, em

155. De acordo com o art. 30, § 2º, da Lei de Registros Públicos, a comprovação do estado de pobreza será realizada por declaração do próprio interessado ou a rogo, tratando-se de analfabeto, neste caso, acompanhada da assinatura de duas testemunhas.

156. STF, RE 388.359, Rel. Min. Marco Aurélio, J em 28-3-07, DJ de 22-6-07. No mesmo sentido: AI 398.933-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, J em 2-4-07, DJ de 29-6-07; AI 408.914-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, J em 2-4-07, DJ de 29-6-07; RE 389.383, Rel. Min. Marco Aurélio, J em 28-3-07, DJ de 29-6-07; RE 390.513, Rel. Min. Marco Aurélio, J em 28-03-07, DJ de 29-06-07.

nítida violação ao princípio da proporcionalidade. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 32 da MP 1699-41 — posteriormente convertida na lei 10.522/2002 —, que deu nova redação ao art. 33, § 2º, do Decreto 70.235/72.¹⁵⁷”

Direito de Petição e pedido de ajuizamento de ADI.

“O direito de petição, presente em todas as Constituições brasileiras, qualifica-se como importante prerrogativa de caráter democrático. Trata-se de instrumento jurídico-constitucional posto à disposição de qualquer interessado — mesmo daqueles destituídos de personalidade jurídica —, com a explícita finalidade de viabilizar a defesa, perante as instituições estatais, de direitos ou valores revestidos tanto de natureza pessoal quanto de significação coletiva. Entidade sindical que pede ao Procurador-Geral da República o ajuizamento de ação direta perante o STF. Provocatio ad agendum. Pleito que traduz o exercício concreto do direito de petição. Legitimidade desse comportamento”.¹⁵⁸

9.30 PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E DO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA.

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

LXXVII - são gratuitas as ações de “habeas-corpus” e “habeas-data”, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da

157. STF, ADI 1.976, Rel. Min. Joaquim Barbosa, J em 28-3-07, DJ de 18-5-07

158. STF, ADI 1.247-MC, Rel. Min. Celso de Mello, J em 17-8-95, DJ de 8-9-95

cidadania;

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

O amplo acesso à Justiça constitui garantia fundamental que também pode se apresentar sob as denominações “princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional”, “princípio da tutela judicial”, “princípio do direito de ação” etc. O homem não pode ficar ao desamparo, submetido às arbitrariedades cometidas no exercício do poder. Assim, todas as pessoas podem pleitear tutela jurisdicional preventiva ou reparatória a lesão ou ameaça a direito. Todos têm direito de serem ouvidos pelos tribunais instituídos por lei, independentes e imparciais. O acesso à Justiça é a expressão máxima de reivindicação do cidadão pelos seus direitos, resolvendo seus conflitos com base em ordem jurídica fundada na democracia e na justiça social. Para tanto, não se pode exigir o esgotamento da instância administrativa para que se permita a invocação do Poder Judiciário.

A exigência de preenchimento das condições da ação e demais pressupostos processuais, bem como a observância dos prazos prescricionais e decadenciais para o exercício do direito de ação não afastam o amplo acesso à justiça, pois apesar de serem critérios limitadores, gozam de plausibilidade.

Ao garantir a assistência judiciária gratuita no inciso LXXIV aos que comprovarem insuficiência de recursos, a Constituição reforça o amplo acesso à justiça, permitindo que não apenas a elite brasileira tenha direito à prestação jurisdicional.

A razoável duração do processo (LXXVIII), inserida como núcleo constitucional por meio da EC 45/04, é importante garantia que veio a reforçar o próprio amplo acesso à justiça, lembrando-se que justiça lenta é injustiça manifesta.

Com a vedação aos juízes e Tribunais de exceção (XXXVII e LIII) a Constituição também aperfeiçoa o amplo acesso à justiça, garantido-se a todos uma jurisdição formada por juízes naturalmente competente para o julgamento das causas e, com isso, a imparcialidade de suas decisões também ficará mais protegida.

A gratuidade das ações de habeas corpus e habeas data a todas as pessoas, independentemente de sua condição financeira, também é importante

corolário do amplo acesso à justiça.

Essa tônica do acesso à justiça, na ordem constitucional brasileira, ganha ainda mais brilho com a existência do Ministério Público, na forma do art. 127 e da Defensoria Pública, conforme anuncia o art. 134.

A garantia constitucional em debate não protege apenas o acesso formal e material à justiça, como também o direito a sentenças justas, coerentes com o arcabouço probatório colimado nos autos, sob pena de responsabilidade objetiva do Estado por erro judiciário (LXXV) e ainda à responsabilidade pessoal do agente estatal, na forma do art. 37, § 6º, da CRFB/88. Da mesma forma, os danos morais e materiais sofridos em decorrência do excesso de prisão também poderão ser reivindicados pela vítima dessa negligência estatal.

Ressalte-se que o duplo grau de jurisdição, apesar de ser um importante desdobramento do amplo acesso à justiça, não é obrigatório, diante da previsão de uma série de ações de competências originárias dos Tribunais.

Súmula 667 do STF: *“Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa.”*

Independência das instâncias judicial e administrativa.

“O Min. Marco Aurélio, relator, tendo em conta o entendimento do STF no sentido de independência das esferas administrativa, cível e criminal, nas quais a atuação pode ser simultânea, ressalvada a previsão do art. 1.525, do CC/16, conheceu e deu provimento ao recurso para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 38, da Lei 6.830/80, e determinar o prosseguimento do processo administrativo - que, na espécie, fora obstado em decorrência da tramitação de outro mandado de segurança anteriormente impetrado pela recorrente. Entendeu o relator que o dispositivo mencionado ofende o direito de livre acesso ao Judiciário, assegurado pelo art. 5º, XXXV, da CRFB/88”¹⁵⁹.

159. STF, RE 234.277, Min. Rel. Marco Aurélio, J 27-05-2004, inf. 349.

Inexistência da obrigatoriedade constitucional ao duplo grau de jurisdição.

“O Senado quando julga o Presidente da República, não atua como órgão legislativo, mas como órgão judicial, exercendo jurisdição recebida da Constituição, e de cujas decisões não há recurso para nenhum tribunal. Isto nada tem de inaudito. Da decisão do STF nas infrações penais comuns em que configure como acusado o Presidente da República, art. 102, I, “a”, da CRFB/88, também não há recurso algum, nem para outro Tribunal nem para o Senado¹⁶⁰.”

9.31 PRINCÍPIO DA SEGURANÇA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS E DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Esta norma versa sobre direito intertemporal, sobre conflito de lei no tempo. É uma das concretizações do princípio da segurança jurídica e está relacionado à ideia da irretroatividade do direito, mas não se confunde com esta. O direito deve ser em regra geral feito para casos futuros e não para cuidar de situações já consolidadas no tempo, o que guarda relação com a própria moralidade do direito.

A expressão “lei”, em nossa opinião, deve ser entendida em seu sentido mais amplo, contendo todas as espécies normativas produzidas no ordenamento jurídico, incluindo-se as emendas constitucionais, que são fruto de um poder derivado e devem respeito às cláusulas pétreas. Então, em nome da segurança das relações jurídicas já consolidadas com o tempo e o princípio da irretroatividade genérico das leis, a norma deve respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, a seguir conceituados.

Definir o direito adquirido não é simples, mas podemos utilizar a sua definição de acordo com previsão ordinária da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, que o define no art. 6º, §2º:

160.s STF, MS 21.689, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ. 7-4-1995.

“Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbitrio de outrem”.

A jurisprudência tem observado, em sua maioria, este conceito. Sobre a existência de direito adquirido em face de normas constitucionais originárias e derivadas, analisamos em capítulo próprio ao tema.

Ato jurídico perfeito é aquele que foi validamente praticado sob a égide da legislação que vigia no momento da sua realização, ou seja, não padecia de vício quando foi praticado. Do ato jurídico perfeito se irradiam efeitos que se incorporam à esfera jurídica do agente, nascendo direitos adquiridos. Coisa julgada é fenômeno de natureza processual que visa evitar a eternização dos conflitos. A sentença é indiscutível, imutável após a utilização de todos os recursos previstos. Está definido no art. 6º, § 3º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, que usa como expressões sinônimas coisa julgada e caso julgado: “Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso”. Lembramos que a proteção constitucional incide sobre a coisa julgada material.

A irretroatividade genérica das leis cede espaço quando a lei penal é mais benéfica ao réu, seja cominando pena menor, estabelecendo atenuante, descriminando fato anteriormente considerado crime, ou qualquer outro benefício que seja mais favorável ao réu. Frise-se que em relação à lei penal mais severa, continua se aplicando o princípio da irretroatividade, não sendo aplicada a fatos pretéritos.

Definição de Direito Adquirido.

“O sistema constitucional brasileiro, em cláusula de salvaguarda, impõe que se respeite o direito adquirido (CRFB/88, art. 5º, XXXVI). A Constituição da República, no entanto, não apresenta qualquer definição de direito adquirido, pois, em nosso ordenamento positivo, o conceito de direito adquirido representa matéria de caráter meramente legal. Não se pode confundir, desse modo, a noção conceitual de direito adquirido (tema da legislação ordinária) com o princípio inerente à proteção das situações definitivamente consolidadas (matéria de extração constitucional), pois é apenas a tutela do direito adquirido que ostenta natureza constitucional, a

*partir da norma de sobredireito inscrita no art. 5º, XXXVI, da Carta Política. Tendo-se presente o contexto normativo que vigora no Brasil, é na lei - e nesta, somente — que repousa o delineamento dos requisitos concernentes à caracterização do significado da expressão direito adquirido. (...) Em suma: se é certo que a proteção ao direito adquirido reveste-se de qualificação constitucional, consagrada que foi em norma de sobredireito que disciplina os conflitos das leis no tempo (CRFB/88, art. 5º, XXXVI), não é menos exato — considerados os dados concretos de nossa própria experiência jurídica — que a positivação do conceito normativo de direito adquirido, ainda que veiculável em sede constitucional, submete-se, no entanto, de lege lata, ao plano estrito da atividade legislativa comum”.*¹⁶¹

Direito Adquirido e Pensão.

*“(...) Pensão. Viúva de deputado estadual. Art. 5º, XXXVI da Constituição. Direito adquirido. Viúva de deputado estadual que vinha percebendo pensão, com base na Lei estadual n. 8.393/83, correspondente a 2/3 do valor do subsídio pago a deputado estadual. Não pode a lei posterior (Lei estadual n. 9.886/89) reduzir o quantum da pensão deferida sob a égide de legislação anterior, para o montante de 35% do atual subsídio pago a deputado estadual. Ofensa ao direito adquirido configurada (...).”*¹⁶²

Direito Adquirido e normas constitucionais originárias

*“A supremacia jurídica das normas inscritas na Carta Federal não permite, ressalvadas as eventuais exceções proclamadas no próprio texto constitucional, que contra elas seja invocado o direito adquirido.”*¹⁶³

Direito Adquirido e regime jurídico de servidor público.

“Servidor público: é da jurisprudência do Supremo Tribunal que não há direito adquirido a regime jurídico, no qual se

161. STF, AI 135.632-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, J em 10-10-95, DJ de 3-9-99

162. STF, RE 460.737, Rel. p/ o ac Min. Joaquim Barbosa, J em 19-6-07, DJE de 30-11-07.

163. STF, ADI 248, Rel. Min. Celso de Mello, J em 18-11-93, DJ de 8-4-94

inclui o nível hierárquico que o servidor ocupa na carreira."¹⁶⁴

Ato jurídico perfeito e lei nova.

"Os contratos submetem-se, quanto ao seu estatuto de regência, ao ordenamento normativo vigente à época de sua celebração. Mesmo os efeitos futuros oriundos de contratos anteriormente celebrados não se expõem ao domínio normativo de leis supervenientes. As consequências jurídicas que emergem de um ajuste negocial válido são regidas pela legislação em vigor no momento de sua pactuação. Os contratos — que se qualificam como atos jurídicos perfeitos (RT 547/215) — acham-se protegidos, em sua integralidade, inclusive quanto aos efeitos futuros, pela norma de salvaguarda constante do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Doutrina e precedentes. A incidência imediata da lei nova sobre os efeitos futuros de um contrato preexistente, precisamente por afetar a própria causa geradora do ajuste negocial, reveste-se de caráter retroativo (retroatividade injusta de grau mínimo), achando-se desautorizada pela cláusula constitucional que tutela a intangibilidade das situações jurídicas definitivamente consolidadas."¹⁶⁵

Ato jurídico perfeito e lei de ordem pública I

"O princípio constitucional do respeito ao ato jurídico perfeito se aplica também, conforme é o entendimento desta Corte, às leis de ordem pública. Correto, portanto, o acórdão recorrido ao julgar que, no caso, ocorreu afronta ao ato jurídico perfeito, porquanto, com relação à caderneta de poupança, há contrato de adesão entre o poupador e o estabelecimento financeiro, não podendo, portanto, ser aplicada a ele, durante o período para a aquisição da correção monetária mensal já iniciado, legislação que altere, para menor, o índice dessa correção."¹⁶⁶

164. STF, AI 598.229-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, J em 13-12-06, DJ de 16-2-07

165. STF, AI 292.979-ED, Rel. Min. Celso de Mello, J em 19-11-02, DJ de 19-12-02

166. STF, RE 202.584, Rel. Min. Moreira Alves, J em 17-9-96, DJ de 14-11-96

Ato jurídico perfeito e lei de ordem pública II

“Se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa (retroatividade mínima) porque vai interferir na causa, que é um ato ou fato ocorrido no passado. O disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva. Precedente do STF. Ocorrência, no caso, de violação de direito adquirido. A taxa referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda. Por isso, não há necessidade de se examinar a questão de saber se as normas que alteram índice de correção monetária se aplicam imediatamente, alcançando, pois, as prestações futuras de contratos celebrados no passado, sem violarem o disposto no artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna. Também ofendem o ato jurídico perfeito os dispositivos impugnados que alteram o critério de reajuste das prestações nos contratos já celebrados pelo sistema do Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional (PES/CP).”¹⁶⁷

Coisa julgada administrativa:

“A coisa julgada a que se refere o artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna é, como conceitua o § 3º do artigo 6º da Lei de Introdução do Código Civil, a decisão judicial de que já não caiba recurso, e não a denominada coisa julgada administrativa.”¹⁶⁸

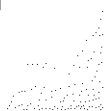
Retroatividade da lei penal mais benéfica I:

“A retroatividade da lei penal mais favorável consiste basicamente em imputar as consequências jurídicas benéficas aos fatos nela previstos, embora ocorridos anteriormente a sua vigência, sem, contudo, poder fazer retroceder o próprio curso do tempo.”¹⁶⁹

167. STF, ADI 493, Rel. Min. Moreira Alves, J em 25-6-92, DJ de 4-9-92

168. STF, RE 144.996, Rel. Min. Moreira Alves, J em 29-4-97, DJ de 12-9-97

169. STF, HC 70.641, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26-08-1994.



Retroatividade da lei penal mais benéfica II:

“A cláusula constitucional inscrita no art. 5º, XL, da Carta Política — que consagra o princípio da irretroatividade da lex gravior — incide, no âmbito de sua aplicabilidade, unicamente, sobre as normas de direito penal material, que, no plano da tipificação, ou no da definição das penas aplicáveis, ou no da disciplinação do seu modo de execução, ou, ainda, no do reconhecimento das causas extintivas da punibilidade, agravem a situação jurídico-penal do indiciado, do réu ou do condenado.”¹⁷⁰

Lei penal mais benéfica promulgada após a prática do delito e revogada antes do julgamento.

“dada a garantia constitucional de retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu, é consensual na doutrina que prevalece a norma mais favorável que tenha tido vigência entre a data do fato e a da sentença: o contrário implicaria retroação da lei nova, mais severa, de modo a afastar a incidência de lei intermediária, cuja prevalência, sobre a do tempo do fato, o princípio da retroatividade in melius já determinara.”¹⁷¹

9.32 PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção.

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

O Tribunal considerado de exceção é aquele que não integra a organização judiciária preestabelecida, que é criado ad hoc, isto é, apenas para o caso, e post facto, ou seja, depois da ocorrência do fato objeto do processo e do julgamento. Esse tipo de juízo não é permitido, pois fere o princípio do juiz natural ou juiz constitucional, aquele que a Constituição previamente institui para o exercício da função jurisdicional, ou seja, pré-constituído, admitindo-se, contudo, o foro privilegiado, mas apenas para os indicados no

170. STF, AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, J em 18-6-96, DJ de 13-9-96

171. STF, RE 418.876, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 4-6-04.

próprio texto constitucional¹⁷².

É como se todo cidadão possuísse uma autoridade jurisdicional para apreciar suas controvérsias, evitando-se com isso os julgamentos de encomenda. Com isso, o princípio da imparcialidade, insito ao Poder judiciário também ficará mais tutelado.

Como mais um pilar da proibição da existência de juízo ou tribunal de exceção, o inciso LIII reforça o princípio do juiz natural, homenageando também o princípio da legalidade, pois somente a lei pode determinar a autoridade competente para a verificação de uma situação jurídica para a própria manutenção do Estado Democrático de Direito: os princípios constitucionais.

Sentido do princípio do Juiz Natural I:

*"Princípio do juiz natural. Relator substituído por Juiz Convocado sem observância de nova distribuição. Precedentes da Corte. O princípio do juiz natural não apenas veda a instituição de tribunais e juízos de exceção, como também impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios constitucionais de repartição taxativa de competência, excluída qualquer alternativa à discricionariedade. A convocação de Juízes de 1º grau de jurisdição para substituir Desembargadores não malfere o princípio constitucional do juiz natural, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei n. 9.788/99. O fato de o processo ter sido relatado por um Juiz Convocado para auxiliar o Tribunal no julgamento dos feitos e não pelo Desembargador Federal a quem originariamente distribuído tampouco afronta o princípio do juiz natural. Nos órgãos colegiados, a distribuição dos feitos entre relatores constitui, em favor do jurisdicionado, imperativo de impessoalidade que, na hipótese vertente, foi alcançada com o primeiro sorteio. Demais disso, não se vislumbra, no ato de designação do Juiz Convocado, nenhum traço de discricionariedade capaz de comprometer a imparcialidade da decisão que veio a ser exarada pelo órgão colegiado competente."*¹⁷³

172. AFONSO DA SILVA, ob. cit. p. 136.

173. STF, HC 86.889, Rel. Min. Menezes Direito, J em 20-11-07, DJE de 15-2-08

Sentido do princípio do Juiz Natural II:

“A consagração constitucional do princípio do juiz natural tem o condão de reafirmar o compromisso do Estado brasileiro com a construção das bases jurídicas necessárias à formulação do processo penal democrático. O princípio da naturalidade do juízo representa uma das matizes político-ideológicas que conformam a própria atividade legislativa do Estado condicionando ainda o desempenho em juízo representa em juízo das funções estatais de caráter penal-persecutório. A lei não pode frustrar a garantia derivada do postulado do juiz natural. Assiste, a qualquer pessoa, quando eventualmente submetida a juízo penal, o direito de ser processada perante Magistrado imparcial e independente, cuja competência é predeterminada, em abstrato, pelo próprio ordenamento constitucional”.¹⁷⁴

Tribunais de Exceção e extradição:

“Ao apreciar um pedido de extradição, o STF considerou como tribunais de exceção: a) os que são criados após o fato que vai ser julgado (ex post facto); b) os que são instituídos para o julgamento de determinadas pessoas ou de certas infrações penais; c) os Tribunais regulares, quando desrespeitam o devido processo legal”.¹⁷⁵

O Tribunal do Júri

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

- a) a plenitude de defesa;*
- b) o sigilo das votações;*
- c) a soberania dos veredictos;*
- d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.*

Em análise simples, haja vista o instituto receber cuidados maiores pelas disciplinas penal e processual penal, poderíamos afirmar que o Tribunal do

174. STF, HC 73.801, Rel. Min. Celso de Mello, RT 744/489

175. STF, RDA 181-182/168.

Júri é um órgão colegiado, heterogêneo e temporário. É formado por um juiz de direito, que é o presidente e de sete cidadãos que integrarão o Conselho de Sentença, desempenhando a tarefa de apreciar a matéria fática e as provas que envolvem o delito. O juiz togado deverá analisar os aspectos técnico-jurídicos e é quem ao final deverá aplicar a pena, de acordo com o veredicto proferido pelos jurados.

Serão garantidos nesse julgamento, a) a plenitude de defesa do réu¹⁷⁶, ou seja, a possibilidade que o acusado se oponha ao que contra ele se afirma utilizando-se de todos os meios em direito disponíveis, de acordo com o princípio do devido processo legal, em que são garantidas a ampla defesa e o contraditório (LIV e LV); b) o sigilo das votações, consistente no fato de que a opinião dos jurados não devem ser conhecidas individualmente e ficam imunes a interferências externas; c) a soberania dos veredictos, que impede o juiz de direito modificar o resultado do julgamento, substituindo a vontade dos jurados¹⁷⁷; e d) a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, ou seja, homicídio, infanticídio, instigação, induzimento ou prestação de auxílio ao suicídio e aborto, consumados ou tentados.

Há, entretanto, hipóteses excepcionais, em que crimes dolosos contra a vida não serão julgados pelo Tribunal do Júri, em razão, por exemplo, do foro privilegiado de processo que possuem algumas autoridades públicas, tendo em vista que normas especiais prevalecem sobre as gerais.¹⁷⁸

Enunciados da Súmula do STF:

Súmula 156: *“É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório.”*

Súmula 162: *“É absoluta a nulidade do julgamento pelo júri, quando os quesitos da defesa não precedem aos das*

176. Segundo Uadi Lammêgo Bulos, “essa vastidão da plenitude de defesa inclui o fato de serem os jurados escolhidos de todas as classes sociais, para que haja livre convencimento e sólida responsabilidade dos votos emitidos, observados ainda os princípios da imediatidade e da concentração de provas. A plenitude de defesa com todos os meios a ela inerentes, inclusive no tocante ao direito de ser informado, engloba a bilateralidade da audiência (contrariedade) e também o direito à prova legitimamente obtida ou produzida”. Em Constituição Federal Anotada, 5ª ed. Saraiva, 2003, p. 242.

177. Importante ressaltar que a soberania dos veredictos não exclui a recorribilidade das decisões do júri.

178. Vide arts. 102, I, b e c; 105, I, a, da CRFB/88, como exemplos.

circunstâncias agravantes.”

Súmula 713: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.”

Tribunal do Júri e Desaforamento.

“Juiz natural de processo por crimes dolosos contra a vida é o Tribunal do Júri. Mas o local do julgamento pode variar, conforme as normas processuais, ou seja, conforme ocorra alguma das hipóteses de desaforamento previstas no art. 424 do C. P. Penal, que não são incompatíveis com a Constituição anterior nem com a atual (de 1988) e também não ensejam a formação de um ‘Tribunal de exceção.’”¹⁷⁹

Tribunal do Júri e recusa de atendimento médico.

“Crime de competência do tribunal do júri. Recusa reiterada e injustificada de atendimento médico à pessoa gravemente enferma. Dolo eventual. Tribunal do júri. Reapreciação de material probatório. Denegação. Para configuração do dolo eventual não é necessário o consentimento explícito do agente, nem sua consciência reflexiva em relação às circunstâncias do evento. Faz-se imprescindível que o dolo eventual se extraia das circunstâncias do evento, e não da mente do autor, eis que não se exige uma declaração expressa do agente. Na realidade, o dolo eventual não poderia ser descartado ou julgado inadmissível na fase do iudicium accusationis. A tese da inépcia da denúncia e do aditamento, à evidência, não se sustenta, eis que foram preenchidos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, inclusive em razão da observância dos atos previstos no art. 384, parágrafo único, do CPP, por força do aditamento à denúncia. (...) no curso da instrução, sobrevieram novos elementos de prova que apontaram para a ocorrência de possível dolo eventual na conduta do paciente. Assim, no segundo momento (o do aditamento à denúncia), descreveu-se a conduta de o paciente haver se recusado, por duas vezes, em

179. STF, HC 67.851, Rel. Min. Sydney Sanches, J em 24-4-90, DJ de 18-5-90

dias consecutivos, a atender à vítima que já apresentava sérios problemas de saúde, limitando-se a dizer para a avó da vítima que a levasse de volta para casa, e somente retornasse quando o médico pediatra tivesse retornado de viagem."¹⁸⁰

Tribunal do Júri e Prerrogativa de foro I.

O réu, na qualidade de detentor do mandato de parlamentar federal, detém prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal, onde deve ser julgado pela imputação da prática de crime doloso contra a vida. A norma contida no art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República, que garante a instituição do júri, cede diante do disposto no art. 102, I, b, da Lei Maior, definidor da competência do Supremo Tribunal Federal, dada a especialidade deste último. Os crimes dolosos contra a vida estão abarcados pelo conceito de crimes comuns. Precedentes da Corte. A renúncia do réu produz plenos efeitos no plano processual, o que implica a declinação da competência do Supremo Tribunal Federal para o juízo criminal de primeiro grau. Ausente o abuso de direito que os votos vencidos vislumbraram no ato. Autos encaminhados ao juízo atualmente competente."¹⁸¹

Tribunal do Júri e Prerrogativa de foro II.

"A competência do Tribunal do Júri não é absoluta. Afasta-a a própria Constituição Federal, no que prevê, em face da dignidade de certos cargos e da relevância destes para o Estado, a competência de tribunais — artigos 29, inciso VIII; 96, inciso III; 108, inciso I, alínea a; 105, inciso I, alínea a e 102, inciso I, alíneas b e c."¹⁸²

Tribunal do Júri e Prerrogativa de foro III.

"Prerrogativa de foro e coautoria "O envolvimento de corréus em crime doloso contra a vida, havendo em relação a um deles foro especial por prerrogativa de função, previsto constitucionalmente, não afasta os demais do juiz natural, ut art. 5º, XXXVIII, alínea d, da Constituição."¹⁸³

180. STF, HC 92.304, Rel. Min. Ellen Gracie, J em 5-8-08, DJE de 22-8-08.

181. STF, AP 333, Rel. Min. Joaquim Barbosa, J em 5-12-07, DJE de 11-4-08

182. STF, HC 70.581, Rel. Min. Marco Aurélio, J em 21-9-93, DJ de 29-10-93

183. STF, HC 73.235, Rel. Min. Néri da Silveira, J em 28-11-95, DJ de 18-10-96

Soberania dos veredictos do Júri e recorribilidade das suas decisões:

"A soberania dos veredictos do Júri — não obstante a sua extração constitucional — ostenta valor meramente relativo, pois as manifestações decisórias emanadas do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade juridico-processual. A competência do Tribunal do Júri, embora definida no texto da Lei Fundamental da República, não confere a esse órgão especial da Justiça comum o exercício de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. A apelabilidade das decisões emanadas do Júri, nas hipóteses de conflito evidente com a prova dos autos, não ofende o postulado constitucional que assegura a soberania dos veredictos desse Tribunal Popular."¹⁸⁴

9.33 DIREITO PENAL CONSTITUCIONAL

Como a análise mais aprofundada sobre os crimes e as penas é realizada pelo direito penal e processual penal, faremos um estudo mais sucinto da matéria, sugerindo ao leitor que se utilize de bibliografia mais especializada na área para estudo do tema.

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;

Este dispositivo constitucional contém os princípios da legalidade penal (ou da reserva legal) – nullum crimen sine lege – e também o da anterioridade da pena (nulla poena sine lege). A tipificação da conduta criminosa só pode ser feita por lei em sentido formal, produzida pelo Congresso Nacional, pois cabe à União legislar sobre a matéria (art. 22, I), de acordo com o devido processo legislativo. Não se admite, portanto, que o assunto seja tratado por meio de medidas provisórias, leis delegadas ou decretos, por exemplo.

184. STF, HC 68.658, Rel. Min. Celso de Mello, J em 6-8-91, DJ de 26-6-92

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;

Esta norma estatui limites ao poder do Estado no sentido de que as liberdades (incluídas entre os direitos) públicas não de ser respeitadas. O preceito em tela tem anunciado bem abrangente e deve seguir de guia para a tarefa do legislador na elaboração de normas que reforcem a proteção à dignidade da pessoa humana, na defesa da eliminação de qualquer forma de preconceito, não mais tolerado no país.

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

O constituinte de 1988 trouxe um forte aparato de normas voltado ao combate ao preconceito. O art. 3º, IV, destaca que é um dos objetivos da República a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade e rechaça quaisquer outras formas de discriminação. O inciso XLI, como já visto, é também uma norma que reforça essa mesma luta, que é favor, antes de tudo da pessoa humana e de sua dignidade.

E foi com essa motivação de prevalência dos direitos humanos que a Constituição de 1988 elevou o racismo a crime inafiançável (sem possibilidade de pagamento de fiança para organizar a defesa em liberdade), imprescritível (sem decurso de tempo para a realização do jus puniendi do Estado) e sujeito à pena de reclusão (sujeito a início de cumprimento de pena em regime fechado).

A fim de dar efetividade ao texto constitucional, surgiu a Lei nº 7.716/89, que definiu os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, que foi alterada em 1997 pela Lei nº 9.459, que ampliou o foco para a proteção de atos resultantes de preconceito de etnia, religião ou procedência nacional.

No âmbito internacional o Brasil também manifestou adesão à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial¹⁸⁵, assumindo também o compromisso internacional de progressivamente eliminar todas as formas de preconceito. O art. 1º da referida Convenção define a discriminação racial como: “qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha o propósito ou o efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício em pé de igualdade dos direitos humanos e liberdades

185. Adotada pela Resolução L44(XLIV) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 20.11.1989 e ratificada pelo Brasil em 27.3.1968.

fundamentais”.

Daí a urgência, segundo Flávia Piovesan¹⁸⁶, em erradicar todas as formas de discriminação, baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenham como escopo a exclusão. Segundo a autora, o combate à discriminação racial é medida fundamental para que se garanta o pleno exercício dos direitos civis e políticos, como também dos direitos sociais, econômicos e culturais.

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

No intuito de coibir ações agressivas como: a tortura (definido pela Lei nº 9455/98 como sendo castigo corporal ou psicológico violento infligido a uma pessoa com o intuito de compeli-la a admitir ou omitir um fato definido), o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins (previsto na Lei nº 6368/76), o terrorismo (prática de ato violento proveniente de pessoa ou grupos armados que pretendem combater certas formas ou organizações de poder) e os crimes hediondos (definidos pelas Leis 8072/90 e 8930/94), a Constituição deu especial destaque quando os tratou de forma rigorosa, impedindo a concessão da fiança, da graça e da anistia.

Graça é medida de clemência solicitada pelo condenado com base em características pessoais e não se confunde com a anistia, que é ato de clemência, por meio do qual são esquecidos os atos ilícitos cometidos pelo agente e é concedida por lei, com o objetivo de promover o arquivamento dos processos pendentes, além de suspender a execução das penas em curso, eliminando os efeitos das penalidades que já foram cumpridas¹⁸⁷.

Importante ressaltar que, no âmbito externo, o Brasil também aderiu à Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumados ou Degradantes¹⁸⁸ em 1989.

186. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional., 7 ed. Saraiva, 2006, p. 182.

187. BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada, 5ª ed. Saraiva, 2003, p. 256.

188. Adotada pela Resolução 39/46 da Assembleia Geral das Nações Unidas em 9.12.1948, aprovada pelo Brasil pelo Decreto Legislativo nº 4, de 23.5.1989, e promulgada pelo Decreto nº 40, de 15.12.1991.

Crimes Hediondos e progressão de regime:

*“Em conclusão de julgamento, o Tribunal, por maioria, deferiu pedido de habeas corpus e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, que veda a possibilidade de progressão do regime de cumprimento da pena nos crimes hediondos definidos no art. 1º do mesmo diploma legal — v. Informativos 315, 334 e 372. Inicialmente, o Tribunal resolveu restringir a análise da matéria à progressão de regime, tendo em conta o pedido formulado. Quanto a esse ponto, entendeu-se que a vedação de progressão de regime prevista na norma impugnada afronta o direito à individualização da pena (CRFB/88, art. 5º, LXVI), já que, ao não permitir que se considerem as particularidades de cada pessoa, a sua capacidade de reintegração social e os esforços aplicados com vistas à ressocialização, acaba tornando inócua a garantia constitucional. Ressaltou-se, também, que o dispositivo impugnado apresenta incoerência, porquanto impede a progressividade, mas admite o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena (Lei 8.072/90, art. 5º). Vencidos os Ministros Carlos Velloso, Joaquim Barbosa, Ellen Gracie, Celso de Mello e Nelson Jobim, que indeferiam a ordem, mantendo a orientação até então fixada pela Corte no sentido da constitucionalidade da norma atacada. O Tribunal, por unanimidade, explicitou que a declaração incidental de inconstitucionalidade do preceito legal em questão não gerará consequências jurídicas com relação às penas já extintas nesta data, uma vez que a decisão plenária envolve, unicamente, o afastamento do óbice representado pela norma ora declarada inconstitucional, sem prejuízo da apreciação, caso a caso, pelo magistrado competente, dos demais requisitos pertinentes ao reconhecimento da possibilidade de progressão”*¹⁸⁹.

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

189. STF, HC 82959/SP, rel. Min. Marco Aurélio, 23-2-2006. Inf. 418.

Tendo em vista a proteção e a manutenção do Estado Democrático de Direito, o constituinte decidiu considerar todas as manifestações de grupos armados, civis e militares que implicam contra a sua manutenção, inafiançáveis e imprescritíveis. O texto não tipifica a conduta delituosa (que deverá ser tratada por lei, em obediência ao princípio da reserva de lei, art. 5º, XXXIX), mas determina a vedação dos benefícios da fiança e da prescrição.

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido;

A responsabilidade penal é pessoal, intransferível. Incide, entretanto, exceção para uma das consequências da sanção penal, qual seja, a obrigação de reparar o dano. Assim, o dever de reparar o dano causado pela prática criminosa estende-se aos herdeiros do condenado no limite do patrimônio transferido em caso de sua morte. Com isso, a herança deixada pelo condenado será atingida pelo dever imposto aos sucessores de arcarem com as despesas com a reparação do dano.

Segundo o entendimento jurisprudencial, vulnera o princípio da incontagiabilidade da pena a decisão judicial que permite ao condenado fazer-se substituir, por terceiro absolutamente estranho ao ilícito penal, na prestação de serviços à comunidade¹⁹⁰.

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

- a) privação ou restrição da liberdade;*
- b) perda de bens;*
- c) multa;*
- d) prestação social alternativa;*
- e) suspensão ou interdição de direitos;*

190. STF, HC 68.309, Rel. Min. Celso de Mello, J em 27-11-90, DJ de 8-3-91

Em nome da proteção à dignidade da pessoa humana, o constituinte preocupou-se em definir alguns tipos de penas, não excluindo outras que possam ser adotadas por lei, desde que harmoniosas com o valor máximo à pessoa humana. São citadas as seguintes penas: **a)** privação da liberdade: que pode ser de reclusão ou detenção e será cumprida em estabelecimento próprio, subtraindo da pessoa o direito de viver em sociedade; **b)** restrição da liberdade: o condenado não fica afastado do convívio social, mas se submete ao cumprimento de algumas restrições como, por exemplo, à limitação de fim de semana; **c)** perda de bens: é pena restritiva de direitos que integra o rol de efeitos da condenação; **d)** multa: obrigação imposta de pagar ao Estado determinada quantia em dinheiro; **e)** prestação social alternativa: consiste na imposição da prestação de um serviço à comunidade ou a entidades públicas, como asilo, hospitais abrigo etc.; **f)** suspensão ou interdição de direitos: é a interrupção temporária de um direito aplicada acessoriamente às demais sanções, como, por exemplo, suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo.

Individualização da pena e prisão preventiva.

“Não há que se falar em inidoneidade do decreto de prisão, se este embasa a custódia cautelar em dados concretos. A prisão preventiva pode ser decretada para evitar que o acusado pratique novos delitos. O decreto preventivo contém dados concretos quanto à periculosidade do paciente e da quadrilha de cujo comando faz parte. Ordem pública a se traduzir na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo-se explícito ‘dever do Estado, direito e responsabilidade de todos’ (art. 144 da CRFB/88). (...) A conveniência da instrução criminal justifica a segregação preventiva, quando há fatos concretos que sinalizem a possibilidade de o paciente influir no ânimo das testemunhas e denunciadores do esquema ilícito. A garantia da ordem econômica autoriza a custódia cautelar, se as atividades ilícitas do grupo criminoso a que, supostamente, pertence o paciente repercutem negativamente no comércio lícito e, portanto, alcançam um indeterminado contingente de trabalhadores e comerciantes honestos. Vulneração do princípio constitucional da livre concorrência. A eventual

aplicação da lei penal é fundamento idôneo para embasar o decreto prisional, quando as condições objetivas do caso dão conta de que a suposta quadrilha possui ramificações em outros países onde, inclusive, corréu se encontra foragido. Ordem denegada."¹⁹¹

Prestação social alternativa e doação de sangue.

*"A prestação de serviços à comunidade constitui sanção jurídica revestida de caráter penal. Trata-se de medida alternativa ou substitutiva da pena privativa de liberdade. Submete-se, em consequência, ao regime jurídico-constitucional das penas e sofre todas as limitações impostas pelos princípios tutelares da liberdade individual. A exigência judicial de doação de sangue não se ajusta aos parâmetros conceituais, fixados pelo ordenamento positivo, pertinentes à própria inteligência da expressão legal 'prestação de serviços à comunidade', cujo sentido, claro e inequívoco, veicula a ideia de realização, pelo próprio condenado, de encargos de caráter exclusivamente laboral. Tratando-se de exigência conflitante com o modelo jurídico-legal peculiar ao sistema de penas alternativas ou substitutivas, não há como prestigiá-la e nem mantê-la".*¹⁹²

XLVII - não haverá penas:

- a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;*
- b) de caráter perpétuo;*
- c) de trabalhos forçados;*
- d) de banimento;*
- e) cruéis;*

Este dispositivo complementa o texto na norma do inciso XLVI, ao dispor sobre penas que não podem ser criadas pelo legislador ordinário, as "penas proibidas", que estão listadas em rol não exaustivo no dispositivo sob comento.

191. STF, HC 91.016, Rel. Min. Carlos Britto, J em 13-11-07, DJE de 9-5-08.

192. STF, HC 68.309, Rel. Min. Celso de Mello, J em 27-11-90, DJ de 8-3-91

Sobre a pena de morte, compartilhamos do mesmo posicionamento de José Afonso da Silva, que diante das belas palavras sobre o tema, merece a nossa longa citação:

*“Sempre que a criminalidade recrudescer e as ações violentas despontam no universo da delinquência, correntes de opinião, geralmente conservadoras – se não de tendência fascista e ditatorial – postulam instituição da pena de morte, que é sem dúvida uma pena altamente desumana e de crueldade tal, que só a maldade humana pode pretender vê-la instaurada. Executar alguém já dominado pela prisão constitui uma bárbara covardia, seja isso um mero ato arbitrário da Polícia – que não raro ocorre – seja um ato formalmente legal. Não há muita diferença entre essas duas formas de eliminar alguém. O suplicio nunca melhorou a qualidade dos homens; mais os revolta, porque nele nunca se traduz um princípio de autêntica justiça. Atrás da postulação da pena de morte sempre estará a ideia de vingança, e – o que é pior – de vingança particular por via de atuação do poder público”*¹⁹³.

Ainda que o país vede em regra geral a pena de morte, há uma exceção permitida pela Constituição justificada por razões extremas e restritas, ou seja, apenas em caso de guerra, quando estarão em jogo valores superiores para a nação e, ainda assim, a pena deverá ser aplicada de forma ponderada e excepcional, na forma do art. 355 e ss. Do Código Penal Militar brasileiro.

A pena de caráter perpétuo desvirtuaria um dos princípios da própria teoria da pena: o de ressocialização e reeducação do criminoso, para que possa voltar ao convívio social com os demais. A pena de trabalhos forçados também é proibida, porque apesar do trabalho durante o cumprimento da pena dever ser sempre estimulado – o que não acontece, infelizmente, em muitos estabelecimentos prisionais do país – todo trabalho deve ser remunerado desde a abolição da escravatura. A pena de banimento impede que os nacionais sejam expulsos do país pela prática de crime. Ademais, como a própria Constituição em outros dispositivos proíbe o tratamento desumano ou degradante e a prática de torturas (arts. 1º, III e 5º, III, XLIII), a pena cruel é inconcebível no país.

193. AFONSO DA SILVA, ob. cit. p. 148.

XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Esses dispositivos constitucionais salientam a proteção que o Estado deve destinar aos presos sob sua tutela. Para auxiliar na ressocialização do condenado, a Constituição ressalta a importância de separação dos presos em estabelecimentos diferenciados, levando-se em consideração dados importantes com relação à gravidade do delito, a idade e o sexo do apenado.

Em âmbito de legislação interna, a Lei de Execuções Penais (Lei nº 7210/84) cumpriu os postulados constitucionais e, por exemplo, em seu art. 5º, determina que os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal.

No âmbito externo, o Brasil ao aderir ao Pacto de San Jose da Costa Rica¹⁹⁴ também se comprometeu a respeitar a integridade pessoal do preso, de acordo com a previsão do art. 5º¹⁹⁵ que expressamente protege os direitos fundamentais.

Ademais, o respeito à integridade física e moral da pessoa humana é corolário da proteção à dignidade que todo indivíduo, independente de suas características pessoais ou ações na vida, deve ter protegida pelo Estado.

L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;

194. Aprovado pelo Brasil pelo Decreto Legislativo nº 27, de 25-9-1992 e promulgado pelo Decreto nº 678, de 6-11-1992.

195. "Artigo 5º - Direito à integridade pessoal

4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas.

5. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos a tribunal especializado, com a maior rapidez possível, para seu tratamento.

6. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados".

O direito ao aleitamento materno pode ser alicerçado em dois importantes princípios: a) primeiramente, a própria dignidade humana; da criança em ter garantido o carinho e o alimento da mãe em sua estreia na vida, e a mãe, que não pode ser privada de conhecer e de alimentar o próprio filho; b) depois, o princípio da intransmissibilidade da pena, evitando-se assim que a criança, que precisa do leite materno, que é indispensável à sua saúde, fique privada desse direito fundamental em razão dos atos ilícitos cometidos por outra pessoa, a sua mãe.

Ressalte-se que a Constituição não dispôs acerca do período que deverá ser assegurado para o exercício do direito ora conferido, deixando essa tarefa para o legislador ordinário, que deverá regulamentá-lo de maneira coerente com a natureza da proteção constitucional.

9.34 EXTRADIÇÃO

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;

Extradição, em linhas gerais seria o ato por meio do qual um Estado entrega uma pessoa que está sob os limites de seu território, a outro país que o solicita e que é competente para processá-lo e eventualmente condená-lo em razão da prática de crime. Como é uma manifestação de soberania estatal, é indispensável a existência de um tratado de extradição entre os países, acordando os termos de sua realização, respeitando-se ainda as leis internas de cada um, ou, então, um compromisso de reciprocidade devidamente firmado entre as partes.

A Constituição de 1988 só tratou da extradição passiva, sendo aquela que pode ocorrer quando o Brasil (como sujeito passivo) recebe o pedido para extraditar alguém que está em seu território. Nesse caso, a solicitação do governo estrangeiro será ainda apreciada pelo STF, na forma do art. 102, I, "g", que deverá levar em consideração o cumprimento de vários requisitos presentes na legislação infraconstitucional¹⁹⁶ antes de decidir sobre a

196. São requisitos para a extradição segundo a Lei 6815/80 (Estatuto do Estrangeiro):

extradição.

Conforme a orientação da norma ora comentada, a Constituição dá proteção absoluta ao brasileiro nato contra a extradição. Já o brasileiro naturalizado, submete-se à extradição desde que verificados os seguintes requisitos:

- se o crime é comum, será possível a sua extradição apenas se tiver sido praticado antes da naturalização; após a naturalização o brasileiro naturalizado responderá pelo crime no Brasil;
- se o crime é de tráfico de drogas, não importa se praticado antes ou depois da naturalização, pois o brasileiro poderá ser extraditado a qualquer tempo. Tal possibilidade se dá em razão de política universal de combate a este nefasto tipo de crime.

Importante destacar que **extradição** não se confunde com a **expulsão** nem com a **deportação**, senão vejamos:

Art. 78. São condições para concessão da extradição:

I - ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado; e

II - existir sentença final de privação de liberdade, ou estar a prisão do extraditando autorizada por Juiz, Tribunal ou autoridade competente do Estado requerente, salvo o disposto no artigo 82.

E ainda,

Art. 77. Não se concederá a extradição quando:

I - se tratar de brasileiro, salvo se a aquisição dessa nacionalidade verificar-se após o fato que motivar o pedido;

II - o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente;

III - o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando;

IV - a lei brasileira impuser ao crime a pena de prisão igual ou inferior a 1 (um) ano;

V - o extraditando estiver a responder a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido;

VI - estiver extinta a punibilidade pela prescrição segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente;

VII - o fato constituir crime político; e

VIII - o extraditando houver de responder, no Estado requerente, perante Tribunal ou Juízo de exceção.

§ 1º A exceção do item VII não impedirá a extradição quando o fato constituir, principalmente, infração da lei penal comum, ou quando o crime comum, conexo ao delito político, constituir o fato principal.

§ 2º Caberá, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal, a apreciação do caráter da infração.

- A expulsão determinará a retirada compulsória do estrangeiro que atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais (na forma do art. 65, do Estatuto do Estrangeiro);
- A deportação será realizada nos casos de entrada ou estada irregular de estrangeiro no país, pois, se este não se retirar voluntariamente do território nacional no prazo fixado em Regulamento, será promovida sua deportação (art. 57, do Estatuto do Estrangeiro).

Ressalte-se que não há expulsão ou deportação de brasileiros do território nacional.

O inciso LII veda a extradição de brasileiros e estrangeiros por crime político e de opinião. Apesar de a Constituição não ter definido exatamente esses crimes, pode-se dizer que o crime político é aquele praticado por razões de natureza pública, ou seja, atentatórias contra o bem-estar da coletividade, e o crime de opinião é aquele praticado quando a pessoa extrapola os limites da liberdade de manifestação do pensamento ofendendo e atacando pessoas e órgãos pelos meios de comunicação.

Súmula 421 do STF: *“Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro.”*

Extradição e prisão perpétua:

“necessidade de prévia comutação, em pena temporária (máximo de 30 anos), da pena de prisão perpétua — Revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em obediência à Declaração Constitucional de Direitos (CRFB/88, art. 5º, XLVII, b). A extradição somente será deferida pelo Supremo Tribunal Federal, tratando-se de fatos delituosos puníveis com prisão perpétua, se o Estado requerente assumir, formalmente, quanto a ela, perante o Governo brasileiro, o compromisso de comutá-la em pena não superior à duração máxima admitida na lei penal do Brasil (CP, art. 75), eis que os pedidos extradicionais — considerado o que dispõe o art. 5º, XLVII, b da Constituição da República, que veda as sanções penais de caráter perpétuo — estão necessariamente sujeitos à autoridade hierárquico-normativa da Lei Fundamental

brasileira.”¹⁹⁷

Igualdade de tratamento e estrangeiros.

*“Tratamento igualitário de brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. O alcance do disposto na cabeça do artigo 5º da Constituição Federal há de ser estabelecido levando-se em conta a remessa aos diversos incisos. A cláusula de tratamento igualitário não obstaculiza o deferimento de extradição de estrangeiro.”*¹⁹⁸

Extradição Passiva de brasileiros naturalizados:

*Admissibilidade. Extraditando. Brasileiro naturalizado. Naturalização posterior aos fatos que, como crimes comuns, motivaram o pedido. Aplicação do art. 5º, LI, da CRFB/88, e art. 77, I, da Lei n. 6.815/80. Pode ser extraditado o brasileiro naturalizado que adquiriu a nacionalidade após a prática do crime comum que fundamenta o pedido de extradição.”*¹⁹⁹

Promessa de reciprocidade e vedação à extradição.

*“Pedido de extradição, formulado com base em promessa de reciprocidade, de cidadão brasileiro naturalizado, por fatos relacionados a tráfico de drogas anteriores à entrega do certificado de naturalização. Inviabilidade da extradição, por impossibilidade de cumprimento da promessa de reciprocidade, uma vez que, no país requerente, a vedação de extradição de seus nacionais não admite exceções como as previstas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (art. 5º, LI). Questão de ordem resolvida pela extinção da extradição, sem julgamento de mérito. Determinada a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, para as finalidades cabíveis, verificando-se a possibilidade de aplicação extraterritorial da lei penal brasileira.”*²⁰⁰

197. STF, Ext 855, Rel. Min. Celso de Mello, J em 26-8-04, DJ de 1º-7-05

198. STF, Ext 1.028, Rel. Min. Marco Aurélio, J em 10-8-06, DJ de 8-9-06

199. STF, HC 87.219, Rel. Min. Cezar Peluso, J em 14-6-06, DJ de 4-8-06

200. STF, Ext 1.010-QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, J em 24-5-06, DJ de 19-12-06

Vedação à extradição de brasileiro nato.

“O brasileiro nato, quaisquer que sejam as circunstâncias e a natureza do delito, não pode ser extraditado, pelo Brasil, a pedido de Governo estrangeiro, pois a Constituição da República, em cláusula que não comporta exceção, impede, em caráter absoluto, a efetivação da entrega extradicional daquele que é titular, seja pelo critério do jus soli, seja pelo critério do jus sanguinis, de nacionalidade brasileira primária ou originária. Esse privilégio constitucional, que beneficia, sem exceção, o brasileiro nato (CRFB/88, art. 5º, LI), não se descaracteriza pelo fato de o Estado estrangeiro, por lei própria, haver-lhe reconhecido a condição de titular de nacionalidade originária pertinente a esse mesmo Estado (CRFB/88, art. 12, § 4º, II, a). Se a extradição não puder ser concedida, por inadmissível, em face de a pessoa reclamada ostentar a condição de brasileira nata, legitimar-se-á a possibilidade de o Estado brasileiro, mediante aplicação extraterritorial de sua própria lei penal (...) — e considerando, ainda, o que dispõe o Tratado de Extradição Brasil/Portugal (...) —, fazer instaurar, perante órgão judiciário nacional competente (...), a concernente persecutio criminis, em ordem a impedir, por razões de caráter ético-jurídico, que práticas delituosas, supostamente cometidas, no exterior, por brasileiros (natos ou naturalizados), fiquem impunes.”²⁰¹

Extradição e crime político I.

“Extradição: Colômbia: crimes relacionados à participação do extraditando — então sacerdote da Igreja Católica — em ação militar das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). Questão de ordem. Reconhecimento do status de refugiado do extraditando, por decisão do comitê nacional para refugiados-CONARE: pertinência temática entre a motivação do deferimento do refúgio e o objeto do pedido de extradição: aplicação da Lei 9.474/97, art. 33 (Estatuto do Refugiado), cuja constitucionalidade é reconhecida: ausência de violação do princípio constitucional da separação dos poderes. De acordo

201. STF, HC 83.113-QO, Rel. Min. Celso de Mello, J em 26-6-03, DJ de 29-8-03

com o art. 33 da L. 9474/97, o reconhecimento administrativo da condição de refugiado, enquanto dure, é elisiva, por definição, da extradição que tenha implicações com os motivos do seu deferimento. É válida a lei que reserva ao Poder Executivo — a quem incumbe, por atribuição constitucional, a competência para tomar decisões que tenham reflexos no plano das relações internacionais do Estado — o poder privativo de conceder asilo ou refúgio. A circunstância de o prejuízo do processo advir de ato de um outro Poder — desde que compreendido na esfera de sua competência — não significa invasão da área do Poder Judiciário. Pedido de extradição não conhecido, extinto o processo, sem julgamento do mérito e determinada a soltura do extraditando. Caso em que de qualquer sorte, incidiria a proibição constitucional da extradição por crime político, na qual se compreende a prática de eventuais crimes contra a pessoa ou contra o patrimônio no contexto de um fato de rebelião de motivação política (Ext. 493).²⁰²

Extradição e crime político II.

“Extraditando acusado de transmitir ao Iraque segredo de estado do Governo requerente (República Federal da Alemanha), utilizável em projeto de desenvolvimento de armamento nuclear. Crime político puro, cujo conceito compreende não só o cometido contra a segurança interna, como o praticado contra a segurança externa do Estado, a caracterizarem, ambas as hipóteses, a excludente de concessão de extradição (...).”²⁰³

Extradição e crime político III.

“Não havendo a Constituição definido o crime político, ao Supremo cabe, em face da conceituação da legislação ordinária vigente, dizer se os delitos pelos quais se pede a extradição, constituem infração de natureza política ou não, tendo em vista o sistema da principalidade ou da preponderância.”²⁰⁴

202. STF, Ext 1.008, Rel. p/ o ac. Min. Sepúlveda Pertence, J em 21-3-07, DJ de 17-8-07

203. STF, Ext 700-QO, Rel. Min. Octavio Gallotti, J em 4-3-98, DJ de 5-11-99

204. STF, Ext 615, Rel. Min. Paulo Brossard, J em 19-10-94, DJ de 5-12-94

9.35 O DEVIDO PROCESSO LEGAL

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

O devido processo legal brasileiro se apoia na cláusula do due process of law norte-americano e pode ser analisado em seu duplo sentido: processual e material (ou substantivo).

No seu sentido processual pode ser considerado o núcleo de todos os direitos processuais; é a ideia de paridade de condições para que as partes possam defender os seus próprios interesses. É marcado, por exemplo, pela assistência técnica do advogado, pela possibilidade de apresentação de provas – com vedação às ilícitas, pelo princípio do juiz natural, bem como pelo exercício do contraditório e ampla defesa.

Ampla defesa e contraditório são dois importantes princípios que integram, portanto, o devido processo legal. Entretanto, não são expressões sinônimas. A ampla defesa deve ser analisada à luz do polo passivo da relação processual, é uma proteção daquele contra quem se postula no processo. Se há o direito de ação, deve haver também o direito de defesa. O contraditório impõe de um lado a necessidade de que a pessoa seja informada acerca da prática de alguma pretensão e a possibilidade de reação da outra parte quanto aos atos desfavoráveis, pois, como o processo se desenvolve em ambiente dialético, o juiz irá decidir depois de sopesar os argumentos de ambas as partes.

Do sentido material do devido processo legal nasce o princípio da razoabilidade (já estudado em capítulo próprio), pelo qual o intérprete deve procurar buscar a aplicação da norma fundado no bom senso, no equilíbrio presente, na inteligência do homem comum, somente sacrificando um direito quando for a única forma de salvaguardar um bem maior.

O devido processo legal deve ser obedecido nos processos judiciais e administrativos, mas não se aplica em sede de inquérito policial, tendo em vista a natureza inquisitiva do procedimento administrativo.

Súmula Vinculante nº 3: *Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.*

Súmula Vinculante nº 5: *A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.*

Devido processo legal e inversão da ordem na sustentação oral.

*“Ação penal. Recurso. Apelação exclusiva do Ministério Público. Sustentações orais. Inversão na ordem. Inadmissibilidade. Sustentação oral da defesa após a do representante do Ministério Público. Provimento ao recurso. Condenação do réu. Ofensa às regras do contraditório e da ampla defesa, elementares do devido processo legal. Nulidade reconhecida. HC concedido. Precedente. (...). No processo criminal, a sustentação oral do representante do Ministério Público, sobretudo quando seja recorrente único, deve sempre preceder à da defesa, sob pena de nulidade do julgamento”.*²⁰⁵

Devido processo legal e advogado suspenso pela OAB.

“Por considerar violada a cláusula do devido processo legal, a Turma deferiu habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática dos crimes de formação de quadrilha, sequestro e roubo qualificado cujas alegações finais foram apresentadas por advogada comprovadamente suspensa por ato disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. Enfatizando que o ato fora subscrito por quem não estava legalmente habilitado a tanto, entendeu-se, na espécie, que a peça oferecida, quanto ao seu conteúdo material, seria superficial, genérica e inconsistente, o que violaria o direito à defesa plena, efetiva e real que assiste a qualquer réu. (...) HC deferido para invalidar a condenação penal decretada contra o paciente, declarando a nulidade dos atos processuais,

205. STF, HC 87.926, Rel. Min. Cezar Peluso, J em 20-2-08, DJ 25-4-08

a partir das alegações finais, inclusive, e determinar, desde que ainda não consumada a prescrição penal, a renovação dos atos e termos processuais."²⁰⁶

Devido processo legal e interrogatório mediante videoconferência.

"Ação penal. Ato processual. Interrogatório. Realização mediante videoconferência. Inadmissibilidade. Forma singular não prevista no ordenamento jurídico. Ofensa a cláusulas do justo processo da lei (due process of law). Limitação ao exercício da ampla defesa, compreendidas a autodefesa e a defesa técnica. Insulto às regras ordinárias do local de realização dos atos processuais penais e às garantias constitucionais da igualdade e da publicidade. Falta, ademais, de citação do réu preso, apenas instado a comparecer à sala da cadeia pública, no dia do interrogatório. Forma do ato determinada sem motivação alguma. Nulidade processual caracterizada. HC concedido para renovação do processo desde o interrogatório, inclusive. (...) Enquanto modalidade de ato processual não prevista no ordenamento jurídico vigente, é absolutamente nulo o interrogatório penal realizado mediante videoconferência, sobretudo quando tal forma é determinada sem motivação alguma, nem citação do réu."²⁰⁷

Devido processo legal nas relações privadas

"Cooperativa — Exclusão de associado — Caráter punitivo — Devido processo legal. Na hipótese de exclusão de associado decorrente de conduta contrária aos estatutos, impõe-se a observância ao devido processo legal, viabilizado o exercício amplo da defesa. Simples desafio do associado à assembleia geral, no que toca à exclusão, não é de molde a atrair adoção de processo sumário. Observância obrigatória do próprio estatuto da cooperativa."²⁰⁸

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

206. STF, HC 85.717, Rel. Min. Celso de Mello, J em 9-10-07, Informativo 483.

207. STF, HC 88.914, Rel. Min. Cezar Peluso, J em 14-8-07, DJ de 5-10-07

208. STF, RE 158.215, Rel. Min. Marco Aurélio, J em 30-4-96, DJ de 7-6-96

A vedação à utilização de provas ilícitas é um dos corolários do devido processo legal, pois, ainda que o processo busque atingir a verdade real, essa missão deve ser realizada à luz das normas presentes no ordenamento jurídico, em respeito aos direitos fundamentais das partes envolvidas.

Com isso, é possível se afirmar que qualquer prova cuja obtenção, pelo Poder Público, derive de transgressão a cláusulas de ordem constitucional, seja violação de direito material ou do direito processual, poderá acarretar a nulidade do processo, em nome da defesa do devido processo legal.

Pelo Supremo Tribunal Federal as provas ilícitas e aquelas outras que dela derivarem devem ser desentranhadas do processo, sob pena de nulidade. Pela “Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada”, ou “The fruit of the poisonous tree” (de criação norte-americana), considera-se também inválida a prova derivada da ilícita, pois a ilicitude se transmite e as provas obtidas também serão imprestáveis como são as originárias.

Imperioso destacar que o STF entende que o fato de ter prova ilícita no processo não faz com que seja invalidado todo o processo. Se uma decisão se baseia em provas lícitas e ilícitas deverão ser afastadas as provas ilícitas a fim de se verificar se as provas lícitas são suficientes para a manutenção da decisão e, neste caso, não haverá nulidade do processo.

Em nome do princípio da proporcionalidade, é pacífico na doutrina e jurisprudência a admissibilidade de prova ilícita obtida em favor do réu em processo penal quando for o único meio de comprovar sua inocência e ainda quando a prova for apresentada em legítima defesa.

Prova ilícita e legítima defesa.

“Utilização de gravação de conversa telefônica feita por terceiro com a autorização de um dos interlocutores sem o conhecimento do outro quando há, para essa utilização, excludente da antijuridicidade. Afastada a ilicitude de tal conduta — a de, por legítima defesa, fazer gravar e divulgar conversa telefônica ainda que não haja o conhecimento do terceiro que está praticando crime —, é ela, por via de consequência, lícita e, também consequentemente, essa gravação não pode ser tida como prova ilícita, para invocar-se o artigo 5º, LVI, da Constituição com fundamento em que houve violação da intimidade (art. 5º, X, da Carta Magna).”²⁰⁹

209. STF, HC. 74.678, Rel. Min. Moreira Alves, J em 10-6-97, DJ de 15-8-97

Prova ilícita e legítima defesa:

*"Habeas corpus. Prova. Litude. Gravação de telefonema por interlocutor. É lícita a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, ou com sua autorização, sem ciência do outro, quando há investida criminosa deste último. É inconsistente e fere o senso comum falar-se em violação do direito à privacidade quando interlocutor grava diálogo com sequestradores, estelionatários ou qualquer tipo de chantagista. Ordem indeferida."*²¹⁰

Interceptação telefônica e prova ilícita:

*Autorização judicial deferida anteriormente à Lei n. 9.296/96, que regulamentou o inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal. Nulidade da ação penal, por fundar-se exclusivamente em conversas obtidas mediante quebra dos sigilos telefônicos dos pacientes."*²¹¹

Prova ilícita por derivação I:

*"Fruits of the poisonous tree. (...) Assentou, ainda, que a ilicitude da interceptação telefônica — à falta da lei que, nos termos do referido dispositivo, venha a discipliná-la e viabilizá-la — contamina outros elementos probatórios eventualmente coligidos, oriundos, direta ou indiretamente, das informações obtidas na escuta."*²¹²

Prova Ilícita por derivação II:

*"Prova ilícita. Escuta telefônica. Fruits of the poisonous tree. Não-acolhimento. Não cabe anular-se a decisão condenatória com base na alegação de haver a prisão em flagrante resultado de informação obtida por meio de censura telefônica deferida judicialmente. É que a interceptação telefônica — prova tida por ilícita até a edição da Lei n. 9.296, de 24-7-96, e que contaminava as demais provas que dela se originavam — não foi a prova exclusiva que desencadeou o procedimento penal, mas somente veio a corroborar as outras lícitamente obtidas pela equipe de investigação policial."*²¹³

210. STF, HC. 75.338, Rel. Min. Nelson Jobim, J em 11-3-98, DJ de 25-9-98

211. STF, HC 81.154, Rel. Min. Maurício Corrêa, J em 2-10-01, DJ de 19-12-01.

212. STF, HC 73.351, Rel. Min. Ilmar Galvão, J em 9-5-96, DJ de 19-3-99

213. STF, HC 74.599, Rel. Min. Ilmar Galvão, J em 3-12-96, DJ de 7-2-97

9.36 PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

O princípio da presunção de inocência está expresso neste dispositivo. De acordo com essa presunção *iuris tantum*, a Constituição de 88 determina que somente será considerado culpado o condenado por sentença irrecorrível. Até aí o acusado tem o direito de não ostentar o status de condenado. A situação de dúvida deve ser observada até o fim para a proteção do homem.

Esse princípio, também denominado como da não culpabilidade, consagra uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados definitivamente por sentença do Poder Judiciário.

De acordo com a jurisprudência, o princípio em tela não conflita com as eventuais prisões processuais que podem ser determinadas, de acordo com a lei, no curso do processo. Diversamente, porém, o lançamento do acusado no rol dos culpados, que viola a não culpabilidade do acusado.

O dispositivo sob nossa atenção gera efeitos também na seara dos direitos políticos, na forma do art. 15, III, da CRFB/88, quando o texto trata da suspensão desses direitos, desde que haja uma sentença condenatória transitada em julgado. Até esse momento, portanto, o acusado, mesmo preso, conservará os seus direitos de eleitor.

Em decisão recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que o artigo 283 do CPP²¹⁴ não impede o início da execução da pena após condenação em segunda instância. O Ministro Roberto Barroso defendeu a legitimidade da execução provisória após decisão de segundo grau e antes do trânsito em julgado para garantir a efetividade do direito penal e dos bens jurídicos por ele tutelados. No seu entendimento, a presunção de inocência é princípio, e não regra, e pode, nessa condição, ser ponderada com outros princípios e valores constitucionais que têm a mesma estatura.

214. * Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.

“A Constituição Federal abriga valores contrapostos, que entram em tensão, como o direito à liberdade e a pretensão punitiva do estado”, afirmou. “A presunção da inocência é ponderada e ponderável em outros valores, como a efetividade do sistema penal, instrumento que protege a vida das pessoas para que não sejam mortas, a integridade das pessoas para que não sejam agredidas, seu patrimônio para que não sejam roubadas”²¹⁵

Súmula nº 9 do STJ: *A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.*

Presunção de inocência e prisão cautelar

“Não há, em tese, incompatibilidade entre as normas infralegais que preveem a possibilidade de prisão anterior ao trânsito em julgado da demanda criminal e o princípio da presunção de inocência. Tema pendente de apreciação do Plenário do STF, que ainda não se pronunciou definitivamente sobre a obrigatoriedade de recolher-se à prisão para apelar. A legalidade da prisão deve ser examinada caso a caso.”²¹⁶

Presunção de inocência e concurso público

“(…) Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. (...) Agravo regimental improvido.”²¹⁷

Presunção de inocência e registro de candidatos

“O Tribunal, por maioria, julgou improcedente arguição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, em que questionava a validade constitucional das interpretações

215 STF, ADC's 43 e 44, O Tribunal, por maioria, indeferiu a cautelar, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, e, em parte, o Ministro Dias Toffoli. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 05.10.2016.

216. STF, HC 89.175, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J em 6-2-07, DJ de 23-3-07

217. STF, RE 559.135-AgrR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J em 20-5-08, DJ de 13-6-08

emanadas do Tribunal Superior Eleitoral - TSE em tema de inelegibilidade fundada na vida pregressa dos candidatos, bem como sustentava, por incompatibilidade com o § 9º do art. 14 da CRFB/88, na redação que lhe deu a ECR n. 4/94 (...), a não recepção de certos textos normativos inscritos na Lei Complementar n. 64/90, nos pontos em que exige o trânsito em julgado para efeito de reconhecimento de inelegibilidade e em que acolhe ressalva descaracterizadora de hipótese de inelegibilidade (...). No mérito, entendeu-se que a pretensão deduzida pela AMB não poderia ser acolhida, haja vista que desautorizada (...) por cláusulas instituídas pela própria Constituição da República e que consagram, em favor da pessoa, o direito fundamental à presunção de inocência (...). Rejeitou-se a pretensão deduzida pela arguente no que respeita às alíneas d, e, e h do inciso I do art. 1º, e ao art. 15, todos da LC n. 64/90, ao fundamento de que o postulado consagrador da garantia de inocência irradia os seus efeitos para além dos limites dos processos penais de natureza condenatória, impedindo, desse modo, que situações processuais ainda não definidas por sentenças transitadas em julgado provoquem, em decorrência das exigências de probidade administrativa e de moralidade a que se refere o § 9º do art. 14 da CRFB/88, na redação dada pela ECR n. 4/94, a inelegibilidade dos cidadãos ou obstem candidaturas para mandatos eletivos (...). Concluiu-se, em suma, que o STF e os órgãos integrantes da justiça eleitoral não podem agir abusivamente, nem fora dos limites previamente delineados nas leis e na CRFB/88, e que, em consequência dessas limitações, o Judiciário não dispõe de qualquer poder para aferir com a inelegibilidade quem inelegível não é. Reconheceu-se que, no Estado Democrático de Direito, os poderes do Estado encontram-se juridicamente limitados em face dos direitos e garantias reconhecidos ao cidadão e que, em tal contexto, o Estado não pode, por meio de resposta jurisdicional que usurpe poderes constitucionalmente reconhecidos ao Legislativo, agir de maneira abusiva para, em transgressão inaceitável aos postulados da não culpabilidade, do devido processo, da divisão funcional do poder, e da proporcionalidade, fixar normas ou impor critérios

*que culminem por estabelecer restrições absolutamente incompatíveis com essas diretrizes fundamentais.*²¹⁸

9.37 IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

LVIII - o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

A pessoa que já possua documento oficial de identificação civil tem o direito de não ser submetida à nova identificação em sede de apuração criminal, por esta ser constrangedora e violadora da dignidade humana. A norma constitucional, entretanto, excepciona a regra geral da não identificação criminal daquele devidamente identificado civilmente, nas hipóteses definidas em lei.

Para o implemento dessas situações, foi editada a Lei nº 10.054/2000, que assim dispõe:

“Art. 3º O civilmente identificado por documento original não será submetido à identificação criminal, exceto quando:

I – estiver indiciado ou acusado pela prática de homicídio doloso, crimes contra o patrimônio praticados mediante violência ou grave ameaça, crime de receptação qualificada, crimes contra a liberdade sexual ou crime de falsificação de documento público;

II – houver fundada suspeita de falsificação ou adulteração do documento de identidade;

III – o estado de conservação ou a distância temporal da expedição de documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais;

IV – constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações;

V – houver registro de extravio do documento de identidade;

VI – o indiciado ou acusado não comprovar, em quarenta e oito horas, sua identificação civil.

218. ADPF 144, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 6-8-08, Informativo 514

9.38 AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA

LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

Pela ação penal provoca-se a jurisdição penal onde se imputa prática criminosa a alguém. A ação será pública, se for de iniciativa do Ministério Público; incondicionada na hipótese de atuar de ofício e, condicionada, caso dependa de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. A ação privada dependerá da provocação da tutela jurisdicional por parte do próprio ofendido, ou de quem a represente nos termos da lei.

Entretanto, se no prazo legal (art. 46, CPP) o titular da ação pública não tomar uma das seguintes providências: oferecer a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou requisitar novas diligências, caberá a apresentação da ação penal privada subsidiária da pública.

9.39 PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

A publicidade é um princípio que orienta a regra da transparência que deverá nortear toda a tarefa da administração pública e a prestação de serviços públicos. As decisões não decorrem da vontade unilateral daquele que a edita; ela deve refletir a adesão ao direito e a fundamentação. Por isso, é essencial porque ela propicia a faculdade das partes, da sociedade e de outros órgãos jurisdicionais controlar o conteúdo de seus julgados, na forma do art. 93, IX, da CRFB/88.

Os atos judiciais são públicos, como regra. De acordo com o dispositivo, somente a lei pode dispor sobre a prática de atos judiciais sob sigilo, nos casos que a intimidade dos envolvidos ou o interesse social recomendarem, como já está presente nas leis processuais que já agasalham essa salvaguarda nos processos que dizem respeito a relações familiares e filiação, onde a questão da intimidade se faz sempre presente.

9.40 A PRISÃO

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por

ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;

LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;

A Constituição consagra a liberdade como regra (inciso XV) e a prisão como exceção, que só poderá ser determinada: em caso de flagrante delito; ou por ordem escrita de autoridade judiciária competente, obedecendo-se neste caso ao princípio da reserva de jurisdição. Já a prisão em flagrante delito, na forma do art. 301 do CPP, pode ser executada por qualquer pessoa do povo (faculdade) e pelas autoridades policiais (que tem o dever jurídico de realizar a prisão).

O inciso trata ainda da prisão administrativa disciplinar, no âmbito das organizações militares, que deverá também ser decretada pela autoridade competente, em decisão devidamente fundamentada.

A identificação da autoridade ou pessoa responsável pela execução da prisão, bem como a necessidade de comunicação da prisão ao juiz, a família do preso e ao advogado, são medidas salutares contra o cometimento de arbítrios e abusos de poder.

De mais a mais, é dever do juiz relaxar imediatamente a prisão considerada ilegal, assim considerada a que se afasta dos critérios da lei. Quando a prisão atender aos requisitos legais, a hipótese será de concessão de liberdade provisória e não de relaxamento de prisão, em face de prisões ilegais.

Sempre que alguém puder, deverá responder pelo processo penal em liberdade. Dois institutos são aplicados para a hipótese: a) a liberdade provisória: que assegura o poder da pessoa acusada permanecer solta enquanto houver decisão recorrível, ou seja, durante todo o transcurso do julgamento ninguém será levado à prisão se couber a liberdade provisória; b) a fiança: é instituto que garante à pessoa o direito de defender-se em

liberdade mediante uma caução real (um pagamento que funcionará como garantia de que a pessoa comparecerá a todos os atos processuais para os quais for comunicada).

Não comunicação da prisão e trancamento da ação penal.

“Descumprimento do inciso LXII do art. 5º da Constituição: circunstância que não compromete a materialidade dos delitos e sua autoria, nem autoriza o trancamento da ação penal, podendo ensinar a responsabilidade das autoridades envolvidas.”²¹⁹

Não comunicação da prisão por ato voluntário do preso.

“Não ocorre descumprimento do inciso LXII do art. 5º da Constituição Federal, quando o preso, voluntariamente, não indica pessoa a ser comunicada da sua prisão. Encontrando-se o paciente cumprindo pena por condenação definitiva, é irrelevante eventual nulidade formal que tenha ocorrido no auto de prisão em flagrante, eis que se encontra preso por outro título.”²²⁰

9.41 DIREITO AO SILÊNCIO

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

Em harmonia com o princípio da ampla defesa, garante-se ao preso o direito ao silêncio. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo e, às vezes, silenciar pode ser uma boa estratégia de defesa. Além do que, seu silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor, não valendo aqui a frase popularmente conhecida de que: “quem cala consente”.

A jurisprudência considera que além do direito ao silêncio propriamente dito, o preso tem direito fundamental a ser informado de que possui tal direito e a ausência do aviso poderá gerar também a nulidade e a desconsideração de todas as informações incriminatórias obtidas no depoimento do acusado.

219. STF, HC 68.503, Rel. Min. Célio Borja, J em 19-3-91, DJ de 29-5-92

220. STF, HC 69.630, Rel. Min. Paulo Brossard, J em 20- 10-92, DJ de 4-12-92

Esse privilégio contra a autoincriminação deverá ser respeitado inclusive perante as Comissões Parlamentares de Inquérito, segundo orientação jurisprudencial já assentada.

Inobservância do dever de informação do direito ao silêncio.

“O direito à informação da faculdade de manter-se silente ganhou dignidade constitucional, porque instrumento insubstituível da eficácia real da vetusta garantia contra a autoincriminação que a persistência planetária dos abusos policiais não deixa perder atualidade. Em princípio, ao invés de constituir desprezível irregularidade, a omissão do dever de informação ao preso dos seus direitos, no momento adequado, gera efetivamente a nulidade e impõe a desconsideração de todas as informações incriminatórias dele anteriormente obtidas, assim como das provas delas derivadas. Mas, em matéria de direito ao silêncio e à informação oportuna dele, a apuração do gravame há de fazer-se a partir do comportamento do réu e da orientação de sua defesa no processo: o direito à informação oportuna da faculdade de permanecer calado visa a assegurar ao acusado a livre opção entre o silêncio — que faz recair sobre a acusação todo o ônus da prova do crime e de sua responsabilidade — e a intervenção ativa, quando oferece versão dos fatos e se propõe a prová-la: a opção pela intervenção ativa implica abdicação do direito a manter-se calado e das consequências da falta de informação oportuna a respeito.”²²¹

Direito ao Silêncio e CPI.

“O privilégio contra a autoincriminação — que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito — traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição

221. STF, HC 78.708, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, J em 9-3-99, DJ de 16-4-99

à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio — enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) — impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado.”²²².

9.42 A PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

Esse importante direito fundamental se relaciona à necessária separação do corpo (e liberdade) do devedor do seu patrimônio. Ninguém deverá pagar com a própria liberdade o que o seu bolso não conseguiu sustentar. Se a própria prisão em razão de condutas tipificadas na legislação penal já é medida de exceção, ainda mais restrita deverá ser a possibilidade de prisão civil por dívida.

Ainda assim, o dispositivo constitucional em tela permite esta modalidade de prisão, imposta como coerção para o cumprimento de obrigação legal, na seguinte hipótese:

- No caso de descumprimento voluntário de obrigação alimentar, ou seja, quando a pessoa podendo, se nega a pagar alimentos a seus dependentes.

Neste caso, portanto, só cabe a prisão se a dívida for inescusável, justamente por se tratar de meio de coerção e não de pena, e pelo mesmo motivo ele deve ser solto ao pagar a dívida. A restrição ao direito fundamental à liberdade justifica-se pela promoção de outro importante direito fundamental: a subsistência de quem depende dos alimentos de outra pessoa para viver.

222. STF, HC 79.812, Rel. Min. Celso de Mello, J em 8-11-00, DJ de 16-02-01

- No caso do depositário infiel – assim considerado aquela pessoa que recebe um bem para manter em depósito para posterior restituição ao proprietário e, no momento da devolução, descumpre este dever desviando ou consumindo o bem – o STF entendeu não ser mais cabível a sua prisão.

Foi com a ratificação do Pacto de San José da Costa Rica em 1992²²³ - que só considera como válida a prisão civil do devedor de alimentos – que a prisão do depositário infiel entrou em debate, tendo o STF decidido, quando do julgamento do RE 466.343, que tal Pacto Internacional sobre direitos humanos, que não foi incorporado na forma do art. 5º, § 3º da CRFB/88, teria natureza de norma “supralegal”, paralisando, então, a eficácia de todo o ordenamento jurídico infraconstitucional que o contrarie.

Sobre o assunto, o STF ainda editou a Súmula Vinculante 25:

“É ilícita a prisão civil do depositário infiel qualquer que seja a modalidade do depósito.”

223. Aprovado pelo Brasil pelo Decreto Legislativo nº 27, de 25-9-1992 e promulgado pelo Decreto nº 678, de 6-11-1992.

CAPÍTULO 10

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS

10.1 REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS

Os remédios constitucionais são garantias fundamentais que visam defender os inúmeros direitos previstos no ordenamento jurídico. Dividem-se em: Remédios constitucionais administrativos e judiciais.

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVOS (art. 5º, XXXIV): O Direito de petição e o Direito de obtenção de certidões são garantias constitucionais para o acesso à informação e também são considerados pela doutrina como remédios constitucionais de natureza administrativa.

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS JUDICIAIS: São instrumentos judiciais de defesa dos direitos fundamentais. São remédios constitucionais judiciais o habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança e ação popular. Importante destacar que em sede de remédios constitucionais não se aplica o princípio da fungibilidade, ou seja, não se pode utilizar um remédio no lugar do outro.

10.2 HABEAS CORPUS

Historicamente, foi a primeira garantia de direito fundamental concedida pelo Rei João Sem Terra (Inglaterra), na Magna Carta de 1215. No Brasil, Dom Pedro I editou em 1821 um Alvará, consagrando a liberdade de locomoção. Em 1830, a garantia passou a ser chamada de Habeas Corpus (“tomes o corpo”) e foi consagrada constitucionalmente no Brasil a partir de 1891.

- a) **Base legal:** art. 5º, LXVIII, CRFB/88, art. 142, § 2º, CRFB/88; arts. 647/667, CPP.
- b) **Conceito:** Remédio constitucional dirigido à tutela da liberdade de locomoção, ameaçada ou lesada em decorrência de violência ou coação eivada de ilegalidade – ato comissivo ou omissivo contrário à lei - ou abuso de poder. Também é utilizado para trancar um inquérito policial ou uma ação penal quando não está presente um dos elementos da persecução estatal. Ex.: conduta é atípica ou fato já está prescrito.

- c) **Suporte probatório mínimo:** A ação de habeas corpus demanda prova pré-constituída, ou seja, deve estar de plano demonstrada a privação da liberdade ou o risco de privação da liberdade. A prova no HC em relação à privação de liberdade é pré-constituída. A questão de mérito a ser enfrentada no habeas corpus é se a restrição ao direito de ir e vir do paciente decorreu de conduta ilegal ou abusiva.
- d) **Espécies:**
- **HC PREVENTIVO:** para evitar a consumação da lesão, muito comum em sede de CPI. O pedido é o Salvo Conduto.
 - **HC REPRESSIVO OU LIBERATÓRIO:** para fazer cessar tal coação. O pedido é o Alvará de Soltura.
- e) **Legitimidade ativa:** Qualquer pessoa natural (brasileiro, estrangeiro, analfabeto, menor de idade) ou pessoa jurídica pode ser IMPETRANTE. A pessoa beneficiada é chamada de PACIENTE, que necessariamente deve ser pessoa natural. Não se admite HC em favor de pessoas jurídicas ou de animais (segundo entendimento dominante na jurisprudência).
- f) **Capacidade postulatória:** É o único remédio constitucional judicial que não precisa da assistência do advogado. A impetração de HC não está listada na Lei 8.906/94 como atividade privativa de advogado.
- g) **Polo passivo:** A autoridade coatora é normalmente um agente do Estado, como Juízes, Desembargadores, autoridades policiais. Entretanto, a jurisprudência permite que particulares também possam estar no polo passivo da ação, como por exemplo: diretores de clínicas médicas, de abrigos, asilos etc.
- h) **Competência:** A competência para processar e julgar o habeas corpus é definida tanto pela autoridade coatora como pela qualidade do paciente.
- i) **Liminar:** como o HC é uma ação impugnativa autônoma, admite concessão de liminar. O fundamento está implícito no art. 654 §2º do CPP. Se os juízes podem conceder ordem de habeas corpus de ofício, também poderão fazê-lo de forma liminar, quando provocados. É a

aplicação da teoria dos poderes implícitos.

j) Gratuidade: é uma ação gratuita, de acordo com o art. 5º, LXXVII.

k) Súmulas do STF:

Súmula nº 693 - *Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada.*

Súmula nº 695 - *Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade.*

10.3 MANDADO DE SEGURANÇA

Constitucionalmente, o Mandado de Segurança individual foi acolhido pelo direito brasileiro em 1934. A sua modalidade coletiva só recebeu amparo constitucional em 1988.

a) Base Legal: Art. 5º, LXIX e LXX, Lei nº 12.016/09.

b) Natureza jurídica: O MS é uma ação civil de procedimento especial, com status de garantia constitucional. É cláusula pétrea, protegido pelo art. 60, §4º, IV da CRFB/88, motivo pelo qual não pode o legislador infraconstitucional erradicar o MS.

c) Conceito: Remédio constitucional dirigido à tutela de direito individual e coletivo, líquido e certo, não amparável por HC ou HD, ameaçado ou lesado em decorrência de ato de autoridade pública ou agente delegado, eivado de ilegalidade ou abuso de poder.

d) Espécies e Legitimidade Ativa:

- **MS Individual (art. 5º, LXIX, CRFB/88):** O Impetrante é o titular do direito líquido e certo, tais como: a pessoa natural, os órgãos públicos despersonalizados, as universalidades patrimoniais, a pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, domiciliada no Brasil ou no exterior.

- **MS Coletivo (art. 5º, LXX, CRFB/88):** O Mandado de Segurança Coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional (ainda que o partido esteja representado em apenas uma das Casas Legislativas), organização sindical, entidade de classe e associações (preenchidas as condições previstas no art. 5º, LXX).

e) Modalidades:

- **MS PREVENTIVO** – Quando somente há ameaça de lesão.
- **MS REPRESSIVO** – Quando a lesão já ocorreu (neste caso deve ser observado o prazo de 120 dias para a sua impetração).

- f) Condições específicas da ação:** Para que se possa valer do MS, é necessário atender os requisitos abaixo:

Não ser caso de habeas corpus ou habeas data – O que demonstra o caráter residual do MS.

Direito líquido e certo: A expressão “direito líquido e certo” é criticada pela doutrina, já que a expressão está ligada aos fatos nos quais se ampara a pretensão, e não ao direito invocado. A expressão quer dizer que o pedido deve estar amparado em fatos demonstrados de plano, através de prova pré-constituída.

ATENÇÃO

Importante! A complexidade da matéria jurídica não impede a utilização do MS, nos termos da súmula 625 do STF. Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.

- **Ato coator** – É ato ou omissão de autoridade pública (ato praticado ou omitido por pessoa investida de parcela de poder público), eivado de ilegalidade ou abuso de poder. As expressões “ilegalidade ou abuso de poder” estão previstas na CRFB/88, no art. 5º, LXIX, mas é certo que ilegalidade é gênero, e abuso de poder é espécie. Isso porque os elementos do ato administrativo (competência, finalidade, forma, motivo e objeto) devem todos ser respeitados, sob pena de ilegalidade, e abuso de poder pode ser vício de competência (excesso de poder) ou finalidade (desvio de finalidade).

Importante! Não é possível a utilização do MS preventivo para questionar lei em tese (súmula 266 do STF). O impetrante estaria, indiretamente, formulando uma consulta ao Poder Judiciário.

Cuidado! A lei prevê expressamente casos em que não será possível se valer do MS. Prevê o art. 5º da lei 12.016/09 que

“Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III - de decisão judicial transitada em julgado.”

- **Prazo:** O prazo de 120 dias, previsto no art. 23 da lei 12.016/09 tem natureza decadencial e é contado da data em que o Impetrante toma ciência do ato ilegal. Por ser decadencial, esse prazo não se interrompe ou suspende, nem mesmo por pedido de reconsideração formulado na via administrativa (Súmula 430 STF).

- a) **Polo passivo:** Há controvérsia na doutrina sobre quem é efetivamente considerado réu no mandado de segurança, a autoridade coatora ou a pessoa jurídica a cujo quadro funcional pertence a autoridade coatora. Adotamos a posição de Hely Lopes Meireles, que sustenta ser a autoridade coatora ré no MS. Assim, irá figurar no polo passivo a autoridade coatora ou quem lhe faça às vezes, como é o caso do agente delegado (art. 175, CRFB/88) no exercício da função pública. Há reiteradas decisões judiciais entendendo caber MS contra ato de diretor de estabelecimento particular de ensino.

A autoridade coatora deve ser quem praticou o ato ou quem tenha poderes para corrigir o ato. O art. 6º §3º da Lei do MS prevê que “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

b) Competência: A competência para o julgamento do MS será definida em função da autoridade coatora. Existem regras de competência na CRFB/88 e também nas Constituições Estaduais.

c) Liminar: É possível a concessão da liminar no MS. A liminar irá perder seus efeitos com a prolação da sentença, qualquer que seja o fundamento da sentença. Quando a liminar é concedida e a segurança é denegada, não subsiste o provimento liminar, não havendo necessidade de revogação expressa da liminar. A tutela de cognição sumária não prevalece sobre a tutela de cognição exauriente. Os efeitos da sentença denegatória também retroagem, criando uma ficção de que jamais teria sido deferida a liminar. Então a sentença fulmina a liminar desde o seu nascedouro. É o que prevê a súmula 405 STF.

Cuidado! O art. 7º §2º prevê casos em que não é possível a concessão de liminar em MS. São quatro as hipóteses:

- compensação de créditos tributários;
- entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior;
- reclassificação ou equiparação de servidores públicos;
- concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

a) Intervenção obrigatória do Ministério Público: Por força do art. 12 da Lei 12.016/09.

b) Recursos:

- Da decisão que concede ou denega a liminar: caberá agravo de instrumento (art. 7º §1º);
- Da sentença concessiva ou denegatória: caberá apelação (art. 14);
- Do acórdão denegatório da segurança proferido em única instância pelos Tribunais (TRF e TJ), cabe Recurso Ordinário Constitucional ao STJ;
- Do acórdão denegatório da segurança proferido em única instância pelos Tribunais Superiores (STJ, STM, TSE e TST), cabe Recurso Ordinário Constitucional ao STF;

- Do acórdão concessivo da segurança em única ou última instância pelos Tribunais (TRF e TJ), caberá RE ou RESP, desde que preenchidos os requisitos específicos dos recursos excepcionais.

c) Súmulas do STF:

Súmula nº 625 - *Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.*

Súmula nº 629 - *A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.*

Súmula nº 630 - *A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.*

Súmula nº 632 - *É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança.*

Súmula nº 266 - *Não cabe Mandado de Segurança contra lei em tese.*

Súmula nº 269 - *O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.*

Súmula nº 268 - *Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.*

Súmula nº 101 - *O mandado de segurança não substitui a ação popular.*

10.4 HABEAS DATA

Apesar de constar da Constituição de Portugal de 1976 e da Constituição da Espanha de 1978, no Brasil, o habeas data só foi consagrado constitucionalmente em 1988.

- a) Base legal: Art. 5º, LXXII; Lei nº 9.507/97.**

- b) **Conceito:** Remédio constitucional sobre procedimento especial, dirigido ao conhecimento ou retificação, como também, anotação, contestação ou explicação de dados pessoais constantes de bancos de dados ou, assentamentos de entidades governamentais ou de caráter público.
- c) **Distinção entre o art. 5º, LXXII e o art. 5º XXXIII:** o direito à informação, previsto no inciso XXXIII é mais amplo do que o direito tutelado no inciso LXXII. No HD, a informação requerida tem natureza pessoal, ou seja, é sempre referente à pessoa do Impetrante.
- d) **Gratuidade:** A ação de HD é gratuita, de acordo com o art. 5º, LXXVII. No entanto, como qualquer outra ação judicial, é necessário indicar valor da causa na petição inicial. A petição inicial deve ser subscrita por advogado.

Hipóteses de cabimento:

- e) A CRFB/88 prevê duas situações em que será possível a utilização do HD – conhecer dados pessoais e retificar dados pessoais equivocados, constantes de bancos de dados públicos. A lei 9507/97 prevê mais uma hipótese de cabimento, qual seja, de complementar informações constantes de tais bancos de dados.
- f) Dados pessoais são aqueles relacionados ao nome, saúde, escolaridade, trabalho, estado civil, etc. Não confundir dados pessoais com dados públicos de interesse particular. Ex.: informação acerca de data de término da obra na rua da residência do sujeito. Dados públicos que não sejam de natureza pessoal devem ser objeto de mandado de segurança, se for o caso.
- g) Banco de dados - as informações perseguidas pelo Impetrante podem estar contidas em banco de dados público, ou seja, o banco de dados administrado pela própria administração pública, direta ou indireta, ou em banco de dados privado, de caráter público, que são os bancos de dados administrados por pessoas jurídicas de direito privado, contendo informações para socializar com terceiros. O conceito de banco de dados público está previsto no art. 1º §1º da lei 9507/97.
- h) O STJ entende que não é possível cumular os pedidos de conhecimento e retificação de dados em um só habeas data. Sustenta o Tribunal que só tem direito de retificar os dados o sujeito que aponta a incorreção nos dados, o que pressupõe o conhecimento prévio de tais dados. No entanto, essa posição é criticada pela doutrina, por conta do princípio

da economia processual.

- i) **Polo ativo:** Como é uma ação personalíssima, apenas o titular do dado (legitimação ordinária), pessoa natural ou jurídica pode impetrar a ação. O STF admite, no entanto, que no caso de sucessão causa mortis, os herdeiros legítimos e necessários do falecido possam requerer informações pessoais do de cujus.
- j) **Polo passivo:** Entidade governamental ou de caráter público (pessoa jurídica de direito privado que forneça dados a terceiros com caráter oneroso ou não). Ex.: SPC e SERASA.
- k) **Competência:** Para a fixação da competência para julgamento do HD é necessário perquirir quem é a pessoa responsável pela exibição das informações.
- l) **Necessidade de comprovar a recusa da informação:**

Súmula nº 2 STJ – *Não cabe o habeas data (CRFB/88, art. 5º, LXXII, “a”) se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa.*

A Lei 9507/97 trata da fase administrativa e também da fase judicial do habeas data. Os artigos 2º ao 4º devem ser analisados sobre o prisma da necessidade do remédio constitucional. Somente será necessária a impetração do HD quando o titular dos dados não puder obter os dados sem a intervenção do Poder Judiciário. Assim, deve ser demonstrado que foi requerida a exibição dos dados pessoais e que tal pretensão foi resistida em âmbito administrativo. Basta a recusa administrativa para configurar a necessidade do HD, não sendo necessário esgotar a via administrativa.

A Lei 9507/97 estabelece que o silêncio da autoridade também faz prova da recusa do dado, senão vejamos:

Art. 8, Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova:

I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão;

II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou

III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2º do art. 4º ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão.

-
- m) **Intervenção do Ministério Público:** Obrigatória, nos termos do art. 12 da Lei 9.507/97.
- n) **Tutela de Urgência:** Não há previsão expressa na lei. A doutrina, no entanto, admite a concessão de tutela antecipada com fundamento no art. 300 do CPC.

10.5 MANDADO DE INJUNÇÃO

O Mandado de Injunção foi criado pelo legislador constituinte em 1988, com o objetivo de tornar as normas da Constituição definidoras de direitos fundamentais plenamente exequíveis (art. 5º, §1º, CRFB/88).

- a) **Base legal:** Art. 5º, LXXI, CRFB/88 e Lei 13.300/2016.
- b) **Conceito:** É remédio constitucional de procedimento especial dirigido à tutela de direitos subjetivos constitucionais, cujo exercício esteja impedido pela ausência de norma reguladora.
- c) **Objeto:** Tutelar direito subjetivo constitucional previsto em norma de eficácia limitada, cuja ausência de norma regulamentadora impede o seu exercício. Normalmente é direito subjetivo próprio, exceto no MI coletivo.
- d) **Espécies:** MI individual e MI coletivo.

O mandado de injunção individual pode ser impetrado por pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas constitucionais.

Já na sua via coletiva, copiamos abaixo o art. 12, da Lei 13.300/2016:

Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido:

I - pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis;

II - por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária;

III - por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial;

IV - pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

e) Posição do STF quanto aos efeitos da decisão:

- **Posição não concretista:** de acordo com esse posicionamento (clássico), em nome da harmonia e separação entre os poderes (art. 2º) o Poder Judiciário não poderia suprir a omissão da norma faltante, tampouco determinar prazo para o legislador elaborar a lei, restando a sentença tendo efeito apenas de declarar a mora legislativa. Esta era a posição do STF, adotada como regra até o ano de 2007. A título de exemplo, ver os mandados de injunção nº 20 e 168.
- **Posição concretista individual:** Foi adotada quando o STF abordou o art. 40 §4º da CRFB/88, que trata da aposentadoria especial do servidor público que trabalha com atividade de “risco”, como policiais. A CRFB/88 prevê aposentadoria especial, cujos requisitos seriam definidos por LC, que não foi editada. Vários servidores ajuizaram MI individuais. O STF decidiu determinar, com efeito inter partes, a lei geral da previdência, para suprir a falha do legislador, enquanto não edita a LC específica. Ver os mandados de injunção nº 721 e 758.
- **Posição concretista geral:** A primeira delas foi adotada em 2007, quando o STF reuniu 3 MI coletivos que tratavam do direito de greve do servidor público. Decidiu o STF que, enquanto não fosse editada lei regulamentando o direito de greve do servidor público, deveria ser aplicada analogicamente a lei de greve da iniciativa privada. É concretista geral porque os efeitos foram erga omnes. Ver os mandados de injunção nº 670, 708 e 712.
- **Posição concretista intermediária:** O STF não aplica por analogia lei já existente, mas fixa prazo para o poder omissor legislar.

A lei 13.300/2016 estabelece que, reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para:

I - determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora;

II - estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado.

Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso I do caput quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma.

- f) Legitimidade passiva:** A legitimidade passiva no MI será formada pelo Poder, o órgão ou autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora.
- g) Intervenção do Ministério Público:** Obrigatória, por força do art. 7º, da lei 13.300/2016.
- h) Competência:** A competência para julgamento do MI leva em conta o órgão ou autoridade a quem cabia a edição da norma regulamentar.

10.6 AÇÃO POPULAR

A origem da ação popular está ligada à história do direito romano. Os jurisconsultos romanos diziam que se denomina ação popular aquela que ampara direito próprio do povo. O primeiro texto constitucional brasileiro que deu guarida à ação popular foi o de 1934.

Pela Lei 4.717/65, a ação popular prestava-se tão somente para anular o ato lesivo ao patrimônio público. A CRFB/88 ampliou o objeto (artigo 5º, LXXIII), passando a ser utilizada a AP também para defesa da moralidade administrativa e do meio ambiente.

- a) **Base Legal:** Art. 5º, LXXIII; Lei 4.717/65.
- b) **Conceito:** Remédio constitucional colocado à disposição de qualquer cidadão para a invalidação de ato ou contrato administrativo, ilegal, ilegítimo ou ilícito e lesivo ao patrimônio público, cultural, histórico ou ambiental.
- c) **Finalidade:** Declarar nulo o ato lesivo e condenar os responsáveis e os beneficiários ao ressarcimento. Não pode ter como pedido a declaração de inconstitucionalidade de lei e também não pode ser utilizada para questionar ato judicial.
- d) **Legitimidade ativa:** Cidadão brasileiro, que é, em regra, pessoa natural, no gozo de direitos políticos. Sobre o assunto, seguem abaixo informações relevantes:
 - A condição de cidadão deve ser demonstrada pela juntada do título de eleitor na forma do art. 1, parágrafo 3 da lei 4717/65.
 - Não podem propor ação popular, por não terem direitos políticos plenos: os inalistáveis (art. 14, p. 2) e os inalistados (os que deveriam se alistar mas não se alistaram).
 - Relativamente incapaz (entre 16 e 18 anos) pode ser autor sem estar assistido, de acordo com parte da doutrina, porque tem direitos políticos plenos.
 - Português equiparado, desde que esteja devidamente alistado, pode ajuizar ação popular.
 - Pessoa jurídica jamais poderá figurar no polo ativo (Súmula 365 STF).
 - É possível litisconsórcio facultativo entre mais de um cidadão. Ingresso no polo ativo após o ajuizamento da demanda será feito na forma de assistência litisconsorcial.
 - O Ministério Público não pode ajuizar a ação popular, mas pode assumir o polo ativo no caso de desistência pelo cidadão que propôs a AP ou no caso de inércia do mesmo.
- e) **Legitimidade passiva:** (1) pessoas públicas ou privadas e entidades mencionadas no artigo 1º da lei de ação popular; (2) autoridades, funcionários ou administradores que tiverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato; (3) aqueles que por omissão tiverem dado oportunidade à lesão e os beneficiários do ato.
 - Todos os beneficiários do ato ou contrato impugnado são litisconsortes necessários e a falta de citação é causa de nulidade absoluta do processo (STJ – Resp. 13493-0).

- O causador do dano pode ser admitido como assistente simples dos réus, de forma a viabilizar ação de regresso.
 - A pessoa jurídica de direito público ou privado que figurar no polo passivo poderá: (1) contestar a ação, se entender que o ato é lícito e que o pedido não tem fundamento; (2) silenciar e atuar ao lado do autor. Se assim optar, apesar de figurar no polo passivo, irá atuar como espécie de assistente simples do autor.
- f) Intervenção do Ministério Público:** Obrigatória, como custos legis. Poderá assumir o polo ativo da demanda:
- No caso de desistência pelo Autor;
 - No caso de inércia do Autor;
 - Na fase de execução, se no prazo de 60 dias a contar do trânsito em julgado, o Autor não der início à mesma.
- g) Competência:** É definida pela origem do ato impugnado. Deve ser analisado o ente político que mantém, subvenciona ou é acionista do autor do ato impugnado.
- **Justiça Federal:** Ato de interesse da União e da administração indireta federal (Art. 109 CRFB/88).

O Art. 109, parágrafo 2º CRFB/88 dispõe que a definição da seção competente é definida pela escolha do Autor, entre as seguintes possibilidades: (1) domicílio do Autor; (2) local do ato ou fato que deu origem à demanda; (3) local de situação da coisa; (4) DF.

- **Justiça Estadual:** Se o ato lesivo for do interesse do Estado o Município.
- **STF:** As ações populares são processadas em 1º grau, ainda que participem autoridades contra as quais eventual MS só possa ser apreciado em 2ª instância, como o Presidente da República. Exceções: A competência será do STF para julgar a ação popular quando:
 - houver conflito entre União e Estado membro (artigo 102, I "f" da CRFB/88);
 - houver interesse direto ou indireto de todos os membros da Magistratura ou em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos de atuar ou sejam interessados (artigo 102, I, "n" da CRFB/88).

CAPÍTULO 11

DIREITOS SOCIAIS

11.1 CONCEITO E DESAFIOS

Quanto à sua natureza jurídica, os direitos sociais são qualificados como direitos fundamentais do indivíduo, garantidos pelo art. 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, da seguinte forma:

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle.

Classicamente, esses importantes direitos estão incluídos na denominada segunda geração de direitos fundamentais, que, como já vimos, traz proteção aos direitos sociais, econômicos e culturais, onde do Estado não mais se exige uma abstenção, mas, ao contrário, impõe-se a sua intervenção, visto que a liberdade do homem sem a sua participação não é protegida integralmente. Essa necessidade de prestação positiva do Estado corresponderia aos chamados direitos sociais dos cidadãos, direitos que transcendem a individualidade e alcançam um caráter econômico e social visando a atingir a justiça social.

11.2 CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA

A Constituição de 1988 consagra como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito o amparo aos menos favorecidos, proporcionando-lhes condições de vida mais decente e em harmonia com a igualdade real, na forma do art. 1º, IV.

O capítulo II do Título II tutela os direitos sociais que engloba o art. 6º, garantindo a todos, na forma da Constituição, os seguintes direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia (incluído pela EC nº 26/2000), o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados e o direito à alimentação (incluído pela EC nº 64/2010) e o transporte (incluído pela EC 91/2015) e os arts. 7º a 11 que cuidam dos direitos dos trabalhadores.

Ao longo do texto constitucional encontramos uma série de categorias de direitos sociais, senão vejamo-las:

- **da seguridade social** – saúde, previdência e assistência social (arts. 194 a 204);
- **da educação, cultura e desporto** (arts. 205 a 217);
- **da ciência, tecnologia e comunicação social** (arts. 218 a 224);
- **do meio ambiente** (art. 225);
- **da família, da criança, do adolescente e do idoso** (arts. 226 a 230);
- **dos índios** (art. 231).

11.3 OS DIREITOS SOCIAIS DO TRABALHADOR

Em rol exemplificativo, a Constituição Federal cuidou dos direitos sociais dos trabalhadores entre os art. 7º e 11, guiando-se pelo princípio da igualdade entre o trabalhador urbano e rural.

Importante ressaltar que a EC 72/13 alterou o art. 7º, parágrafo único, garantindo aos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.

De acordo com o art. 39, § 3º, aplica-se aos **servidores ocupantes de cargo público** o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Abaixo transcrevemos os dispositivos relacionados aos direitos sociais dos trabalhadores, individuais e coletivos, além da jurisprudência do STF pertinente ao tema.

11.4 MECANISMOS DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

A Constituição de 1988 avançou na seara das garantias constitucionais, individuais e coletivas, produtos da Constituição cidadã, que podem ser utilizadas também na tutela dos direitos sociais. O mandado de injunção (art. 5º, LXXI), na via individual ou coletiva; o mandado de segurança coletivo (art. 5º, LXX); a ação civil pública (art. 129, III); a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2º); e a arguição de

descumprimento de preceito fundamental (art. 102, § 1º) são importantes ferramentas de defesa dos direitos sociais do povo brasileiro que estrearam no atual texto constitucional.

11.5 OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS SOCIAIS

Princípio do Mínimo Existencial

Em acurada pesquisa no Direito alemão, Ingo Sarlet²²⁴ afirma que o primeiro jurista de renome a sustentar a possibilidade do reconhecimento de uma garantia positiva dos recursos mínimos para uma vida digna foi o publicista Otto Bachof, que já no início da década de 1950 defendia na Alemanha que a dignidade da pessoa humana restaria sacrificada se um mínimo de segurança social não estivesse garantido. No Brasil, o primeiro ensaio de que se tem notícia sobre o tema é o do Professor Ricardo Lobo Torres, em trabalho publicado em 1989²²⁵ e desde então o assunto vem ganhando espaço na doutrina brasileira.

De acordo com Ana Paula de Barcellos,²²⁶ o mínimo existencial corresponderia ao conjunto de situações materiais indispensáveis à existência humana digna, considerada não apenas como experiência física – sobrevivência e manutenção do corpo – mas também espiritual e intelectual, aspectos fundamentais de um Estado Democrático de Direito. Assim sendo, a violação desse mínimo acarretaria desrespeito à própria dignidade da pessoa humana, pois, segundo a autora, o núcleo material da dignidade e as condições mínimas que devem ser asseguradas à vida de todos descreveriam o mesmo fenômeno.

O princípio ultrapassa a mera garantia de sobrevivência física, situando-se, portanto, além do limite da chamada pobreza absoluta. Com isso seria possível concluir que o mínimo existencial não pode ser confundido com o mínimo vital ou de sobrevivência, sob pena de violação da própria dignidade da pessoa humana.²²⁷

224. SARLET, Ingo e TIMM, Luciano Bennetti. *Direitos Fundamentais, Orçamento e Reserva do Possível*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.

225. TORRES, Ricardo Lôbo. “O mínimo existencial e os direitos fundamentais”. *Revista de Direito Administrativo*, no 177, 1989, p. 20-49.

226. BARCELLOS, Ana Paula de. *A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais*. O princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 230-250.

227. Ob. cit.

Não há garantia expressa na Constituição sobre o princípio em tela,²²⁸ mas é inegável que independe de disposição explícita para ser protegido, diante do fundamento da dignidade da pessoa humana, pilar da República Federativa, presente no art. 1º, III, além das previsões nos arts. 5º, III e 60 § 4º, IV, todos da Constituição.

Princípio da Reserva do Possível

É sabido que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, cunhada no conhecido princípio da “reserva do possível”²²⁹ (*Vorbehalt des Möglichen*), firmado pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, segundo o qual, a entrega de prestações sociais ficaria sujeita à reserva da lei orçamentária.

Segundo a maestria das palavras do Ministro Celso de Mello, em julgado importante sobre o direito à saúde: *Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese – mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa – criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – ressaltada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta*

228. Em que pese a expressão “mínimo existencial” já está consagrada pela renomada doutrina brasileira, bem como na jurisprudência sobre o assunto. Entendemos que o verdadeiro substrato axiológico da dignidade da pessoa humana exigiria referência diferente do “mínimo” existencial, porque guarda relação inextricável com a noção de equilíbrio. Passamos, então, a nos referir ao princípio sob a denominação de “equilíbrio existencial”, por entendê-la como expressão mais fidedigna, tanto à dignidade da pessoa humana quanto à vontade do próprio Estado Constitucional de Direito.

229. BverfGE 33, 333: “Os direitos e prestações não são garantidos de antemão para qualquer situação existencial, senão que permanecem sob a reserva do possível, no sentido de saber o que cada qual pode razoavelmente exigir da sociedade. Em primeiro lugar encontra-se sob a responsabilidade do legislador avaliar a pretensão, considerando a economia orçamentária, as outras necessidades da comunidade e o dispositivo expresso do art. 109, inciso 2 da Constituição, que manda levar em conta o equilíbrio geral da economia”.

*governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais.*²³⁰

Conforme as palavras do Ministro, a simples alegação de insuficiência de verbas orçamentárias para a concretização das políticas públicas anunciadas pela Constituição e pleiteadas na via judicial, não é suficiente para caracterizar a impossibilidade material ou jurídica da prestação. Nessas situações, cabe ao julgador a realização da ponderação e realizar escolhas acertadas com base na própria Constituição.

Daí, valiosas as considerações de Ana Paula de Barcellos,²³¹ que sobre o assunto afirma que a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode ignorar. Os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração – de implantação sempre onerosa –, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. Desnecessário acentuar-se, segundo a autora, considerado o encargo governamental de tornar efetiva a aplicação dos direitos econômicos, sociais e culturais, que os elementos componentes do mencionado binômio (razoabilidade da pretensão + disponibilidade financeira do Estado) devem configurar-se de modo afirmativo e em situação de cumulativa ocorrência, pois, ausente qualquer desses elementos, descaracterizar-se-á a possibilidade estatal de realização prática de tais direitos.

Princípio da Vedação ao Retrocesso Social

Mais uma vez, auxiliando-nos da autorizada lição de Canotilho, registramos que o princípio da vedação ao retrocesso social expressa a ideia de que uma vez obtido um determinado grau de realização dos direitos sociais, eles passam a constituir, simultaneamente, uma garantia institucional e um direito subjetivo, podendo formular-se assim: o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado através de medidas legislativas deve considerar-se constitucionalmente garantido sendo inconstitucionais quaisquer medidas do Estado que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam, na prática, numa “anulação”, “revogação” ou “aniquilação” pura e simples desse núcleo essencial.

230. STF, ADPF 45, Min. Rel. Celso de Mello.

231. BARCELLOS. Ana Paula de. Ob. cit., p. 230 a 250.

Nesse sentido, o princípio da vedação ao retrocesso social traz a lume a ideia de que os avanços na área da saúde (a criação do SUS e da “Farmácia Popular”, por exemplo) não podem retroceder, estando dessa maneira fora da discricionariedade do Poder Público. É forçoso reconhecer que, em nome da razoabilidade, essa vedação não é absoluta e nem tem por objetivo derrotar a autonomia do Legislativo e do Executivo, mas serve como importante vetor de proteção às políticas públicas já adotadas pelo Poder Público. Se forem necessárias mudanças, porque o destino do país não é previsível, com base nesse princípio, seriam necessárias medidas substitutivas para que os direitos fundamentais continuassem assegurados e para que a população não sofresse fortes abalos com a extinção da referida política.

O princípio também pode ser concebido com a denominação de proibição de evolução reacionária.

CAPÍTULO 12

NACIONALIDADE

12.1 CONCEITO

A nacionalidade é o vínculo jurídico que liga o indivíduo a um Estado, tornando-o nacional, componente do povo e titular de direitos e obrigações. O conceito de nacionalidade no Brasil não se confunde com o de cidadania, que recebeu pelo constituinte originário sentido restrito e vinculado ao exercício de direitos políticos por meio do título de eleitor. O conjunto dos nacionais é muito maior que o conjunto de cidadãos, quando a gente vincula a cidadania *strictu sensu* ao pleno gozo dos direitos eleitorais mediante o título de eleitor.

12.2 ESPÉCIES DE NACIONALIDADE

- **NACIONALIDADE ORIGINÁRIA OU PRIMÁRIA**

Resulta do nascimento a partir do qual, por critérios sanguíneos, territoriais ou mistos, será estabelecida. É também conhecida como involuntária.

- **NACIONALIDADE DERIVADA OU SECUNDÁRIA**

É um vínculo criado em razão da manifestação de vontade do indivíduo, e em regra por meio do processo de naturalização.

12.3 CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE NACIONALIDADE ORIGINÁRIA

De acordo o critério estabelecido pelo *ius sanguinis*, será nacional todo o descendente de nacionais, independente do local de nascimento. Por meio do critério territorial, *ius soli*, será nacional o nascido no território do Estado, independentemente da nacionalidade de sua ascendência. Como no Brasil o critério de atribuição de nacionalidade originária dominante é o da origem territorial, ainda que se reconheça em algumas situações a origem sanguínea, pode-se dizer que temos um sistema de *ius soli* relativo ou misto.

12.4 AQUISIÇÃO DE NACIONALIDADE ORIGINÁRIA

O Art. 12, I e suas alíneas “a”, “b” e “c”, da CRFB/88, encerram as únicas formas de aquisição de nacionalidade originária brasileira, não podendo a legislação infraconstitucional ampliá-las.

O Art. 12, I, “a” representa o critério de maior destaque da nacionalidade primária no país, ou seja, a origem territorial. De acordo com seu dispositivo, serão brasileiros natos: “a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país”. Daí se infere que, em regra geral, quem nasce no Brasil²³² será brasileiro nato, a não ser que seja filho de pai e mãe estrangeira (não importa de qual nacionalidade) e ainda que um dos pais esteja a serviço oficial de seu país de origem (assim reconhecido pelo país que lhe encaminhou ao Brasil). Pode-se concluir que filho de brasileiro (pai ou mãe) seja nato ou naturalizado, nascido em nosso país, será sempre brasileiro nato.

Na alínea seguinte temos a combinação entre o critério sanguíneo, associado à questão funcional, senão vejamos: serão também brasileiros natos: “b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil”. Da mesma maneira que não se impõe a um estrangeiro que está a serviço de seu país em território brasileiro a nacionalidade brasileira ao seu filho aqui nascido. A Constituição determina que o filho de brasileiro a serviço do Brasil no exterior também possa dar a nacionalidade brasileira a seu filho, mesmo tendo nascido fora do território nacional. Ressalte-se que “a serviço” do país deve englobar a Administração Pública Direta ou Indireta de quaisquer das esferas da Federação²³³.

O art. 12, I, “c”, determina que: “os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

Na redação atual os filhos de brasileiros podem ser registrados em Consúladoss (ou as seções consulares nas Embaixadas), sem a necessidade de vir ao país e proceder à opção. Os que não sejam registrados no exterior ainda podem vir residir a qualquer tempo no Brasil e manifestar a opção após atingida a maioridade²³⁴. A opção é feita na forma do art. 109, X, perante a

232. Também se incluem como extensões do território nacional o espaço aéreo, mares, rios, lagos, baías, ilhas, navios e aeronaves de guerra brasileiras, onde quer que se encontrem, por exemplo.

233. AFONSO DA SILVA, ob. cit. p. 326.z

234. Antes da própria EC 54/07, o STF já dizia que a opção só poderia ser feita após atingida a maioridade e que tinha a natureza personalíssima, senão vejamos:

“São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham a residir no Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. A

justiça federal, num processo de jurisdição voluntária.

12.5 AQUISIÇÃO DE NACIONALIDADE DERIVADA

A naturalização permite ao estrangeiro, que detém outra nacionalidade, ou ao apátrida (que não tem nenhuma), a aquisição da nacionalidade brasileira, na forma do art. 12, II, "a" e "b" e ainda de acordo com o Estatuto do Estrangeiro. Pode-se dizer, com isso que as hipóteses de aquisição de nacionalidade secundária não se esgotam completamente na Constituição Federal. Como a naturalização no Brasil decorre de uma manifestação da vontade, podemos dizer que não há naturalização tácita ou por decurso de prazo.

Em sede constitucional, encontramos duas situações de aquisição de nacionalidade derivada:

- a) **Naturalização ordinária:** para os originários de países da língua portuguesa (Angola, Açores, Portugal, Cabo Verde, Moçambique etc.), de acordo com o art. 12, II, "a", é exigida a residência por um ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral e, para os demais estrangeiros, as exigências estão no Estatuto do Estrangeiro (ou, como diz o texto, na "forma da lei").²³⁵ Apesar dos requisitos necessários

opção pode ser feita a qualquer tempo, desde que venha o filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, nascido no estrangeiro, a residir no Brasil.

Essa opção somente pode ser manifestada depois de alcançada a maioridade. É que a opção, por decorrer da vontade, tem caráter personalíssimo. Exige-se, então, que o optante tenha capacidade plena para manifestar a sua vontade, capacidade que se adquire com a maioridade. Vindo o nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, a residir no Brasil, ainda menor, passa a ser considerado brasileiro nato, sujeita essa nacionalidade à manifestação da vontade do interessado, mediante a opção, depois de atingida a maioridade. Atingida a maioridade, enquanto não manifestada a opção, esta passa a constituir-se em condição suspensiva da nacionalidade brasileira. (RE 418.096, Rel. Min. Carlos Velloso, J. 22-3-05, DJ de 22-4-05).

235. São disposições do Estatuto do Estrangeiro, Lei n 6.815/80:

Art. 112. São condições para a concessão da naturalização:

- I - capacidade civil, segundo a lei brasileira;
- II - ser registrado como permanente no Brasil;
- III - residência contínua no território nacional, pelo prazo mínimo de quatro anos, imediatamente anteriores ao pedido de naturalização;
- IV - ler e escrever a língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando;
- V - exercício de profissão ou posse de bens suficientes à manutenção própria e da família;
- VI - bom procedimento;

para a aquisição da nacionalidade brasileira dos originários de países de língua portuguesa serem fixados pela Constituição, a natureza do ato administrativo de concessão do pedido é discricionária do Poder Executivo federal.

- b) **Naturalização extraordinária ou quinquenária:** na forma do art. 12, II, “b”, serão brasileiros naturalizados: “os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos²³⁶ e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira”. Originariamente o prazo de residência era de 30 (trinta) anos, reduzido pela metade com a ER 3/94.. Estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais de 15 (quinze) anos, ininterruptamente, e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

VII - inexistência de denúncia, pronúncia ou condenação no Brasil ou no exterior por crime doloso a que seja cominada pena mínima de prisão, abstratamente considerada, superior a 1 (um) ano; e

VIII - boa saúde.

§ 1º não se exigirá a prova de boa saúde a nenhum estrangeiro que residir no País há mais de dois anos.

E ainda,

Art. 115. O estrangeiro que pretender a naturalização deverá requerê-la ao Ministro da Justiça, declarando: nome por extenso, naturalidade, nacionalidade, filiação, sexo, estado civil, dia, mês e ano de nascimento, profissão, lugares onde haja residido anteriormente no Brasil e no exterior, se satisfaz ao requisito a que alude o artigo 112, item VII e se deseja ou não traduzir ou adaptar o seu nome à língua portuguesa.

§ 1º. A petição será assinada pelo naturalizando e instruída com os documentos a serem especificados em regulamento.

§ 2º. Exigir-se-á a apresentação apenas de documento de identidade para estrangeiro, atestado policial de residência contínua no Brasil e atestado policial de antecedentes, passado pelo serviço competente do lugar de residência no Brasil, quando se tratar de:

I - estrangeiro admitido no Brasil até a idade de 5 (cinco) anos, radicado definitivamente no território nacional, desde que requeira a naturalização até 2 (dois) anos após atingir a maioridade;

II - estrangeiro que tenha vindo residir no Brasil antes de atingida a maioridade e haja feito curso superior em estabelecimento nacional de ensino, se requerida a naturalização até 1 (um) ano depois da formatura.

236. A ausência temporária do estrangeiro do território brasileiro, segundo o STF, “não significa que a residência não foi contínua, pois há que se distinguir entre residência contínua e permanência contínua” (STF, AI nº 32.04, Min. Rel. Hermes Lima, J. 2.04.65, DJ. 5.5.65)

12.6 TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE BRASILEIROS

Os nossos nacionais originários são os brasileiros natos, e os nacionais derivados são chamados de brasileiros naturalizados. Saliente-se, entretanto, que, quando a CRFB/88 dispõe sobre um direito dos “brasileiros”, está se referindo tanto aos natos quanto aos naturalizados, e essa é a regra geral, em nome do princípio da igualdade da não discriminação, os nossos brasileiros ou têm vínculo originário ou têm vínculo secundário, mas são ambos brasileiros, e em direitos e obrigações devem ser tratados de forma mais equânime possível.

Na forma do art. 12, § 2º, em nome do princípio da igualdade, somente a Constituição pode estabelecer tratamento diferenciado entre seus brasileiros, como o faz em alguns dispositivos legais, a seguir lembrados.

Na forma do art. 12, § 3º:

Art. 12, § 3º - São privativos de brasileiros natos os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas;

VII - de Ministro de Estado da Defesa.

Como esse rol é taxativo, nada impede, portanto, que um brasileiro naturalizado concorra a cargo na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, não podendo apenas ser eleito Presidente das duas casas, da mesma maneira, Governadores de Estado e Prefeitos podem ser brasileiros naturalizados, por inexistir proibição constitucional.

De acordo com o art. 89, VII, a representação direta do povo no Conselho da República também é privativa de brasileiros natos:

“(…) VII - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução”. Ressalte-se que nem todo membro do Conselho da República é brasileiro nato (líderes da maioria e

da minoria das casas legislativas, por exemplo), mas na forma do dispositivo citado a participação do povo no Conselho só pode ser preenchida por brasileiro nato.

Nos termos do art. 5º, LI, não haverá extradição passiva de brasileiro nato “LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei”. Conforme orientação do STF, o brasileiro nato que possui dupla nacionalidade também não poderá ser extraditado²³⁷.

Ainda na forma do art. 222, a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.

237. Segundo o STF:

“O brasileiro nato, quaisquer que sejam as circunstâncias e a natureza do delito, não pode ser extraditado, pelo Brasil, a pedido de Governo estrangeiro, pois a Constituição da República, em cláusula que não comporta exceção, impede, em caráter absoluto, a efetivação da entrega extradicional daquele que é titular, seja pelo critério do *jus soli*, seja pelo critério do *jus sanguinis*, de nacionalidade brasileira primária ou originária. Esse privilégio constitucional, que beneficia, sem exceção, o brasileiro nato (CRFB/88, art. 5º, LI), não se descaracteriza pelo fato de o Estado estrangeiro, por lei própria, haver-lhe reconhecido a condição de titular de nacionalidade originária pertinente a esse mesmo Estado (CRFB/88, art. 12, § 4º, II, a). Se a extradição não puder ser concedida, por inadmissível, em face de a pessoa reclamada ostentar a condição de brasileira nata, legitimar-se-á a possibilidade de o Estado brasileiro, mediante aplicação extraterritorial de sua própria lei penal (CP, art. 7º, II, b, e respectivo § 2º) — e considerando, ainda, o que dispõe o Tratado de Extradicação Brasil/Portugal (Artigo IV) —, fazer instaurar, perante órgão judiciário nacional competente (CPP, art. 88), a concorrente *persecutio criminis*, em ordem a impedir, por razões de caráter ético-jurídico, que práticas delituosas, supostamente cometidas, no exterior, por brasileiros (natos ou naturalizados), fiquem impunes.” (HC 83.113-QO, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26-6-03, DJ de 29-8-03).

12.7 PERDA DA NACIONALIDADE

De acordo com a orientação jurisprudencial²³⁸, as hipóteses de perda da nacionalidade estão taxativamente previstas na Constituição Federal, não podendo, portanto, a legislação infraconstitucional ampliar as hipóteses de restrição ao importante direito fundamental à nacionalidade.

Assim dispõe o art. 12. § 4º:

Art. 12, § 4º: Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;

II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis”;

• **Perda - sanção ou punição:** Brasileiros naturalizados.

O art. 12, §4º, destaca que o brasileiro naturalizado, depois de enfrentar uma ação de cancelamento de naturalização transitada em julgado, terá declarada judicialmente a perda de sua nacionalidade brasileira. Como a perda ocorreu em razão da prática de ato nocivo ao interesse nacional, pode ser denominada de perda sanção, ou de perda punição.

A ação de cancelamento de naturalização é ajuizada pelo Ministério Público Federal e tramita perante a Justiça Federal, na forma do art. 109, X, da CRFB/88. Após declarada a perda, o ex-brasileiro não poderá enfrentar

238. Segundo a posição do STF:

“A perda da nacionalidade brasileira, por sua vez, somente pode ocorrer nas hipóteses taxativamente definidas na Constituição da República, não se revelando lícito, ao Estado brasileiro, seja mediante simples regramento legislativo, seja mediante tratados ou convenções internacionais, inovar nesse tema, quer para ampliar, quer para restringir, quer, ainda, para modificar os casos autorizadores da privação — sempre excepcional — da condição político-jurídica de nacional do Brasil.” (HC 83.113-QQ, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 26-3-03, DJ de 29-8-03)

novo processo administrativo para aquisição de nacionalidade nacional.

- **Perda - mudança:** Brasileiros Natos e Naturalizados.

O art. 12, §4º, II, traz a hipótese de perda de nacionalidade administrativa para o brasileiro nato ou naturalizado que optar pela aquisição voluntária de outra nacionalidade. A doutrina entende que o dispositivo trata de uma perda-mudança, porque não há punição do brasileiro.

A Constituição consagra ainda a possibilidade de dupla-nacionalidade, em que não haverá perda de nacionalidade do brasileiro, nos casos de “a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; e b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis”. A primeira situação é muito comum, num país que recebeu tantos imigrantes como o nosso, por meio desta exceção, filhos ou netos (dependendo da legislação estrangeira) de estrangeiros, nascidos no Brasil, serão brasileiros natos, ainda que possuam o reconhecimento de sua nacionalidade por outro país. Na segunda situação, brasileiros que tenham sido obrigados a se naturalizar, por força de casamento, trabalho, herança, ou, como condição de permanência, manterão intacta a nacionalidade brasileira.

Segundo José Afonso da Silva²³⁹, em caso de reaquisição de nacionalidade brasileira, o readquirente recupera a condição que perdera: se era brasileiro nato, voltará a ser brasileiro nato; se naturalizado, retomará essa qualidade²⁴⁰.

239. AFONSO DA SILVA, ob. cit. p. 333.

240. O procedimento para reaquisição de nacionalidade consta da lei 818/49.

CAPÍTULO 13

DIREITOS POLÍTICOS

13.1 DIREITOS POLÍTICOS

Do art. 1º, parágrafo único da CRFB/88 extraímos que a soberania é popular, ou seja, o titular do Poder Constituinte é o povo, e é ele que deve exercer a sua vontade política, diretamente ou indiretamente, de acordo com o modelo de democracia participativo adotado pelo Brasil.

A democracia direta se realizará quando o cidadão, em pleno gozo de seus direitos políticos, participa de referendos, plebiscitos, quando ajuíza ação popular, dentre outras manifestações. Indiretamente, a democracia se manifesta quando os atos principais da vida política do país são realizados por nossos representantes eleitos para essa finalidade.

O art. 14, da CRFB/88, reitera o teor do artigo citado, dispondo que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto na forma da lei.

13.2 AQUISIÇÃO DE DIREITOS POLÍTICOS: ALISTAMENTO ELEITORAL

Ao se alistar perante a Justiça eleitoral, o cidadão adquire os seus direitos políticos ativos, recebendo autorização constitucional para atuar na formação da vontade política no Brasil. Em regra geral, o cidadão é o brasileiro nato ou naturalizado em pleno gozo de seus direitos políticos.

De acordo com o art. 14, §1º, o alistamento eleitoral é obrigatório para os maiores de dezoito anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de setenta anos e os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Pode-se concluir, então, que o alistamento eleitoral é obrigatório para os brasileiros alfabetizados, com mais de dezoito e menos de setenta anos.

13.3 INALISTABILIDADE

A Constituição veda no art. 12, § 2º o alistamento eleitoral aos estrangeiros (salvo o português equiparado, que na forma do art. 17, do Decreto 3927/01, poderá se alistar). E, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Estes últimos são os convocados para o serviço militar obrigatório. Findada essa situação, extingue-se o proibitivo da Constituição.

Classificação dos direitos políticos positivos (manifestações do sufrágio).

Os direitos políticos positivos se classificam em: ativos e passivos, que serão analisados a seguir.

13.4 DIREITOS POLÍTICOS ATIVOS

a) Alistabilidade – capacidade eleitoral ativa

A alistabilidade é adquirida mediante o processo de aquisição de direitos políticos perante a Justiça eleitoral. Com o título de eleitor em mãos, nós adquirimos o direito de poder votar, de participar de referendos, plebiscito, de propor ação popular, de apresentar projeto de lei popular. São, intervenções ativas diretas do cidadão na vida política do país.

b) Plebiscito e Referendo

A Constituição prevê que uma das formas de exercício da soberania popular será por meio de consultas populares, realizadas mediante plebiscitos e referendos. O plebiscito é uma consulta prévia que se faz aos cidadãos no gozo de seus direitos políticos, sobre determinada matéria a ser, posteriormente, discutida pelo Poder Público. O referendo consiste na consulta posterior sobre determinado ato governamental para ratificá-lo, ou no sentido de conceder-lhe eficácia (condição suspensiva), ou, ainda para retirar-lhe a eficácia (condição resolutiva). Ressalte-se que por se tratar de exercício da soberania, somente as pessoas que tiverem capacidade eleitoral ativa é que poderão participar de ambas as consultas.

O art. 49, da CRFB/88, destinou ao Congresso Nacional a competência exclusiva para autorizar referendo e convocar plebiscito e o assunto foi regulamentado pela Lei nº 9709/98²⁴¹.

241. Artigo 2º - Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa.

§ 1º - O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido.

§ 2º - O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição.

Artigo 3º - Nas questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, e no caso do § 3º do artigo 18 da Constituição Federal, o plebiscito e o referendo são convocados mediante decreto legislativo, por proposta de um terço, no mínimo, dos membros que compõem qualquer das Casas do Congresso Nacional, de conformidade com esta Lei.

c) Ação Popular

A ação popular é ao mesmo tempo um remédio constitucional e um exercício de direito político ativo, pois, na forma do art. 5, LXVIII, conforme já estudado, só poderá ser proposta pelo cidadão.

d) Iniciativa popular de apresentação de projetos de lei

Os cidadãos, por força do art. 61, §2º, também poderão deflagrar o processo legislativo brasileiro apresentando projetos de lei complementar e ordinária, desde que satisfaçam os seguintes requisitos constitucionais: o projeto deve ser subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional + esses eleitores devem estar distribuídos pelo menos por cinco Estados brasileiros + e em cada um desses Estados, o número de eleitores não pode ser inferior a três décimos por cento dos eleitores locais. Os arts. 27, § 4º e 29, XIII, cuidam da iniciativa popular de apresentação de projetos de leis estaduais e municipais.

e) O “Voto”

Como já visto, a aquisição dos direitos políticos se faz mediante o alistamento, perante o órgão da Justiça Eleitoral. Ao se inscrever como eleitor, o cidadão terá o direito de votar. São características constitucionais do voto: pessoal, há obrigatoriedade formal do comparecimento; Livre, Sigiloso, Direto, Periódico, com valor igual para todos. Pode-se dizer que o voto possui natureza híbrida, pois é, ao mesmo tempo: direito público subjetivo, uma função social (função da soberania popular no regime democrático adotado pelo Brasil) e um dever sócio-político (na eleição dos governantes) e um dever jurídico, pois o seu descumprimento gera sanções jurídicas no país²⁴².

13.5 DIREITOS POLÍTICOS PASSIVOS**• Elegibilidade — capacidade eleitoral passiva**

A elegibilidade identifica a capacidade eleitoral passiva. Como iremos analisar nas condições de elegibilidade, não basta ter a capacidade eleitoral

242. AFONSO DA SILVA, José Afonso. Comentários Contextual à Constituição. Malheiros, São Paulo, 2005, p. 218.

Com a recente reforma política, a idade mínima para o cargo de vereador deve ser comprovada na data de registro da candidatura. Para os demais cargos, a comprovação da idade é exigida na data da posse.

ativa para poder se eleger. Com isso, nem todos que possuem capacidade eleitoral ativa possuem necessariamente capacidade eleitoral passiva (os analfabetos, por exemplo), ou ainda, nem todos que podem votar podem ser votados. Por sua vez: todos que possuem capacidade eleitoral passiva possuem capacidade eleitoral ativa, ou seja, para ser votado, precisa poder votar, como na forma do art. 14, § 3º, que traz as condições de elegibilidade.

São condições genéricas cumulativas de elegibilidade, com base no art. 14 §3º: I - a nacionalidade brasileira (a nacionalidade originária só é exigida para os cargos do art. 12, §3º); II - o pleno exercício dos direitos políticos (não pode estar sofrendo nenhuma das restrições do art. 15); III - o alistamento eleitoral (que gera a capacidade eleitoral ativa); IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; V - a filiação partidária (pois não se admite candidatura avulsa no país); VI - a idade mínima de: a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; d) dezoito anos para Vereador.

13.6 OS DIREITOS POLÍTICOS NEGATIVOS

Em contraposição aos direitos políticos positivos, os direitos políticos negativos configuram situações em que o indivíduo não poderá participar da vida política ativa ou passiva do país e dividem-se em dois principais núcleos: as inelegibilidades (art. 14) e a perda e suspensão de direitos políticos, que serão a seguir analisados.

a) As inelegibilidades

As inelegibilidades afetam a capacidade eleitoral passiva do indivíduo, ora completamente (absolutas), ou ainda parcialmente (relativas):

As Inelegibilidades absolutas: na forma do art. 14, §4º, não podem concorrer a nenhum pleito eleitoral no país: os inalistáveis (estrangeiros e conscritos) e os analfabetos (que possuem alistabilidade, mas não alistabilidade). Essas situações são taxativas, ou seja, não pode a legislação infraconstitucional ampliar as hipóteses de inelegibilidades absolutas.

Inelegibilidades relativas: são restrições existentes para certos pleitos eleitorais e determinados mandatos, cujo núcleo principal está presente no art. 14, §5º (reeleição) e §6º (desincompatibilização) e §7º (inelegibilidade reflexa). Na forma do art. 14, §9º, lei complementar poderá ampliar esse tipo de inelegibilidade (LC 64/90).

• A Reeleição

Art. 14 § 5º. O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente.

Essa não é a redação originária da Constituição. Em 1988, o mandato para os titulares do Executivo era de cinco anos, sem reeleição. Por meio da ER no 05/94, o mandato foi reduzido para quatro anos, ainda sem reeleição. Somente pela EC no 16/97 é que a recondução para um mandato consecutivo foi inserida no texto constitucional.

De acordo com a norma em referência, são permitidos apenas dois mandatos consecutivos no mesmo cargo e, desde que respeitada essa disposição, não há número máximo de mandatos.

Em recente interpretação sobre o artigo ora analisado, o STF vedou a figura do “Prefeito itinerante” ou “Prefeito profissional”, muito comum no país e tolerada durante muito tempo pelo próprio TSE. Hoje, o prefeito reeleito não pode se candidatar ao terceiro mandato consecutivo de Prefeito nem para o mesmo Município, tampouco para um Município próximo²⁴³.

243. “(...) Além disso, preceituou que o princípio republicano também seria base do instituto da reeleição, a impedir a perpetuação de pessoa ou grupo no poder. Reputou sensato entender que esse princípio obstaría a terceira eleição não apenas no mesmo Município, mas em relação a qualquer outra municipalidade da Federação. Se assim não fosse, tornar-se-ia possível a figura do denominado ‘prefeito itinerante’ ou ‘prefeito profissional’, claramente incompatível com esse princípio republicano, que também traduziria postulado de temporariedade/alternância do exercício do poder. Inferiu que a reeleição, como condição de elegibilidade, somente estaria presente nas hipóteses em que esses princípios fossem igualmente contemplados e concretizados. Nestes termos, placitou interpretação de que somente seria possível eleger-se para o cargo de prefeito municipal por duas vezes consecutivas. Após isso, só se permitiria, respeitado o prazo de desincompatibilização de seis meses, a candidatura a outro cargo, ou seja, a mandato legislativo, ou aos cargos de governador de estado ou de presidente da República. (...) Por fim, assentou, sob o regime da repercussão geral, que: a) o art. 14, § 5º, da CRFB/88 interpretar-se-ia no sentido de que a proibição da segunda reeleição seria absoluta e tornaria inelegível para determinado cargo de chefe do Poder Executivo o cidadão

Para quem sucede o titular do Executivo, as normas são as mesmas ora explanadas. Com relação ao substituto, a redação da Constituição não é muito clara, pois quem substitui é apenas chamado para exercer o cargo temporariamente, e não deixa de ser Vice-Presidente ou Presidente da Câmara, do Senado ou do STF, no exercício da Presidência. Portanto, a disposição do art. 14, § 5º, quando afirma que quem houver substituído o titular pode ser reeleito para um período subsequente, não se aplica a eles²⁴⁴.

Importante destacar que não há número máximo de reeleições para os cargos do Legislativo.

• A Desincompatibilização

Art. 14, § 6º - Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

O dispositivo grifado traz a hipótese de desincompatibilização, que significa a necessidade de renúncia (o desfazimento do vínculo) do cargo do Executivo para quem pretende se candidatar a outro cargo eletivo, pelo menos 6 (seis) meses antes do pleito eleitoral. A regra se aplica aos titulares dos cargos no Executivo, salvo em caso de sucessão ou de substituição nos seis meses anteriores ao pleito, como decidiu o STF: “Presidente da Câmara Municipal que substitui ou sucede o prefeito nos seis meses anteriores ao pleito é inelegível para o cargo de vereador. CRFB/88, art. 14, § 6º. Inaplicabilidade das regras dos § 5º e § 7º do art. 14, CRFB/88”. (RE 345.822, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 18.11.2003, Segunda Turma, DJ 12.12.2003.)

Ressalte-se que a Constituição não faz menção à necessidade de desincompatibilização para quem pretende se reeleger (recondução para o mesmo cargo). Em nossa opinião ocorre aí um profundo desrespeito ao princípio da igualdade entre os candidatos, que não disputam em condições paritárias, haja vista o candidato à reeleição ter a máquina administrativa

que já cumprira dois mandatos consecutivos (reeleito uma única vez) em cargo da mesma natureza, ainda que em ente da Federação diverso; e b) as decisões do TSE que acarretassem mudança de jurisprudência no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento não se aplicariam imediatamente ao caso concreto e somente teriam eficácia sobre outras situações em pleito eleitoral posterior.” (RE 637.485, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 1.8.2012, Plenário, Informativo 673, com repercussão geral.)

244. AFONSO DA SILVA, José. Ob. cit., p. 227.

do cargo pretendido sob o seu comando. Mas, não é esse, infelizmente, o entendimento do STF sobre o assunto, a seguir transcrito: *Somente a Constituição poderia, de expresso, estabelecer o afastamento do cargo, no prazo por ela definido, como condição para concorrer à reeleição prevista no § 5º do art. 14, da Lei Magna, na redação atual. (...) A Emenda Constitucional no 16/97 não alterou a norma do § 6º do art. 14 da Constituição. Na aplicação do § 5º do art. 14 da Lei Maior, na redação atual, não cabe, entretanto, estender o disposto no § 6º do mesmo artigo, que cuida de hipótese distinta. A exegese conferida ao § 5º do art. 14 da Constituição, na redação da Emenda Constitucional no 16/97, ao não exigir desincompatibilização do titular para concorrer à reeleição, não ofende o art. 60, § 4º, IV, da Constituição, como pretende a inicial, com expressa referência ao art. 5º, § 2º, da Lei Maior. Não são invocáveis, na espécie, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, da isonomia ou do pluripartidarismo, para criar, por via exegética, cláusula restritiva da elegibilidade prevista no § 5º do art. 14, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional no 16/97, com a exigência de renúncia seis meses antes do pleito, não adotada pelo constituinte derivado²⁴⁵.*

Não há desincompatibilização para os ocupantes de cargos do Legislativo.

• A Inelegibilidade reflexa

Art. 14, § 7º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

Para evitar o continuísmo familiar no poder, prática infelizmente muito comum no Brasil, a Constituição estabeleceu a inelegibilidade chamada de reflexa porque seus efeitos não atingem o titular do cargo do executivo, mas os seus familiares²⁴⁶.

245. ADI 1.805-MC/DF, Plenário, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 26.03.98, DJ 14.11.2003.

246. Na esteira desse raciocínio:

“Inelegibilidade. Artigo 14, § 7º, da Constituição do Brasil. O artigo 14, § 7º, da Constituição do Brasil, deve ser interpretado de maneira a dar eficácia e efetividade aos postulados republicanos e democráticos da Constituição, evitando-se a perpetuidade ou alongada presença de familiares no poder.” (STF, RE 543.117-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento

Vale destacar que o comando constitucional torna inelegível a “família” do titular (como exemplo: cônjuge, companheiro, pai/mãe, avô/avó, filhos, netos, irmãos, sogros, genros, noras, cunhados) para quaisquer cargos eletivos no território da circunscrição sob seu comando, salvo se o familiar já é titular de cargo eletivo e candidato à reeleição.

Ainda sobre o tema, será que a inelegibilidade será mantida para o ex-cônjuge com a separação ou o divórcio do casal? No primeiro caso, não há dúvidas que sim, pois não há um desfazimento definitivo do vínculo matrimonial. Quanto à segunda hipótese, o TSE²⁴⁷ decidiu que “Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a separação conjugal durante o mandato, permanece a inelegibilidade até o fim do mandato do ex-cônjuge”. Ressalte-se que essa regra não é absoluta, pois se o titular do Poder Executivo vier a ser reeleito, o ex-cônjuge poderá concorrer, por ter se divorciado antes do segundo mandato.

O STF criou, sobre o assunto, a Súmula Vinculante 18:

“A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no §7º do art. 14 da Constituição Federal.”

Feitas essas considerações, é possível destacar que:

- A “família” do Prefeito²⁴⁸ não pode se candidatar aos cargos de: Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito pelo mesmo Município;

em 24-6-08, DJ de 22-8-08.)

247. CTA, 1089, Rel. Humberto Gomes de Barros, DJ 6.7.2004

248. Sobre o desmembramento de Municípios e a inelegibilidade, são as palavras do STF: “É inelegível para o cargo de Prefeito de Município resultante de desmembramento territorial o irmão do atual Chefe do Poder Executivo do Município-mãe. O regime jurídico das inelegibilidades comporta interpretação construtiva dos preceitos que lhe compõem a estrutura normativa. Disso resulta a plena validade da exegese que, norteadas por parâmetros axiológicos consagrados pela própria Constituição, visa a impedir que se formem grupos hegemônicos nas instâncias políticas locais. O primado da idéia republicana — cujo fundamento ético-político repousa no exercício do regime democrático e no postulado da igualdade — rejeita qualquer prática que possa monopolizar o acesso aos mandatos eletivos e patrimonializar o poder governamental, comprometendo, desse modo, a legitimidade do processo eleitoral.” (RE 158.314, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 15-12-92, DJ de 12-2-93)

- A “família” do Governador de Estado²⁴⁹ não pode se candidatar aos cargos de: Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito pelos municípios localizados no mesmo Estado e também aos cargos de: Deputado Estadual, Deputado Federal, Senador, Governador e Vice-Governador do mesmo Estado;
- A “família” do Presidente da República não poderá se candidatar a nenhum cargo eletivo no país.

A renúncia é um mecanismo utilizado para afastar a inelegibilidade reflexa, para a qual deve ser obedecida a seguinte regra:

- Se o titular do Poder Executivo estiver no primeiro mandato e renunciar até seis meses antes do pleito eleitoral, ficará afastada a inelegibilidade reflexa e seus familiares podem concorrer a qualquer pleito eleitoral, inclusive ao cargo antes ocupado pelo renunciante. Neste último caso, entretanto, o familiar eventualmente eleito não poderá pleitear a reeleição, pois isso caracterizaria um terceiro mandato na mesma família, o que acarretaria um esvaziamento do comando constitucional;
- Se o titular do Poder Executivo estiver no segundo mandato e renunciar até seis meses antes do pleito eleitoral, ficará afastada a inelegibilidade reflexa para os demais cargos. Entretanto, seus familiares não podem concorrer ao cargo antes por ele ocupado, pois também acarretaria três mandatos consecutivos na mesma família.

b) Perda e Suspensão de Direitos Políticos

A perda ou suspensão dos direitos políticos constituem exceção à plenitude dos direitos de votar e ser votado. A perda é a privação definitiva dos direitos políticos positivos, e a suspensão é a privação temporária dos respectivos direitos. Ressalte-se que a cassação – ato arbitrário de retirada de direitos políticos – é vedada pela Constituição. São privações dos direitos políticos, conforme o art. 15, da CRFB/88:

- cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado – hipótese de perda;

249. Sobre o assunto, o STF decidiu

“A causa de inelegibilidade prevista no artigo 14, § 7º da Constituição alcança a cunhada de Governador quando concorre a cargo eletivo de município situado no mesmo Estado.” (RE 171.061, Rel. Min. Francisco Rezek, julgamento em 2-3-94, DJ de 25-8-95)

-
- incapacidade civil absoluta²⁵⁰ – hipótese de suspensão de direitos políticos. Com a mudança no Código Civil feita pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), esse dispositivo foi esvaziado, pois o menor de 16 anos não pode sequer se alistar.
 - condenação criminal transitada em julgado – a suspensão dos direitos políticos persistirá enquanto durarem as sanções impostas ao condenado;
 - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII, CRFB/88 – para a doutrina majoritária, seguindo a tradição das Constituições pretéritas, esta seria mais uma hipótese de perda de direitos políticos, entretanto, o assunto não é pacífico, em parte, face ao disposto no art. 4, § 2º, da Lei 8.239/91, que cuida do serviço alternativo ao serviço militar, que assim afirma: “(...) o certificado só será emitido após a decretação, pela autoridade competente, da suspensão dos direitos políticos do inadimplente, que poderá, a qualquer tempo, regularizar sua situação mediante cumprimento das obrigações devidas”.(grifamos). Esta hipótese de restrição de direitos políticos não tem sido cobrada em prova objetiva tendo em vista a controvérsia apresentada;
 - improbidade administrativa - os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, na forma do art. 37, § 4º, CRFB/88.

250. Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.

CAPÍTULO 14

PARTIDOS POLÍTICOS



14.1 CONCEITO

Os partidos políticos são associações de pessoas com ideologias ou interesses comuns, que mediante uma organização estável, influenciam a orientação política de um país. Segundo definição legal o partido é pessoa jurídica de direito privado (art. 17, § 2º, da CRFB/88 e art. 7º, caput, da Lei nº 9.096/1995).

A Constituição Federal assegura aos partidos políticos no seu art. 17 autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias, sendo vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Importante ressaltar que essa liberdade de organização partidária não é absoluta, pois devem ser resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os preceitos a seguir apresentados, de acordo com o art. 17, I a IV, da CRFB/88.

14.2 PRECEITOS FUNDAMENTAIS

- a) **Caráter nacional:** somente será reconhecido como partido político aquele que tiver repercussão no país inteiro, protegendo o Estado Democrático de Direito. Com isso, partido de caráter estadual ou municipal não será aceito;
- b) **Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes:** Este preceito visa proteger a soberania popular. O partido que receber tais recursos terá o seu registro cassado;
- c) **Prestação de contas à Justiça Eleitoral:** é uma espécie de controle ou fiscalização financeira que se justifica em face da moralidade pública;
- d) **Funcionamento parlamentar de acordo com a lei:** derivado do princípio da legalidade.

14.3 A CRIAÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS

Na forma do art. 8º da Lei nº 9.096/1995, o requerimento do registro de partido político deverá ser dirigido ao cartório competente do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, da Capital Federal; deve ser subscrito pelos seus fundadores, em número nunca inferior a cento e um, com domicílio eleitoral em, no mínimo, um terço dos Estados, e será acompanhado de: I – cópia autêntica da ata da reunião de fundação do partido; II – exemplares do Diário Oficial que publicou, no seu inteiro teor, o programa e o estatuto; III – relação de todos os fundadores com o nome completo, naturalidade, número do título eleitoral com a Zona, Seção, Município e Estado, profissão e endereço da residência.

Adquirida a personalidade jurídica na forma do artigo supracitado, o partido promove a obtenção do apoio mínimo de eleitores a que se refere o § 1º do art. 7º da Lei nº 9.096/1995²⁵¹ e realiza os atos necessários para a constituição definitiva de seus órgãos e designação dos dirigentes, na forma do seu estatuto. Feita a constituição e designação dos seus dirigentes, estes promoverão o registro do estatuto do partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral. As alterações programáticas ou estatutárias, após registradas no Ofício Civil competente, devem ser encaminhadas, para o mesmo fim, ao Tribunal Superior Eleitoral (art. 10 da Lei nº 9.096/1995).

14.4 A FIDELIDADE PARTIDÁRIA

Segundo muito bem destacado por Marcos Ramayana²⁵², sobre fidelidade partidária é preciso diferenciar duas disciplinas: a infidelidade tratada pela Resolução do TSE no 22.610/2007, que acarreta a perda do mandato; e a infidelidade partidária por violação a algum preceito normativo constante do estatuto do partido político, a qual vem disciplinada pela Lei no 9.096/95, nos arts. 23 a 25. Esta última não será objeto da nossa análise, tendo em vista ser matéria mais específica do Direito Eleitoral, não cobrada, portanto, nas

251. Art. 7º, § 1º da Lei nº 9.096/1995:

“Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove o apoio de eleitores correspondente a, pelo menos, meio por cento dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos por um terço, ou mais, dos Estados, com um mínimo de um décimo por cento do eleitorado que haja votado em cada um deles”.

252. Ramayana, Marcos. Direito Eleitoral. 9. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009.

questões de prova do Direito Constitucional. Quanto à primeira hipótese, abordaremos nos tópicos a seguir o passo a passo da mudança jurisprudencial sobre o tema.

A Resposta à Consulta (CTA) no 1.398 do TSE

O partido intitulado de Democratas (DEM) questionou ao TSE se os partidos e coligações teriam o direito de preservar a vaga obtida pelo sistema eleitoral proporcional quando houvesse pedido de cancelamento de filiação ou de transferência do candidato eleito por um partido para outra legenda. Em resposta à Consulta no 1.398, o TSE decidiu que os mandatos conquistados pelos deputados federais da eleição de 2006, assim como todos os eleitos pelo sistema de representação proporcional, no fundo, pertencem aos respectivos partidos políticos, e não aos parlamentares.

A Resolução do TSE no 22.610/2007

A norma acima, alterada posteriormente pela Resolução no 22.733/2008, disciplina o processo de perda de cargo eletivo, bem como de justificação de desfiliação partidária, nos termos seguintes:

Art. 1º O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa:

- I) incorporação ou fusão do partido;*
- II) criação de novo partido;*
- III) mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;*
- IV) grave discriminação pessoal.*

A Manifestação do STF sobre a Fidelidade Partidária

Considerando a importância e clareza das manifestações dos Ministros sobre o tema, destacamos abaixo trechos do voto do Ministro Celso de Mello:

Relativamente ao mandado de segurança impetrado pelo PSDB, de relatoria do Min. Celso de Mello, o Tribunal, por maioria, indeferiu o writ. Na espécie, a impetração mandamental fora motivada pela resposta dada pelo Tribunal Superior Eleitoral

– TSE à Consulta 1.398/DF na qual reconheceu que os partidos políticos e as coligações partidárias têm o direito de preservar a vaga obtida pelo sistema eleitoral proporcional, se, não ocorrendo razão legítima que o justifique, registrar-se ou o cancelamento de filiação partidária ou a transferência para legenda diversa, do candidato eleito por outro partido. Entendeu-se correta a tese acolhida pelo TSE. Inicialmente, expôs-se sobre a essencialidade dos partidos políticos no processo de poder e na conformação do regime democrático, a importância do postulado da fidelidade partidária, o alto significado das relações entre o mandatário eleito e o cidadão que o escolhe, o caráter eminentemente partidário do sistema proporcional e as relações de recíproca dependência entre o eleitor, o partido político e o representante eleito. Afirmando que o caráter partidário das vagas é extraído, diretamente, da norma constitucional que prevê o sistema proporcional (CRFB/88, art. 45, caput: “A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal”), e que, nesse sistema, a vinculação entre candidato e partido político prolonga-se depois da eleição, considerou-se que o ato de infidelidade, seja ao partido político, seja ao próprio cidadão-eleitor, mais do que um desvio ético-político, representa, quando não precedido de uma justa razão, uma inadmissível ofensa ao princípio democrático e ao exercício legítimo do poder, na medida em que migrações inesperadas não apenas causam surpresa ao próprio corpo eleitoral e as agremiações partidárias de origem, privando-as da representatividade por elas conquistada nas urnas, mas acabam por acarretar um arbitrário desequilíbrio de forças no Parlamento, vindo, em fraude à vontade popular e afronta ao próprio sistema eleitoral proporcional, a tolher, em razão da súbita redução numérica, o exercício pleno da oposição política.253

253. STF, MS 26603/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 03 e 04.10.2007.

A Constitucionalidade das Resoluções do TSE – STF, ADI 3.999²⁵⁴

Em 12 de novembro de 2008, o Supremo Tribunal Federal confirmou a Constitucionalidade das Resoluções nos 22.610/2007 e 22.733/2008, ambas do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, as quais disciplinam o processo de perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa, bem como de justificação de desfiliação partidária. No mérito, julgaram-se válidas as resoluções impugnadas até que o Congresso Nacional disponha sobre a matéria. Considerou-se a orientação fixada pelo Supremo no julgamento dos Mandados de Segurança 26.602/DF (DJE 17.10.2008), 26.603/DF (j. 04.10.2007) e 26.604/DF (DJE 03.10.2008), no sentido de reconhecer aos partidos políticos o direito de postular o respeito ao princípio da fidelidade partidária perante o Judiciário, e de, a fim de conferir-lhes um meio processual para assegurar concretamente as consequências decorrentes de eventual desrespeito ao referido princípio, declarar a competência do TSE para dispor sobre a matéria durante o silêncio do Legislativo.

A fidelidade partidária é exigida do parlamentar eleito pelo sistema proporcional

Em decisão de 2015, o STF concluiu que a perda do mandato em razão de mudança de partido não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor.²⁵⁵

A Questão Relativa ao Direito de Sucessão na Vaga

Importante destacar que o STF decidiu que o reconhecimento da justa causa para transferência de partido político afasta a perda do mandato eletivo por infidelidade partidária. Entretanto, ela não transfere ao novo partido o direito de sucessão na vaga, tendo em vista que o voto do eleitor foi manifestado ao partido de origem do parlamentar e não ao partido final.²⁵⁶

254. STF, ADI 3.999/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 12.11.2008, DJE 17.04.2009.

255. STF, ADI 5081/DF, rel. Min. Roberto Barroso, 27.5.2015.

256. MS 27.938, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 11.3.2010, Plenário, DJE 30.4.2010.

14.5 A VERTICALIZAÇÃO DAS COLIGAÇÕES

O art. 2º da EC no 52/2006 alterou a redação do art. 17, § 1º, da CRFB/88, para inserir em seu texto, no que se refere à disciplina relativa às coligações partidárias eleitorais, a regra da não obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, em reforço à autonomia partidária. Determinou ainda a aplicação dos efeitos da referida Emenda “às eleições que ocorrerão no ano de 2002”.

Contra o referido dispositivo foi ajuizada a ADI 3.685²⁵⁷, julgada procedente pelo STF, em face do que dispõe o princípio da anualidade em matéria eleitoral no art. 16 da CRFB/88: “Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência”.

257. STF, ADI 3.685/DF, Rel.a Min.a Ellen Gracie, Plenário. j. 22.03.2006, DJE 10.08.2006.

“Pedido que se julga procedente para dar interpretação conforme no sentido de que a inovação trazida no art. 1º da EC nº 52/2006 somente seja aplicada após decorrido um ano da data de sua vigência.”

CAPÍTULO 15

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO



15.1 ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

O Estado é a formação política na modernidade, e é composto pelo POVO, seu elemento subjetivo, pelo TERRITÓRIO, que representa a sua porção física, pelo GOVERNO, que instrumentaliza a sua vontade, e pela SOBERANIA, que é o reconhecimento perante a comunidade jurídica internacional.

a) Formas de Estado: Hoje existem duas formas de Estado principais, examinando se há ou não divisão geográfica interna de poder político.

- No Estado unitário não há divisão geográfica de poder político. Até pode haver divisão administrativa interna, mas não há divisão de poder. O Poder Central concentra o poder político. Ex: Chile, Uruguai, França, Itália, Portugal.
- No Estado composto há divisão geográfica de poder político. Na confederação, os Estados preservam a sua soberania e se unem apenas para estabelecer determinadas tarefas comuns, tais como defender o território confederativo e assegurar a segurança interna. A Federação é a forma mais comum de Estado Composto e é caracterizada pela descentralização geográfica do poder político. Não há relação de subordinação entre os entes políticos e as unidades federativas detêm apenas autonomia. O Estado Federal é soberano para o Direito Internacional, ao passo que os Estados-membros são autônomos para o Direito Interno.

b) Histórico do Federalismo: O Federalismo norte-americano surgiu de um movimento centrípeto, por meio de força de agregação, ou seja, os Estados Membros mantiveram desde os primórdios da federação norte americana muito poder político. Já a federação brasileira surgiu de um movimento centrífugo, por meio de segregação. Com isso, podemos concluir que o Poder Central sempre foi mais fortalecido no Brasil do que em outros países como os Estados Unidos.

c) Federalismo Brasileiro atual: O federalismo Brasileiro é atípico, pela presença de Municípios (não há no direito comparado municípios como entes federativos) e do DF. Pode-se dizer que se trata de um

federalismo tricotômico, pois engloba:

- União - Poder Central;
- Estados - Poder Regional;
- Distrito Federal – Poder regional e local;
- Municípios - Poder Local.

Obs.: Os Territórios não são entidades federativas.

15.2 A FEDERAÇÃO BRASILEIRA

Inspirada no modelo norte-americano, a federação brasileira surge com a proclamação da República em 15.11.1889, por meio do Decreto nº 1, fruto da transformação das antigas províncias em Estados membros, num movimento de segregação.

A Federação brasileira de 1988 configura um dos princípios fundamentais do país, na forma do art. 1º, e é composta de acordo com o art. 18 pelo vínculo indissolúvel entre a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, entes da federação, todos autônomos e ainda é protegida como cláusula pétrea, com esteio no art. 60, § 4º, I da CRFB/88.

15.2.1 Características Da Federação Brasileira

São essas as principais características da nossa federação:

- a) Descentralização política, que significa a divisão do Poder Público no espaço territorial, através de repartição constitucional de competências. De acordo com os arts. 21 a 24, 25 e 30, a Constituição delimitou a esfera de poder interno da cada um de seus entes, que será estudado em capítulo próprio;
- b) Autonomia dos entes federativos, que é identificada pela tríplice capacidade de que os mesmos possuam Governo próprio, administração própria e organização própria;
- c) Inexistência do direito de secessão (de retirada), pois de acordo com o art. 1º, da CRFB/88, o vínculo que une os entes da federação é indissolúvel. Ressalte-se que o direito de secessão é permitido nos Estados Confederados;
- d) Existência do bicameralismo no poder legislativo central, com um dos órgãos representando a vontade dos entes federativos na formação das leis centrais. No Brasil, esse papel foi destinado ao Senado Federal;

- e) A rigidez constitucional que protege a competência dos vários entes federativos, suas autonomias e a própria estabilidade da Federação como um todo;
- f) Existência de órgão judicial para resolver eventuais litígios entre os entes da federação, sendo do STF essa função, na forma do art. 102, I, "F";
- g) Existência de um mecanismo de defesa para a proteção do Estado, consistindo na intervenção federal, na forma dos arts. 34 e 35;
- h) O controle concentrado na constitucionalidade, que oferece mais estabilidade ao texto constitucional e, portanto, essencial à manutenção do equilíbrio entre os diversos entes federativos, já que a solução de seus eventuais conflitos reside na própria Constituição;
- i) A adoção de um federalismo tricotômico, com três manifestações de poder (Local, Regional, Nacional), em vez de duas, como no federalismo clássico, dual (Nacional e Regional) norte-americano;
- j) Por fim, deve-se recordar que a forma federativa do estado Nacional brasileiro é "cláusula pétrea" e limite material à reforma constitucional (art. 60, § 4º, I).

15.2.2 O Equilíbrio Federativo

Com a finalidade de estabelecer um equilíbrio na federação brasileira, o constituinte previu no art. 19 uma série de vedações que devem ser respeitadas por todos os entes, quais sejam: a) estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público; b) recusar fé aos documentos públicos; c) criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

A primeira vedação se origina da opção pela liberdade religiosa feita pelo Estado Laico brasileiro. Daí porque as unidades federativas não podem criar cultos, tampouco concorrer com dinheiro público para que se exerça a atividade religiosa, muito menos restringir a sua prática por meio de imposições administrativas desnecessárias. A colaboração estatal na forma da lei deverá ser feita de maneira a não discriminar as diversas religiões.

A segunda vedação, em nome da harmonia entre os entes da federação, seus documentos públicos não podem deixar de ser reconhecidos tanto pelos particulares como para cada um dos entes.

O princípio da igualdade lastreia a terceira vedação, impedindo que um ente da federação discrimine o indivíduo de outra unidade, pois são todos “filhos” de um único país, independentemente da região de sua residência. Ademais, a discriminação autorizada entre os brasileiros só pode ser realizada pela própria Constituição, na forma do art. 12, § 2º.

15.3 AUTONOMIA X SOBERANIA

A soberania é uma qualidade do Estado, ou segundo alguns autores, um dos elementos do Estado, que pode ser analisado sob a perspectiva interna - dando unidade à Federação - e externa, ao ser reconhecido e respeitado perante a comunidade jurídica internacional. A autonomia, entretanto, está alinhada apenas ao ambiente interno do país e se identifica pela capacidade política interna do ente federativo, caracterizada pela trílice capacidade de: auto-organização (consistente no poder de elaborar as leis próprias), autogoverno (com manifestações de Legislativo, Executivo e Judiciário próprio) e autoadministração (com administração descentralizada e serviços públicos próprios).

A federação brasileira é singular, pois possui três eixos de poder (nacional, regional e local) que se manifestam por meio de quatro entes federativos, União, Estados, Municípios e Distrito Federal (que exprime o poder regional e local), cujas manifestações da autonomia se diferenciam de acordo com a previsão constitucional.

15.4 DA UNIÃO

A União é pessoa jurídica de direito público interno formada pelas demais partes componentes do país, dotada de executivo, legislativo e judiciário próprios (autogoverno), auto-organizada pela Constituição Federal, com administração própria, sendo, portanto, autônoma, e não se confunde com a Federação, que é pessoa jurídica de direito público externo, reconhecida pela comunidade internacional em razão de sua soberania. Importante destacar que são os órgãos da União que representam a Federação nos atos de Direito Internacional, mas não é a União quem aparece, e sim a República Federativa do Brasil, de que ela é apenas uma das entidades componentes.²⁵⁸

258. AFONSO DA SILVA, José. Comentário Contextual à Constituição, Malheiros, São Paulo, 2005, p. 254.

Os demais países não reconhecem nos Estados-membros e nos Municípios personalidades de Direito Internacional, pois eles são apenas pessoas jurídicas de direito público do Brasil (internas). No âmbito interno, a União atua como uma das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação, ou seja, exerce, em nome próprio, a parcela de competência que lhe é atribuída pela Constituição.

Bens da União: O Código Civil lista no art. 99 os bens que são considerados públicos, ficando a cargo do art. 20 da CRFB/88 listar os bens públicos que pertencem à União. Os bens públicos podem ser classificados em:

- De uso comum do povo: São utilizados pela coletividade, como rios, mar, praças, ruas;
- De uso especial: Também são utilizados pela coletividade, mas estão destinados a atividades específicas do Estado. Ex.: prédios destinados às repartições públicas;
- Dominicais: Constituem o patrimônio da União, Estados, Municípios, Distrito Federal e entidades da Administração Direta e Indireta como objeto de direito real ou pessoal. Ex.: terreno sem qualquer utilização.

Os bens da União, como bens públicos, são impenhoráveis, inalienáveis (enquanto afetados, devendo obedecer às regras da Lei 8.666/93 para alienação) e imprescritíveis (não se sujeitam à aquisição por meio de usucapião).

De acordo com o art. 20, da CRFB/88, são bens da União:

1) os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos (por força de doação, compra, desapropriação etc);

II - as terras devolutas²⁵⁹ indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;

IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;

V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;

VI - o mar territorial²⁶⁰;

VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;

VIII - os potenciais de energia hidráulica;

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;

259. De acordo com o Dec-Lei nº 9.760/66:

Art. 5º São devolutas, na faixa da fronteira, nos Territórios Federais e no Distrito Federal, as terras que, não sendo próprios nem aplicadas a algum uso público federal, estadual territorial ou municipal, não se incorporaram ao domínio privado: a) por força da Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, Decreto nº 1.318, de 30 de janeiro de 1854, e outras leis e decretos gerais, federais e estaduais; b) em virtude de alienação, concessão ou reconhecimento por parte da União ou dos Estados; c) em virtude de lei ou concessão emanada de governo estrangeiro e ratificada ou reconhecida, expressa ou implicitamente, pelo Brasil, em tratado ou convenção de limites; d) em virtude de sentença judicial com força de coisa julgada; e) por se acharem em posse contínua e incontestada com justo título e boa fé, por termo superior a 20 (vinte) anos; f) por se acharem em posse pacífica e ininterrupta, por 30 (trinta) anos, independentemente de justo título e boa fé; g) por força de sentença declaratória proferida nos termos do art. 148 da Constituição Federal, de 10 de Novembro de 1937.

260. Conforme o art. Art. 1º da lei nº 8.617/93:

O mar territorial brasileiro compreende uma faixa de doze milhas marítima de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil.

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios (neste dispositivo a Constituição reitera o disposto no art. 231, onde são reconhecidos aos índios os seus direitos sobre a terra).

15.5 DOS ESTADOS FEDERADOS

Os Estados-membros são as organizações jurídicas das coletividades regionais para o exercício, em caráter autônomo, das competências que lhes são deferidas pela Constituição Federal. Não são soberanos, e sim autônomos. Entre Estados e União não há hierarquia, convivendo todos em um mesmo nível jurídico, razão pela qual a União não pode interferir nos assuntos que a Constituição reserva aos Estados.

a) Características da autonomia estadual:

- **Autogoverno** - Os Estados possuem os poderes legislativo (art. 27, CRFB/88), executivo (art. 28, CRFB/88) e judiciário (art. 125, CRFB/88);
- **Auto-organização** - Por meio de seu poder constituinte decorrente elaboram as suas constituições (art. 25, CRFB/88);
- **Autolegislação** - Capacidade de elaborar leis próprias (art. 25, CRFB/88);
- **Autoadministração** - É a existência de órgãos e servidores próprios, formadores da administração pública estadual;
- **Autonomia tributária, financeira e orçamentária** - Há atividade financeira, tributos (art. 155, CRFB/88) e orçamento próprios dos Estados-membros.

b) Bens dos Estados: Os bens que se incluem no patrimônio do Estado estão previstos no art. 26, CRFB/88.

Na forma do art. 26, incluem-se entre os bens dos Estados:

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;

II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros;

III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União (O

art. 20, IV, declara que se incluem entre os bens da União apenas as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países);

IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da União.

c) Criação de Estados e Territórios – art. 18 §3º da CRFB/88.

O art. 18 §3º prevê os requisitos para criação de novos Estados e Territórios. Territórios não têm autonomia, são apenas descentralização político-administrativa da União. Por isso não têm status de ente federativo. Mas a CRFB/88 não veda a criação de novos territórios.

Como já mencionado, não é permitido o direito de secessão; o pacto federativo é indissolúvel, não se admite que um Estado forme um novo país. Mas permite-se criação de novos Estados, fusão e desmembramento de Estados.

São requisitos para criação, fusão e desmembramento de Estados:

- Plebiscito da população diretamente interessada;
- Lei complementar do Congresso Nacional.

A Lei 9709/98 prevê que a expressão “população diretamente interessada” refere-se à população de todo o Estado, e não somente da parte do Estado que se pretende desmembrar. Em nome do princípio da unidade socioeconômica e cultural, toda a população do Estado precisa ser consultada. A constitucionalidade deste dispositivo foi confirmada na ADI 2650 (Inf. 637).

Após o plebiscito favorável, deve ser elaborada LC do Congresso Nacional. É uma lei em sentido formal, mas é de efeitos concretos. Essa lei de efeitos concretos já foi admitida pelo STF como objeto do controle concentrado (ver ADI 2240 e 3682).

Considerando a soberania popular, uma vez aprovada a criação por meio do plebiscito, seria possível defender a obrigatoriedade de edição da lei. No entanto, não há prazo para edição desta lei. Se não foi editada em prazo razoável, seria possível o ajuizamento de ADO. Ocorre que, na prática, a menos que fosse adotada uma posição concretista em ADO (que não encontra precedentes, exceto na ADI 3682), não haveria como compelir o Legislativo a editar a lei.

15.6 DOS MUNICÍPIOS

O Brasil possui uma forma bem peculiar de federação. A despeito das demais federações possuírem um modelo dual, bipartido entre a União e os Estados, a nossa é tricotômica, onde se reconhece ao município um verdadeiro ente federativo, em que pese não termos registro de nenhuma outra federação que assim o intitule.²⁶¹

a) Capacidades dos municípios:

- Capacidade de autogoverno - elegem os seus prefeitos e os seus vereadores, não havendo, no entanto, Poder Judiciário próprio;
- Capacidade de auto-organização - Lei orgânica própria (art.29, CRFB/88). O STF entende que as leis orgânicas dos Municípios não são manifestações de poder constituinte decorrente, e assim não é possível que sejam parâmetro para controle de constitucionalidade;
- Capacidade de autolegislação - elaboração de leis municipais sobre áreas que são reservadas à sua competência exclusiva e suplementar;
- Capacidade de autoadministração - existência de uma Administração Pública municipal própria, para manter e prestar os serviços de interesse local;
- Capacidade de autonomia tributária e financeira - instituição de tributos próprios para aplicação de suas rendas.

Diante do fato de que os Municípios não possuem Judiciário próprio, tampouco são representados pelo Senado Federal no poder legislativo central, muito menos são reconhecidos entes federativos em outros países, José Afonso da Silva faz críticas sobre a inclusão efetiva do município no rol de entes da federação brasileira, a saber: "(...) Não é porque uma entidade territorial tenha autonomia político-constitucional que necessariamente integre o conceito de entidade federativa.(...) Não existe federação de

261. Prof. Paulo Bonavides afirma

"Não conhecemos uma única forma de união federativa contemporânea onde o princípio da autonomia municipal tenha alcançado grau de caracterização política e jurídica tão alto e expressivo quanto aquele que consta da definição do novo modelo implantado no país com a carta de 1988, a qual impõe aos aplicadores de princípios e regras constitucionais uma visão hermenêutica muito mais larga tocante à defesa e sustentação daquela garantia". (Curso de Direito Constitucional, Malheiros, 18ª ed., São Paulo, p. 347)

Municípios. Existe federação de Estados. Estes é que são essenciais ao conceito de qualquer federação (...) Em que muda a federação brasileira com o incluir os Municípios como um de seus componentes?"

Em que pese as críticas do renomado jurista, não paira dúvidas sobre a inclusão dos Municípios como entes federativos pela Constituição de 1988, de acordo com os dispositivos constitucionais e com a sua interpretação jurisdicional²⁶².

b) Criação de novos Municípios – art. 18 § 4º da CRFB/88

A criação de novos Municípios tem amparo no art. 18 § 4º da CRFB/88. De acordo com o texto constitucional, são requisitos para criação de novos Municípios:

- Estudo de viabilidade
- Plebiscito
- Lei estadual
- Lei complementar federal

A exigência de lei complementar é fruto da EC/15, com o objetivo de frear a criação de Municípios. No entanto, até a presente data não foi editada a lei complementar exigida pelo Constituinte originário, o que fez com que todo Município criado por meio de lei estadual a partir da EC/15 tivesse sua constitucionalidade questionada. O STF, na ADI 2240, declarou a inconstitucionalidade da norma, mas sem pronunciar a nulidade. Fixou prazo de 24 meses para regularização de um determinado Município. Só que durante este prazo de 24 meses veio a EC 57/08, alterando o art. 96 do ADCT, regularizando a situação de todos os Municípios criados sem amparo da lei complementar federal, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006. Podemos concluir, portanto, que todos os Municípios criados a partir de 1º de janeiro de 2007 estão com a sua situação irregular e a lei estadual de criação é inconstitucional.

262. A título de exemplo:

“Longe fica de vulnerar a autonomia municipal, considerado o decreto do Chefe do Poder Executivo, decisão mediante a qual se glosa ato proibindo, em todo o território do município, a fabricação e comercialização de armas de fogo e munição.” (STF, AI 189.433-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 29-9-97, *DJ* de 21-11-97).

E ainda:

Constituição do Estado do Ceará. Atividade peculiar aos municípios estabelecida compulsoriamente. Intervenção que, aparentemente, fere a autonomia municipal.” (STF, ADI 307-MC, Rel. Min. Célio Borja, julgamento em 29-6-90, *DJ* de 28-9-90)

15.7 DO DISTRITO FEDERAL

A Constituição de 1988 também inovou ao atribuir ao Distrito Federal o status de ente federativo, possuindo Legislativo (identificado pela Câmara legislativa) e Executivo (representado pelo Governador), de acordo com o art. 32. Entretanto, seu Poder Judiciário é tutelado pela União Federal, na forma do art. 21, XIII, da CRFB/88. Como a Constituição não permite a sua divisão em Municípios (art.32), a competência legislativa deste ente peculiar da federação, compreende as que são atribuídas aos Estados e aos Municípios, por isso produz leis distritais de matéria estadual e também municipal.

É também uma pessoa jurídica de direito público e não se confunde com Brasília, que é capital federal, localizada em seu território. Possui Lei Orgânica, que também é manifestação legislativa (fruto do poder constituído) e ainda tem seu próprio quadro de servidores, que devem respeitar ao disposto nos arts. 37 a 41 da CRFB/88.

15.8 DOS TERRITÓRIOS

Os territórios não são pessoas políticas e possuem mera capacidade administrativa. Isso significa que não legislam. Não são entes federativos e por isso não integram a Federação. A criação, a transformação em Estado ou a reintegração a este dependerão de lei complementar. O Governador é escolhido pelo Presidente da República.

Alguns doutrinadores entendem que os territórios são descentralizações políticas da própria União Federal e possuem status de autarquia.

15.9 INTERVENÇÃO

Princípio da não intervenção

O princípio que norteia a intervenção é o da não intervenção, pois ela é a antítese da autonomia, tendo em vista que afasta momentaneamente a atuação autônoma do Estado, Distrito Federal ou Município. Seu objetivo é proteger a estrutura federativa contra os abusos e os atos das ordenações jurídicas parciais que contrariem as normas constitucionais presentes nos arts. 34 e 35, da CRFB/88. Visa preservar a soberania do Estado Federal, sendo, portanto, uma medida política de exceção, que poderá restringir temporariamente qualquer um dos poderes do ente federativo, sendo

possível de ser realizada no Executivo, no Legislativo e ainda no Judiciário.

Destaque-se que a intervenção ocorre da entidade federativa “maior” para a “menor”, pois não existe intervenção de baixo para cima. Com isso, a União pode intervir no Distrito Federal e nos Estados, e esses nos seus Municípios. A União só poderá intervir em Municípios de Territórios, por não ser este ente federativo com capacidade de intervir.

O Decreto Interventivo, por força do art. 84, X, da CRFB/88, é de exclusividade do Presidente da República (em caso de intervenção federal) ou do Governador de Estado (caso se trate de intervenção estadual).

15.9.1 Hipóteses Constitucionais Taxativas

A enumeração das hipóteses de intervenção pela Constituição Federal é exaustiva ou “*numerus clausus*”, não podendo ser acrescentadas outras hipóteses pela legislação. Nem mesmo através de emenda constitucional, pois estaria fragilizando a ordem federativa tal como desenhada no texto constitucional, o que é vedação material e explícita do texto constitucional na forma do art. 60, §4º, I.

15.9.2 Natureza Jurídica

A natureza jurídica da intervenção é a de um ato político-administrativo. Significa que pressupõe um juízo político do Presidente da República ou do Governador do Estado que a decretou (intervenção, respectivamente, federal ou estadual). Importante destacar que, apesar de ser político, não é completamente discricionário, pois as hipóteses estão presentes na Constituição e, se configuradas, o decreto interventivo deverá ser, de maneira razoável, editado.

15.9.3 Espécies de Intervenção

A intervenção poderá ser, de acordo com o tratamento jurídico a ela destinado pelos arts. 34 a 36 espontânea ou provocada, a saber:

- a) **Espontânea** – é aquela iniciada pelo Chefe do Executivo competente, depois de verificados os seus pressupostos de fundo, sendo desnecessária a requisição ou solicitação de alguma autoridade ou poder. Seriam hipóteses dessa intervenção:

- se federal, para: art. 34, I - manter a integridade nacional; II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra; III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública; V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que: a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior; b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;
- se estadual, caso: art. 35, I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada; II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

b) Provocada – é aquela que depende de solicitação ou requisição de autoridade ou poder. **Se federal**, para:

- art. 34, IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação; neste caso, de acordo com o art. 36, I, se houver **solicitação** (faculdade) do Poder Legislativo ou Executivo coacto ou impedido ou de **requisição** (obrigatoriedade) do STF caso se trate de restrição ao Poder Judiciário;
- art. 34, VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, neste caso, na forma do art. 36, II, dependerá de **requisição** (obrigatoriedade) do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral, caso se trate de desobediência a ordem ou decisão judiciária; e ainda, na forma do art. 36, III, de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, no caso de recusa à execução de lei federal;
- art. 34, VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais (denominados de princípios constitucionais sensíveis): a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; b) direitos da pessoa humana; c) autonomia municipal; d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta; e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

Nestes casos, na forma do art. 36, III, dependerá de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República. (Neste caso será proposta uma ADI interventiva federal, que será estudada em capítulo próprio).

Caso **seja estadual**, a intervenção provocada deverá ser realizada na forma do art. 35, IV, ou seja, se o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. (Neste caso será proposta uma ADI interventiva estadual, que também será analisada em capítulo específico).

15.9.4 Pressupostos do Decreto Interventivo

Como já tratamos, a intervenção deverá ser realizada com exclusividade pelo Chefe do Executivo, e o decreto interventivo deverá fixar amplitude, prazo e as condições de execução e a nomeação ou não de interventor. Se a intervenção se der no Poder Executivo, é imprescindível a nomeação de interventor para que exerça as funções de Governador ou de Prefeito, se for o caso. É possível, no entanto, intervenção sem interventor. Ressalte-se que a intervenção será sempre temporária (art. 36, § 4º).

Na forma dos arts. 90, I e 91, §1º, II, é da competência dos Conselhos da República e da Defesa Nacional se pronunciarem sobre o assunto, ainda que em parecer não vinculativo, sem prazo fixado pela Constituição.

15.9.5 Controle Político

É a submissão do decreto de intervenção ao Congresso Nacional ou à Assembleia Legislativa no prazo de 24h. Nos casos do art. 34, VI e VII e 35, IV é dispensada a referida apreciação. Se houver rejeição por parte do Congresso ou da Assembleia, conforme o caso, a intervenção deverá ser suspensa imediatamente, sob pena de inconstitucionalidade, e a sua eventual manutenção poderá ensejar o cometimento de crime de responsabilidade do Chefe do Executivo.

15.9.6 Controle Jurisdicional

O Judiciário não ficará afastado da apreciação das ilegalidades cometidas durante a medida de exceção, na forma do art. 5º, XXXV.

15.9.7 Intervenção da União em Municípios de Territórios (art. 35)

Se a intervenção da União for a Município de Território, a medida será federal e segue as observações feitas sobre o art. 35, sendo que o decreto será presidencial e submetido ao Congresso Nacional.

15.9.8 Repartição de Competências

O Professor José Afonso da Silva define competência como “a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade ou a um órgão ou agente do Poder Público para tomar decisões”. Segundo ele, o princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades federativas é o da predominância de interesses, pelos quais cabem à União as matérias e questões de predominate interesse geral, nacional; aos Estados cabem as matérias e assuntos de predominate interesse regional; e aos municípios concernem os assuntos de interesse local.

a) A repartição de competências e o princípio da predominância de interesses

Uma das características principais da federação é a repartição de competências que exterioriza justamente qual é a parcela de poder interno que possui para a tomada das decisões políticas. Cada país tem o seu próprio modelo federativo de repartir o poder internamente, uns mais descentralizados, como é o caso dos Estados Unidos; outros, como o Brasil, possuem uma forte concentração de poderes na União, deixando poderes remanescentes para os Estados.

A divisão das competências internas deve seguir o princípio da predominância de interesse (apesar de não ser de simples identificação). Com isso, as matérias que sejam de interesse nacional, ou geral, devem ser tratadas pela União Federal; os assuntos relativos às regiões aos Estados e de predominância local, aos Municípios. Na prática, alguns assuntos se confundem, como, por exemplo, a seca do Nordeste, apesar de preocupação efetiva dos estados dessa região, não deixa de ser também de interesse

nacional.

As competências podem ser divididas genericamente como legislativas (que determinam uma divisão de poder legiferante entre os entes); administrativas (delimitam decisões políticas) e tributárias. Estas últimas, como são analisadas de forma especial pelo direito tributário, não receberam nossa atenção nesse trabalho.

b) A competência legislativa

As competências legiferantes dos entes federativos, de acordo com a Constituição, podem ser:

1) Privativas da União Federal, quanto aos assuntos de interesse nacional, na forma do art. 22, podem ser objeto de delegação com relação a matérias específicas, por meio de lei complementar aos Estados e Distrito Federal (art. 22, parágrafo único). Há rica jurisprudência do STF sobre a invasão da competência privativa dos entes federativos às matérias atinentes à União Federal²⁶³;

263. A título de exemplo:

Súmula Vinculante 2: “É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.”

“Trânsito: idade mínima para habilitação a conduzir veículo automotor: matéria de competência privativa da União: inconstitucionalidade de legislação estadual a respeito.” (ADI 476, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 18-2-99, *DJ* de 9-4-99);

“Parcelamento do pagamento de multas de trânsito, sem correção. Incompetência do Estado-Membro para dispor sobre a matéria que está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Ausência de lei complementar, art. 22, parágrafo único da CRFB/88. Inconstitucionalidade formal, vício de competência.” (ADI 2.432-MC, Rel. Min. Nelson Jobim, julgamento em 7-6-01, *DJ* de 21-9-01);

“À União, nos termos do disposto no artigo 22, inciso I, da Constituição do Brasil, compete privativamente legislar sobre direito processual. Lei estadual que dispõe sobre atos de Juiz, direcionando sua atuação em face de situações específicas, tem natureza processual e não meramente procedimental.” (ADI 2.257, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 6-4-05, *DJ* de 26-8-05);

“Invade a competência da União, norma estadual que disciplina matéria referente ao valor que deva ser dado a uma causa, tema especificamente inserido no campo do Direito Processual.” (ADI 2.655, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 9-3-04, *DJ* de 26-3-04)

SÚMULA VINCULANTE 39

Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.

SÚMULA VINCULANTE 46

A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.

2) Concorrentes entre União, Estados e Distrito Federal, na forma do art. 24. Nessa situação²⁶⁴, os entes da federação citados legislam em colaboração, tendo em vista que os assuntos relacionados no dispositivo dizem respeito ao interesse também regional. Dos parágrafos do artigo em análise se extrai ainda: a competência da União em editar normas gerais (art. 24, §1º), a competência suplementar dos Estados e Distrito Federal para adaptarem as normas gerais às suas próprias realidades (art. 24, § 2º), a competência legislativa plena dos Estados e Distrito Federal para atender às suas peculiares (art. 24, § 3º), sendo que com a superveniência da lei federal, suspender-se-á a legislação distrital ou estadual no que forem contrárias à nova legislação. (art. 24, p. 4)

3) Enumeradas ou expressas dos Municípios e do Distrito Federal, de acordo com o art. 30, I, para legislar sobre assuntos de interesse local²⁶⁵;

264. Diante de normas estaduais e distritais que avançam aos limites previstos para a sua competência, também há julgados do STF sobre a competência concorrente, vejamos alguns deles:

“Lei n. 7.737/2004, do Estado do Espírito Santo. Garantia de meia entrada aos doadores regulares de sangue. Acesso a locais públicos de cultura esporte e lazer. Competência concorrente entre a União, Estados-Membros e o Distrito Federal para legislar sobre direito econômico. Controle das doações de sangue e comprovante da regularidade. Secretaria de Estado da Saúde. Constitucionalidade.” (ADI 3.512, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 15-2-06, *DJ* de 23-6-06);

“Lacres eletrônicos nos tanques dos postos de combustíveis. Competência concorrente que permite ao Estado regular de forma específica aquilo que a União houver regulado de forma geral.” (ADI 2.334, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 24-4-03, *DJ* de 30-5-03);

“IPVA. Lei estadual. Alíquotas diferenciadas em razão do tipo do veículo. Os Estados-membros estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, no exercício da competência concorrente prevista no artigo 24, § 3º, da Constituição do Brasil. Não há tributo progressivo quando as alíquotas são diferenciadas segundo critérios que não levam em consideração a capacidade contributiva.” (RE 414.259-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 24-6-08, *DJE* de 15-8-08).

265. Sobre o assunto, vejamos abaixo alguns julgados do STF:

“É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.” (STF, SÚM. 645)

“Ação direta. Resolução n. 12.000-001, do Secretário de Segurança do Estado do Piauí. Disciplina do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, consumo e assuntos análogos. Inadmissibilidade. Aparência de ofensa aos arts. 30, I, e 24, V e VI, da CRFB/88. Usurpação de competências legislativas do Município e da União. Liminar concedida com efeito *ex nunc*. Aparenta inconstitucionalidade a resolução de autoridade estadual que, sob pretexto do exercício do poder de polícia, discipline horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, matéria de consumo e assuntos análogos.” (STF, ADI 3.731-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 29-8-07, *DJ* de 11-10-07).

“Os Municípios têm autonomia para regular o horário do comércio local, desde que não

4) Suplementar dos Municípios, na forma do art. 30, II, quando suplementar a legislação federal e estadual, no que couber; (no que tange às matérias do art. 24)

5) Residual, remanescente ou reservada aos Estados, na forma do art. 25, §1º. De acordo com os poderes remanescentes, os Estados poderão legislar sobre assuntos que não foram destinados expressamente à União Federal nem aos Municípios. Como a Constituição destinou muitas competências legislativas aos demais entes, o poder remanescente estadual ficou esvaziado, diante de ser praticamente inexistente legislar sobre assuntos não destinados aos demais entes;

6) Enumeradas ou expressas dos Estados, na forma do art. 25, §2º e §3º. Esses dispositivos apresentam raras competências legislativas reservadas aos Estados expressamente pela Constituição, a saber:

§ 2º - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de para a sua regulamentação.

§3º. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum”.

c) A competência administrativa

As competências de natureza político-administrativas, ainda chamadas de materiais, podem ser:

1) Exclusivas da União Federal, na forma do art. 21. Ressalte-se que não há possibilidade de delegação, tendo em vista que tratam de assuntos que concernem, em sua maioria, ao interesse nacional;

2) Comuns, cumulativas ou paralelas da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, que atuam administrativamente no sentido de preservar todas as matérias presentes no art. 23;

3) Expressas ou enumeradas dos Municípios e do Distrito Federal, na forma do art. 30, III a IX, pois tratam de assuntos de interesse local;

infrinjam leis estaduais ou federais válidas, pois a Constituição lhes confere competência para legislar sobre assuntos de interesse local.” (STF, AI 622.405-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 22-5-07, DJ de 15-6-07)

4) Residual, remanescente ou reservada aos Estados, na forma do art. 25, §1º. Como já tratamos, de acordo com os poderes remanescentes os Estados poderão cuidar dos assuntos que não foram destinados expressamente à União Federal nem aos Municípios. Mais uma vez, podemos reforçar que como a Constituição destinou muitas competências administrativas aos demais entes, o poder remanescente estadual ficou prejudicado.



CAPÍTULO 16

MECANISMOS DE DEFESA DO ESTADO





16.1 DO SISTEMA CONSTITUCIONAL DAS CRISES

A democracia é o equilíbrio mais estável entre os grupos do poder. Segundo José Afonso da Silva²⁶⁶, fora desses parâmetros democráticos, as competições pelo poder geram uma situação de crise, que poderá assumir as características de crise constitucional, e, esta, se não for convenientemente administrada, governada, poderá provocar o rompimento do equilíbrio constitucional e, por conseguinte, pôr em risco as instituições democráticas. O sistema constitucional das crises poderia ser definido como o conjunto ordenado de normas constitucionais que, informadas pelos princípios da necessidade, da proporcionalidade e da temporariedade, têm por objeto as situações de crise e por finalidade o restabelecimento da normalidade constitucional.

As crises podem ser resolvidas com a decretação do estado de exceção (de legalidade extraordinária) que deve cessar, tão logo as situações motivadoras da situação de anormalidade forem extintas.

O Estado de Sítio fora, realmente, o tipo de estado de exceção que tradicionalmente vigorou no Brasil, presente na história do constitucionalismo desde 1934²⁶⁷. Em 13 de dezembro de 1968, o povo brasileiro vivenciou perplexo um estado de legalidade extraordinária permanente com a decretação do Ato institucional nº 5, sendo este último exemplo moderno de situação de “emergência” do país.

O aparato constitucional de 1988 para as situações de crise está centralizado nos arts. 136 a 141, que tratam do estado de defesa e do estado de sítio, que serão brevemente analisados a seguir.

16.2 PRINCÍPIOS INFORMADORES DO ESTADO DE DEFESA E DO ESTADO DE SÍTIO²⁶⁸

- Necessidade – que significa a justificativa imperiosa das medidas, caso contrário estaria configurado um golpe de Estado, simples arbítrio;

266. AFONSO DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo, 23ª ed., Malheiros, São Paulo, 2004, p. 740/741.

267. A título de exemplo: na CRFB 1934, art. 175 – Estado de Sítio; no texto de CRFB 1937, art. 166 – Estado de emergência e em caso de invasão armada, estado de guerra; em 1946, art. 206 – Estado de Sítio; na CRFB 1967, art. 152 – Estado de Sítio; na EC 1/69, art. 155 – Estado de Sítio.

268. AFONSO DA SILVA, José Afonso. Ob. cit. p. 741.

-
- Temporariedade – é necessário que se fixe um tempo limitado para a vigência da legalidade extraordinária;
 - Proporcionalidade - as medidas devem ser proporcionais aos fatos que justificaram a sua adoção.

16.3 REQUISITOS PARA O ESTADO DE DEFESA

São requisitos para o Estado de Defesa, na forma do art. 136:

- a) Existência de grave perturbação da ordem pública ou da paz social, ou ainda, manifestação de calamidade de grandes proporções na natureza que atinja a mesma ordem pública ou a paz social;
- b) Impossibilidade de restabelecer, pelas vias de normalidade, a ordem pública e a paz social;
- c) Consulta prévia ao Conselho da República e da Defesa Nacional;
- d) Determinação, no Decreto do Presidente da República, do tempo de sua duração, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, prorrogáveis por apenas uma vez, por igual período (ou inferior, evidentemente), se persistirem as razões que justificaram a sua decretação;
- e) O ato deverá ser apresentado ao Congresso Nacional em 24h, para que aprecie o decreto. Caso negue, o Estado de Defesa será extinto. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de cinco dias;
- f) Localidade determinada, diferente do Estado de Sítio, que poderá ser decretado em todo território nacional.

16.3.1 Medidas Coercitivas que podem vigorar durante o Estado de Defesa

De acordo com o art. 136, § 1º, I e II, podem ser determinadas as seguintes restrições aos direitos fundamentais:

- a) de reunião, ainda que exercida no seio das associações;
- b) sigilo das correspondências;
- c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;
- d) ocupação e uso temporário de bens e serviços, na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes;

- e) prisão por crime contra o Estado, pelo executor da medida, que deverá comunicá-la, com declaração do estado físico ou mental do detido, ao juiz competente (que deverá ser imediatamente comunicado e relaxará a prisão se esta não for legal). Sendo que a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 (dez) dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário.

Ressalte-se que o preso não pode ficar incomunicável.

16.4 REQUISITOS PARA O ESTADO DE SÍTIO

Na forma do art. 137, I e II e 138, são requisitos para a decretação do estado de sítio:

- a) Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa (137, I); ou ainda declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira (137,II);
- b) Consulta prévia ao Conselho da República e da Defesa Nacional;
- c) Autorização, por parte da maioria absoluta do Congresso Nacional, para que seja decretado, em atendimento à solicitação fundamentada do Presidente da República. Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias, a fim de apreciar o ato;
- d) Prazo, no caso do art. 137, I, de 30 (trinta dias), nem prorrogado, de cada vez por prazo superior (o que se permite mais de uma prorrogação) e na hipótese do art. 137, II, poderá ser mantido por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira;
- e) Pode ser decretado em todo o território nacional.

16.4.1 Medidas que podem vigorar durante o Estado de Sítio

Na vigência do estado de sítio com fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas coercitivas:

-
- a) obrigação de permanência em localidade determinada;
 - b) detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, o que acaba por deter as pessoas em prisão dos quartéis da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica;
 - c) restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei (o que significa necessidade de elaboração de uma lei que preveja a possibilidade e limites dessas restrições, que, como se nota, importam em interceptação e censura aos meios de comunicação em geral; mas não se inclui, nessas restrições, a difusão de pronunciamento de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva Mesa);
 - d) suspensão da liberdade de reunião;
 - e) busca e apreensão em domicílio, o que é uma derrogação da inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5º, XI;
 - f) intervenção nas empresas de serviços públicos (empresas de telecomunicações, de transportes, de fornecimento de água etc);
 - g) requisição de bens;

Quanto ao estado de sítio com fundamento no art. 137, II, não há previsão constitucional expressa sobre as restrições aos direitos fundamentais, mas é sabido que as medidas devem respeitar aos princípios informadores do estado de legalidade extraordinário: necessidade, temporariedade e proporcionalidade.

16.5 CONTROLE POLÍTICO E JURISDICIONAL

Importante destacar que o estado de sítio e o de defesa não podem configurar situações de arbítrio, porque são medidas constitucionalmente regradas. Ambas estão sujeitas ao controle político e jurisdicional. Qualquer pessoa prejudicada por medidas ou providências do Presidente da República ou de seus delegados, executores ou agentes, com inobservância das prescrições constitucionais não excepcionadas e das constantes dos arts. 136 e 139, tem o direito de recorrer ao Poder Judiciário para responsabilizá-lo e pedir a reparação do dano que lhe tenha sido causado.

Estado de Defesa x Estado de Sítio

	Estado de Defesa	Estado de Sítio
Base legal	Art. 136 da CRFB/88	Arts. 137 da CRFB/88
Prazo	Máximo de 30 dias podendo ser prorrogado por mais 30 dias, uma única vez. Art. 136, § 2º da CRFB/88	- No caso do inciso I do art. 137 da CRFB/88: 30 dias, não prorrogado, de cada vez por prazo superior (o que se permite mais de uma prorrogação). - No caso do inciso II do art. 137 da CRFB/88: poderá ser mantido por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira.
Prévia autorização do Congresso Nacional?	Não	Sim. Art. 137, parágrafo único da CRFB/88
Consulta prévia ao Conselho da República e da Defesa Nacional	Sim. Art. 136, caput da CRFB/88	Sim. Art. 137, caput da CRFB/88
Abrangência	Localidade determinada	Pode ser decretado em todo território nacional

**Direitos
fundamentais
sujeitos à
restrição**

De acordo com o art. 136, §§ 1º e 3º da CRFB/88:

a) de reunião, ainda que exercida no seio das associações; b) sigilo das correspondências; c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica; d) ocupação e uso temporário de bens e serviços, na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes; e) prisão por crime contra o Estado, pelo executor da medida, que deverá comunicá-la, com declaração do estado físico ou mental do detido, ao juiz competente (que deverá ser imediatamente comunicado e relaxará a prisão se esta não for legal). Sendo que a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Obs.: O preso não pode ficar incomunicável.

De acordo com o art. 139, da CRFB/88:

- No caso do inciso I do art. 137 da CRFB/88:

a) obrigação de permanência em determinada localidade; b) detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns (o que acaba por deter as pessoas em prisão dos quartéis da Marinha ou da Aeronáutica); c) restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei (o que significa necessidade de elaboração de uma lei que preveja a possibilidade e limites dessas restrições). Não se inclui, nessas restrições, a difusão de pronunciamento de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa; d) suspensão da liberdade de reunião; e) busca e apreensão em domicílio; f) intervenção nas empresas de serviços públicos; g) reaqusição de bens.

- No caso do inciso II do art. 137 da CRFB/88: não há previsão constitucional expressa, mas as medidas devem respeitar aos princípios informadores do estado de legalidade extraordinário: necessidade, temporariedade e proporcionalidade.

Além da dignidade da pessoa humana.

CAPÍTULO 17

PODER LEGISLATIVO

17.1 CONCEITO

A sua função típica é a de elaborar normas genéricas e abstratas dotadas de força proeminente dentro do ordenamento jurídico, as quais se denominam leis e também a de fiscalizar a atuação contábil da administração pública, na forma do art. 70. Mas também exerce subsidiariamente as funções executiva e judicial, por exemplo, quando faz concurso para seus cargos e quando julga o Presidente da República por crime de responsabilidade.

Exercício da função legislativa: A função legislativa federal é exercida pelo Congresso Nacional, que é um órgão bicameral, ou seja, formado de duas Casas, o Senado Federal (representação dos Estados e do Distrito Federal, art. 46, CRFB/88) e a Câmara dos Deputados (representação do povo, art. 45, CRFB/88). Entre as duas Casas não há qualquer relação de hierarquia ou predominância. No entanto, no processo legislativo, os projetos de iniciativa do Presidente da República, STF, STJ e dos cidadãos começam a sua tramitação na Câmara dos Deputados. Diferentemente do Poder Legislativo Federal, no Poder legislativo estadual, distrital e municipal o sistema é unicameral (arts. 27, 32 e 29, CRFB/88).

Órgãos internos das casas do Congresso Nacional

- - Mesas:

Da Câmara - art. 57, § 4º; 58, § 1º, CRFB/88;

Do Senado - art. 57, § 4º; 58, § 1º, CRFB/88;

Do Congresso - art. 57, § 5º; 58, § 1º, CRFB/88.

- - Comissões Parlamentares (art. 58, CRFB/88):

Permanentes - Subsistem por todas as legislaturas;

Temporárias - Constituídas apenas para opinar sobre determinada matéria;

De Inquérito (CPI) - art. 58, § 3º;

Representativa - Durante o recesso- art. 58, § 4º.

Períodos de atividade:

As atividades do CN são exercidas nos seguintes períodos:

Legislatura: Na forma do art. 44, parágrafo único, da CRFB/88, é o período de 4 anos, que equivale ao mandato dos Deputados. O mandato dos Senadores equivale a duas legislaturas (8 anos).

Sessão Legislativa: é o período anual em que deve estar reunido o Congresso para os trabalhos legislativos. Art. 57, da CRFB/88.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

É composta por representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em cada Estado, Território e no Distrito Federal, sendo que o número de deputados será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, nos termos do art. 45, § 1º. A duração do mandato dos Deputados será de 4 (quatro) anos. Segundo o art. 45, § 2º, cada Território elegerá 4 (quatro) Deputados.

SENADO FEDERAL

Compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário, sendo que cada um terá o número fixo de 3 (três) senadores, com mandato de oito anos. A sua renovação acontecerá, parcialmente, de quatro em quatro anos, alternadamente, por um ou dois terços do Senado Federal (art. 46, § 2º, CRFB/88). A representação é uniforme em nome do chamado “equilíbrio federativo”. Território não elege Senador!

17.2 ESTATUTO DOS CONGRESSISTAS

É o regime jurídico dos membros do Congresso Nacional, disciplinando direitos, deveres, impedimentos, incompatibilidades, imunidades, prerrogativas (arts. 53 a 56, CRFB/88). As imunidades parlamentares não existem para proteger o parlamentar em suas relações de cunho particular; são prerrogativas decorrentes de sua função e são estabelecidas muito mais em favor do Poder Legislativo do que do Deputado ou Senador individualmente considerados. Dividem-se em:

Imunidade material: art. 53, caput;

Imunidade formal: §2º a §5º do art. 53;

Prerrogativa de foro: art. 53, § 1º - STF;

Isenção do dever de testemunhar: art. 53, § 6º;

Serviço militar: art. 53, § 7º, c/c 143;

Imunidades durante o estado de sítio art. 53, p. 8;

Incompatibilidades (art. 54).

Importante destacar que os suplentes não gozam das imunidades materiais e formais porque não desempenham as funções do mandato. Também é importante frisar que as imunidades são irrenunciáveis, pois pertencem ao cargo e não ao parlamentar.

a) Prerrogativa de Foro

Art. 53. (...) § 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

O dispositivo constitucional em apreço trata da prerrogativa de foro criminal para julgamento de parlamentar enquanto estiver no exercício da atividade pública (obedecendo-se à regra da atualidade do mandato), mas nem sempre foi assim.

Em breves observações sobre o assunto, a Súmula nº 394 do STF previu durante muitos anos a prorrogação de competência da Corte para julgamento criminal de ex-parlamentares, ferindo o princípio da igualdade. Em 2002, a Lei nº 10.628/2002 reacendeu a chama da já cancelada súmula, prevendo o retorno da prorrogação de competência, tendo sido declarada inconstitucional pelo STF por meio da ADI 2.797.

Com a atual disposição constitucional, podemos observar três situações:

- se o parlamentar houver cometido o crime antes da diplomação (ato que comprova a realização de uma eleição válida e é anterior à posse), esse processo inicia o trâmite perante a justiça comum; mas uma vez diplomado, o processo segue para julgamento no STF;
- a prática de crime pelo parlamentar após a diplomação leva-o a julgamento direto perante a Corte;
- se o crime for cometido após o fim do mandato, não há prerrogativa.

É importante destacar que a regra da atualidade do mandato é excepcionada em caso de abuso de direito, como por exemplo: se o parlamentar renunciar às vésperas do julgamento, com o objetivo claro de procrastinar a decisão final, o STF já decidiu que a sua competência prorrogar-se-á e que a Corte julgará o ex-membro do Parlamento.

Segundo entendimento do STF, o parlamentar licenciado na forma do art. 56, I, terá as suas imunidades suspensas, entretanto, será mantida a prerrogativa de foro funcional, tendo em vista que o seu cargo de parlamentar foi mantido.

b) Imunidade Material

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

A imunidade material implica subtração da responsabilidade penal, civil, disciplinar ou política do parlamentar, por suas opiniões, palavras e votos. Trata-se de cláusula de irresponsabilidade geral de Direito Constitucional material e garante que o congressista exerça a sua atividade com a mais ampla liberdade de manifestação. A isenção de responsabilidade é total, não podendo o parlamentar responder por qualquer dos chamados delitos de opinião (calúnia, injúria, difamação, desacato...). Refere-se somente a atos funcionais, ainda que não exercidos exclusivamente no âmbito do Congresso Nacional. Os pronunciamentos feitos à rede televisiva, aos jornais e revistas estão, em regra, protegidos por esta imunidade, desde que relacionados à função parlamentar.

c) Imunidade Formal

A imunidade formal se refere à impossibilidade de prisão do parlamentar e também sobre as regras especiais relativas ao processo, presentes no art. 53, § 2º e § 3º, a seguir transcritos.

§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.

§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.

Com relação à prisão, o parlamentar só poderá ser preso no caso de flagrante de crime inafiançável e, ainda assim, a manutenção da sua prisão ainda será resolvida pela casa parlamentar respectiva. A palavra “prisão” deve ser entendida em sentido amplo: o parlamentar não pode sofrer qualquer tipo de prisão: temporária, prisão em flagrante por crime afiançável, prisão preventiva etc. Segundo a doutrina, além da prisão em

flagrante por crime inafiançável, o parlamentar pode ser preso em razão de sentença condenatória criminal transitada em julgado.

Com relação à imunidade formal processual, oferecida a denúncia, o processo contra parlamentares tramita normalmente, podendo a casa a que pertence o denunciado deliberar sobre a sua sustação. De acordo com o texto constitucional, a deliberação pode ser feita até a decisão final do processo (trânsito em julgado) e deve, obrigatoriamente, ser apreciada no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do recebimento do pedido pela Mesa Diretora. Os legitimados para formular pedido de sustação de ações criminais contra parlamentares são os partidos políticos com representação na Casa do denunciado (não precisa ser do mesmo partido do parlamentar acusado).

Importante destacar que a imunidade formal processual só alcança o parlamentar que cometer crime após a diplomação. Aquele que cometer crime antes da diplomação não terá direito à referida imunidade.

Destacamos, também, que sobre as regras relativas ao processo, a EC no 35/2001 alterou substancialmente o instituto da imunidade formal. Antes da reforma, para que os parlamentares fossem processados durante os seus mandatos, era necessária licença da Casa Legislativa à qual pertenciam. Diante dos insucessos das autorizações, transformando-se imunidade em impunidade, a reforma constitucional dispensou a licença legislativa. Desde então, o STF tem competência para dar início ao processo contra o parlamentar, devendo apenas dar ciência à Casa à qual o parlamentar pertence.

Imunidades de Deputados Estaduais, Distritais e Vereadores

Art. 27. (...) § 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

Art. 32. (...) § 3º Aos Deputados Distritais e à Câmara legislativa aplica-se o disposto no art. 27.

Art. 29. (...) VIII – inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

De acordo com o acima disposto, Deputados estaduais e distritais gozam das mesmas imunidades, materiais e formais, destinadas aos parlamentares federais, inclusive quanto à prerrogativa de foro para julgamento criminal perante os respectivos Tribunais de Justiça (inclusive quanto à prática de crimes dolosos contra a vida).

Como aplicamos aos Deputados Estaduais e Distritais a Súmula 702, do STF (*A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau*). Caso eles cometam crimes federais, serão julgados pelo TRF e, caso o crime seja eleitoral, pelo TRE.

Os vereadores, entretanto, possuem apenas imunidade material,²⁶⁹ no limite da circunscrição de seus respectivos Municípios, não usufruindo das imunidades formais já detalhadas, sendo, entretanto, permitido que as Constituições estaduais e leis orgânicas municipais disponham sobre eventual prerrogativa de foro, desde que respeitada a Súmula Vinculante 45: *A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela constituição estadual*.

Com isso, concluímos que vereadores são julgados pelo júri pela prática de crime doloso contra a vida.

Imunidades Durante Estado de Defesa e Estado de Sítio

Art. 53. (...) § 8º As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso

269. “O texto da atual Constituição, relativamente aos Vereadores, refere à inviolabilidade no exercício do mandato e na circunscrição do Município. Há necessidade, portanto, de se verificar a existência do nexo entre o mandato e as manifestações que ele faça na Câmara Municipal, ou fora dela, observados os limites do Município. No caso, esses requisitos foram atendidos. As manifestações do paciente visavam proteger o mandato parlamentar e a sua própria honra. Utilizou-se, para tanto, de instrumentos condizentes com o tipo de acusação e denúncia que lhe foram feitas pelo Delegado de Polícia. Ficou evidenciado que as referidas acusações e ameaças só ocorreram porque o paciente é Vereador. A nota por ele publicada no jornal, bem como a manifestação através do rádio, estão absolutamente ligadas ao exercício parlamentar. Caracterizado o nexo entre o exercício do mandato e as manifestações do paciente Vereador, prepondera a inviolabilidade. Habeas deferido” (STF, HC no 81.730/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 18.06.2002, DJ 1º.08.2003).

Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida.

Da exegese do dispositivo acima, é possível se concluir que as imunidades não poderão ser suspensas durante o estado de defesa (situação de emergência menos grave do que o estado de sítio), sendo passíveis de restrições durante o estado de sítio, se preenchidos os requisitos constitucionais: voto de dois terços de seus membros + nos casos de atos praticados fora do recinto (desde que sejam incompatíveis com a execução das medidas).

Isenção do Serviço Militar

Art. 53. (...) § 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.

Como o serviço militar obrigatório é imposto a todos, na forma do art. 143, essa disposição se assemelha à de uma verdadeira imunidade, que impõe, ainda que em tempo de guerra, a licença da Casa Legislativa respectiva, mesmo que se trate de parlamentar militar.

Limitação ao Dever de Testemunhar

Art. 53. (...) § 6º Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.

Os deputados e senadores devem se apresentar como testemunhas em juízo sobre fatos de seu conhecimento que sejam indispensáveis à instrução de processo criminal ou cível, não sendo, contudo, instados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.

As Incompatibilidades

Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:

I – desde a expedição do diploma:

- a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;*
- b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado,*

inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior;

II – desde a posse:

- a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;*
- b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas no inciso I, a;*
- c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, a;*
- d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.*

O art. 54 traz as chamadas incompatibilidades dos deputados e senadores que configuram vedações acerca de certas funções, ocupações ou atividades que não podem ser realizadas, sob pena da perda do cargo, algumas fixadas desde a diplomação, outras a partir da sua posse. José Afonso da Silva²⁷⁰ as divide em:

- a) Funcionais**, desde a expedição do diploma não podem: *aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis “ad nutum”, em pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público (art. 54, I, “b”) e, ainda, desde a posse: ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis “ad nutum” naquelas mesmas entidades (art. 54, II, “b”), salvo nas hipóteses permitidas no art. 56, I.*
- b) Negociais**, desde a expedição do diploma estão impedidos de: *firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes (art. 54, I, “a”).*
Ressalte-se que contrato com cláusula uniforme é aquele que deixa pouquíssima margem de negociação inerente à autonomia privada; são os chamados “contrato de adesão”.
- c) Políticas**, desde a posse não podem: *ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo (art. 54, II, “d”).*

270. AFONSO DA SILVA, José. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 422.

- d) **Profissionais**, desde a posse estão impedidos de: *ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada (art. 54, II, "a") e, ainda, de: patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, "a" (art. 54, II, "c").*

Perda do Cargo

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I – que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;

III – que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada;

IV – que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição;

VI – que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo,

terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º.

A sanção da violação das incompatibilidades do art. 54 é a perda do mandato, na forma do art. 55, I. Da mesma maneira, perderá o cargo o parlamentar que atue de maneira contrária ao decoro parlamentar (conjunto de normas éticas e morais que devem nortear a sua conduta no exercício da função pública), conforme o art. 55, II. Também perderá o cargo o parlamentar que faltar, sem licença da Casa, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias. Sofrerá igualmente a sanção aquele que tiver suspensos, ou perder os direitos políticos (art. 55, IV), ou quando o decretar a Justiça Eleitoral (art. 55, V), ou ainda, quando o parlamentar sofrer condenação criminal transitada em julgado (art. 55, VI).

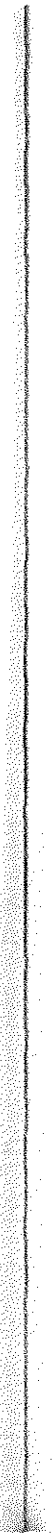
Como se verifica dos parágrafos do art. 55, nenhuma dessas situações gera uma perda automática, garantida em todas as situações a ampla defesa. Nos casos do art. 55, § 3º, a decretação da perda seria um ato vinculado e, por sua vez, as hipóteses do art. 55, § 2º, seriam ato discricionário da Mesa da Casa a qual pertence o parlamentar, segundo afirma parte da doutrina.²⁷¹ Entretanto, no caso recente do “Mensalão” (AP 470), o STF decidiu que em caso de sentença criminal transitada em julgado a Mesa da Casa não possui discricionariedade de decisão sobre a perda ou não do mandato, devendo apenas cumprir o que o Tribunal decidiu.

Para que o parlamentar não fuja das consequências da decretação da perda do mandato, o art. 55, § 4º, anuncia que a renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os dispositivos constitucionais.

271. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 34. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 181.

CAPÍTULO 18

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO



18.1 COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI)

No exercício de uma de suas funções principais, a de fiscalizar, a CPI é uma comissão temporária, com atribuição de fiscalização político-administrativa. Seu escopo não é apurar crimes, tampouco puni-los, competência esta do Poder Judiciário. Se, no curso de uma investigação, vier a se deparar com fato criminoso, dele dará ciência ao Ministério Público, para os fins de direito.

18.2 REQUISITOS PARA SUA CRIAÇÃO

De acordo com o art. 58, § 3º, os requisitos constitucionais necessários para a abertura da CPI são:

1) requerimento de um terço dos membros da Câmara e/ou um terço das assinaturas de Senadores; podendo ser a CPI instaurada em uma das Casas ou nas duas, desde que, neste último caso, o requerimento seja subscrito por Deputados e Senadores;

2) apuração de fato determinado, ou seja, direcionado para alguma situação específica; nada impede que os fatos surgidos no decorrer das investigações que tenham pertinência com o fato principal também sejam apurados²⁷²;

3) prazo certo, mas segundo orientação do STF são admissíveis prorrogações sucessivas do prazo inicialmente fixado para uma CPI, desde que dentro do período correspondente à legislatura em que se iniciou.

272 "A comissão parlamentar de inquérito deve apurar fato determinado. CRFB/88, art. 58, § 3º. Todavia, não está impedida de investigar fatos que se ligam, intimamente, com o fato principal." (STF, HC 71.231, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 5-5-94, DJ de 31-10-96).

18.3 CPI NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

É possível a criação de CPI's Estaduais, Distritais²⁷³ e Municipais²⁷⁴ desde que haja previsão nas respectivas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais. Imperioso destacar que as referidas Comissões devem obedecer ao princípio da simetria e devem ser abertas para apurar fatos direcionados ao Estado ou ao Município, conforme o caso, em nome da preservação do Pacto Federativo²⁷⁵. O STF também decidiu que as assinaturas para a abertura da CPI não se submetem à votação dos plenários das Casas em nome do direito das minorias Parlamentares²⁷⁶.

273 "A Câmara do Distrito Federal ombréia, sob o ângulo da atuação, com as Assembléias Legislativas, tendo-se, em linhas gerais, simples distinção de nomenclaturas." (STF, ACO 796-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, julgamento em 19-8-05, DJ de 26-8-05)

274 "Constitucionalidade do art. 12 da Constituição gaúcha, que assegura às câmaras municipais, no exercício de suas funções legislativas e fiscalizadoras, a prerrogativa de solicitarem informações aos órgãos da administração direta e indireta, situados no respectivo município." (STF, ADI 1.001, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 8-8-02, DJ de 21-2-03)

275. "A possibilidade de criação de CPI se não duvida, nem discute; é tranquila; sobre todo e qualquer assunto? Evidentemente, não; mas sobre todos os assuntos de competência da Assembleia; assim, Câmara e Senado podem investigar questões relacionadas com a esfera federal de governo; tudo quanto o Congresso pode regular, cabe-lhe investigar; segundo Bernard Schwartz, o poder investigatório do Congresso se estende a toda a gama dos interesses nacionais a respeito dos quais ele pode legislar, "it may be employed over the Whole range of the national interests concerning which the Congress may legislate or decide", A Commentary on the Constitution of the United States, 1963, I, n. 42, p. 126. O mesmo vale dizer em relação às CPI's estaduais; seu raio de ação é circunscrito aos interesses do estado; da mesma forma quanto às comissões municipais, que hão de limitar-se às questões de competência do município. " (STF, HC 71.039, voto do Min. Paulo Brossard, julgamento em 7-4-94, DJ 6-12-96)

276. "Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 34, § 1º, e 170, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Comissão Parlamentar de Inquérito. Criação. Deliberação do Plenário da assembleia legislativa. Requisito que não encontra respaldo no texto da Constituição do Brasil. Simetria. Observância compulsória pelos estados-membros. Violação do artigo 58, § 3º, da Constituição do Brasil. A Constituição do Brasil assegura a um terço dos membros da Câmara dos Deputados e a um terço dos membros do Senado Federal a criação da comissão parlamentar de inquérito, deixando, porém ao próprio parlamento o seu destino. A garantia assegurada a um terço dos membros da Câmara ou do Senado estende-se aos membros das assembleias legislativas estaduais — garantia das minorias. O modelo federal de criação e instauração das comissões parlamentares de inquérito constitui matéria a ser compulsoriamente observada pelas casas legislativas estaduais. A garantia da instalação da CPI independe de deliberação plenária, seja da Câmara, do Senado ou da Assembleia Legislativa. Precedentes. Não há razão para a submissão do requerimento de constituição de CPI a qualquer órgão da Assembleia Legislativa. Os requisitos indispensáveis à criação das comissões parlamentares de inquérito

18.4 PODERES DAS CPI

Têm poderes imanescentes ao natural exercício de suas competências, como colher depoimentos, ouvir indiciados, inquirir testemunhas (inclusive sob condução coercitiva), notificando-as a comparecer perante ela e a depor. Não tem o poder de ordenar a prisão de investigado, porque não possui competência para tanto.

Além das competências acima citadas, a CPI pode, por ato próprio:

- a) autorizar quebra de sigilo de dados bancário, telefônico e fiscal dos indiciados, desde que haja fundamentação, comprovando a existência de causa provável que indique a necessidade da quebra do sigilo;
- b) requisitar aos órgãos públicos documentos e informações necessárias para a investigação;
- c) promover a pertinente investigação, ainda que os atos investigatórios possam incidir, eventualmente, sobre aspectos referentes a acontecimentos sujeitos a inquéritos policiais ou a processos judiciais que guardem conexão com o evento principal objeto da apuração congressual.

18.5 VEDAÇÕES À CPI

Por uma necessidade funcional, a comissão parlamentar de inquérito não detém poderes universais de investigação. Suas atribuições são limitadas, porque se restringem a fatos determinados. No entanto, podem existir tantas comissões quantas forem necessárias para se realizar investigações recomendáveis. Os eventuais excessos da CPI serão controlados pelo STF.

A CPI não pode:

- a) proibir alguém de se ausentar de determinada localidade ou de sair do país;
- b) expedir decreto de indisponibilidade de bens de particular;
- c) determinar a interceptação telefônica;

estão dispostos, estritamente, no artigo 58 da CB/88. Pedido julgado procedente para declarar inconstitucionais o trecho 'só será submetido à discussão e votação decorridas 24 horas de sua apresentação, e, constante do § 1º do artigo 34, e o inciso I do artigo 170, ambos da Consolidação do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.' (STF, ADI 3.619, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 1º-8-06, DJ de 20-4-07)

-
- d) determinar busca e apreensão domiciliar de documentos e demais objetos de interesses da investigação.

Competência para Julgar Atos da CPI

Compete ao STF processar e julgar, em sede originária, mandados de segurança e habeas corpus impetrados contra Comissões Parlamentares de Inquérito constituídas no âmbito do Congresso Nacional ou em qualquer de suas Casas.

Ciência ao Ministério Público

A Constituição Federal, no § 3º do seu art. 58, dispõe que as conclusões da CPI, “se for o caso”, serão encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores. Com isso, o STF entendeu que somente a comissão poderá decidir se se verifica, ou não, a hipótese do referido encaminhamento das conclusões, o que não implica, necessariamente, que sejam elas acompanhadas dos documentos sigilosos.

Quórum para Deliberação

Segundo orientação jurisprudencial, a observância do quórum previsto regimentalmente para deliberação – maioria absoluta dos membros que integram a comissão – é formalidade essencial à validade das decisões da Comissão, presente ato de constrição a alcançar terceiro.

Imunidades Parlamentares e CPI

A liberdade de manifestação do parlamentar que configura a sua imunidade material deverá ser respeitada em sede de CPI, quando convocado a prestar depoimento.

Convocação de Magistrado e CPI

O magistrado pode ser convocado para falar em sede de CPI desde que para tratar de questões administrativas e não jurisdicionais, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

18.6 POSIÇÃO DO STF SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO

“O privilégio contra a auto-incriminação — que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito — traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa,

que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio — enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) — impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado(...) .” (HC 79.812, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16/02/01)

CAPÍTULO 19

TRIBUNAIS DE CONTAS



Conforme já estudamos, o Poder Legislativo realiza como uma de suas atividades típicas a função de fiscalização contábil, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, mediante controle externo, auxiliado pelo Tribunal de Contas (arts. 70 e 71 da CRFB/88).

Além do sistema externo, de acordo com o art. 74 da CRFB/88, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, reforçado pela regra presente no art. 74, § 1º, na medida em que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela deverão dar ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

19.1 HISTÓRICO DO TRIBUNAL DE CONTAS

As discussões em torno da criação de um Tribunal de Contas começaram em 1826 e duraram quase um século, polarizadas entre aqueles que defendiam a sua necessidade – para quem as contas públicas deviam ser examinadas por um órgão independente –, e aqueles que o combatiam, por entenderem que as contas públicas podiam continuar sendo controladas por aqueles mesmos que as realizavam.

Somente a queda do Império e as reformas político-administrativas da jovem República tornaram realidade, finalmente, o Tribunal de Contas da União. Em 7 de novembro de 1890, por iniciativa do então Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, o Decreto nº 966-A criou o Tribunal de Contas da União, norteado pelos princípios da autonomia, fiscalização, julgamento e vigilância. A Constituição de 1891, a primeira republicana, ainda por influência de Rui Barbosa, institucionalizou definitivamente o Tribunal de Contas da União, inscrevendo-o no seu art. 89. Contudo a sua instalação só ocorreu em 1893.

O Tribunal foi mantido em todas as Constituições seguintes, mas, na atual Constituição a sua jurisdição (administrativa) e competência foram substancialmente ampliadas, como analisaremos neste capítulo.

19.2 CARACTERÍSTICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

O Tribunal de Contas tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.

Importante destacar que a expressão “jurisdição” é utilizada no seu sentido administrativo, tendo em vista que o referido tribunal não exerce atividade jurisdicional típica. Os seus atos são de natureza técnica e administrativa e não integra o Poder Judiciário.

É órgão auxiliar do Congresso Nacional e sua relação com este é de colaboração, e não de subordinação. Em que pese a natureza de órgão auxiliar do Legislativo, o Tribunal de Contas da União possui atribuições próprias, enumeradas nos incisos do art. 71 da Constituição Federal.

Nesse sentido, é importante transcrevermos decisão do STF em defesa da autonomia da Corte de Contas: *A posição constitucional dos Tribunais de Contas – órgãos investidos de autonomia jurídica – inexistência de qualquer vínculo de subordinação institucional ao Poder Legislativo – atribuições do Tribunal de Contas que traduzem direta emanção da própria Constituição da República. Os Tribunais de Contas ostentam posição eminente na estrutura constitucional brasileira, não se achando subordinados, por qualquer vínculo de ordem hierárquica, ao Poder Legislativo, de que não são órgãos delegatários nem organismos de mero assessoramento técnico. A competência institucional dos Tribunais de Contas não deriva, por isso mesmo, de delegação dos órgãos do Poder Legislativo, mas traduz emanção que resulta, primariamente, da própria Constituição da República. Doutrina. Precedentes...*²⁷⁷ (grifos nossos).

19.3 MINISTROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

O Tribunal de Contas da União é integrado por nove ministros, nomeados entre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos, previstos no art. 73, da CRFB/88: I – mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade; II – idoneidade moral e reputação ilibada; III – notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública e; IV – mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade

277. STF, ADI 4.190-REF-MC/RJ. Rel. Min. Celso de Mello. Plenário, j. 10.03-2010, DJE 11.06.2010.

profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Eles serão escolhidos da seguinte forma: um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento e dois terços pelo Congresso Nacional.

Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40 da CRFB/88.

19.4 O MINISTÉRIO PÚBLICO PERANTE O TCU

Segundo precedente do STF²⁷⁸ os Procuradores das Cortes de Contas são ligados administrativamente a elas, sem qualquer vínculo com o Ministério Público comum, tendo em vista que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União é instituição que não integra o Ministério Público da União, cujo rol no art. 128, I, da CRFB/88 é taxativo.

Assim, não se permite que membros do Ministério Público estadual sejam “aproveitados” para atuar junto ao Tribunal de Contas.

19.5 ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE O TCU

O TCU não Dispõe de Competência para Determinar a Quebra do Sigilo Bancário

O STF entendeu que a Lei Complementar nº 105/2001, que dispôs específica e exaustivamente sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, não conferiu ao TCU poderes para determinar a quebra do sigilo bancário de dados constantes do Banco Central do Brasil. Asseverou-se que o art. 38 da Lei nº 4.595/64, que regulava o sigilo das operações ativas e passivas e serviços prestados pelas instituições financeiras, foi revogado pela referida lei complementar, que previu a possibilidade de quebra do sigilo bancário por determinação do Poder Judiciário, do Poder Legislativo federal, bem como das Comissões Parlamentares de Inquérito, após prévia aprovação do pedido pelo Plenário da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do plenário de suas respectivas comissões parlamentares de

278. STF, ADI 3.315/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.03.2008, Plenário, DJE 11.04.2008.

inquérito (Lei Complementar nº 105/2001, arts. 3º e 4º, §§ 1º e 2º)²⁷⁹.

A Denúncia Anônima Não Pode, Por Si, Justificar a Condenação de Investigado (ou Réu), mas Pode ser Aceita Para Iniciar um Procedimento Investigativo Sigiloso, Voltado a Apurar a Existência dos Fatos Apontados pelo Denunciante

Segundo o Ministro Celso de Mello, os escritos anônimos não podem justificar, por si sós, desde que isoladamente considerados, a imediata instauração da *persecutio criminis*, eis que peças apócrifas não podem ser incorporadas, formalmente, ao processo, salvo quando tais documentos forem produzidos pelo acusado, ou, ainda, quando constituírem, eles próprios, o corpo de delito (como sucede com bilhetes de resgate no delito de extorsão mediante sequestro, ou como ocorre com cartas que evidenciem a prática de crimes contra a honra, por exemplo). Nada impede, contudo, que o Poder Público, provocado por delação anônima (“disque-denúncia”, p. ex.), adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, “com prudência e discrição”, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da *persecutio criminis*, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas.²⁸⁰

O Tribunal de Contas, no Desempenho de suas Atribuições, Pode Realizar Controle de Constitucionalidade das Leis

O entendimento do STF sobre essa questão está consolidado na Súmula nº 347, nos termos seguintes: *O tribunal de contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público*. Com isso é possível que a Corte de Contas rejeite a prestação de contas fundada em lei inconstitucional.

Importante ressaltar que o controle de constitucionalidade realizado pelos tribunais de contas é do tipo **incidental**, isto é, realizado diante de casos concretos submetidos à sua apreciação.

Contraditório e Ampla Defesa nos Processos de Competência do TCU

Acerca desse assunto, dispõe a Súmula Vinculante nº 3 do STF: *Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar*

279. STF, MS 22801/DF, Plenário, DJ 14.03.2008, Rel. Min. Menezes Direito, 17.12.2007

280. STF, HC 95.244/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, 23.03.2010.

anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão (grifamos).

O STF, em recente julgado,²⁸¹ firmou entendimento que constitui verdadeira exceção à aplicação da parte final da sua Súmula Vinculante nº 3, conforme explicações abaixo.

Anote-se que, pelo trecho da Súmula acima destacado, não se asseguram ao interessado o contraditório e a ampla defesa nos casos de processos referentes à apreciação da legalidade do ato inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Entretanto, em respeito à segurança jurídica, e considerando o prazo de cinco anos previsto na Lei nº 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo Federal) para que a Administração anule um ato administrativo quando favorável ao administrado, o próprio STF passou a entender que o TCU está obrigado a assegurar o contraditório e a ampla defesa ao interessado mesmo nesses casos – apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão – *quando essa Corte de Contas só verificar a irregularidade do ato de concessão de tais benefícios após o prazo de cinco anos, contados da data de sua concessão*.

As Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista, Integrantes da Administração Indireta, estão Sujeitas à Fiscalização do TCU?

281. “Em conclusão, o Tribunal, por maioria, concedeu mandado de segurança para anular acórdão do TCU no que se refere ao impetrante e para o fim de se lhe assegurar a oportunidade do uso das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Na situação dos autos, a Corte de Contas nega registro a ato de aposentadoria especial de professor – outorgada ao impetrante – por considerar indevido o cômputo de serviço prestado sem contrato formal e sem o recolhimento das contribuições previdenciárias – v. Informativos 415, 469, 589 e 590. Não obstante admitindo o fato de que a relação jurídica estabelecida no caso se dá entre o TCU e a Administração Pública, o que, em princípio, não reclamaria a audição da parte diretamente interessada, entendeu-se, tendo em conta o longo decurso de tempo da percepção da aposentadoria até a negativa do registro (cinco anos e oito meses), haver direito líquido e certo do impetrante de exercer as garantias do contraditório e da ampla defesa. Considerou-se, ao invocar os princípios da segurança jurídica e da lealdade, ser imperioso reconhecer determinadas situações jurídicas subjetivas em face do Poder Público. Salientou-se a necessidade de se fixar um tempo médio razoável a ser aplicado aos processos de contas cujo objeto seja o exame da legalidade dos atos concessivos de aposentadorias, reformas e pensões, e afirmou-se poder se extrair, dos prazos existentes no ordenamento jurídico brasileiro, o referencial de cinco anos. Com base nisso, assentou-se que, transcorrido in albis o prazo quinquenal, haver-se-ia de convocar o particular para fazer parte do processo de seu interesse”. STF, MS 25116/DF. Info no 599 – não há DJ. Rel. Min. Ayres Britto, 08.09.2010.

De acordo com a jurisprudência do STF, a Constituição da República, art. 71, II, estabelece competir ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Expressamente, pois, a Constituição submete à fiscalização do Tribunal de Contas da União as contas dos administradores de entidades que integram a Administração indireta, dentre elas, **as empresas públicas e as sociedades de economia mista**.²⁸²

19.6 OS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros.

O dispositivo constitucional acima transcrito fundamenta a obrigatoriedade da criação de uma Corte de Contas nos Estados, a qual, em nome do princípio da simetria, deverá ter atribuições similares às do Tribunal de Contas da União, sob pena da declaração de inconstitucionalidade das normas estaduais.²⁸³

282. STF, MS 25.092/DF, Plenário, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 10.11.2005, DJ 17.03.2006.

283. “Tribunal de Contas. Norma local que obriga o Tribunal de Contas Estadual a examinar previamente a validade de contratos firmados pela administração. Regra da simetria. Inexistência de obrigação semelhante imposta ao Tribunal de Contas da União. Nos termos do art. 75 da Constituição, as normas relativas à organização e fiscalização do TCU se aplicam aos demais tribunais de contas. O art. 71 da Constituição não insere na competência do TCU a aptidão para examinar, previamente, a validade de contratos administrativos celebrados pelo Poder Público. Atividade que se insere no acervo de competência da Função Executiva. É inconstitucional norma local que estabeleça a competência do tribunal de contas para realizar exame prévio de validade de contratos firmados com o Poder Público” (STF, ADI 916/MT, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 02.02.2009, Plenário, DJE 06.03.2009).

Com isso, concluímos que a Constituição do Estado não pode outorgar competência para que a Assembleia Legislativa julgue as próprias contas e as dos administradores dos Poderes Executivo e Judiciário sem o auxílio do Corte de Contas Estadual.

Quanto à composição do Tribunal de Contas dos Estados, a Súmula nº 653 do STF determina: *No Tribunal de Contas estadual, composto por sete Conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro à sua livre escolha.*

Os Conselheiros dos tribunais de contas dos estados são julgados perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), na forma do art. 105, I, *a*, em que pese os membros da Assembleia legislativa (deputados estaduais) serem julgados pelos tribunais de justiça locais, conforme prevê o art. 27, § 1º.

19.7 OS TRIBUNAIS DE CONTAS MUNICIPAIS

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

§ 4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.

Segundo entendimento doutrinário, a proibição a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais, prevista no § 4º do art. 31 da Constituição Federal, dirige-se exclusivamente aos municípios, que não poderão criar esses órgãos como integrantes da estrutura orgânica municipal. Significa dizer que essa vedação *não alcança os Estados-membros*,²⁸⁴ que podem, discricionariamente, criar ou extinguir tribunais ou conselhos de contas municipais, como órgãos integrantes de sua própria estrutura orgânica, com o fim de atribuir a esses órgãos a competência para realizar a fiscalização dos municípios do seu território.

No tocante aos conselhos ou tribunais de contas organizados e mantidos pelos próprios municípios, só foram reconhecidos aqueles já existentes na data da promulgação da Constituição, uma vez que a própria Constituição veda aos municípios a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais.

A título de ilustração, os únicos Tribunais de Contas genuinamente municipais são os do Rio de Janeiro e de São Paulo, criados, respectivamente, em 23 de outubro de 1980 e em 20 de novembro de 1968, portanto, antes do advento da atual Constituição.

284. “Municípios e Tribunais de Contas. A Constituição da República impede que os Municípios criem os seus próprios Tribunais, Conselhos ou órgãos de contas municipais (CRFB/88, art. 31, § 4º), mas permite que os Estados-membros, mediante autônoma deliberação, instituem órgão estadual denominado Conselho ou Tribunal de Contas dos Municípios (RTJ 135/457, Rel. Min. Octavio Gallotti – ADI 445/DF, Rel. Min. Néri da Silveira), incumbido de auxiliar as Câmaras Municipais no exercício de seu poder de controle externo (CRFB/88, art. 31, § 1º). Esses Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios – embora qualificados como órgãos estaduais (CRFB/88, art. 31, § 1º) – atuam, onde tenham sido instituídos, como órgãos auxiliares e de cooperação técnica das Câmaras de Vereadores. A prestação de contas desses Tribunais de Contas dos Municípios, que são órgãos estaduais (CRFB/88, art. 31, § 1º), há de se fazer, por isso mesmo, perante o Tribunal de Contas do próprio Estado, e não perante a Assembleia Legislativa do Estado-membro. Prevalência, na espécie, da competência genérica do Tribunal de Contas do Estado (CRFB/88, art. 71, II, c/c o art. 75)” (ADI 687/PA, Rel. Min. Celso de Mello, j. 02.02.1995, Plenário, DJ 10.02.2006.)

CAPÍTULO 20

PROCESSO LEGISLATIVO



20.1 PROCESSO LEGISLATIVO

É o conjunto de atos realizados pelos órgãos legislativos visando à formação das espécies normativas, previstas no art. 59, CRFB/88. Ressalte-se que o desrespeito às normas do processo legislativo previstas na CRFB/88 terá por consequência a declaração de sua inconstitucionalidade formal, apreciada tanto no controle difuso quanto pelo método concentrado.

20.2 INTRODUÇÃO

Há hierarquia entre LO e LC?

Ambas são atos normativos primários, porque extraem seu fundamento jurídico de validade diretamente da CRFB/88. Se a norma que serve de fundamento da validade é a mesma, não existe hierarquia entre essas duas espécies normativas. Não há grau de subordinação jurídica entre elas.

Diferenças entre LO e LC:

A LC é exigida para algumas matérias específicas. A CRFB/88 deve indicar expressamente quais matérias somente podem ser disciplinadas por LC. Ex.: art. 22 parágrafo único, art. 7º, I CRFB/88). Quando a CRFB/88 não diz expressamente que deve ser LC, a matéria poderá ser disciplinada por LO. Ex.: art. 5º, XXXII. Também há distinção formal com relação ao quorum, que será logo abaixo abordada.

LO pode revogar LC?

Em regra não. Mas o STF já disse que se uma LC dispuser sobre assunto de LO, ou seja, for formalmente LC mas tratar de tema de LO, poderá ser alterada ou revogada por LO. A questão foi examinada no caso da COFINS, que foi criada por meio de LC, quando não seria necessária a forma qualificada. Posteriormente, veio LO para alterar essa LC.

Ver RE 377457/PR (DJE de 19.12.2008) e do RE 381964/MG.

Medida Provisória pode alterar LC que dispõe sobre direito civil?

É o mesmo raciocínio acima. Se a LC tratou de direito civil, que não é matéria reservada à LC, deve ser considerada materialmente como LO. Assim, em que pese a Medida Provisória não poder tratar de matéria reservada à LC, neste caso não haveria problema, já que estaria na essência alterando LO.

20.3 FASES DO PROCESSO LEGISLATIVO DE ELABORAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA E COMPLEMENTAR

a) Fase iniciadora – composta pelo ato de Iniciativa, que pode ser:

Extraparlamentar

Parlamentar

Privativa/Reservada (art. 61 §1º e art. 93 caput)

Concorrente (art. 61, caput)

Popular (art. 61 §2º)

Fase constitutiva

Deliberação parlamentar – composta pelos seguintes atos:

Discussão e Emendas – CCJs (art. 63, I)

b) Votação

LO -> Maioria simples/relativa

LC -> Maioria absoluta

c) Deliberação executiva – composta pelos seguintes atos:

Sanção e Veto

Fase complementar

Promulgação e Publicação

Iniciativa Privativa

A Constituição Federal exige que algumas matérias somente possam ser reguladas por meio de leis de iniciativa privativa de certas autoridades ou órgãos. Somente a pessoa legitimada poderá propor projeto de lei sobre aquela matéria específica. Existe muita violação de iniciativa, o que implica na inconstitucionalidade formal da lei.

Pelo princípio da simetria ou paralelismo das formas, se no plano federal cabe ao Presidente oferecer projeto de lei sobre criação de órgão público, no plano estadual a atribuição será do Governador, e no âmbito municipal será do Prefeito. A sanção do chefe do Executivo NÃO convalida o vício de iniciativa, restando a súmula 5 do STF superada pela jurisprudência da Corte.

O rol de iniciativas privativas não se exaure no art. 61, §1º da CRFB/88, mas é o mais cobrado em provas:

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI ;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.

Iniciativa popular

O art. 61, §2º prevê que o projeto de lei popular depende do preenchimento de três requisitos cumulativos:

- Assinatura de 1% dos eleitores do país (equivale a aproximadamente 1 milhão e 400 mil eleitores);
- Assinaturas divididas entre 5 Estados;
- Em cada Estado, essas assinaturas devem representar 0,3% do eleitorado do Estado.

Art. 61, § 2º - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

A iniciativa popular está limitada à LO e LC, e o povo não tem legitimidade para apresentar Proposta de Emenda à Constituição, tendo em

vista que o rol de legitimados do art. 60 é taxativo.

Em regra, a casa iniciadora da votação é a Câmara dos Deputados, que é a casa que representa o povo. Mas se a iniciativa do projeto for do Senado, a votação irá começar pelo Senado. Previsão no art. 64 da CRFB/88:

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados.

Discussão e Emendas

Existem no Congresso inúmeras Comissões temáticas, mas destaca-se a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), que faz o controle preventivo político de constitucionalidade dos projetos de leis apresentados. Mas o parecer da CCJ não tem o condão de arquivar o projeto de lei em tramitação.

Na fase constitutiva há deliberação sobre o projeto e apresentação de emendas. As emendas são alterações ao projeto. Quanto ao tema, é importante destacar o art. 63, inciso I da CRFB/88, que prevê:

Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º;

Em princípio, projetos de lei de iniciativa privativa do Presidente podem sofrer alterações durante a tramitação, desde que:

- Não sejam alterações substanciais;

- Não haja aumento de despesas, ressalvado o disposto no art. 166 §3º e §4º:

§ 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para Estados,

Municípios e Distrito Federal; ou

III - sejam relacionadas:

a) com a correção de erros ou omissões; ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 4º - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

Votação

Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.

Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.

Para a aprovação da Lei Complementar, a referência do cálculo é a totalidade dos membros da Casa Legislativa.

O quorum de instauração da sessão é a maioria absoluta dos membros.

O quorum para aprovação da LC também é a maioria absoluta dos membros.

Para a aprovação da Lei Ordinária, a referência para cálculo é a maioria absoluta (ou mais) dos membros da Casa Legislativa.

O quorum de instauração da sessão é a maioria absoluta dos membros.

O quorum para aprovação da LO é a maioria simples dos presentes.

Importante destacar que, em regra, o projeto de lei rejeitado só pode ser reapresentado em uma sessão legislativa distinta, mas, na forma do art. 67, da CRFB/88: A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

Lei Complementar		Lei Ordinária	
Maioria Absoluta		Maioria Simples ou Relativa	
Câmara	Senado	Câmara	Senado
513 total	81 total	257 instauração	41 instauração
257 instauração e aprovação	41 instauração e aprovação	129 aprovação	21 aprovação

* Se na instauração da sessão para aprovação da LO estiverem presentes mais do que 257 membros, o quorum para aprovação poderá ser maior, porque é a maioria dos membros PRESENTES.

Sanção e Veto

São atos exclusivos do Chefe do Executivo, e devem ser realizados no prazo de 15 dias úteis contados do recebimento do projeto de lei. A sanção pode ser tácita ou expressa, mas o veto somente pode ser expresse. O transcurso do prazo de 15 dias úteis sem manifestação expressa do Presidente implica na sanção tácita.

Na forma do art. 66, são características constitucionais do veto:

- Irretratável;
- Superável pela derrubada do Congresso Nacional;
- Pode ser total ou parcial. No caso de ser parcial, não pode ser de palavra ou expressão, pois deve abranger texto integral de artigo, inciso, alínea ou parágrafo.

O veto pode ser material/político ou formal/jurídico. Na primeira hipótese, o Presidente veta projeto contrário ao interesse público, e no segundo caso, contrário à CRFB/88, realizando assim controle preventivo político de constitucionalidade.

Promulgação e Publicação

São atos do processo legislativo que recaem sobre a lei e não mais sobre o projeto. A promulgação certifica formalmente a existência da norma, confirmando seu plano de validade. A publicação dá notoriedade à lei, com a sua inserção no Diário Oficial. Não são atos exclusivos do Chefe do Executivo.

Derrubada do Veto

A partir do veto, o Presidente tem 48 horas para apresentação das razões do veto ao Presidente do Senado Federal – art. 66 CRFB/88.

§1º - Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.

Recebidas as razões do veto, deverá ser marcada sessão conjunta em 30 dias, para deliberação sobre a derrubada do veto. O veto não é mantido tacitamente por ausência da sessão conjunta. Se não realizada a sessão no prazo de 30 dias, haverá trancamento de pauta.

§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013)
(...)

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.

É realizada sessão conjunta, mas deputados e senadores votam separadamente. É necessária maioria absoluta de cada casa para derrubada (257 Deputados + 41 Senadores). Derrubado o veto, a lei prevê o encaminhamento para promulgação.

§ 7º - Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos casos dos § 3º e § 5º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.

A lei é encaminhada primeiro para o Presidente, que poderá promulgar no prazo de 48 horas. Se não o fizer neste prazo, a lei é então encaminhada ao Presidente do Senado, que terá mais 48 horas para promulgar. Se também não o fizer, caberá ao Vice Presidente do Senado fazê-lo, também no prazo de 48 horas. Somente se este último não promulgar, poderá ser questionada a prática de eventual crime de responsabilidade.

ATENÇÃO

O desrespeito a esta ordem implica em inconstitucionalidade formal da lei, por ofensa ao processo legislativo. Não é mera irregularidade, ainda que o Presidente da República tenha a faculdade de promulgar ou não. Então o Presidente do Senado não pode promulgar direto após a derrubada do veto. É obrigatório o envio para o Presidente da República para promulgação.

O processo legislativo sumário

Na forma do art. 64, § 1º, com relação aos projetos de iniciativa do Presidente da República, em caso de solicitação por ele de urgência para a sua apreciação, o processo será realizado com prazos menos dilatados do que os existentes para a deliberação no processo ordinário. Nesse caso, se a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação do projeto (art. 64, § 2º). Somando-se ao prazo de 90 dias os 10 dias para apreciação das emendas feitas pelas Casas, o processo deverá se encerrar em 100 dias.

Assevere-se que, na forma do art. 64 § 4º, o referido prazo não corre nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplica aos projetos de código.

20.4 MEDIDAS PROVISÓRIAS

Base Legal: Art. 62 da CRFB/88 com a alteração promovida pela EC 32, aprovada em 11 de setembro de 2001.

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

Natureza Jurídica

É ato normativo primário, com força de lei ordinária. Assim, não pode dispor sobre matéria reservada à LC. É espécie normativa precária, porque tem prazo certo para produzir os efeitos jurídicos. Após a edição, o Presidente

remete imediatamente à Câmara dos Deputados. Se não for aprovada no prazo de produção de seus efeitos, será considerada rejeitada. Com isso, podemos concluir que não há conversão tácita de MP em lei ordinária.

MP nos Estados e nos Municípios

O processo legislativo federal serve como parâmetro para as Constituições Estaduais e leis orgânicas municipais. Assim, é possível (não obrigatório) que o Estado e Municípios prevejam nas suas Constituições Estaduais e leis orgânicas se a medida provisória será adotada como espécie normativa.

A doutrina costuma indicar o art. 25 §2º da CRFB/88 como previsão expressa da possibilidade de edição de medida provisória por Estados. A contrario sensu, o Estado teria liberdade para editar medidas provisórias, mas não sobre gás canalizado.

“Art. 25 § 2º - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação”.

Controle de Constitucionalidade e MP

a) Requisitos de relevância e urgência

Admite-se o controle judicial, ainda que em caráter excepcional, dos requisitos de relevância e urgência. A urgência é a justificativa da necessidade de utilização de processo legislativo mais célere. Não dá tempo para o processo legislativo normal. Ex.: tragédia das chuvas na Serra do RJ. A relevância é em relação ao assunto. É a importância econômica, social, etc.

No informativo 599, o STF ratificou posição de os critérios de relevância e urgência podem ser analisados ainda que excepcionalmente pelo Judiciário, não sendo mais considerados, como no passado, conceitos jurídicos indeterminados. Ver também ADI 2213.

b) Controle concentrado e difuso

A medida provisória poderá ser objeto tanto de controle concentrado como difuso. Para o controle difuso, não é importante a mudança de status da M.P no curso do feito (se foi convertida em lei, se foi rejeitada, etc.). Na hora do julgamento, o juiz vai avaliar incidentalmente a medida provisória ou eventual lei ordinária de conversão. Mas no controle concentrado, a espécie normativa não é um incidente, mas sim o próprio mérito da ação.

Assim, o STF tem adotado o seguinte procedimento:

Se no curso da ADI a M.P. for rejeitada ou convertida em lei com alterações substanciais -> Haverá perda do objeto.

Se no curso da ADI a M.P. for convertida em lei sem alterações substanciais -> Haverá regular prosseguimento do feito, mas o autor da ADI deverá aditar a inicial, para adequar o pedido, informando o novo status da norma objeto de controle.

A conversão da MP em lei não convalida eventuais vícios. Ex.: Medida Provisória sobre matéria penal (vedação expressa no art. 62 §1º). Ainda que haja a sua conversão em lei ordinária.

Limitações Materiais

a) Explícitas – art. 62 §1º; art. 25 §2º; art. 246; art. 73 ADCT

Art. 62 § 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

I - relativa a:

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;

b) direito penal, processual penal e processual civil;

c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;

II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;

III - reservada a lei complementar;

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

Merece destaque o art. 62, §1º ‘d’, porque sempre justificou o mau uso das medidas provisórias para abertura de crédito. Somente é possível a abertura de crédito por meio de M.P. de forma válida na hipótese do art. 167 §3º: situação de guerra, comoção interna ou calamidade pública.

“Art. 167 § 3º - A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.”

Outras vedações explícitas:

Art. 73 do ADCT. Na regulação do Fundo Social de Emergência não poderá ser utilizado o instrumento previsto no inciso V do art. 59 da Constituição.

Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive.

b) Implícitas – art. 49; art. 51; art. 52.

Em nome do princípio da separação de poderes, doutrina e jurisprudência entendem que é vedada a edição de medida provisória sobre matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional, privativa da Câmara dos Deputados e privativa do Senado, respectivamente nos artigos 49, 51 e 52 da CRFB/88.

Procedimento

- a) Casa iniciadora: art. 62 §8º
- b) Prazos: art. 62 §3º, §4º e §7º
- c) Trancamento de pauta: art. 62 §6º
- d) Aprovação com ou sem alterações: art. 62 §12
- e) Rejeição tácita ou expressa: art. 62 §11.
- f) Reedição: art. 62 §10
- g) Medidas Provisórias anteriores à EC 32/01
- h) Medidas Provisórias. Revogação e Suspensão.

A Constituição não cuidou dos detalhes do processo legislativo de conversão porque não precisava. É o procedimento de aprovação de um projeto de lei ordinária, com alguns detalhes. Mas quorum de instalação e aprovação, etc., são os mesmos já vistos. O trâmite é o mesmo do art. 66 da CRFB/88.

Como a medida provisória é elaborada pelo Presidente, o processo de conversão SEMPRE será iniciado na Câmara. O Senado será sempre casa revisora. Previsto no art. 62 §8º da CRFB/88.

A medida provisória nasce para produzir efeitos por somente 60 dias, e se nesse período ela não for objeto de deliberação, será prorrogada automaticamente por igual período. Entretanto, o prazo máximo de produção dos efeitos jurídicos não é, ao que parece à primeira vista, de 120 dias, isto porque, por exemplo, o art. 62, §4º, afirma que o prazo não corre durante o recesso parlamentar, restando a sua contagem suspensa durante esse período.

Trancamento de pauta: A partir do 45º dia de sua publicação, vai haver trancamento de pauta da casa onde ela estiver. A outra casa estará com a pauta liberada. Nunca a pauta de ambas as casas estará trancada ao mesmo tempo por conta da mesma medida provisória.

No procedimento de conversão da medida provisória em lei, deve se analisar se houve ou não alterações durante as votações.

Se não houve alteração, a lei será promulgada pelo Presidente do Congresso Nacional, SEM sanção ou veto do Presidente.

Se foram promovidas alterações, o projeto será encaminhado ao Presidente para sanção ou veto, no prazo de 15 dias úteis.

Se a medida provisória for rejeitada (expressa ou tacitamente), não poderá ser reeditada na mesma sessão legislativa. Previsão no art. 62 §10 da CRFB/88.

O art. 2º da EC 32 diz que as medidas provisórias anteriores continuam a vigorar, até que sejam rejeitadas pelo Congresso, revogadas por outra medida provisória convertida em LO ou por lei ordinária.

20.5 LEI DELEGADA

a) Natureza jurídica

É ato normativo primário, que pode ser objeto tanto do controle difuso quanto do concentrado.

b) Base Legal – art. 68 CRFB/88

“Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.”

c) Limitações materiais expressas

“Art. 68 § 1º - Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do

Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos."

d) Espécies de delegação

Do autorizar o Presidente a elaborar a lei, o Congresso tem duas opções. imprópria, atípica ou impura – Exige que o Presidente submeta o projeto de lei à apreciação do Congresso. Se o Congresso não aprovar o projeto apresentado, não haverá lei delegada. Prevista, a contrario sensu, no art. 68 §3º CRFB/88. É uma forma de controle político preventivo de constitucionalidade.

§ 3º - Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda.

Própria, típica ou pura – o Congresso dá uma carta em branco, ou seja, não exige que seja submetido o projeto para apreciação antes da edição da lei.

20.6 RESOLUÇÕES E DECRETOS LEGISLATIVOS

Normalmente as resoluções são elaboradas quando as Casas do Congresso estão trabalhando separadamente, para tratar das matérias indicadas nos artigos 51 e 52 da CRFB/88. Já o Congresso, quando atua em conjunto (art. 49), geralmente edita decreto legislativo. Mas a CRFB/88 poderá determinar que o Congresso edite resolução e as Casas editem decretos legislativos.

O Congresso autoriza a lei delegada por meio de resolução (art. 68 §2º). Mas para sustar os efeitos da lei delegada que exorbite os limites, o Congresso irá editar decreto legislativo.

Em nome da separação de poderes, não há sanção ou veto do Presidente da República no processo de elaboração, nem de decretos legislativos, nem de resoluções. Atenção com o artigo 68 §2º da CRFB/88, porque é exceção à regra.

CAPÍTULO 21

PODER EXECUTIVO



21.1 CONCEITO

O Poder Executivo é o órgão constitucional cuja função típica é a prática de atos relacionados à função executiva, ou seja, a tarefa de realizar, dentro da lei, as atividades materiais atinentes à chefia de Estado, de Governo e da Administração Pública. No exercício das suas funções atípicas, também legisla (art. 62- Medidas Provisórias) e julga (contencioso administrativo).

21.2 SISTEMAS DE GOVERNO

- a) **Parlamentarismo:** o Poder Executivo se divide em duas partes: um Chefe de Estado (monarca ou Presidente da República) e um Chefe de Governo (primeiro – ministro ou Presidente do Conselho). O Governo é exercido pelo Conselho de Ministros;
- b) **Presidencialismo:** é o sistema típico das repúblicas e o Presidente exerce o Poder Executivo em sua inteireza, acumulando as funções de Chefe de Estado, Chefe de Governo e Chefe da Administração Pública. Cumpre um mandato por tempo fixo, não dependendo da confiança do órgão do Poder Legislativo nem para sua investidura nem para o exercício de Governo.

21.3 FORMAS DE GOVERNO

- a) **República:** a República é uma forma de governo em que os exercentes das funções Executiva e Legislativa representam o povo, decidindo em seu nome, à luz dos princípios da responsabilidade, eletividade e temporariedade. A periodicidade também garante a fidelidade do mandato, permitindo a alternância no poder num lapso temporal rigorosamente estabelecido;
- b) **Monarquia:** é caracterizada por ser o governo de um só, baseado no poder divino, sem a participação popular e vitalício.

21.4 REQUISITOS PARA PRESIDENTE E VICE (ART. 14, § 3º)

- nacionalidade brasileira (brasileiro nato);
- pleno exercício dos direitos políticos;
- alistamento eleitoral;
- domicílio eleitoral na circunscrição;

-
- filiação partidária;
 - idade mínima de 35 anos.

21.5 MANDATO PRESIDENCIAL (ART. 77)

O Presidente e o vice são eleitos conjuntamente, em chapa, através do sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. A eleição, de acordo com o art. 77, obedece ao princípio da maioria absoluta dos votos, não se computando os votos em branco e os nulos, em razão do que há possibilidade de realização de dois turnos de votação, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta no primeiro turno.

Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Em caso de empate, qualificar-se-á o mais idoso.

Obs.: O sistema constitucional brasileiro não admite nem a candidatura autônoma (sem registro em partido político), nem a candidatura avulsa (é preciso que esteja na mesma chapa eleitoral o Presidente e o Vice).

21.6 ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (ART. 84)

O Presidente exerce, ao mesmo tempo, a chefia de Estado e a chefia de Governo. Como chefe de Estado ele representa a República como um todo, tanto na órbita interna, como na órbita internacional. No último caso, age em nome da soberania nacional. Já como chefe de governo, o Presidente almeja realizar os fins do Estado, comandando a máquina administrativa e as Forças Armadas, com vistas à eliminação dos problemas permanentes e conjunturais.

- Chefia de Estado: art. 84, VII, VIII, XIV, XV, XVI, primeira parte, XVIII, segunda parte, XIX, XX, XXI, XXII;

- Chefia de Governo: art. 84, I, III, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII, XVIII, primeira parte, XXIII, XXIV e XXVII;

- Chefia da Administração Federal: art. 84, II, VI, XVI, segunda parte, XXIV e XXV;

- Exercício de outras atribuições constitucionais: art. 84, XVII;

- Delegação de atribuições constitucionais: parágrafo único do art. 84.

21.7 HIPÓTESES DE PERDA DO MANDATO

- Cassação - Na hipótese dos arts. 52, parágrafo único e 86, da CRFB/88. Só se aplica ao vice quando em exercício da Presidência;

- Extinção - Nos casos de morte, renúncia, perda ou suspensão dos direitos políticos e perda da nacionalidade brasileira;

- Declaração de vacância do cargo pelo Congresso Nacional - Quando não comparecerem para tomar posse dentro do prazo de 10 dias a partir da designação (art. 78);

- Ausência do país, por mais de 15 dias, sem licença do Congresso Nacional (83, CRFB/88) - Quem aplica a sanção é o próprio Congresso, pois é ele quem pode dar a licença. A ausência sem licença e sem motivo de força maior (ex.: doença súbita no exterior) leva à perda do mandato.

21.8 VACÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO

No caso de vacância do cargo de Presidente da República, caberá ao vice suceder-lhe, assumindo o mandato no restante do tempo para o seu término. Na falta do vice-presidente, serão sucessivamente chamados para ocupar, temporariamente, o exercício da Presidência da República: Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribunal Federal. O único sucessor do Presidente é o Vice. São substitutos: o Vice, o Presidente da República: Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o artigo 81, CRFB/88, vagando os cargos de Presidente e de Vice, deverá ser feita nova eleição, obedecidos os prazos e requisitos abaixo elencados:

- a) **ELEIÇÃO DIRETA**, no prazo de noventa dias de aberta a última vaga, quando a vacância se der nos dois primeiros anos do mandato presidencial;
- b) **ELEIÇÃO INDIRETA**, pelo Congresso Nacional, no prazo de trinta dias de aberta a última vaga, quando a vacância se der nos dois últimos anos do mandato presidencial.

21.9 PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

a) Imunidades formais

As imunidades formais se dividem entre a prisão e o processo, senão vejamos:

Quanto à prisão, o art. 86, §3º, afirma que enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito à prisão. Ressalte-se que esse dispositivo constitucional não trata de qualquer prisão: ele só trata de prisão penal. Então, podemos extrair deste artigo a seguinte regra geral: não haverá prisão criminal do Presidente da República, não existindo empecilho jurídico, portanto, para a realização de prisões civis.

Quanto ao processo, o art. 86, caput dispõe que compete à Câmara dos Deputados a realização de juízo de admissibilidade das acusações criminais e políticas contra o Presidente da República, considerando-se aprovadas por pelo menos 2/3 dos votos favoráveis dos Deputados. Essa imunidade configura uma blindagem contra o processo seja criminal ou político do Presidente da República.

b) Prerrogativa de Foro

Em razão de crime de responsabilidade, quem efetua o impeachment do Presidente da República é o Senado federal, na forma do art. 52, I e parágrafo único. Em razão de crime comum, é o STF, com base no art. 102, I. Ressaltemos, entretanto, que nem o Senado e nem o STF tem autorização para iniciar o julgamento contra o Presidente da República se não houver o juízo de admissibilidade da Câmara dos deputados favorável ao julgamento.

Observe-se que a prerrogativa de foro prevista em nossa Constituição é apenas política e criminal. Não há prerrogativas de foro para o julgamento em sede de ação trabalhista, divórcio, adoção etc.

c) Os crimes de responsabilidade

De acordo com o rol exemplificativo do art. 85 de eventuais infrações político-administrativas que podem ser cometidas pelo Presidente da República, levando-o ao impeachment pelo Senado Federal, temos as que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:

- I - a existência da União;*
- II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;*
- III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;*
- IV - a segurança interna do País;*
- V - a probidade na administração;*
- VI - a lei orçamentária;*
- VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.*

A Lei 1079/50 ainda traz mais alguns tipos de infrações político-administrativas.

No recente caso de Impeachment vivenciado pelo país, algumas regras novas sobre o procedimento foram estabelecidas pelo STF no julgamento da ADPF 378, ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil (art. 103, VIII da CRFB/88). Seguem abaixo os principais aspectos:

PRINCIPAIS DESTAQUES

- a) Não há que se falar em direito à defesa prévia antes do recebimento da denúncia pelo Presidente da Câmara;
 - b) A eleição da comissão especial do impeachment deve se dar por indicação dos líderes e voto aberto do Plenário;
 - c) É possível a aplicação subsidiária dos Regimentos Internos da Câmara e do Senado que tratam sobre o procedimento do impeachment;
 - d) No que diz respeito ao papel da Câmara no processo de impeachment, a sua atuação [... deve ser entendida como parte de um momento pré-processual, isto é, anterior à instauração do processo pelo Senado.
- Segundo o Min. Barroso: “a Câmara apenas autoriza a instauração do processo: não o instaura por si própria, muito menos determina que o Senado o faça.

Dessa forma, os arts. 23, §§ 1º e 5º; 80 e 81, da Lei nº 1.079/50 não foram recepcionados por serem incompatíveis com os arts. 51, I; 52, I; e 86, § 1º, II, da CRFB/88. Dessa forma, ao Senado compete decidir (por maioria simples) se deve receber ou não a denúncia cujo prosseguimento foi autorizado pela Câmara. Se a rejeitar, haverá o arquivamento do pedido; se a receber, será iniciado o impeachment propriamente dito (fase processual), com a produção de provas e, ao final, o Senado votará pela absolvição ou condenação do Presidente (na forma do art. 52, parágrafo único, da CRFB/88).

Obs.: Apesar de o art. 52, p. único estabelecer que, se condenado, o Presidente, perderá o cargo e ficará inabilitado ao exercício de cargo, emprego e função pública por 8 (oito) anos, no caso da Ex-Presidente Dilma, o Senado decidiu que as penas não são cumulativas e apesar de condená-la a perda do cargo, manteve os seus direitos políticos.

d) Suspensão das funções

De acordo com o art. 86, § 1º e § 2º, o Presidente ficará suspenso de suas funções: nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal; nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Se decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

e) Cláusula de irresponsabilidade penal relativa

Art. 86 § 4º - O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.

Qual o alcance dessa chama de cláusula de irresponsabilidade penal relativa? Primeiramente, ela só se aplica a situações penais e deve ser analisada de forma restrita. De acordo com o art. 86, §4º, o STF só poderá julgar o Presidente da República por crime relacionado ao exercício das funções presidenciais. Com isso, não haverá processo criminal contra o Presidente da República durante o seu mandato por crime ocorrido antes da diplomação ou durante o mandato, mas sem relação com as funções presidenciais.

f) Prerrogativas de Governadores e Prefeitos

Segundo a jurisprudência do STF, a imunidade formal quanto à prisão e a cláusula de irresponsabilidade penal relativa são exclusivas do Chefe de Estado, que é o Presidente da República. Entretanto, a imunidade formal processual deve ser reproduzida nas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais para os Chefes de Governo estaduais e municipais²⁸⁵.

285. Sobre o assunto, vasta é a jurisprudência do STF:

“A Corte, no julgamento de cautelar na ADI 1.628-SC, já adotou posição quanto à aplicabilidade do quorum de 2/3 previsto na Constituição Federal como o a ser observado, pela Assembleia Legislativa, na deliberação sobre a procedência da acusação contra o

Ressalve-se que por crime comum os governadores são julgados perante o STJ, na forma do art. 105, I, "a", da CRFB/88, e os Prefeitos pelos Tribunais de Justiça, de acordo com o art. 29, X, da CRFB/88. (importante destacar a Súmula 702 do STF que determina que se o Prefeito cometer crime eleitoral, será julgado pelo TRE e, caso cometa crime federal, o seu julgamento será feito pelo TRF).

Por crime de responsabilidade, o Governador será julgado pelo Tribunal especial anunciado no art. 78, § 3º, da Lei 1079/50, composto de cinco membros do Legislativo e de cinco desembargadores, sob a presidência do Presidente do Tribunal de Justiça local, que terá direito de voto no caso de empate. A escolha desse Tribunal será feita - a dos membros do legislativo, mediante eleição pela Assembleia; a dos desembargadores, mediante sorteio.

Governador do Estado." (ADI 1.634-MC, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 17-9-97, DJ de 8-9-00)

"Orientação desta Corte, no que concerne ao art. 86, §§ 3º e 4º, da Constituição, na ADI 1.028, de referência à imunidade à prisão cautelar como prerrogativa exclusiva do Presidente da República, insuscetível de estender-se aos Governadores dos Estados, que institucionalmente, não a possuem." (ADI 1.634-MC, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 17-9-97, DJ de 8-9-00)

"O Estado-Membro, ainda que em norma constante de sua própria Constituição, não dispõe de competência para outorgar ao Governador a prerrogativa extraordinária da imunidade à prisão em flagrante, a prisão preventiva e à prisão temporária, pois a disciplinação dessas modalidades de prisão cautelar submete-se, com exclusividade, ao poder normativo da União Federal, por efeito de expressa reserva constitucional de competência definida pela Carta da República. A norma constante da Constituição estadual — que impede a prisão do Governador de Estado antes de sua condenação penal definitiva — não se reveste de validade jurídica e, conseqüentemente, não pode subsistir em face de sua evidente incompatibilidade com o texto da Constituição Federal." (ADI 978, Rel. p/ o ac. Min. Celso de Mello, julgamento em 19-10-95, DJ de 24-11-95).

E ainda, no mesmo sentido:

"Os Governadores de Estado — que dispõem de prerrogativa de foro *ratione muneris*, perante o Superior Tribunal de Justiça (CRFB/88, art. 105, I, a) — estão sujeitos, uma vez obtida a necessária licença da respectiva Assembléia Legislativa (RTJ 151/978-979 — RTJ 158/280 — RTJ 170/40-41 — Lex/Jurisprudência do STF 210/24-26), a processo penal condenatório, ainda que as infrações penais a eles imputadas sejam estranhas ao exercício das funções governamentais." (HC 80.511, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 21-8-01, DJ de 14-9-01)

"Os Estados-membros não podem reproduzir em suas próprias Constituições o conteúdo normativo dos preceitos inscritos no art. 86, §§ 3º e 4º, da Carta Federal, pois as prerrogativas contempladas nesses preceitos da Lei Fundamental — por serem unicamente compatíveis com a condição institucional de Chefe de Estado — são apenas extensíveis ao Presidente da República." (ADI 978, Rel. p/ o ac. Min. Celso de Mello, julgamento em 19-10-95, DJ de 24-11-95)

Já o Prefeito, por crime de responsabilidade, será julgado, em regra pela Câmara dos Vereadores.

21.10 OS MINISTROS DE ESTADO

A tarefa dos Ministros é a de chefiar departamento básicos da administração pública, conduzir os trabalhos das grandes seções especializadas da máquina estatal – os ministérios.

Seu papel político é, em geral, o de auxiliares graduados do chefe do governo, a quem devem assessorar e aconselhar. Podem ser, todavia, cotitulares do poder governamental, o que sucede quando este cabe a um órgão coletivo, caso em que não há chefe do governo, mas apenas um primeiro-ministro, porta-voz do órgão coletivo.

A nomeação, porém, só pode recair em pessoas que preencham os seguintes requisitos: ser brasileiro (lembrando que o Ministro de Estado da Defesa deve ser necessariamente brasileiro nato, na forma do art. 12, § 3º, VII, da CRFB/88); estar no gozo dos direitos políticos e ter mais de vinte e um anos.

De acordo com o art. 87 da Constituição, devem realizar, entre outras, as seguintes tarefas: referendar os atos presidenciais, expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos etc. Incumbe-lhes também, sob pena de crime de responsabilidade, a obrigação de comparecer ao Congresso sempre que para tanto convocados (embora possam lá comparecer espontaneamente também). Devem, outrossim, apresentar ao Presidente relatório anual dos trabalhos realizados em seu Ministério.

21.11 ÓRGÃOS DE APOIO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Conta hoje o Presidente da República com dois órgãos superiores de consulta. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, ambos com composições e competência definidas na Lei Maior, e cuja organização e funcionamento foram deixados para serem regulados pela lei ordinária.

a) O Conselho da República

Na forma do art. 89, o Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam:

- I - o Vice-Presidente da República;*
- II - o Presidente da Câmara dos Deputados;*
- III - o Presidente do Senado Federal;*
- IV - os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados;*
- V - os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal;*
- VI - o Ministro da Justiça;*
- VII - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.*

O art. 90 menciona as atribuições não exaustivas do aludido Conselho, que são a de pronunciar-se sobre: intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.

b) O Conselho da Defesa Nacional

Suas atribuições definidas no §1º do art. 91 são as de opinar em matérias ligadas à defesa do território nacional, tais como: declaração de guerra, celebração da paz, decretação de estado de sítio, de defesa e intervenção federal, uso efetivo de áreas indispensáveis à segurança do território nacional, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo etc.

Segundo previsão no dispositivo em apreço, são membros do Conselho de Defesa Nacional o Vice-Presidente da república, o presidente da Câmara dos Deputados e o do Senado Federal, e os Ministros da Justiça, da defesa, das Relações Exteriores e do Planejamento, bem como os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

CAPÍTULO 22

PODER JUDICIÁRIO



22.1 CONCEITO

Ao lado das funções de administrar e legislar, ao Estado também compete a função judicial, ou jurisdicional, dirimindo as controvérsias que surgem quando da aplicação das leis. O Judiciário, porém, como as demais funções do Estado, possui outras atribuições, denominadas atípicas, de natureza administrativa e legislativa. Ex.: concessão de férias de seus membros e elaboração de seus regimentos internos.

A função típica do Poder Judiciário é exercer a atividade jurisdicional, pela qual o Judiciário substitui a vontade das partes solucionando os conflitos ao declarar o Direito e julgar.

22.2 ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO

A estrutura do Estado é organizada com base na forma federativa, que admite duas ordens de organização: Federal e Estadual. Portanto, coexistem a Justiça Federal, que tem as competências previstas expressamente, e a Justiça Estadual, cabendo-lhe a competência residual.

Quanto à competência, prevista na Constituição Federal, o Judiciário estrutura-se em 2 (dois) âmbitos: comum e especializado. A Justiça Federal pode ser: comum ou especializada (Justiça do Trabalho, Eleitoral e Militar). Já na Justiça Estadual há somente a Justiça Militar especializada.

Não existe previsão de contencioso administrativo. Exceção: “Justiça” desportiva, que na realidade foi instituída no âmbito administrativo e não exerce atividade jurisdicional típica.

a) Supremo Tribunal Federal (art. 101 e ss)

Órgão de cúpula do Poder Judiciário, guardião da Constituição, decide em última instância os litígios intersubjetivos.

O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 (onze) membros, divididos em duas Turmas, que se encontram no mesmo plano hierárquico. O Presidente da República escolhe livremente o candidato, que será sabatinado pelo Senado Federal, devendo ser aprovado pela maioria absoluta de seus membros (art. 52, III, “a”, e art. 101, parágrafo único, CRFB/88). Suas competências são definidas nos arts. 102 a 103 da Constituição Federal.

São requisitos para a escolha dos 11 (onze) ministros do STF:

- idade: 35 a 65 anos;
- ser brasileiro nato (CRFB/88, art. 12, § 3º, IV);
- ser cidadão (no gozo dos direitos políticos);
- notável saber jurídico e reputação ilibada.

b) Superior Tribunal de Justiça (art. 104 e ss)

É a última instância do Judiciário em matéria de leis federais.

O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 (trinta e três) ministros escolhidos pelo Chefe do Poder Executivo, porém não livremente, pois obrigatoriamente, deverão ser:

- 1/3 de Juizes dos TRF's (Tribunais Regionais Federais);
- 1/3 de desembargadores dos Tribunais de Justiça Estaduais;
- 1/3 divididos da seguinte maneira: 1/6 de advogados; 1/6 de membros do Ministério Público Federal, Estaduais e Distrital.

São requisitos para o cargo de Ministro do STJ:

- idade: 35 a 65 anos;
- ser brasileiro nato ou naturalizado;
- notável saber jurídico e reputação ilibada.

Competência: possui competências originárias, descritas no art.105, I da CRFB/88, e recursais que abrangem o recurso ordinário (art.105, I da CRFB/88) e o recurso especial (art.105, II da CRFB/88).

Obs.: Não existe hierarquia recursal entre o STJ e os Tribunais nacionais especializados (Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar).

c) Justiça Federal Comum (art. 106 e ss)

Órgãos: Tribunais Regionais Federais e juizes federais. A Justiça Federal se divide em seções judiciárias, uma em cada Estado (art.110 da CRFB/88).

Composição: art. 107 da CRFB/88

Competência:

- 1) Tribunais Regionais Federais (art. 108)
- 2) Juizes federais (art. 109)

d) Justiça Federal do Trabalho (art. 111 e ss)

São órgãos da Justiça do Trabalho:

- 1) Tribunal Superior do Trabalho
- 2) Tribunais Regionais do Trabalho
- 3) juízes do trabalho

Composição: art. 111-A da CRFB/88

Competência: foi ampliada pela E.C. 45/2004 para julgar todas as causas que envolvam relação de trabalho, independentemente de lei. A expressão “relação de trabalho” deve ser entendida em sentido amplo, abrangendo todo trabalhador prestador de serviços, independentemente de subordinação. Anteriormente competia à Justiça do Trabalho processar e julgar ações oriundas apenas da relação de emprego, que é espécie de relação de trabalho, e controvérsias da relação de trabalho dispostas em lei.

A EC 45/2004 determinou uma mudança de competência, mas não alterou as leis de regência dos contratos. Com isso, a Justiça do Trabalho não se limita à aplicação da CLT, devendo aplicar as regras de Direito Civil quando for cabível. A Justiça do Trabalho continua não tendo competência para julgar: crimes do trabalho e funcionários públicos (estatutários).

e) Justiça Federal Eleitoral (art. 118 e ss)

A Justiça Eleitoral possui os seguintes órgãos (art. 118 da CRFB/88):

- 1) Tribunal Superior Eleitoral
- 2) Tribunais Regionais Eleitorais
- 3) juízes eleitorais
- 4) Juntas Eleitorais

Composição: art. 119 e 120 da CRFB/88.

Competência: estabelecida no Código Eleitoral (Lei nº. 4737/65 c/c art 121 da CRFB/88)

f) Justiça Federal Militar (art. 122 e ss)

A Justiça Militar se compõe dos seguintes órgãos (art. 122 da CRFB/88):

- 1) Superior Tribunal Militar
- 2) Tribunais Militares, instituídos por lei
- 3) juízes militares, instituídos por lei.

Composição: art.123 CRFB/88

Competência: processar e julgar os crimes militares definidos em lei (art. 124, caput da CRFB/88) e demais competências que deverão ser disciplinadas em lei (art. 124, parágrafo único da CRFB/88 c/c Lei nº 8236/91).

g) Justiça Estadual (art. 125 e 126)

Órgãos: Tribunais de Justiça nos Estados.

Competência: será definida pelas Constituições Estaduais (art.125, § 1º da CRFB/88)

Obs.: A Justiça Estadual Militar está regulada nos art. 125, §§ 3º, 4º e 5º da CRFB/88)

h) Conselho Nacional de Justiça

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi acrescentado ao rol de órgãos do Poder Judiciário pela EC 45/04 e, de acordo com o art. 103-B, é composto por quinze membros com mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:

I - o Presidente do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 61, de 2009)

II - um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal;

III - um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal;

IV - um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;

V - um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;

VI - um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;

VII - um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;

VIII - um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;

IX - um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;

X - um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República;

XI - um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual;

XII - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

XIII - dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

O Conselho é presidido pelo Presidente do STF, e os demais membros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.

Importante destacar que, apesar de ser órgão do Poder Judiciário, o CNJ não exerce atividade jurisdicional típica e foi criado para reforçar a fiscalização administrativa e financeira dos órgãos do Poder Judiciário, à exceção do STF (ADI 3367).

O STF reconheceu na ADC 12 o poder normativo do Conselho, com isso, as suas resoluções podem ser objeto das ações do controle concentrado.

Das suas atribuições constitucionais, presentes no art. 103-B, § 4º, observamos que o referido Conselho poderá, de ofício, ou mediante provocação, desconstituir ou rever os atos administrativos (mas não jurisdicionais) praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas. Poderá, ainda, de acordo com a disposição constitucional em referência, avocar processos disciplinares em curso e rever (em favor ou contra o acusado) os processos disciplinares de juízes e membros de Tribunais julgados há menos de 1 (um) ano.

O texto da Constituição também prevê a determinação de criação de Ouvidorias de justiça pela União (art. 103-B, § 7º), as quais serão competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares. A ouvidoria representará diretamente ao Conselho e este se reportará a ela também sem necessidade de intermediação.

Sobre a importância do papel do Conselho Nacional de Justiça, afirma Luís Roberto Barroso²⁸⁶: "(...) a relação do Judiciário com a sociedade deve passar por um órgão de controle externo, na verdade misto, apto a promover a comunicação adequada entre as duas instâncias. Uma via de mão dupla,

286. BARROSO, Luiz Roberto. "O controle externo é favorável ao Judiciário". In Opinião. Folha de São Paulo, 15 de fevereiro de 2004, p.3.

capaz de transmitir as expectativas dos cidadãos e de compreender as circunstâncias das instituições judiciais. Dentre outras funções, ao Conselho Nacional de Justiça caberia, sem interferir na atividade jurisdicional, planejar estrategicamente a instituição, reivindicar verbas e compromissos, apresentar relatórios estatísticos, zelar pela universalização do acesso à justiça e, quando for o caso, punir desvios de conduta”.

Ainda com atuações um pouco tímidas, o referido Conselho poderá se tornar em mais uma frente de fiscalização efetiva das atividades administrativas do Poder Judiciário, zelando, também, pela garantia fundamental da razoável duração do processo, inserida por meio da EC 45/04 ao art. 5º da CRFB/88,²⁸⁷ como também pelos princípios da impessoalidade e moralidade que devem guiar a realização dos concursos públicos para magistrados no Brasil.

As eventuais ilegalidades cometidas pelo Conselho são analisadas pelo STF, na forma do art. 102, I, r da CRFB/88.

22.3 GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PODER JUDICIÁRIO E DE SEUS INTEGRANTES

22.3.1 Garantias Orgânicas ou Institucionais

- a) Capacidade de autogoverno – possibilidade de eleger seus próprios órgãos, organizar sua estrutura administrativa interna e deliberar sobre assuntos próprios (art. 96, I).
- b) Autonomia financeira – possibilidade de elaborar sua própria proposta financeira, dentro dos limites da lei de diretrizes orçamentárias (art. 99 c/c art. 168 da CRFB/88).
- c) Capacidade normativa – cada Tribunal deve elaborar seu Regimento Interno (art. 96, II da CRFB/88)
- d) Inalterabilidade de sua organização – a composição dos quadros dos Tribunais só pode ser alterada mediante proposta dos próprios tribunais (art. 96, II).
- e) Escolha dos dirigentes – garantia prevista no art. 96, I, a da CRFB/88.

22.3.2 Garantias da Magistratura (art. 95)

287. “Art. 5º, LXXVIII: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

a) Vitaliciedade - o Juiz, após dois anos de exercício, só pode perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Antes dos dois anos, estando o magistrado no período de estágio probatório, a perda do cargo pode operar-se por deliberação do Tribunal a que o Juiz estiver vinculado;

b) Inamovibilidade – esta garantia proíbe que os juízes sejam removidos do local em que se encontram, mesmo sob a forma de promoção, sem o seu consentimento, salvo motivo de interesse público (art. 93, VIII, e 95, II, CRFB/88).

A EC 45/2004 fez a seguinte alteração: o motivo de interesse público, que era decidido pelo voto de 2/3 do respectivo Tribunal, passou a ser decidido pelo voto da maioria absoluta do mesmo Tribunal ou pelo CNJ.

c) Irredutibilidade de subsídio – almeja garantir aos magistrados a necessária tranquilidade para o exercício do cargo, protegendo-os de perseguições governamentais de natureza econômica (art.95, III c/c art. 37, XV).

22.3.3 Vedações – Garantias de Imparcialidade (art. 95, parágrafo único, I, II, III, IV e V, alterado pela EC 45/2004)

- a) exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;
- b) receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;
- c) dedicar-se à atividade político-partidária;
- d) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;
- e) exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

22.4 REFORMA DO PODER JUDICIÁRIO – ALGUMAS ALTERAÇÕES

EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004

- ▶ *a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5º, LXXVIII);*
- ▶ *a possibilidade de se criarem varas especializadas para a solução das questões agrárias. (art. 126);*
- ▶ *a “constitucionalização” dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos desde que aprovados pelo quórum qualificado das emendas constitucionais (art. 5º, § 3º);*
- ▶ *a submissão do Brasil à jurisdição do Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão (art. 5º, § 4º);*
- ▶ *a federalização de crimes contra direitos humanos, objetivando o deslocamento de competência para a Justiça Federal (art. 109, V-A e § 5º);*
- ▶ *previsão do controle externo da Magistratura por meio do Conselho Nacional de Justiça (art. 92, I-A § 1º);*
- ▶ *previsão do controle externo do Ministério Público por meio do Conselho Nacional do Ministério Público (art. 130 –A);*
- ▶ *ampliação de algumas regras mínimas a serem observadas na Elaboração do Estatuto da Magistratura, todas no sentido de se dar maior produtividade e transparência à prestação jurisdicional, na busca da efetividade do processo (art. 93);*
- ▶ *ampliação da garantia de imparcialidade dos órgãos jurisdicionais (art. 95, § parágrafo único, IV e V);*
- ▶ *a extinção dos Tribunais de Alçada, passando os seus membros a integrar os TJ’s dos respectivos Estados e uniformizando assim a nossa Justiça (art. 4º da EC 45/2004);*
- ▶ *transferência de competência do STF para o STJ no tocante à homologação de sentenças estrangeiras e a concessão do exequator às cartas rogatórias (art. 102, I, “h”(revogada); 105, I, “i”);*

- ▶ criação da *Súmula Vinculante do STF* (art. 103-A);
- ▶ a aprovação da nomeação de Ministro do STJ pelo quórum de maioria absoluta dos membros do Senado Federal (art. 104, parágrafo único);
- ▶ ampliação da garantia de imparcialidade dos membros do MP (art. 128)

22.5 A SÚMULA VINCULANTE

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade.

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

A súmula vinculante foi instituída pela EC 45/04 como um instrumento de uniformização de jurisprudência do STF sobre matéria constitucional e aponta uma relação mais próxima do Direito brasileiro - construído pela influência do sistema romano-germânico, no qual a lei é a fonte formal de maior destaque nas decisões judiciais - com o Direito norte-americano de common law, que possui um sistema de precedentes mais destacado do que o da produção legislativa.

a) Órgão competente para edição da súmula

De acordo com o art. 103-A, regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, o único órgão competente no país para editar súmula de natureza vinculante é o Supremo Tribunal Federal, diante de seu papel de guardião da Constituição Federal que lhe foi determinado pelo constituinte originário, na forma do art. 102.

b) Requisitos para sua criação

Consoante os dispositivos legais em análise, podemos relacionar os seguintes requisitos necessários à edição da súmula: a) preexistência de reiteradas decisões em matéria constitucional; e b) controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses, a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica e c) quórum de 2/3 dos Ministros para sua aprovação.

Em que pese não existir um número mínimo de decisões judiciais sobre a matéria constitucional sujeita à súmula, entendemos que o assunto deverá já estar amadurecido nos julgados da Corte, evitando-se assim que temas novos sejam objeto da uniformização de jurisprudência.

Ademais, a exigência de controvérsia atual sobre o tema é indispensável, pois se o assunto já estiver sedimentado pelas decisões judiciais e administrativas, não haverá necessidade da pacificação de entendimento pelo STF por meio da súmula.

c) Do procedimento

Além do STF, que poderá de ofício deflagrar a edição da súmula, de acordo com o art. 3º, da Lei nº 11.417/2006, são legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante:

*Art. 3º. I - o Presidente da República;
 II - a Mesa do Senado Federal;
 III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
 IV - o Procurador-Geral da República;
 V - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
 VI - o Defensor Público-Geral da União;
 VII - partido político com representação no Congresso Nacional;
 VIII - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional;
 IX - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
 X - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
 XI - os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares."*

Ressalte-se que na forma do § 1º do dispositivo em análise, o Município poderá propor, incidentalmente no curso de processo em que seja parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo.

De acordo com o art. 2º, § 2º da Lei nº 11.417/2006, o procurador-geral da República, nas propostas que não houver formulado, manifestar-se-á previamente à edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante.

A deliberação sobre a edição, cancelamento ou revisão da súmula dependerá de decisão tomada por 2/3 (dois terços) dos membros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária.

A lei também previu a participação do *amicus curiae*, na forma do art. 3º, § 2º:

No procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado da súmula vinculante, o relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros na questão, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal".

Entendemos que os enunciados não vinculantes do STF podem se tornar obrigatórios, caso sejam submetidos aos requisitos presentes no art. 103-A, da CRFB/88 e da lei específica. Ademais, a súmula não pode ser objeto de ADI (ou de ADPF). Caso se pretenda a mudança ou cancelamento, deverá ser apresentado um pedido administrativo nesse sentido ao STF.

O STF asseverou que, para admitir-se a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante, seria necessário demonstrar: a) a evidente superação da jurisprudência do STF no trato da matéria; b) a alteração legislativa quanto ao tema; ou, ainda, c) a modificação substantiva de contexto político, econômico ou social. O mero descontentamento ou eventual divergência quanto ao conteúdo de verbete vinculante não autorizariam a rediscussão da matéria.

d) Dos efeitos obrigatórios e a reclamação constitucional

Consoante o art. 4º, da Lei nº 11.417/2006, a súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, a partir de sua publicação em imprensa oficial, em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, por decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, poderá restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir de outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público.

A reclamação constitucional pode ser apresentada diretamente ao STF em caso de inobservância do conteúdo da súmula vinculante, de acordo com o art. 7º da Lei: “Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação”.

Com relação às decisões administrativas, entretanto, a lei trouxe a necessidade de um contencioso administrativo obrigatório, conforme dicção do §1º do art. 7º: “Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas”.

Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

e) Súmulas Vinculantes

Até o momento o STF editou 56²⁸⁸ (cinquenta e seis) súmulas vinculantes, abaixo transcritas:

SÚMULA VINCULANTE Nº 1

Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validade e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela lei complementar 110/2001.

SÚMULA VINCULANTE Nº 2

É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.

SÚMULA VINCULANTE Nº 3

Nos processos perante o tribunal de contas da união, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

SÚMULA VINCULANTE Nº 4

Salvo nos casos previstos na constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

SÚMULA VINCULANTE Nº 5

A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a constituição.

SÚMULA VINCULANTE Nº 6

Não viola a constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial.

288. Até o fechamento desta edição.

SÚMULA VINCULANTE Nº 7

A norma do §3º do artigo 192 da constituição, revogada pela emenda constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

SÚMULA VINCULANTE Nº 8

São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do decreto-lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.

SÚMULA VINCULANTE Nº 9

O disposto no artigo 127 da lei nº 7.210/1984 (lei de execução penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58.

SÚMULA VINCULANTE Nº 10

Viola a cláusula de reserva de plenário (CRFB/88, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

SÚMULA VINCULANTE Nº 11

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

SÚMULA VINCULANTE Nº 12

A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal.

SÚMULA VINCULANTE Nº 13

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança

ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

SÚMULA VINCULANTE Nº 14

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

SÚMULA VINCULANTE Nº 15

O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.

SÚMULA VINCULANTE Nº 16

Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.

SÚMULA VINCULANTE Nº 17

Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

SÚMULA VINCULANTE Nº 18

A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal.

SÚMULA VINCULANTE Nº 19

A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.

SÚMULA VINCULANTE Nº 20

A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo

único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória no 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos.

SÚMULA VINCULANTE Nº 21

É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

SÚMULA VINCULANTE Nº 22

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04.

SÚMULA VINCULANTE Nº 23

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.

SÚMULA VINCULANTE Nº 24

Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.

SÚMULA VINCULANTE Nº 25

É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.

SÚMULA VINCULANTE Nº 26

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

SÚMULA VINCULANTE Nº 27

Compete à Justiça estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente.

SÚMULA VINCULANTE Nº 28

É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.

SÚMULA VINCULANTE Nº 29

É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.

SÚMULA VINCULANTE Nº 30

(A Súmula Vinculante 30 está pendente de publicação).

SÚMULA VINCULANTE Nº 31

É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis.

SÚMULA VINCULANTE Nº 32

O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras.

SÚMULA VINCULANTE Nº 33

Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.

SÚMULA VINCULANTE Nº 34

A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho – GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 (sessenta) pontos, desde o advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005).

SÚMULA VINCULANTE Nº 35

A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.

SÚMULA VINCULANTE Nº 36

Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil.

SÚMULA VINCULANTE Nº 37

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

SÚMULA VINCULANTE Nº 38

É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

SÚMULA VINCULANTE Nº 39

Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.

SÚMULA VINCULANTE Nº 40

A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.

SÚMULA VINCULANTE Nº 41

O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.

SÚMULA VINCULANTE Nº 42

É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

SÚMULA VINCULANTE Nº 43

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

SÚMULA VINCULANTE Nº 44

Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.

SÚMULA VINCULANTE Nº 45

A competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela constituição estadual.

SÚMULA VINCULANTE Nº 46

A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da união.

SÚMULA VINCULANTE 47

Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

SÚMULA VINCULANTE 48

Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro.

SÚMULA VINCULANTE 49

Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.

SÚMULA VINCULANTE 50

Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade.

SÚMULA VINCULANTE 51

O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8622/1993 e 8627/1993, estende-se aos servidores civis do poder executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais.

SÚMULA VINCULANTE 52

Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.

SÚMULA VINCULANTE 53

A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados.

SÚMULA VINCULANTE 54

A medida provisória não apreciada pelo congresso nacional podia, até a Emenda Constitucional 32/2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de trinta dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição.

SÚMULA VINCULANTE 55

O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.

SÚMULA VINCULANTE 56

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

CAPÍTULO 23

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

23.1 CONCEITO

É a verificação da adequação (compatibilidade) de lei ou ato normativo com a Constituição Federal, sob os aspectos dos requisitos formais ou materiais.

23.2 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

São princípios norteadores do controle de constitucionalidade: (1) princípio da supremacia da constituição; (2) presunção relativa de constitucionalidade das normas constitucionais derivadas e das normas infraconstitucionais; (3) presunção absoluta de constitucionalidade das normas originárias; (4) princípio da rigidez constitucional.

O princípio da supremacia da constituição coloca a Constituição no topo do ordenamento jurídico, impedindo que qualquer norma do país seja elaborada em ofensa a ela. As leis em sentido amplo devem se conformar formal e materialmente em face dessas regras maiores. O Legislativo e o Executivo, como autores das leis do país, conhecem a CRFB/88. Por isso todas as normas derivadas possuem presunção relativa de constitucionalidade. Nasce produzindo seus efeitos jurídicos essenciais, mas podem posteriormente ser reconhecidas como inconstitucionais. Somente gozam de presunção absoluta as normas constitucionais originárias (ADI 185). Eventuais conflitos serão resolvidos com base nos princípios integradores.

O princípio da rigidez constitucional também norteia o controle de constitucionalidade. A rigidez implica em necessidade de procedimento mais solene, mais dificultoso, para alteração das normas constitucionais. Por isso a CRFB/88 é colocada no topo do ordenamento, já que as normas inferiores não podem alterar as suas disposições.

Em suma, o controle de constitucionalidade visa proteger a supremacia da Constituição, a unidade do ordenamento jurídico e os nossos direitos e garantias fundamentais. A fiscalização, portanto, visa verificar a compatibilidade material e formal das normas produzidas no país para com a CRFB/88.

23.3 PARÂMETRO DO CONTROLE

A Constituição é dividida em três partes: Preâmbulo, corpo fixo e ADCT. Não há dúvidas de que todas as normas do corpo fixo da CRFB/88 e do ADCT, em regra, podem ser consideradas parâmetro do controle, mas o mesmo não pode ser dito sobre o preâmbulo da Constituição.

O STF, desde a ADI 2070, diz que o preâmbulo é fonte política, e que pode servir para interpretação, mas é desprovido de normatividade, e não é norma de reprodução obrigatória. Assim, o preâmbulo não é parâmetro para o controle de constitucionalidade.

23.4 TIPOS DE INCONSTITUCIONALIDADE

23.4.1 Inconstitucionalidade Material e Formal

- a) **MATERIAL** - Também conhecida como inconstitucionalidade nomoestática. Ocorre quando a espécie normativa, no todo ou em parte, contraria o conteúdo de normas ou princípios constitucionais;
- b) **FORMAL** - também conhecida como inconstitucionalidade nomodinâmica, é a inconstitucionalidade observada no processo legislativo e também quando há vício de competência. Divide-se em objetiva e subjetiva:
 - **OBJETIVA:** também conhecida como vício de rito ou de procedimento, caracteriza-se por uma desobediência do rito legislativo constitucional. Ex.: desobediência ao art. 60, § 2º.
 - **SUBJETIVA:** também chamada de vício de iniciativa ou de competência, quando um dos dois é desrespeitado. Ex.: desobediência ao art. 93, caput, CRFB/88, ou ainda, lei estadual dispõe sobre matéria penal (violando o art. 22, I). Neste tocante o art. 61 §1º tem relevância, que trata da iniciativa privativa do Presidente. O vício de iniciativa não é sanado pela sanção presidencial, quando ao presidente cabe a iniciativa privativa. O Presidente não está acima da CRFB/88.

Segundo parte da doutrina, a inconstitucionalidade formal também pode ser dividida em:

- **Orgânica** - quanto aos vícios de competência
- **Propriamente dita** - vício de iniciativa e nos demais atos do processo

legislativo.

23.4.2 Inconstitucionalidade Total e Parcial

- a) **TOTAL:** o vício diz respeito a todo o ato normativo.
- b) **PARCIAL:** o vício refere-se à parte do ato normativo. Possibilidades:
1. nulidade parcial: se a parte que resta da norma for autônoma da parte impugnada, persistirá sua validade e se anulará apenas a parte impugnada.
 2. nulidade total: se o restante da norma não for considerado inconstitucional em si, mas depender da parte inválida, toda a norma será considerada inválida.

ATENÇÃO

Importante! O vício formal também admite a inconstitucionalidade parcial. Em nome do princípio da parcelaridade, é possível que seja declarada a inconstitucionalidade de apenas uma palavra ou expressão. Normalmente a inconstitucionalidade formal gera a declaração de inconstitucionalidade total. Entretanto, pode ser parcial, como nos seguintes exemplos: (a) projeto de lei ordinária traz alguns dispositivos que tratam de matéria reservada à LC; (b) projeto de lei de iniciativa do Presidente que também traz dispositivos sobre matéria de iniciativa de outra autoridade da república; (c) projeto de lei alterado em parte pela casa revisora, que não retorna para deliberação da casa iniciadora e segue diretamente para sanção ou veto do Presidente. Neste último caso, a inconstitucionalidade formal estaria limitada aos dispositivos alterados.

23.4.3 Inconstitucionalidade por Ação ou por Omissão

- a) **Inconstitucionalidade por ação** – é combatida principalmente pela ADI, tendo como objeto leis ou outros atos normativos que violam a constituição.
- b) **Inconstitucionalidade por omissão** – combatida por meio da ADI por omissão (ADO), e tem como objeto da inexistência de lei sobre determinada matéria. A CRFB/88 prevê a necessidade de lei para regulamentar certas situações, mas o legislador não edita essa lei. Ex.:

art. 7º, XXI, art. 37, VII, art. 18 §4º e 40 §4º CRFB/88. Tanto a ação como a omissão ofendem a CRFB/88, com a mesma intensidade. Para fins de inconstitucionalidade, tem o mesmo valor.

23.5 MODALIDADES DE CONTROLE

O controle de constitucionalidade pode ser exercido de várias formas, sendo que as modalidades de controle são assim classificadas pela doutrina:

a) Quanto ao momento

- **Preventivo (a priori)** – tem como objeto projeto de lei ou Proposta de - EC
- **Repressivo (a posteriori)** – tem como objeto a lei ou a EC.

b) Quanto ao órgão

- **Político** – feito pelo Legislativo e Executivo
- **Judicial** – feito pelo Poder Judiciário

Em regra o controle preventivo será feito de forma política (legislativo e executivo). Ex.: (1) pareceres da comissão de constituição e justiça. (2) veto do presidente da república. Da mesma forma, em regra o controle repressivo será judicial, dividido nos sistemas Difuso e Concentrado.

23.5.1 Exceções

a) Controle preventivo judicial:

O STF vem entendendo que o parlamentar possui direito líquido e certo de somente participar de processo legislativo que for compatível com a CRFB/88. Permite, assim, que o Parlamentar possa impetrar MS preventivo em face do ato da mesa da câmara ou do senado que tenha colocado para votação projeto inconstitucional. O MS tem como finalidade garantir o direito do parlamentar de não participar deste processo legislativo. Para dar provimento, o STF terá que analisar se o projeto é inconstitucional. A doutrina e jurisprudência defendem que é o único exemplo de controle preventivo judicial. A legitimidade ativa para o MS será somente do parlamentar. Não pode ser partido político, cidadão, etc. Por este motivo o STF entendeu no Informativo 647 (MS 27971) que, se no curso do MS o parlamentar perder tal qualidade (por exemplo, término do mandato), haverá perda do objeto, já que não haverá mais direito líquido e certo do Parlamentar a ser tutelado.

No Informativo 711 (MS 32033), o STF entendeu que o parlamentar pode impetrar o MS em caso de a) proposta de emenda à Constituição manifestamente ofensiva a cláusula pétrea; e b) projeto de lei ou de emenda em cuja tramitação se verificasse manifesta afronta a cláusula constitucional que disciplinasse o correspondente processo legislativo. Aduziu que, em ambas as hipóteses, a justificativa para excepcionar a regra de que o controle judicial é repressivo, estaria claramente definida na jurisprudência do STF.

b) Controle repressivo político:

1. Na lei delegada (art. 68 CRFB/88), o legislativo edita resolução, com os limites a serem respeitados pelo Presidente no momento de edição da lei delegada. Se houver exorbitância dos poderes, o legislativo poderá editar resolução, suspendendo os efeitos da lei delegada, na forma do art. 49. V.

2. Art. 62 §5º c/c §9º – Possibilidade de Câmara e Senado analisarem a compatibilidade da medida provisória com a CRFB/88 antes da conversão em lei.

3. Possibilidade da Administração revogar os próprios atos ilegais ou inconstitucionais – súmula 473 STF.

4. Possibilidade de o Presidente não aplicar no âmbito federal lei que reputar inconstitucional. Se a constitucionalidade dessa lei for confirmada pelo STF, o Presidente ficará sujeito ao impeachment (crime de responsabilidade).

23.6 FORMAS DE CONTROLE REPRESSIVO JUDICIAL

a) **RESERVADO OU CONCENTRADO:** é o controle abstrato, exercido por via de ação, normalmente de competência do STF, independe de um processo concreto. Difere do processo em geral pelas seguintes razões:

1. finalidade de eliminar a norma inconstitucional do sistema jurídico e não de resolver um conflito de interesses;
2. legitimação restrita;
3. ausência de partes contrapostas, já que é um processo objetivo.

São espécies de ações do controle concentrado:

- Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica, Art. 102, I, “a”, CRFB/88 e Lei nº 9868/99.
- Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, Art. 103, § 2º, CRFB/88 e Lei nº 9868/99
- Ação Declaratória de Constitucionalidade, Art. 102, I, “a”, última parte, CRFB/88 e Lei nº 9868/99.
- Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, Art. 102, §1º, CRFB/88 e Lei nº 9882/99.

- d) DIFUSO OU ABERTO:** é exercido por via de exceção ou de defesa e permite que qualquer órgão do Poder Judiciário tenha competência para realizar, no caso concreto, a análise sobre a compatibilidade do ordenamento jurídico com o ordenamento constitucional.

23.7 CONTROLE DIFUSO

- a) **Legitimidade ativa:** Por ser controle concreto, é realizado no curso de processos, e a inconstitucionalidade pode ser suscitada por qualquer dos envolvidos no feito (autor, réu, terceiros, Ministério Público, ou o próprio juiz, de ofício).
- b) **Órgão julgador:** O controle concreto ou difuso de constitucionalidade pode ser realizado por qualquer juiz ou Tribunal, inclusive STF, em qualquer fase do processo.
- c) **Normas objeto de controle:** Qualquer lei pode ser objeto de controle difuso, não há qualquer restrição, como no controle concentrado. Qualquer lei ou ato normativo, primário ou secundário, federal, estadual ou municipal, anterior ou posterior à CRFB/88 pode ser analisada no controle difuso.
- d) **Controle incidental:** É na fundamentação da sentença ou do acórdão que será realizado o controle incidental, faz parte da atividade precípua do judiciário. É uma questão prejudicial de mérito. O objeto principal da demanda não é a inconstitucionalidade. Assim, nenhum processo poderá ter como pedido a declaração de inconstitucionalidade de uma lei.

ATENÇÃO

Importante! Ação civil pública/Ação Popular e controle incidental – A doutrina moderna defende ser possível a discussão da inconstitucionalidade da lei, por via incidental, na ACP. O que não pode é discutir a constitucionalidade da lei, em tese, na ACP, como objetivo principal. Assim, ainda que seja reconhecida a inconstitucionalidade de uma lei na ACP, a lei não deixa de produzir efeitos para outras situações.

e) **Efeitos:** Em regra os efeitos desta sentença serão inter partes, somente produzirão efeito naquele caso concreto, entre as partes daquele feito. Excepcionalmente, a CRFB/88 prevê a possibilidade de efeitos erga omnes. Ocorrerá quando um processo chega ao STF por meio de recurso extraordinário ou qualquer outro feito de competência originária, e o STF decide, incidentalmente, que uma lei é inconstitucional. Pelo Regimento Interno do Tribunal (art. 178), o STF tem a obrigação de comunicar o Senado Federal sobre essa decisão. Então o Senado, quando e se quiser (art. 52, X), vai editar resolução, suspendendo a eficácia dessa lei inconstitucional. Se o Senado assim proceder, a execução da lei valerá para todos, a lei será retirada do ordenamento jurídico.

f) **Atuação do Senado Federal:** A participação do Senado está prevista desde 1934, mas, de acordo com a separação de poderes, o Senado não é obrigado, tampouco tem prazo para editar a resolução prevista no art. 52, X. Entretanto, se decidir suspender a norma, deverá seguir os limites da decisão do STF, e não pode suspender em parte lei declarada inconstitucional de forma plena pelo Supremo. A atuação do órgão legislativo, para efeito no art. 52, X, está prevista apenas no sistema difuso.

Sobre os efeitos produzidos em relação ao tempo, duas são as correntes doutrinárias:

- Para a primeira corrente, os efeitos da inconstitucionalidade devem operar *ex nunc*. A resolução só pode produzir efeitos do momento de sua publicação em diante. Isso significa que o efeito da resolução em relação ao tempo é produzido de

maneira diferente daquele verificado para quem é parte (*ex tunc*) na causa onde houve a declaração incidental. Funda-se esta corrente no fato de que a suspensão da norma é uma faculdade do Senado Federal; não é uma obrigatoriedade. Portanto, se ele pode decidir não suspender, caso suspenda, a decisão só valerá dali por diante. Esta corrente é a majoritária na doutrina, a qual também compartilhamos.

- A segunda corrente diz que os efeitos têm que ser *ex tunc*, sob pena de se violar o princípio da igualdade entre as pessoas. Não se pode determinar efeitos diferentes para quem é parte e para quem não é.

g) Princípio da reserva de plenário (ou regra do *full bench*): Em sede de controle difuso aplica-se o princípio de reserva de plenário, previsto no art. 97 da CRFB/88. O tema também é tratado nos artigos 948 a 950 do CPC e na Súmula Vinculante nº 10.

De acordo com o art. 97 da CRFB/88, uma norma só pode ser declarada inconstitucional pela maioria absoluta dos membros do tribunal ou de seu órgão especial. Eis o seu texto: “Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

Esse dispositivo atende ao princípio da presunção de constitucionalidade das leis que deve orientar o intérprete, pois toda norma deve ser interpretada de forma a se respeitar a vontade de seu criador (o Poder Legislativo). Assim, para que uma lei seja declarada inválida em decisão de órgão colegiado, a Constituição exige que a questão seja examinada por um grupo de juízes. Há presunção de que uma decisão tomada pela maioria estará menos exposta a erros.

Por maioria absoluta entende-se o primeiro número inteiro após a metade dos integrantes do órgão julgador. No caso, pode ser a maioria dos integrantes do Tribunal ou de seu órgão especial. O art. 93, XI, da CRFB/88, autoriza que sejam criados órgãos especiais nos tribunais cuja composição ultrapasse vinte e cinco julgadores. Os órgãos especiais, quando criados, exercerão a competência do órgão pleno, de acordo com a previsão nos regimentos internos dos respectivos Tribunais.

O princípio da reserva de plenário deve ser respeitado tanto no controle difuso quanto no concentrado.

A observância da cláusula da reserva de plenário não é necessária na hipótese de reconhecimento da constitucionalidade (princípio da presunção de constitucionalidade das leis), inclusive em se tratando de interpretação conforme, e não se aplica às decisões de juízes singulares, das turmas recursais dos juizados especiais, nem ao caso de não recepção de normas anteriores à Constituição.

O princípio ora analisado não se aplica à Turma Recursal de Juizado Especial, tendo em vista que, apesar de ser órgão colegiado, não possui status de Tribunal.

Reserva de Plenário nos Tribunais (Arts. 948 a 950 do CPC)

Quando a discussão da inconstitucionalidade da lei é colocada para exame de órgão fracionário do Tribunal (turmas, ou câmaras, por exemplo), deve-se observar os arts. 948 a 950 do CPC, quando três caminhos podem se abrir:

- a) se o órgão fracionário entender que a norma questionada é válida, prossegue no julgamento do mérito da causa, conforme dispõe o art. 949, I do CPC;
- b) se o órgão fracionário concordar com a inconstitucionalidade suscitada, não pode declará-la (em princípio). Deve promover a cisão do julgamento e remeter ao órgão pleno ou ao órgão especial do tribunal o exame da inconstitucionalidade. Nessa hipótese, o órgão pleno ou especial do tribunal examina tão somente se existe a inconstitucionalidade alegada e, lavrando acórdão, devolve-o ao órgão fracionário para a continuidade do julgamento, com a apreciação do mérito;
- c) se o órgão fracionário entender que a norma invocada para a solução do caso concreto é inválida e se esta invalidade já tiver sido declarada pelo órgão pleno ou especial daquele tribunal ou pelo órgão pleno do STF em outra causa, pode aplicar o entendimento de qualquer destas Cortes e julgar imediatamente o mérito da causa. Ou seja, por medida de economia e celeridade processuais, pode ocorrer de o órgão fracionário julgar diretamente o mérito da causa fundado em decisão anterior de inconstitucionalidade daquela mesma norma. É o que autoriza o art. 949, parágrafo único, do CPC.

Podemos concluir que o órgão fracionário não pode examinar e declarar a inconstitucionalidade de uma norma que ainda não tenha sido submetida ao órgão pleno ou ao órgão especial do tribunal ou do STF (princípio da reserva de plenário), sob pena de ofensa ao art. 97 da CRFB/88.

Para evitar a burla ao princípio de reserva de plenário pelos órgãos fracionários (decisão “escamoteada” de inconstitucionalidade da lei), o STF editou a Súmula Vinculante no 10, que assim afirma: Viola a cláusula de reserva de plenário (CRFB/88, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

ATENÇÃO

Importante!

– O princípio somente se aplica à declaração de inconstitucionalidade. Se o órgão fracionário entender que a norma é constitucional, poderá reconhecer sem a necessidade de fracionamento do julgamento.

– Turma Recursal de Juizado Especial não precisa observar o art. 97 para reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade, já que não é órgão fracionário de Tribunal; é órgão de 1º grau.

– O órgão fracionário poderá suscitar a inconstitucionalidade de uma lei, ainda quando as partes não o tenham feito. O que não poderá fazer é reconhecer a inconstitucionalidade. Deverá promover a cisão funcional de julgamento.

	Controle Difuso, aberto, ou “concreto”	Controle Concentrado, reservado ou fechado em âmbito federal
Julgador	Qualquer juiz ou Tribunal	STF (CRFB/88)
Legitimados	Qualquer pessoa (autor, réu, terceiros, Ministério Público, juiz, de ofício)	Art. 103, I a IX da CRFB/88
Forma de alegação	Via incidental, de defesa, de exceção	Via ação direta, principal. Formas: ADI, ADC, ADO e ADPF

Eficácia	Inter partes – regra Eficácia erga omnes - RISTF, art. 178 e art. 52, X da CRFB/88	Erga omnes
----------	---	------------

23.8 CONTROLE CONCENTRADO

As ações do controle concentrado, anteriormente indicadas, possuem algumas características comuns, ora relacionadas:

- Ausência de lide, já que não há caso concreto a ser decidido pelo judiciário;
- Todas as ações objetivas visam preservar a supremacia da CRFB/88;
- Nenhuma das ações admite desistência, porque é indisponível o interesse discutido;
- Não há prazo, prescricional ou decadencial, para o ajuizamento;
- Não se admite intervenção de terceiros;
- O rol de legitimados é restrito (art. 103, I a IX da CRFB/88);

O STF não está preso à congruência, adstrição e correlação. Pode entender pela inconstitucionalidade de dispositivos correlatos aos impugnados, não mencionados expressamente, ou seja, pela teoria da inconstitucionalidade por arrastamento (da adstrição ou da reverberação normativa) é possível declarar a inconstitucionalidade de dispositivos não impugnados na peça inicial mas com eles relacionados;

Todas as decisões do STF produzem efeitos subjetivos erga omnes.

Não há verdadeiro contraditório e ampla defesa, já que não importa a opinião do legislador, que editou a lei.

Não cabe recurso ou ajuizamento de ação rescisória.

23.8.1 Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica (ADI)

- a) **Histórico:** A ADI foi inserida pela EC 16/65, que alterou a Constituição de 1946. Na época era chamada de RI, representação de inconstitucionalidade, e só poderia ser proposta pelo PGR (Procurador Geral da República). Em 1988 ela ganhou contornos novos, passando a ser chamada de ADI, com a ampliação da legitimidade ativa e outros efeitos.

- b) **Finalidade:** A ADI tem por finalidade a declaração de inconstitucionalidade da lei que contraria a CRFB/88. Fundamento no art. 102, I, “a” da CRFB/88, que é norma de eficácia plena. Os aspectos processuais da ADI são tratados na Lei 9868/99.
- c) **Competência:** Se o conflito tem como objeto lei ou ato normativo federal ou estadual que contraria a CRFB/88, a competência é do STF, art. 102, I, “a”. Se o conflito é sobre a constitucionalidade de uma lei ou de ato normativo estadual ou municipal frente a uma Constituição Estadual, cabe ao TJ de cada Estado, sendo que neste caso ainda é chamada de representação de inconstitucionalidade, na forma do art. 125, §2º. Ambas as situações obedecem ao art. 97, CRFB/88.
- d) **Legitimidade ativa:** O rol dos legitimados para a propositura da ADI e de todas as demais ações do controle concentrado está previsto no art. 103 da CRFB/88.

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

I - o Presidente da República;

II - a Mesa do Senado Federal;

III - a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;

V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;

VI - o Procurador-Geral da República;

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

Legitimados Especiais: precisam demonstrar a pertinência temática, que é a comprovação no nexó entre o objeto da ação e o interesse que o legitimado pode defender. São legitimados especiais os previstos no art. 103, IV, V e IX.

Confederação deve provar também que foi criada em respeito ao art. 535 da CLT Segundo o STF, federações e sindicatos não podem apresentar a ação.

Já a entidade de classe de âmbito nacional – deve ter representação em pelo menos 9 estados brasileiros. Analogia com a lei de partido político (art. 8, da Lei 9096/95). Os interesses defendidos devem ser homogêneos, ou seja, devem pertencer a um mesmo grupo ou classe.

A Associação de associações tem legitimidade com fundamento no inciso IX do art. 103. São as associações nacionais que defendem os interesses das associações que congrega.

Legitimados Universais: não precisam demonstrar a pertinência temática. São os previstos no art. 103, I a III e VI a VIII.

O partido político, apesar de não precisar demonstrar pertinência temática, deverá demonstrar que tem representação do Congresso Nacional. Entende-se que basta um membro da Câmara dos Deputados ou do Senado. Se perder a representação no curso da ação, não haverá nenhum prejuízo ao regular trâmite da ação. O STF pacificou o entendimento de que a representação deve ser verificada no momento da propositura da ação. As ações devem ser propostas pelo Diretório Nacional do Partido.

- e) **Capacidade postulatória:** Alguns legitimados também possuem capacidade postulatória, ou seja, não precisam de advogado para ajuizar a ADI. Na ADI 127, o STF entendeu que somente não teriam capacidade postulatória (e, assim, precisam de advogado para ajuizar a ADI), os legitimados dos incisos VIII e IX.

Legitimado	Especial/Universal	Capacidade Postulatória
I - o Presidente da República;	Universal	Sim
II - a Mesa do Senado Federal;	Universal	Sim
III - a Mesa da Câmara dos Deputados;	Universal	Sim
IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;	Especial	Sim
V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;	Especial	Sim
VI - o Procurador-Geral da República;	Universal	Sim
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;	Universal	Sim

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;	Universal	Não
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional	Especial	Não

- f) **Objeto:** Segundo Clèmerson Merlin Clève²⁸⁹, podem ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade: as emendas constitucionais, atos normativos formalmente legislativos (leis complementares, ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos etc.), tratados internacionais, desde que integrem o ordenamento jurídico atual, leis distritais que tenham como tema matéria de competência estadual.

As normas constitucionais originárias não podem ser objeto de controle, difuso ou concentrado, porque segundo o STF gozam de presunção absoluta de constitucionalidade. Já as normas constitucionais derivadas, provenientes de EC, podem ser inconstitucionais, já que podem confrontar as normas constitucionais originárias. Assim, pode ser dito que há norma constitucional inconstitucional.

Os “atos normativos” são aqueles que não passam pelo processo legislativo completo (ex.: são editados pelo Executivo, ou não passam pelo crivo do Executivo para sanção ou veto), mas possuem os atributos da abstração, generalidade e são advindos do Poder Público. Os atos normativos primários poderão ser objeto de controle, desde que provenham do Poder Público federal ou estadual.

Não podem ser objeto do controle concentrado:

- Leis municipais e leis distritais de conteúdo municipal

- **Atos normativos secundários** - O STF entende que para que seja possível o controle concentrado, é necessário que o ato normativo seja primário, ou seja, retire fundamento de validade diretamente da CRFB/88. Se a fonte de validade direta for um ato normativo primário, não há que se falar em controle de constitucionalidade, mas sim controle de legalidade.

- **Normas pré-constitucionais** - Normas pré-constitucionais também não podem ser objeto de ADI. Se não forem compatíveis com a nova ordem constitucionais, o fenômeno será o da não recepção (e da revogação), e não

289. CLÉVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000

da inconstitucionalidade.

- Projetos de lei e propostas de EC – o controle concentrado é repressivo. Enquanto não for lei (ou EC), não há que se falar em controle concentrado.

- Normas já revogadas

- Súmulas – o STF já se manifestou no sentido de que súmula é uniformização de jurisprudência e não possui as características de abstração e generalidade necessárias para se caracterizar como ato normativo.

- Leis de efeitos concretos (via de regra) - Formalmente se apresenta como lei. No entanto, não possui a característica da abstratividade e generalidade. Ex.: lei que altera nome de aeroporto, de ruas. O STF entende que como regra não é possível análise de lei de efeitos concretos em ADI. Mas na ADI 4048 aceitou controle de lei orçamentária, que é doutrinariamente reconhecida como lei de efeitos concretos, já que trata de questão administrativa.

Obs.: Medida Provisória - Se no curso da ADI a medida provisória for convertida em lei ordinária sem alterações ou com alterações não substanciais, não haverá prejuízo ao regular prosseguimento do feito, devendo apenas o autor promover o aditamento à petição inicial, informando ao STF a mudança do objeto. Se, entretanto, no curso da ADI a medida provisória é rejeitada ou convertida em lei ordinária com alterações significativas, a ADI perderá o objeto e será julgada extinta sem decisão de mérito. Vale para ADC e ADI.

g) Concessão de medidas cautelares: A possibilidade de cautelar é prevista expressamente no art. 10 da Lei 9868/99. O objetivo da medida cautelar é a suspensão da norma até que sobrevenha decisão definitiva. Por ser ação do controle abstrato, os efeitos subjetivos são erga omnes.

Não há previsão legal para a vinculação do Poder Judiciário ou da Administração Pública, em sede de cautelar. No entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que há vinculação também em relação à medida cautelar.

Efeitos temporais – a regra geral é que a decisão cautelar produz efeitos ex nunc, até mesmo porque se trata de liminar. Mas excepcionalmente o STF poderá conceder efeitos ex tunc. A exceção está prevista no art. 11, §1º da lei 9868.

Efeitos repristinatórios – previsto no art. 11, §2º. A suspensão da norma em sede liminar torna aplicável a legislação anterior, supostamente revogada pela norma tida por inconstitucional. Visa evitar a lacuna legislativa. O efeito será automático. Somente não será assim se houver expressa manifestação em sentido contrário na decisão que concedeu a liminar.

- h) ***Amicus Curiae***: A figura do *amicus curiae* está prevista no art. 7º, §2º da lei 9868/99 e art. 3º, §2º da lei 11.417/06. É um colaborador em qualquer ação do controle direto. Ajuda nas questões técnicas (ex.: lei de biossegurança), ou para demonstrar ao STF o impacto social de determinada decisão. É um instrumento de legitimação social das decisões do STF, tendo em vista que o cidadão não pode ajuizar nenhuma das ações do controle concentrado de constitucionalidade, tampouco participar do processo de edição das súmulas vinculantes.

O pedido de colaboração é feito ao ministro relator da ADI. Não cabe recurso da decisão que aceita a colaboração. A negativa de atuação enseja o recurso de agravo, para que a questão seja decidida pelo plenário. O *amicus curiae* pode pedir para atuar até a remessa dos autos para julgamento. Se aceita a colaboração, o *amicus curiae* poderá oferecer memoriais, perícias, e até mesmo realizar sustentação oral.

- i) **Procurador Geral da República** (art. 103, § 1º da CRFB/88): atua como custos legis (fiscal da lei), devendo pronunciar-se a respeito da controvérsia constitucional. Inclusive, ele pode ser em alguns casos autor e fiscal (ele é um dos legitimados para a propositura).

É possível que o PGR ajuíze uma ADI e, posteriormente, altere seu posicionamento pronunciando-se pela constitucionalidade da lei ou ato normativo em parecer. Esta mudança de posição não equivale à desistência (art. 5º da Lei nº 9868/99), já que o STF proferirá normalmente sua decisão.

- j) **Advogado Geral da União** (art. 103, § 3º): atua nas ações diretas como uma espécie de defensor do Princípio da Constitucionalidade das leis. Sua função na realidade limita-se a lembrar ao STF que toda lei, ao menos em tese, nasce compatível, material e formalmente com a CRFB/88.

O STF entende que nesse processo o AGU não age na sua função ordinária de representante judicial ou extrajudicial da União (art. 131 da CRFB/88), mas age na defesa da constitucionalidade da norma (competência especial) garantindo o contraditório.

Até recentemente, o STF defendia que como curador das normas infraconstitucionais, em sede de controle abstrato, não poderia opinar pela inconstitucionalidade da norma. Entretanto, na ADI 1616 o STF decidiu que o AGU não é obrigado a defender norma quando a Corte já tenha fixado entendimento pela sua inconstitucionalidade, por exemplo, no controle difuso.

Já no julgamento da ADI 3916 o STF relativizou ainda mais a atuação do AGU, entendendo que o AGU não é mais obrigado a fazer a defesa da constitucionalidade do texto impugnado. Deverá agir de acordo com a sua livre convicção jurídica. Se entender que é inconstitucional, não deverá defender a norma, até mesmo porque não haverá qualquer sanção.

Assim, o texto do art. 103 §3º continua intacto, mas pode ser dito que a atuação obrigatória do AGU foi relativizada pela jurisprudência do STF, sofrendo mutação constitucional.

- k) Efiácia:** Os efeitos da decisão proferida em ADI estão previstos nos artigos 22 a 28 da Lei 9868/99. Os efeitos são sempre erga omnes, já que se trata de ação do controle concentrado. Essa decisão vincula não só a sociedade, mas também aos órgãos do poder judiciário e executivo. O legislativo não fica vinculado, sob pena de fossilização do ordenamento jurídico.

Efeitos temporais: O Brasil adota a teoria da nulidade. Assim, a regra é que a lei inconstitucional não produzirá efeitos válidos, perdendo efeito desde a sua edição. Ocorre que em alguns casos, o STF pode concluir que os efeitos ex tunc serão prejudiciais à sociedade. Assim, o art. 27 da lei 9868/99 traz o importante instituto da modulação temporal dos efeitos. Portanto, o STF, por razões de segurança jurídica ou relevante interesse social, pode decidir que a norma não será válida:

- a partir do trânsito em julgado da decisão (efeito ex nunc)
- posteriormente ao acórdão (eficácia pro futuro)
- em qualquer momento entre a vigência da norma e o trânsito em julgado do acórdão.

A reserva de plenário impõe ao STF que respeite a necessidade de maioria absoluta de votos para reconhecer a inconstitucionalidade (6 votos). Mas para modular os efeitos, será necessário quórum qualificado de 2/3 dos ministros (8 votos).

Para que haja modulação dos efeitos da sentença, é necessário que haja pedido neste sentido. Segundo a jurisprudência clássica do STF, quando houver pedido de modulação e o STF não se manifestar, caberá embargos de declaração. Não seria possível a utilização do ED, no entanto, quando na inicial não tivesse sido requerida a modulação dos efeitos. Entretanto, o STF relativizou recentemente essa posição, ao aceitar ED para fins de modulação ainda que o autor não houvesse pleiteado na inicial e tampouco a Corte houvesse decidido a seu respeito (ADI 3601, Informativo 599 STF).

A decisão de inconstitucionalidade na ADI vincula o próprio STF, produzindo coisa julgada material. Isso quer dizer que o STF não vai receber outra ação no controle concentrado ou difuso questionando a constitucionalidade dos mesmos dispositivos já descartados pela corte.

Mas a decisão de constitucionalidade na ADI não vincula o STF, que entende que, alteradas as circunstâncias fáticas, nada impede que a matéria venha a ser rediscutida.

1) Jurisprudência relevante do STF

Súmula 360 do STF: *“Não há prazo de decadência para a representação de inconstitucionalidade prevista no art. 8º, parágrafo único, da Constituição Federal.”*

“Pedido de desistência. Legitimidade ativa. Em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade, já se firmou, nesta Corte, o entendimento de que ação dessa natureza não é suscetível de desistência.” (ADI 164, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 17/12/93)

Súmula 642 do STF: *“Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal.”*

m) Interpretação conforme a Constituição e declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto:

A base legal: art. 28 parágrafo único da Lei 9868/99, são técnicas utilizadas tanto no controle concentrado como no controle difuso.

Interpretação conforme a Constituição - Quando uma lei possui mais de uma interpretação (plurissignificativa), e apenas uma forma de interpretar se adequa à CRFB/88, o STF não precisa julgar inconstitucional, porque existe uma interpretação de acordo. Assim, o STF confirma a constitucionalidade da lei, desde que interpretada de uma forma específica. Afasta as interpretações da lei que sejam contrárias à CRFB/88.

Declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto - A lei impugnada não possui mais de uma interpretação. Da forma como foi criada, a lei é inconstitucional. Mas é possível que o STF retire uma hipótese de incidência que seria inconstitucional, não apreciando o mérito do resto da lei. Ex.: Lei da Ficha Limpa – não decidiu se a lei seria inconstitucional ou constitucional. Somente disse que não seria constitucional a aplicação da lei nas eleições de 2010, por ferir o princípio da anualidade. A lei poderá ser objeto de nova análise pelo STF. Ainda, os demais órgãos do Judiciário somente serão obrigados a seguir o entendimento do STF quando à hipótese de não incidência da lei. Mas nos demais aspectos da lei, sua atuação é livre.

23.9 AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE (ADC)

a) Base Legal: art. 102, I, a da CRFB/88 e Lei 9868/99.

b) Finalidade: A ADC surgiu com a EC 03/93, com o objetivo de defender a segurança jurídica diante de decisões controvertidas a respeito da aplicação da lei, que inclusive devem ser apresentadas na petição inicial, na forma do art. 14, III da Lei 9869/99. Na ADC 08 o STF decidiu que deve existir um volume expressivo de decisões judiciais controvertidas da lei objeto da ação para fins de recebimento da petição inicial.

-
- c) **Legitimidade ativa:** Atualmente, são os mesmos legitimados da ADI, com as considerações anteriormente mencionadas. Deve ser ressaltado, no entanto, que o rol da CRFB/88 (art. 103) difere do art. 13 da Lei 9868/99. Isso porque a CRFB/88 foi alterada com a EC 45/2004, para adequar o rol à ADI, revogando implicitamente o art. 13 da referida lei.
- d) **Objeto:** O objeto da ADC é mais restrito, porque no art. 102, I, 'a' da CRFB/88 há previsão de que somente é possível ajuizar ADC em face de lei ou ato normativo federal. Não cabe em relação a leis estaduais, que podem ser objeto de ADI.
- e) **PGR:** A participação é idêntica à ADI.
- f) **AGU:** Na ADI, o AGU tem o papel de defender a presunção de constitucionalidade da lei. Na ADC, não há participação do AGU, porque quem ajuizou a ação apresentou argumentos em defesa da presunção de constitucionalidade da norma.
- g) ***Amicus Curiae:*** A participação é idêntica à ADI.
- h) **Cautelar:** A cautelar de ADC é diferente da cautelar de ADI. Na forma do art. 21 da Lei 9868/99, a concessão da cautelar em sede de ADC produz efeitos erga omnes e vinculantes e determina a suspensão dos processos em curso que dependam da aplicação da lei objeto da ação. O parágrafo único do dispositivo prevê que se em 180 dias não houver conclusão do julgamento, a cautelar perde sua eficácia e os juízes poderão aplicar ou não a lei, de acordo com seu livre convencimento, até a decisão de mérito do STF. Entretanto, no julgamento da Reclamação 5758 (Inf. 546), o STF entendeu pela extensão dos efeitos da cautelar para além do prazo de 180 dias, ao analisar a ADC nº 11, que versa sobre a constitucionalidade da ampliação do prazo de embargos a execução opostos pela Fazenda Pública (art. 730 do CPC e 884 da CLT).

i) Ambivalência entre ADI e ADC em relação à decisão de mérito:

De acordo com o art. 24 da Lei 9868/99, é possível que seja declarada a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei em sede de ADI ou ADC, tendo em vista a natureza ambivalente, dúplice ou fungível das duas ações.

Em sede de ADI, o STF pode:

Dar provimento = norma é inconstitucional.

Negar provimento = norma é constitucional.

Em sede de ADC, o STF pode:

Dar provimento = norma é constitucional.

Negar provimento = norma é inconstitucional

Não há ambivalência quanto às cautelares, somente em relação à decisão de mérito.

23.10 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO

- a) **Histórico:** A ADO nasceu em 1988, inspirada pelo direito português, com o objetivo de defender a CRFB/88 em face da síndrome da inefetividade das normas constitucionais de eficácia limitada dependentes de regulamentação. Até 2007 a Corte adotava uma posição conservadora a respeito da sua decisão final, mas o entendimento hoje é mais concretista do que o anteriormente adotado.
- b) **Base Legal:** art. 103, §2º CRFB/88. O procedimento está previsto na Lei 9868/99, com a redação da Lei 12.063/2009. A Lei 12.063 acrescentou vários dispositivos à Lei 9868/99 (art. 12-A e seguintes).
- c) **Finalidade:** É a de dar plena efetividade a todas as normas constitucionais de eficácia limitada dependentes de regulamentação. Não se refere apenas a normas constitucionais que tratam de direitos fundamentais. Serve para qualquer norma constitucional de eficácia limitada que dependa de regulamentação.

- d) Legitimidade Ativa:** Os mesmos legitimados ativos da ADI e ADC.
- e) Objeto:** Podem ser objeto da ADO as omissões normativas, totais ou parciais. Ficam de fora as omissões administrativas e judiciais. As omissões administrativas são questionadas via ação civil pública, MS ou ação popular. Já as omissões judiciais são combatidas por meio dos recursos. As omissões normativas, que são objeto da ADO, podem ser classificadas em:
- Omissão Total: Ocorre quando não há lei, mas há previsão constitucional pendente de normatividade: Ex.: artigo 37, VII (direito de greve); artigo 40, §4º (direito à aposentadoria especial por tempo de serviço).
 - Omissão Parcial: A CRFB/88 exige lei, mas a lei existente não trata da matéria de forma a satisfazer as exigências constitucionais. Ex.: art. 7º, IV da CRFB/88 (salário mínimo).
- f) PGR:** É diferente da ADI e ADC. Nos termos do art. 12-E, §3º da Lei 9868/99, alterada pela Lei 12.063, o PGR somente irá atuar como custos legis nas ações que não tenham sido por ele propostas.
- g) AGU:** Em que pese o art. 12-E §3º da Lei 9868/99 prever a possibilidade de manifestação do AGU, esta somente faz sentido quando se trata de omissão parcial. Isso porque o AGU é o defensor da constitucionalidade das leis e, no caso de omissão total, não há lei a ser defendida.
- h) Amicus Curiae:** Atuação idêntica à ADI e ADC.
- i) Cautelar:** O artigo 12-F, parágrafo 1º, da Lei 9868/99 prevê que a cautelar da ADO poderá consistir na suspensão da aplicação da lei em caso de omissão parcial, na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos ou, ainda, em qualquer outra providência a ser fixada pelo Tribunal. É importante destacar que até o momento o STF não concedeu cautelares em sede de ADO.

- j) Efeitos da Decisão Definitiva:** O entendimento do STF quanto às omissões legislativas vem sofrendo alteração ao longo dos anos, em especial desde 2007, tal como já exposto por ocasião da análise do mandado de injunção. A regra geral em sede de ADO é a adoção da posição não concretista, em que o STF somente declara a mora do Poder omissor.

No entanto, na ADI 3682, o STF adotou a chamada posição concretista intermediária. Nesta ação, que versava sobre o art. 18, §4º, o STF entendeu que, apesar de ter sido ADI, em sentido material era ADO. O art. 18, §4º diz que, para criação de novo município, é necessária lei estadual, em prazo definido em LC federal, que ainda não foi editada. O STF em maio de 2007 julgou esta ação e não se limitou a reconhecer a mora. Fez mais, determinando prazo de 18 meses para esta regulamentação. Ocorre que essa posição é frágil, porque o STF não indica qualquer sanção para descumprimento do prazo fixado. O princípio da separação de poderes é o argumento suscitado para impedir qualquer sanção.

É um momento de transição, sendo que a posição concretista intermediária somente foi aplicada neste caso específico, não podendo ser afirmado que será a regra a partir de então.

k) Quadro Comparativo MI x ADO

	Mandado de Injunção	ADO
Origem	Direito Norte Americano	Direito Português
Base Legal	Art. 5º, LXXI Lei 13.300/2016	Art. 103, § 2º, Lei 9868/99
Natureza Jurídica	Remédio Constitucional Processo Subjetivo	Ação do Controle Concentrado Processo Objetivo
Extensão	Defender Direitos Fundamentais dependentes de regulamentação	Defender Normas Constitucionais dependentes de regulamentação
Legitimidade Ativa	MI Individual/Coletivo	Art. 103, I a IX
Órgão Competente	Depende do polo passivo	STF
Efeitos	Via de regra inter partes	erga omnes
Cautelar?	NÃO	SIM

ATENÇÃO

Importante! Tudo o que pode ser questionado em sede de MI poderá ser questionado em sede de ADO, mas a recíproca não é verdadeira. Já que ADO serve para questionar omissões de qualquer norma constitucional, enquanto o objetivo do MI é somente viabilizar o exercício de direito fundamental de que dependa de regulamentação.

23.11 ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

- a) **Base Legal:** 102, §1º CRFB/88; Lei 9.882/99: A ADPF foi prevista no artigo 102, §1º da CRFB/88, que previa que caberia ao STF julgar a ADPF, na forma da lei. A regulamentação só veio com a Lei 9.882, de dezembro de 1999 (11 anos depois). Só a partir de então o STF entendeu que seria possível a utilização da ADPF. Por isso se diz que é a ação mais nova do controle concentrado.
- b) **Finalidade:** Segundo Gilmar Mendes, a ADPF nasceu para suprir algumas lacunas até então existentes do controle concentrado de constitucionalidade, como, por exemplo, a possibilidade da análise, em tese, de lei municipal perante a Constituição Federal.
- c) **Preceito fundamental:** Não há artigo ou lei com uma “lista” do que é preceito fundamental. Deve ser consultada a jurisprudência do STF, já que somente as normas constitucionais qualificadas como preceitos fundamentais poderão ser parâmetro de ADPF. No julgamento da ADPF 33 o STF trouxe um rol meramente exemplificativo do que é considerado preceito fundamental:

Art. 1º a 4º -> Princípios fundamentais

Art. 5º a 17 -> Direitos e garantias fundamentais

Art. 34, VII -> Princípios constitucionais sensíveis

Art. 37, caput -> Princípios da Administração pública: “LIMPE”

Art. 60, §4º -> Cláusulas pétreas

Princípios constitucionais “sensíveis” ou “sensoriais”: Alguns autores dizem que são chamados de sensíveis pois seriam de fácil percepção. Outra explicação é que seriam os assuntos sensíveis ao Estado, já que cuidam da proteção da democracia, da república, dos direitos fundamentais, da autonomia municipal, entre outros.

- d) **Legitimidade Ativa:** Os legitimados ativos são os mesmos da ADI, ADC e ADO – Art. 103, I a IX. Não há legitimidade ativa popular para a apresentação das ações do controle concentrado!
- e) **Caráter subsidiário:** A ADPF apresenta caráter subsidiário, por força do art. 4º §1º da Lei 9.882/99, que prevê que somente poderá ser utilizada a ADPF quando não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade. Se couber ADI ou ADC não caberá ADPF.

Atualmente, a ADPF também é vista como subsidiária em relação ao controle concentrado estadual. Se a lei municipal violar tanto CE como CRFB/88, só caberá RI, em face do art. 125 §2º. Lembrando que a decisão do TJ em RI será passível de Recurso Extraordinário, a ser julgado pelo STF. Somente será possível ADPF se a lei municipal não violar a CE mas violar a CRFB/88 diretamente.

- f) **Objeto:** Considerando o caráter subsidiário da ADPF, e as questões já abordadas pelo STF, são hipóteses de cabimento:
 - Lei municipal que ofende a CRFB/88, sem ofender a Constituição Estadual.
 - **Lei distrital de caráter municipal** – se for de caráter estadual caberá ADI.
 - **Norma pré-constitucional** - É certo que a norma pré-constitucional não é inconstitucional, mas sim não recepcionada. Mas como a ADPF admite múltiplos pedidos, é possível pedir que em razão da não recepção da norma pré-constitucional, o STF revogue a norma. Essa possibilidade foi analisada na ADPF 130 (o STF reconheceu a não recepção de artigos da lei de imprensa) e também na ADPF 153 (o STF entendeu pela recepção da lei de anistia - de 1979).
 - **Atos normativos secundários** (portarias, circulares, etc.)

g) **PGR:** Atuação idêntica à ADI.

h) **AGU:** A atuação do AGU não é obrigatória em toda ADPF. Vai atuar na defesa dos atos normativos e não irá atuar obrigatoriamente quando são questionados atos do poder público não normativos, como o veto. A lei prevê, no entanto, que o Relator da ADPF solicite a manifestação do AGU nestas hipóteses.

i) ***Amicus Curiae:*** Atuação idêntica em todas as ações do controle concentrado.

j) **Modalidades / Espécies de ADPF:** ADPF principal e ADPF incidental.

ADPF principal: Prevista no art. 1º caput da Lei 9882/99 e no art. 102, §1º da CRFB/88. É a ação autônoma, que vai formar processo objetivo, a ser julgada pelo STF. É a ADPF mais comum. É a que segue as regras da ADI.

ADPF incidental: Esta ADPF foi criada com base na expressão do dispositivo: “caberá também, ADPF (...)”. A doutrina sustenta que seria uma segunda espécie de ADPF, proposta dentro de um processo subjetivo, que promoveria uma cisão funcional vertical de competência, levando ao STF a análise da constitucionalidade, paralisando o processo subjetivo até a análise da questão prejudicial. É uma ação do controle concentrado concreto.

Controle Concentrado Abstrato: ADI, ADC, ADO, ADC, ADPF principal.

Controle Concentrado Concreto: ADPF incidental e ADI interventiva.

A ADPF incidental não é utilizada na prática, porque os sujeitos do processo não têm legitimidade para ajuizar a ADPF. A legitimidade pertence somente aos legitimados do art. 103 da CRFB/88. Assim, na ADPF Incidental, a parte deste processo subjetivo deverá peticionar a um dos legitimados ativos, requerendo a propositura desta ação (pedido de cisão funcional vertical de competência, passando a um órgão com competência acima daquele Tribunal ou Juiz, remetendo-se o feito). Ajuizada a ADPF incidental, remete-se o feito ao STF e, em sendo aceita a ação, suspende-se o processo esperando que a questão prejudicial seja decidida.

ADPF Principal

ADPF Incidental

Processo Objetivo	Processo Subjetivo
Via de Ação	Via Indireta
Artigo 1º, caput	Artigo 1º, parágrafo único, I

- k) **Cautelar/Decisão definitiva:** O art. 5º, §3º da Lei 9882/99 prevê a possibilidade de cautelar em ADPF, que pode ser para suspender o andamento do feito ou qualquer outra medida que apresente relação com a matéria. A decisão cautelar irá produzir efeitos erga omnes e vinculantes. Quanto à decisão final, o artigo 11 da referida Lei ainda prevê a modulação temporal dos efeitos da sentença da ADPF nos moldes da técnica adotada em sede de ADI.

CAPÍTULO 24

QUESTÕES RELEVANTES NO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE



24.1 A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL

Se a decisão do STF produz efeito vinculante, significa dizer que o seu descumprimento possibilita a interposição da reclamação perante o Tribunal, na forma do art. 102, I, I, da CRFB/88, a fim de que seja garantida a autoridade de sua decisão ou a sua competência. Da mesma maneira, qualquer desrespeito ao rol constitucional de suas atribuições previstas no art. 102, I a III, pode ser levado ao conhecimento da Corte por meio da reclamação, com base no dispositivo mencionado e também em consonância com os arts. 988 a 993 do CPC. O descumprimento de súmulas vinculantes também podem ensejar a apresentação de uma Reclamação diretamente ao STF.

O art. 13 da Lei no 9.882/99 também reforça o instituto da reclamação:

“Caberá reclamação contra o descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na forma do seu Regimento Interno”.

Mas qual é a natureza jurídica da Reclamação? O assunto ainda é controvertido na doutrina, conforme bem sintetizou o Ministro do STF, Celso de Mello, na Rcl. no 336²⁹⁰, mas entendemos, com apoio em abalizada doutrina²⁹¹, que se trata de uma verdadeira ação autônoma de impugnação de decisão judicial e administrativa violadora das decisões ou competência do STF.

Até 2002 a jurisprudência do STF indicava que a reclamação, em sede de controle de constitucionalidade, só poderia ser proposta pelos legitimados do art. 103, I a IX, da CRFB/88. De 2002 para cá a

290. “A reclamação, qualquer que seja a qualificação que se lhe dê – ação (Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, tomo v/384, Forense), recurso ou sucedâneo recursal (Moacyr Amaral Santos, RTJ 56/546-548; Alcides de Mendonça Lima, O Poder Judiciário e a Nova Constituição, p. 80, 1989, Aide), remédio incomum (Orosimbo Nonato, apud Cordeiro de Mello, O Processo no Supremo Tribunal Federal, vol.1/280), incidente processual (Moniz de Aragão, A Correição Parcial, p. 110, 1969) (...) configura, modernamente, instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504, destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem político-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do STF (CRFB/88, art. 102, I, I) e do STJ (CRFB/88, art. 105, I, f) (...).” (j. 19.12.90, DJU 15.03.91).

291. Nesse sentido, PONTES DE MIRANDA. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense. t. v.

Corte²⁹² mudou o seu entendimento anterior para admitir que qualquer pessoa que esteja sofrendo prejuízo pela não observância do efeito vinculante possa provocar o STF por meio da reclamação.

Inclusive, recentemente, o STF reconheceu a legitimidade ativa ad causam do Ministério Público dos Estados-membros para ajuizar, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, reclamação destinada a fazer prevalecer a autoridade de enunciado constante de súmula vinculante, cujo teor normativo tenha sido concretamente desrespeitado por ato emanado do Poder Executivo ou proferido por qualquer órgão do Poder Judiciário²⁹³.

Já o Ministério Público do Trabalho não tem legitimidade para o oferecimento da Reclamação perante o STF, tendo em vista que quem atua em nome do Ministério Público da União perante a Corte é o Procurador-Geral da República, nos termos do art. 46 da Lei Complementar no 75/93²⁹⁴.

Também é importante destacar que como a atividade legiferante do Estado não está vinculada ao teor das decisões vinculantes do STF nas ações do controle concentrado, não cabe Reclamação em face da lei ou do ato normativo.

Ressalte-se que na forma da Súmula nº 734 do STF e também do art. 988, § 5º, I, do CPC, não caberá reclamação contra decisão judicial transitada em julgado.

292. Um dos julgados importantes que demonstram essa evolução jurisprudencial pode ser visto na Rcl. no 1.880/QO/AgRg/SP, Plenário, 23.05.2002, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU 19.03.2004.

293. STF, Rcl 7245, Min. Rel. Celso de Mello, j. 02.08.2010.

294. “Na linha do que decidido na Rcl 4453 AgR-AgR-MC/SE (DJE 08.05.2009) – no sentido de que incumbe privativamente ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo, nos termos do art. 46 da Lei Complementar no 75/93 –, e salientando o princípio da unidade institucional do Ministério Público, o Tribunal, por maioria, não conheceu de embargos de declaração opostos pelo Subprocurador-Geral do Trabalho, em nome do Ministério Público do Trabalho, contra acórdão que julgara procedente pedido formulado em reclamação e, declarando a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, determinara a imediata remessa dos autos à Justiça Comum estadual. O acórdão reclamado vislumbra ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo na ADI 3395 MC/DF (DJU de 10.11.2006), que suspendera qualquer interpretação ao art. 114 da CRFB/88 que incluísse na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, tendo por base o vínculo de ordem estatutária ou jurídico-administrativa. Vencido o Min. Marco Aurélio, que conhecia dos embargos por considerar que o MPT, por atuar como parte na ação civil pública apreciada na reclamação, e não como fiscal da lei, teria legitimidade para embargar.” Rcl 5381 ED/AM, Rel. Min. Carlos Britto, 20.05.2009 (Rcl-5381) Informativo 547.

24.2 JURISPRUDÊNCIA SOBRE RECLAMAÇÃO

“Inexiste ofensa à autoridade de Súmula Vinculante quando o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema.” (Rcl 6.449-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 25-11-2009, Plenário, DJE de 11-12-2009).

“Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do STF destituída de efeito vinculante. Precedentes. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos Ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC 45/2004).” (Rcl 3.284-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 1º-7-2009, Plenário, DJE de 28-8-2009).

“(…) somente as decisões concessivas das liminares em ADIs e ADCs é que se dotam de efeito vinculante. Não as denegatórias. Ante a natureza subjetiva do processo, as decisões proferidas em reclamação não têm eficácia erga omnes (contra todos).” (Rcl 3.424-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 11-10-2007, Plenário, DJE de 1º-8-2008). No mesmo sentido: Rcl 2.658-AgR, Rcl 2.811-AgR e Rcl 2.821-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 16-9-2009, Plenário, DJE de 16-10-2009.

“Reclamação não é recurso e não se destina a examinar o ato impugnado com vistas a repudiá-lo por alguma invalidade processual-formal ou corrigi-lo por erros em face da lei ou da jurisprudência.” (Rcl 3.800-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 2-2-2006, Plenário, DJ de 9-6-2006.)

“A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl 4.058-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 17-2-2010, Plenário, DJE de 9-4-2010.)

“Impossibilidade de utilização de reclamação quando há recurso apropriado e cabível contra a decisão reclamada.” (Rcl 5.159-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 26-6-2007, Primeira Turma, DJ de 10-8-2007.)

“É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do STF, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados.”
(Rcl 9.732-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 20-6-2012, Plenário, DJE de 8-3-2013.)

24.3 NATUREZA DO ATO INCONSTITUCIONAL

O ato normativo inconstitucional é um ato nulo ou anulável?

Em regra o ato inconstitucional é nulo. Nulo é o que nunca existiu. Se o ato normativo for nulo, significa que não produziu efeitos, segundo a teoria clássica da nulidade.

Com o advento da Lei no 9.868/99²⁹⁵, essa teoria foi relativizada ao se dar ao Supremo Tribunal Federal o poder de trabalhar com os efeitos da decisão no tempo e tornar o ato inconstitucional anulável. Se o ato inconstitucional é anulável, enquanto não tenha sido declarado inválido, pode ter produzido efeitos. Portanto, se o STF toma uma decisão declaratória de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc, o ato é anulável. Em consequência, é possível a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade.

Com isso, são efeitos no tempo que uma decisão em ADI ou ADC pode produzir:

- **Regra – ex tunc: ato nulo.**
- **Exceção – ex nunc ou prospectivo: ato anulável.**

24.4 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO ABSTRATO ESTADUAL

A EC no 16/65 foi responsável pela criação da Representação de Inconstitucionalidade nos Estados, mas, à época, a ação só poderia ter como objeto lei ou ato normativo municipal que violasse a Constituição do Estado. A atual Constituição Federal ampliou o objeto da ação e no art. 125, § 2º,

295. “Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.”

dispõe que a Representação de Inconstitucionalidade (que pode ser chamada de ADI ou RI estadual) pode ser proposta em face de lei ou ato normativo estadual ou municipal.

Importante destacar que a criação da ação é obrigatória e que será proposta perante o Tribunal de Justiça do próprio Estado, tendo por parâmetro a Constituição Estadual (e não federal). Se o Tribunal estadual declarar a inconstitucionalidade de uma lei estadual ou municipal, no âmbito da RI com base na Constituição Federal, estará, claramente, usurpando competência do STF, que é o único órgão responsável pelo controle concentrado federal (art. 102, I, a, CRFB/88).

Ainda no que diz respeito ao parâmetro do controle estadual, o STF já decidiu que toda a Constituição do Estado, inclusive as normas de observância obrigatória ao modelo federal, servem como base do controle estadual.

Embora não tenha sido incluída previsão para a criação, em âmbito estadual, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, da ação declaratória de constitucionalidade, muito menos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, o STF entende que nada impede esta inovação pelas Constituições Estaduais, em nome do princípio da simetria.

No que tange à legitimidade ativa das ações estaduais, a Constituição Federal fez apenas uma recomendação: que a legitimação para agir não seja atribuída a apenas um órgão ou entidade. Quis o constituinte originário que a jurisdição constitucional estadual fosse exercida democraticamente, como ocorreu com a fixação da legitimação prevista no art. 103, I a IX. Antes da Constituição de 1988 apenas o procurador-geral da República era legitimado para o controle abstrato da constitucionalidade das normas.

Em muitas situações pode ocorrer de o ato normativo estadual ser objeto, ao mesmo tempo, de ADI perante o STF e de representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual, quando a norma do Estado viola tanto a Constituição Federal quanto a Carta Estadual no dispositivo que reproduz norma de observância obrigatória. Nesse caso, a representação de inconstitucionalidade estadual fica suspensa até o julgamento final da ADI proposta perante o STF, a fim de evitar decisões contraditórias²⁹⁶.

296. A instauração do processo de fiscalização normativa abstrata, perante o Supremo Tribunal Federal, em que se postule a invalidação de legislação editada por Estado-membro, questionada em face da Constituição da República (CRFB/88, art. 102, I, "a"),

Também é importante destacar que a decisão tomada no âmbito estadual pode ser objeto de recurso ao STF desde que haja na decisão do Tribunal de Justiça alguma ofensa à Constituição Federal. Nesse caso, a Suprema Corte brasileira terá a palavra final sobre a validade do ato normativo estadual. O veículo que levará ao conhecimento do STF a decisão do Tribunal de Justiça será o recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da CRFB/88. Nesse caso, se julgado procedente, o recurso extraordinário produzirá, excepcionalmente, efeitos erga omnes (sem a necessidade de atuação do Senado Federal), pois no processo de origem não havia partes, tendo em vista se tratar de uma ação do controle abstrato.

A atuação do *amicus curiae*, prevista no art. 7º, § 2º, da Lei no 9.868/99, também é perfeitamente admitida no controle estadual, desde que preencham o requisito da pertinência temática, dada a natureza democrática do instituto.

Tendo em vista que não há lei regulamentando o controle no plano estadual, muitos Tribunais aplicam, por analogia, ao controle de constitucionalidade estadual as mesmas normas relativas ao controle de constitucionalidade federal. Por exemplo, o Tribunal de Justiça pode modular os efeitos temporais de uma declaração de inconstitucionalidade mediante a aplicação do art. 27 da Lei no 9.868/99.

Ressalte-se que não é possível controlar a constitucionalidade de emenda

qualifica-se como causa de suspensão prejudicial do processo de controle concentrado de constitucionalidade, que, promovido perante o Tribunal de Justiça local (CRFB/88, art. 125, § 2º), tenha, por objeto de impugnação, os mesmos atos normativos emanados do Estado-membro, contestados, porém, em face da Constituição estadual, como sucede na espécie. Tal entendimento, no entanto, há de ser observado sempre que tal impugnação – deduzida perante a Corte Judiciária local – invocar, como parâmetro de controle, princípios inscritos na Carta Política local impregnados de predominante coeficiente de federalidade, tal como ocorre com os postulados de reprodução necessária constantes da própria Constituição da República (RTJ 147/404 – RTJ 152/371-373, v.g.). Isso significa, portanto, que, em ocorrendo hipótese caracterizadora de simultaneus processus, impor-se-á a paralisação do processo de fiscalização concentrada em curso perante o Tribunal de Justiça local, até que esta Suprema Corte julgue a ação direta, que, ajuizada com apoio no art. 102, I, a, da Constituição da República, tenha por objeto o mesmo diploma normativo local, embora contestado em face da Carta Federal. Cabe assinalar, neste ponto, por relevante, que esse entendimento achasse consagrado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem sido reafirmada em sucessivas decisões que proclamam, em situações como a destes autos, a necessidade de suspensão prejudicial do processo de fiscalização normativa abstrata instaurado perante Tribunal de Justiça local (CRFB/88, art. 125, § 2º), se houver, em tramitação simultânea no Supremo, processo de controle concentrado em que se questione a constitucionalidade do mesmo diploma normativo, também contestado na ação direta ajuizada no âmbito local. STF, ADI 4138, MIn. Rel. Celso de Mello. DJE 17.12.2009.

à Constituição Estadual em face da Constituição Estadual. Isto porque, ambas são produto de um mesmo poder: o constituinte derivado decorrente (art. 11 do ADCT). Isto significa que a emenda à Constituição Estadual apenas poderá ser objeto de controle abstrato perante a Constituição Federal, em julgamento a ser realizado pelo STF.

O princípio da reserva de plenário, presente no art. 97 da CRFB/88, também deve ser respeitado no plano do controle estadual.

Eventualmente, é permitido que o Tribunal de Justiça considere inconstitucional a própria norma da Constituição do Estado que serviu como parâmetro para o ajuizamento da RI, seja de ofício ou por provocação. Neste caso, é como se a norma estadual fosse analisada na parte do fundamento da decisão, e não na parte dispositiva, sendo cabível da decisão a interposição do recurso extraordinário ao STF²⁹⁷.

24.5 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCEN- TRADO ABSTRATO DISTRITAL E MUNICIPAL

Segundo a orientação do STF, a Lei Orgânica do Distrito Federal possui natureza de Constituição Estadual, sendo parâmetro para o controle de constitucionalidade abstrato de normas distritais. O controle de constitucionalidade distrital está presente na Lei no 11.697/2008, que prevê a existência de três ações: a ação direta de inconstitucionalidade (ADI), a ação declaratória de constitucionalidade (ADC) e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO).

O órgão competente para realizar o controle é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e aplicam-se ao controle distrital as mesmas regras do controle estadual, apenas atentando-se para o fato de que o Distrito Federal tem competência administrativa e legislativa híbrida, ou seja, os órgãos do Distrito Federal podem editar normas no exercício de competência de Estado-membro e de Município (art. 32, § 1º, da CRFB/88).

Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, na forma do art. 8º, § 2º, Lei no 11.697/2008: o Governador do Distrito Federal; a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal; o Procurador-Geral de Justiça; a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal; as entidades sindicais ou de classe, de atuação no Distrito Federal, demonstrando que a pretensão por elas deduzida guarda relação de pertinência direta com os seus objetivos institucionais e os partidos políticos com representação na Câmara

297. STF, Rcl 526, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 04.04.97.

Legislativa.

Já a ADC pode ser ajuizada pelo: Governador do Distrito Federal; pela Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal e pelo Procurador-Geral de Justiça, conforme dispõe o art. 8º, § 2º, da Lei no 11.697/2008.

O Procurador-Geral de Justiça será sempre ouvido nas ações diretas de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade e aplicam-se, no que couber, ao processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal, em face da sua Lei Orgânica, as normas sobre o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

Já com relação ao Município, não existe controle de constitucionalidade em face de Lei Orgânica Municipal. Entende a doutrina que a Lei Orgânica não tem natureza de Constituição, que não há relação de hierarquia entre ela e as demais leis municipais, admitindo-se, apenas, o controle de legalidade dessas normas, realizado no sistema difuso.

24.6 ADI INTERVENTIVA FEDERAL (OU REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INTERVENTIVA) E ADI INTERVENTIVA ESTADUAL

Como podemos verificar da análise das ações já estudadas, o Brasil adota um modelo difuso-concreto e concentrado-abstrato de controle de constitucionalidade. Na primeira situação, todos os juízes e Tribunais podem aplicar ou deixar de aplicar leis inconstitucionais no julgamento dos casos concretos submetidos à sua análise e, na segunda hipótese, o STF analisa a lei ou a falta da lei em teses, ou seja, sem um conflito real a ser resolvido.

Bem, apesar de ser a mais antiga das ações do controle concentrado (1934), a Ação Direta Interventiva Federal ou Representação de Inconstitucionalidade Interventiva (RI interventiva federal) é uma ação que visa a manter a proteção do pacto federativo adotado pelo país e não faz, portanto, uma análise em abstrato da norma. A ação analisa um conflito entre a União e um Estado ou entre a União e o Distrito Federal (no caso de RI interventiva federal); ou ainda, um conflito entre um Estado e um Município (RI interventiva estadual).

A base constitucional da RI interventiva federal é formada pelo art. 34, VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial (primeira parte), pelo art. 34, VII, ambos combinados com o art. 36, III, da CRFB/88, nas hipóteses a seguir analisadas, que só podem ser propostas, exclusivamente

pelo Procurador-Geral da República.

No caso do art. 34, VI, na hipótese de descumprimento de lei federal por parte de Estados ou pelo Distrito Federal, o Procurador-Geral da República deverá ajuizar a ação diretamente ao STF. Por sua vez, caso os Estados ou o Distrito Federal descumpram os princípios constitucionais sensíveis: a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; b) direitos da pessoa humana; c) autonomia municipal; d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta. e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, também caberá ao Procurador-Geral da República ajuizar a ação diretamente ao STF.

No âmbito infraconstitucional, a presente ação foi regulamentada recentemente pela Lei no 12.562/2011, que dispõe sobre os aspectos procedimentais principais da mesma, a seguir indicados:

- l)** a petição inicial deverá conter: I - a indicação do princípio constitucional que se considera violado ou, se for o caso de recusa à aplicação de lei federal, das disposições questionadas; II - a indicação do ato normativo, do ato administrativo, do ato concreto ou da omissão questionados; III - a prova da violação do princípio constitucional ou da recusa de execução de lei federal; IV - o pedido, com suas especificações. (art. 3º da lei);
- m)** a decisão de indeferimento da petição inicial caberá agravo, no prazo de 5 (cinco) dias. (art. 4º, parágrafo único);
- n)** o Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na representação interventiva. A liminar poderá consistir na determinação de que se suspenda o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais ou administrativas ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da representação interventiva. (art. 5º da lei);
- o)** apreciado o pedido de liminar ou, logo após recebida a petição inicial, se não houver pedido de liminar, o relator solicitará as informações às autoridades responsáveis pela prática do ato questionado, que as prestarão em até 10 (dez) dias. (art. 6º da lei);

-
- p) decorrido o prazo para prestação das informações, serão ouvidos, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de 10 (dez) dias. (art. 6º § 1º, da lei);
 - q) a decisão sobre a representação interventiva somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 8 (oito) Ministros. (art. 9º da lei);
 - r) realizado o julgamento, proclamar-se-á a procedência ou improcedência do pedido formulado na representação interventiva se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos 6 (seis) Ministros. (art. 10 da lei);
 - s) julgada a ação, far-se-á a comunicação às autoridades ou aos órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, e, se a decisão final for pela procedência do pedido formulado na representação interventiva, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, publicado o acórdão, levá-lo-á ao conhecimento do Presidente da República para, no prazo improrrogável de até 15 (quinze) dias, dar cumprimento aos §§ 1º e 3º do art. 36 da Constituição Federal. (art. 11 da lei);
 - t) Segundo prevê o art. 12, a decisão que julgar procedente ou improcedente, o pedido da representação interventiva é irrecorrível, sendo insuscetível de impugnação por ação rescisória.

Percebe-se do exposto que a RI interventiva federal é a única das ações do controle concentrado que não possui legitimidade ativa plural.

O STF não tem tradição no julgamento favorável da RI interventiva federal, talvez em nome do próprio pacto federativo e um dos exemplos de não provimento da ação foi o caso envolvendo corrupção no Distrito Federal, amplamente noticiado pela imprensa, a seguir transcrito:

O Tribunal, por maioria, julgou improcedente pedido de intervenção federal no Distrito Federal, formulado pelo Procurador-Geral da República, por alegada violação aos princípios republicano e democrático, bem como ao sistema representativo (CRFB/88, art. 34, II, a). Na espécie, o pedido de intervenção federal teria como causa petendi, em

suma, a alegação da existência de esquema de corrupção que envolveria o ex-Governador do DF, alguns Deputados Distritais e suplentes, investigados pelo STJ, e cujo concerto estaria promovendo a desmoralização das instituições públicas e comprometendo a higidez do Estado Federal. Tais fatos revelariam conspícua crise institucional hábil a colocar em risco as atribuições político-constitucionais dos Poderes Executivo e Legislativo e provocar instabilidade da ordem constitucional brasileira. Preliminarmente, a Corte, por maioria, rejeitou requerimento do Procurador-Geral da República no sentido de adiar o julgamento da causa para a primeira data do mês de agosto em que a Corte estivesse com sua composição plena. Ao salientar a ansiedade da população por uma resposta pronta da Corte quanto ao pedido de intervenção e a proximidade do início formal do período eleitoral, reputou-se estar-se diante de questão importante que demandaria decisão o mais célere possível. Vencidos, no ponto, os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello que deferiam o adiamento, por considerarem que a análise da matéria recomendaria a presença do quórum completo dos integrantes do Tribunal. IF 5179/DF, rel. Min. Cezar Peluso, 30.6.2010. (IF-5179)

Quanto à RI interventiva estadual, a sua previsão constitucional se encontra no art. 35, IV, da CRFB/88, a seguir transcrito: O Estado não intervirá em seus Municípios, exceto quando (...) IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

Em nome do princípio da simetria, a legitimidade ativa para a propositura da ação é do Procurador Geral de Justiça e ela será julgada pelo Tribunal de Justiça do próprio Estado. Importante destacar que a ação é regulamentada pelas Constituições Estaduais.

24.7 COLETÂNEA DE JURISPRUDÊNCIA SOBRE ALGUNS TEMAS DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

A Questão da “Lei Ainda Constitucional”

...enquanto o Estado de São Paulo não instituir e organizar a Defensoria Pública local, tal como previsto na Constituição da República (art. 134), subsistirá, íntegra, na condição de norma ainda constitucional – que configura um transitório estágio intermediário, situado “entre os estados de plena constitucionalidade ou de absoluta inconstitucionalidade”, a regra inscrita no art. 68 do CPP, mesmo que sujeita, em face de modificações supervenientes das circunstâncias de fato, a um processo de progressiva inconstitucionalização... (“Transcrições”, RE 341.717-SP, Inf. 272).

O julgado acima analisa a possibilidade de reconhecimento de um estágio transitório entre a constitucionalidade e a inconstitucionalidade de uma lei. O caso em destaque trata da possibilidade de propositura da Ação Civil Ex Delicto pelo Ministério Público, de acordo com o art. 68 do CPP, enquanto não houver a criação e a instituição da Defensoria Pública local.

Inconstitucionalidade por Arrastamento ou por Atração, Sequencial ou por Reverberação Normativa

O Tribunal iniciou julgamento de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal contra a Lei distrital 3.228/2003, que obriga as distribuidoras de combustíveis locais a colocar lacres eletrônicos nos tanques dos postos de combustíveis que exibam sua marca e dá outras providências. A Min.a Cármen Lúcia, relatora, julgou procedente o pedido, registrando que as normas dos arts. 1º e 2º determinam a declaração de inconstitucionalidade das demais por arrastamento, por se tornarem ineficazes, quando não inexecutáveis, sem aqueles dispositivos, no que foi acompanhada pelos Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa (STF, ADI 3.236/DF, Rel.a Min.a Cármen Lúcia, 17.09.2007, Inf. 480).

Em conclusão, o Tribunal conheceu em parte de ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral da República e, na parte conhecida, julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade do inciso II do § 1º do art. 82, do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, bem como, por arrastamento, dos §§ 4º, 5º e 6º do mesmo art. 82, os quais foram acrescentados pela Emenda Constitucional estadual 70/2005. Os dispositivos impugnados criaram a Universidade do Estado de Minas Gerais e estabeleceram outras providências (ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais: Art. 81. Fica criada a Universidade do Estado de Minas Gerais, sob a forma de autarquia, que terá sua reitoria na Capital e suas unidades localizadas nas diversas regiões do Estado. V. Informativo 268298.

Nestas decisões, há uma relação de dependência, um liame, uma conexão, que faz com que dispositivos, além dos originariamente imputados inconstitucionais, sejam declarados incompatíveis com a Constituição, configurando uma exceção ao princípio da congruência ou da adstrição em sede de processo civil.

Também é possível se observar a inconstitucionalidade por arrastamento ou por atração quando a lei objeto do controle concentrado fundamenta a validade de uma série de atos secundários, como os decretos, por exemplo. Nesses casos, ao declarar a inconstitucionalidade da lei, a Corte pode reconhecer, “por arrastamento”, a invalidade das normas que dela se originavam.

A Inconstitucionalidade “Chapada”

Esta expressão vem sendo utilizada pelos Ministros quando se referem a uma inconstitucionalidade mais do que evidente, flagrante, não existindo nenhuma dúvida sobre o vício, seja ele formal ou material. Podemos observar a expressão na transcrição abaixo: ... *Em voto-vista proferido em 2 de fevereiro deste ano (2007), Eros Grau entendeu que a lei impugnada padece de “inconstitucionalidade chapada”, acentuando a violação à regra*

298. STF, ADI 2501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 04.09.2008, Inf. 518.

A “Fossilização da Constituição”

Como já foi explicado, a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal. Está visto, pois, que nosso ordenamento não estendeu ao legislador os efeitos vinculantes da decisão de inconstitucionalidade, sob pena de uma verdadeira fossilização da Constituição, conforme o STF manifestou de acordo com a transcrição abaixo:

...Já se demonstrou alhures, com abundância de argumentos, que, como fruto de exegese de textos similares ou análogos, a proibição de reprodução de norma idêntica à que foi declarada inconstitucional não pode inspirar-se nalgum princípio processual geral que iniba renovação do comportamento subjacente a ato concreto anulado ou tido por ilegal, o que, sob a autoridade da res iudicata, conviria apenas a processos de índole subjetiva. Ademais, o postulado da segurança jurídica acabaria, contra uma correta interpretação constitucional sistemático-teleológica, sacrificando, em relação às leis futuras, a própria justiça da decisão. Por outro lado, tal concepção comprometeria a relação de equilíbrio entre o tribunal constitucional e o legislador, reduzindo este a papel subalterno perante o poder incontrolável daquele, com evidente prejuízo do espaço democrático-representativo da legitimidade política do órgão legislativo. E, como razão de não menor tomo, a proibição erigiria mais um fator de resistência conducente ao inconcebível fenômeno da fossilização da Constituição: “A consequência é particularmente grave: as Constituições, enquanto planos normativos voltados para o futuro, não podem de maneira nenhuma perder a sua flexibilidade e abertura. Naturalmente e na medida do possível, convém salvaguardar

299. STF, RE 461.366, Min. Rel. Marco Aurélio, DJE 29.08.2008.

a continuidade dos standards jurisprudenciais: alterações de rota, decisões overruling demasiado repentinas e brutais contrastam com a própria noção de jurisdição. A percepção da continuidade como um valor não deve, porém, significar uma visão petrificada da jurisprudência...” (grifamos)³⁰⁰.

300. STF, Rcl 2617, Min. Rel, Cezar Peluso, DJ 17.06.2004.